

제1강 불능미수의 중지미수

♣ 학습목표

불능미수의 중지미수에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

불능미수의 위험성

중지미수의 자의성과 착수미수와 실행미수의 요건

불능미수의 중지미수의 인정여부

♣ 사전테스트

1. 불능미수의 위험성은 결과반가치의 하한으로서의 의미를 지닌다.

정답 : O

해설 : 불능미수의 위험성은 결과반가치의 최하한으로서의 의미를 지니므로 타당한 지문이다.

2. 불능미수와 불능범은 위험성 유무에 따라 구별된다.

정답 : O

해설 : 위험성이 인정되면 불능미수, 위험성이 인정되지 않으면 불능범이 되므로 타당한 지문이다.

3. 우리나라의 중지미수의 효과는 필요한 면제이다.

정답 : X

해설 : 형법 제26조에 따르면 중지미수의 효과는 필요적 감면이므로 타당하지 않은 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

甲과 乙(A의 처)은 불륜관계를 유지하여 오던 중, A를 살해하고 함께 살기로 하였다. 甲과 乙은 범행계획을 숙의한 끝에 甲이 독약을 구해 오면 乙이 이 독약을 A에게 먹여 살해하기로 의견을 모았다. 甲으로부터 독약을 건네받은 乙이 약속한 범행일에 A를 독살하지 못하고 차일피일 범행을 미루자 甲은 乙에게 전화하여 “오늘 A가 퇴근하면 반드시 독살하라.”라고 말하였다. 甲의 독촉을 받은 乙은 평소 A가 즐겨 마시던 포도주에 독약을 혼입하여 놓고 A가 퇴근하여 귀가하자 위 포도주를 A에게 건네주어 마시게 하였다. A가 구토를 하고 극심한 복통을 호소하자, 이를 본 乙은 후회하고 A를 살리기 위해 병원 응급실로 데려가 치료를 받게 하였다. 그런데 당시 乙이 포도주에 혼입한 독약은 치사량 미달이어서 A는 전치 2주의 내장손상을 입었을 뿐, 그대로 두어도 사망하지 않았을 것이었다. 甲과 乙의 죄책을 논하시오. (25점)

[해설]

I. 서 언

사안에서 甲과 乙은 A를 살해하기 위하여 모의하였으나 실제 실행행위는 乙만이 하고 있다. 따라서 이하에서는 실행행위를 한 乙의 죄책을 먼저 논하고, 이에 따른 甲의 죄책을 검토한다.

II. 乙의 죄책

1. 논의점

乙은 A를 살해하기 위하여 A에게 독약을 먹였으나 乙이 A에게 준 독약은 결과발생이 불가능한 경우이었고 실행행위 후에 후회하고 결과발생을 방지하고자 하였다. 따라서 乙의 행위는 ① 불능미수인지 아니면 불능범인지 ② 중지미수의 자의성이 인정되는지 ③ 실행중지의 경우에 결과발생이 불가능한 경우에도 중지미수의 객관적 요건을 구비했다고 볼 수 있는지가 문제된다.

2. 불능미수 여부

- (1) 불능미수가 성립하기 위하여는 ① 실행의 착수 ② 수단 또는 대상의 착오로 인한 결과발생의 불가능 ③ 위험성의 요건이 구비되어야 한다. 사안에서 ①과 ②의 요건은 구비되었으나 ③ 위험성의 요건이 구비되었는지가 문제된다.
- (2) 불능미수의 위험성판단에 대한 학설에는 ① 절대적·상대적 불능설 ② 구체적 위험설 ③ 추상적 위험설 ④ 주관설 등이 대립하고 있으며, ⑤ 판례는 절대적·상대적 불능설을 따른 판례와 추상적 위험설을 따른 판례가 혼재하고 있다.
- (3) 생각건대 위험성의 판단은 기본적으로 추상적인 법질서가 기준이 되어야 하므로 행위자가 인식한 사정을 판단의 대상으로 하여 일반인의 입장에서 위험성을 판단하는 추상적 위험설이 타당하다. 이러한 추상적 위험설에 따르면 사안의 경우에는 위험성이 인정될 수 있으므로 乙에게는 살인죄의 불능미수범이 성립된다.

3. 중지미수의 인정여부

(1) 중지미수의 성립요건

중지미수가 성립하기 위하여는 기본적으로 ① 주관적 요건으로서 자의성이 요구되고 ② 객관적 요건이 구비되어야 한다.

(2) 주관적 요건으로서의 자의성의 인정여부

중지미수의 자의성의 판단에는 ① 객관설 ② 주관설 ③ 프랑크의 공식 ④ 절충설 등이 대립하고 있으나, 다수설과 판례는 사회통념에 따라 구별하는 절충설을 따르고 있다. 사안에서 乙은 자신의 행위를 후회하고 있으므로 어떠한 견해를 따르더라도 乙에게는 자의성이 인정된다.

(3) 객관적 요건으로서의 실행중지미수 요건

- 1) 실행중지미수가 성립하기 위하여는 ① 결과발생을 방지하기 위한 진지한 노력 ② 결과발생의 방지 ③ 양자사이의 인과관계가 요구된다. 사안의 경우에는 ①과 ②의 요건은 구비되었으나 ③의 요건이 문제된다. 사안과 같이 애초에 결과발생이 불가능한 불능미수의 경우에도 중지미수를 인정할 것인가에 대하여 논의가 있다.
- 2) 이에 대하여는 ① 실행중지미수의 성립요건을 형식적으로 고찰하여 인과관계가 인정되지 않으므로 중지미수의 성립을 부정하는 부정설 ② 중지미수의 실질적인 의미를 고려하여 결과발생이 불가능해 인과관계가 인정되지 않는 경우에도 중지미수의 성립을 인정하는 긍정설이 대립하고 있다. 그러나 우리나라는 중지미수의 효과에 감경도 있다는 점을 고려하면 중지미수의 성립요건을 엄격하게 해석할 필요가 없으므로 긍정설이 타당하다.

4. 乙의 죄책

乙은 살인죄의 중지미수가 성립한다.

III. 甲의 죄책

1. 서 언

甲은 乙과 A를 살해하려고 모의하였고 독약 등을 구해주었으나 실제 실행행위는 하지 않고 있다. 따라서 이러한 甲에게 ① 공동정범이 성립할 수 있는지가 문제되고 ② 전체범행이 미수이고 일방이 중지미수가 인정되는 경우에 자의성이 없는 甲에게도 중지미수가 인정되는가가 문제된다.

2. 공모공동정범의 성립여부

(1) 공모공동정범에 대한 논의

공모공동정범의 인정여부에 대하여는 종래에는 논의가 있었지만, 최근의 학설과 2000년 이후의 판례는 모두 기능적 행위지배설의 입장에서 실행행위를 하지 않은 자일지라도 기능적 행위지배가 인정되는 경우에는 공동정범이 성립할 수 있다고 보고 있다.

(2) 사안의 해결

사안의 경우에 이러한 기능적 행위지배설에 따르면 ① 甲은 乙과 살해를 공모하고 ② 독약을 구해오고 ③ 범행을 독촉했다는 점에서 乙의 범행에 본질적으로 기여하고 있다고 볼 수 있으므로 甲에게는 기능적 행위지배가 인정되어 공동정범이 성립한다.

3. 중지미수의 효과 적용여부

사안에서 A는 사망하지 않았으므로 ① 甲의 죄책은 기본적으로 미수범이 성립하고 ② 乙의 결과발생이 불가능한 실행행위로 인하여 불능미수범이 성립한다. 그러나 ③ 본 사안에서 乙에게는 자의성이 인정되어 중지미수가 성립하지만, 이러한 중지미수의 법적성질은 형사정책적이고 개인적인 책임과 관련된 부분이므로 자의성이 인정되지 않는 甲에게는 중지미수의 효과는 인정되지 않는다.

4. 甲의 죄책

甲은 살인죄의 불능미수의 공동정범이 성립한다.

관련판례

1. 소송비용 사건

[사실관계] 甲은 을로부터 소송비용 명목으로 100만 원을 이미 송금받았음에도 불구하고 을을 피고로 하여 종전에 甲이 을을 상대로 제기하였던 여러 소와 관련한 소송비용 상당액의 지급을 구하는 손해배상금 청구의 소를 제기하였다가 담당 판사로부터 소송비용의 확정은 소송비용액 확정절차를 통하여 하라는 권유를 받고 소를 취하하였다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 불능범의 판단 기준으로서 위험성 판단은 피고인이 행위 당시에 인식한 사정을 놓고 이것이 객관적으로 일반인의 판단으로 보아 결과 발생의 가능성이 있느냐를 따져야 하고(대법원 1978. 3. 28. 선고 77도4049 판결 참조), 한편 민사소송법상 소송비용의 청구는 소송비용액 확정절차에 의하도록 규정하고 있으므로, 위 절차에 의하지 아니하고 손해배상금 청구의 소 등으로 소송비용의 지급을 구하는 것은 소의 이익이 없는 부적법한 소로서 허용될 수 없다고 할 것이다. 따라서 소송비용을 편취할 의사로 소송비용의 지급을 구하는 손해배상청구의 소를 제기하였다고 하더라도 이는 객관적으로 소송비용의 청구방법에 관한 법률적 지식을 가진 일반인의 판단으로 보아 결과 발생의 가능성이 없어 위험성이 인정되지 않는다고 할 것이다.(대판 2005.12.8. 2005도8105)

2. 초우뿌리 사건

[사실관계] 甲과 乙女는 공모하여 乙女の 남편인 丙을 살해하려고 하였다. 甲과 乙은 일정량 이상을 마시면 사람이 사망에 이를 수 있는 ‘초우뿌리’ 또는 ‘부자’달인 물을 丙에게 먹였으나, 丙은 이를 마시고 즉시 토해버려 사망에 이르지 않았다. 이에 대한 甲의 죄책은?

[판결요지] [1] 불능범은 범죄행위의 성질상 결과발생 또는 법익침해의 가능성이 절대로 있을 수 없는 경우를 말하는 것이다(대법원 1998.10.23. 선고 98도2313 판결 참조). [2] 일정량 이상을 먹으면 사람이 죽을 수도 있는 ‘초우뿌리’나 ‘부자’ 달인 물을 마시게 하여 피해자를 살해하려다 미수에 그친 행위가 불능범이 아닌 살인미수죄에 해당한다고 본 사례.(대판 2007.7.26. 2007도3687)

3. 판례에서의 중지미수

중지미수라 함은 범죄의 실행행위에 착수하고 그 범죄가 완수되기 전에 자기의 자유로운 의사에 따라 범죄의 실행행위를 중지하는 것으로서 장애미수와 대칭되는 개념이나 중지미수와 장애미수를 구분하는데 있어서는 범죄의 미수가 자의에 의한 중지이나 또는 어떤 장애에 의한 미수이냐에 따라 가려야 하고 특히 자의에 의한 중지중에서도 일반사회통념상 장애에 의한 미수라고 보여지는 경우를 제외한 것을 중지미수라고 풀이함이 일반이다.(대판 1985.11.12. 85도2002)

4. 겁이 나서 불끈 사건

[사실관계] 甲은 乙의 집을 소훼하려고 乙의 집 안방 장롱 안에 있는 옷가지에 불을 놓았으나 불길에 치솟는 것을 보고 겁이 나서 물을 부어 불을 꺾다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 범죄의 실행행위에 착수하고 그 범죄가 완수되기 전에 자기의 자유로운 의사에 따라 범죄의 실행행위를 중지한 경우에 그 중지가 일반사회통념상 범죄를 완수함에 장애가 되는 사정에 의한 것이 아니라면 이는 중지미수에 해당한다. 위와 같은 경우 치솟는 불길에 놀라거나 자신의 신체 안전에 대한 위해 또는 범행 발각시의 처벌 등에 두려움을 느끼는 것은 일반사회통념상 범죄를 완수함에 장애가 되는 사정에 해당한다고 보아야 할 것이므로 이를 자의에 의한 중지라고는 볼 수 없다.(대판 1997.6.13. 97도957)

5. 많은 피에 겁을 먹고 그만둔 사건

[사실관계] 甲은 乙女를 살해하려고 목 부위와 왼쪽 가슴 부위를 칼로 수 회 찔렀으나 乙女の 가슴 부위에서 많은 피가 흘러나오는 것을 발견하고 겁을 먹어 그만 두는 바람에 乙女가 사망에 이르지 아니하였다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 범죄의 실행행위에 착수하고 그 범죄가 완수되기 전에 자기의 자유로운 의사에 따라 범죄의 실행행위를 중지한 경우에 그 중지가 일반 사회통념상 범죄를 완수함에 장애가 되는 사정에 의한 것이 아니라면 이는 중지미수에 해당한다고 할 것이지만, 피고인이 피해자를 살해하려고 그의 목 부위와 왼쪽 가슴 부위를 칼로 수 회 찔렀으나 피해자의 가슴 부위에서 많은 피가 흘러나오는 것을 발견하고 겁을 먹고 그만 두는 바람에 미수에 그친 것이라면, 위와 같은 경우 많은 피가 흘러나오는 것에 놀라거나 두려움을 느끼는 것은 일반 사회통념상 범죄를 완수함에 장애가 되는 사정에 해당한다고 보아야 할 것이므로, 이를 자의에 의한 중지미수라고 볼 수 없다.(대판 1999.4.13. 99도640)

6. 기능적 행위지배설 입장에서의 판례

[1] 형법 제30조의 공동정범은 공동가공의 의사와 그 공동의사에 기한 기능적 행위지배를 통한 범죄 실행이라는 주관적·객관적 요건을 충족함으로써 성립하는바, 공모자 중 구성요건 행위 일부를 직접 담당하여 실행하지 않은 자라도 경우에 따라 이른바 공모공동정범으로서의 죄책을 질 수도 있는 것이기는 하나, 이를 위해서는 전체 범죄에 있어서 그가 차지하는 지위, 역할이나 범죄 경과에 대한 지배 내지 장악력 등을 종합해 볼 때, 단순한 공모자에 그치는 것이 아니라 범죄에 대한 본질적 기여를 통한 기능적 행위지배가 존재하는 것으로 인정되는 경우여야 한다. [2] 그리고 이 경우, 범죄의 수단과 태양, 가담하는 인원과 그 성향, 범행 시간과 장소의 특성, 범행과정에서 타인과의 접촉 가능성과 예상되는 반응 등 제반 상황에 비추어, 공모자들이 그 공모한 범행을 수행하거나 목적 달성을 위해 나아가는 도중에 부수적인 다른 범죄가 파생되리라고 예상하거나 충분히 예상할 수 있는데도 그러한 가능성을 외면한 채 이를 방지하기에 족한 합리적인 조치를 취하지 아니하고 공모한 범행에 나아갔다가 결국 그와 같이 예상되던 범행들이 발생하였다면, 비록 그 파생적인 범행 하나하나에 대하여 개별적인 의사의 연락이 없었다 하더라도 당초의 공모자들 사이에 그 범행 전부에 대하여 암묵적인 공모는 물론 그에 대한 기능적 행위지배가 존재한다고 보아야 할 것이다. [3] 피고인이 노조원들의 폭행, 상해, 특수공무집행방해치상 등 범행들에 대하여 구체적으로 모의하거나 이를 직접 담당·실행한 바 없었더라도, 피고인이 파업투쟁에 가담하게 된 경위, 위 파업투쟁 및 폭력사태의 경위와 진행 과정, 그 과정에서 피고인의 지위 및 역할, 피고인이 작성한 문건의 내용 및 성격 등을 종합할 때, 위 각 범행에 대하여 암묵적인 공모는 물론 본질적 기여를 통한 기능적 행위지배가 있었다고 보아 그 공동정범으로 의율한 원심판단을 수긍한 사례.(대판 2010.12.23. 2010도7412)

♣ 돌발퀴즈

판례와 다수설은 중지미수의 자의성에 대하여 절충설을 따르고 있으므로 겁을 먹거나 놀라서 범행을 중지한 경우에도 자의성을 인정하고 있다.

[정답] X

[해설] <겁이 나서 불끈 사건> [판결요지] 범죄의 실행행위에 착수하고 그 범죄가 완수되기 전에 자기의 자유로운 의사에 따라 범죄의 실행행위를 중지한 경우에 그 중지가 일반사회통념상 범죄를 완수함에 장애가 되는 사정에 의한 것이 아니라면 이는 중지미수에 해당한다. 위와 같은 경우 치솟는 불길에 놀라거나 자신의 신체 안전에 대한 위해 또는 범행 발각시의 처벌 등에 두려움을 느끼는 것은 일반사회통념상 범죄를 완수함에 장애가 되는 사정에 해당한다고 보아야 할 것이므로 이를 자의에 의한 중지라고는 볼 수 없다.(대판 1997.6.13. 97도 957)

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 장애미수의 법적 효과는?

- ① 임의적 감경 ② 필요적 감경 ③ 임의적 감면 ④ 필요적 감면 ⑤ 형의 면제

정답 : ①

해설 : 형법 제25조 참조.

2. 중지미수의 법적 효과는?

- ① 임의적 감경 ② 필요적 감경 ③ 임의적 감면 ④ 필요적 감면 ⑤ 형의 면제

정답 : ④

해설 : 형법 제26조 참조.

3. 불능미수의 법적 효과는?

- ① 임의적 감경 ② 필요적 감경 ③ 임의적 감면 ④ 필요적 감면 ⑤ 형의 면제

정답 : ③

해설 : 형법 제27조 참조.

♣ 학습내용 정리

1. 불능미수가 성립하기 위하여는 ① 실행의 착수 ② 수단 또는 대상의 착오로 인한 결과발생의 불가능 ③ 위험성의 요건이 구비되어야 한다.
2. 불능미수의 위험성판단에 대한 학설에는 ① 절대적·상대적 불능설 ② 구체적 위험설 ③ 추상적 위험설 ④ 주관설 등이 대립하고 있으며, ⑤ 판례는 절대적·상대적 불능설을 따른 판례와 추상적 위험설을 따른 판례가 혼재하고 있다.
3. 중지미수의 자의성의 판단에는 ① 객과설 ② 주관설 ③ 프랑크의 공식 ④ 절충설 등이 대립하고 있으나, 다수설과 판례는 사회통념에 따라 구별하는 절충설을 따르고 있다.
4. 실행중지미수가 성립하기 위하여는 ① 결과발생을 방지하기 위한 진지한 노력 ② 결과발생의 방지 ③ 양자사이의 인과관계가 요구된다.
5. 공모공동정범의 인정여부에 대하여는 종래에는 논의가 있었지만, 최근의 학설과 2000년 이후의 판례는 모두 기능적 행위지배설의 입장에서 실행행위를 하지 않은 자일지라도 기능적 행위지배가 인정되는 경우에는 공동정범이 성립할 수 있다고 보고 있다.

제2강 원자행과 예비의 중지

♣ 학습목표

원인에 있어 자유로운 행위와 예비의 중지에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

원인에 있어 자유로운 행위의 실행의 착수시기

잠정적 중지의 자의성 인정여부

예비의 중지에 대한 중지미수규정 유추 여부

♣ 사전테스트

1. 원인에 있어 자유로운 행위의 실행의 착수시기를 주관설인 원인설정시에 있다고 보면 행위·책임 동시 존재의 원칙을 지킬 수 있다.

정답 : O

해설 : 주관설인 원인설정시설을 따를 경우에 원인설정시에는 행위자가 책임능력이 있었으므로 행위·책임 동시 존재의 원칙을 지킬 수 있어 타당한 지문이다.

2. 잠정적 중지의 자의성 인정여부에 대해 다수설과 판례인 절충설은 자의성을 인정한다.

정답 : O

해설 : 잠정적 중지의 경우에도 자율성을 인정하여 자의성을 인정하는 것이 다수설과 판례의 태도이므로 타당한 지문이다.

3. 예비죄의 경우 중지미수규정을 유추적용할 수 있다는 것이 판례의 태도이다.

정답 : X

해설 : 판례는 예비의 중지의 경우에 중지미수 규정을 유추하지 않으므로 타당하지 않은 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

甲은 평소 원한이 있는 A를 죽이기로 결심하였으나 용기가 나지 않아 술을 마시고 심신미약 상태에서 흥기를 품고 A를 찾아갔다. A를 만난 甲은 A가 병약해진 것을 발견하고 나중에 건강해지면 죽이는 것이 진정으로 원수를 갚는 길이라고 생각하여 범행을 포기하고 그대로 돌아왔다. 원인에 있어서 자유로운 행위와 중지미수에 관한 학설들을 근거로 하여, 甲을 (1) 가장 가볍게 처벌할 수 있는 논리와, (2) 가장 무겁게 처벌할 수 있는 논리를 각각 제시하시오. (20점)

[해설]

1. 논점의 정리

사안에서 甲의 죄책과 관련하여 논의될 수 있는 것은 ① 원인에 있어 자유로운 행위의 실행의 착수시기 ② 잠정적 중지의 자의성 인정여부 ③ 예비의 중지가 문제된다. 논의점을 먼저 검토한 뒤에 甲을 가장 가볍게 처벌할 수 있는 논리와 甲을 가장 무겁게 처벌할 수 있는 논리를 제시한다.

2. 원인에 있어 자유로운 행위의 실행의 착수시기에 대한 논의

원인에 있어 자유로운 행위의 실행의 착수시기에 대하여는 ① 주관주의 입장에서 행위자의 반사회적 성격이 나타나는 원인설정행위시에 실행의 착수가 있다는 원인설정행위시설 ② 객관주의 입장에서 행위자가 법익침해를 향한 구성요건에 해당하는 행위를 개시하였을 때 실행의 착수가 있다는 법익침해행위시설이 대립하고 있다.

3. 잠정적 중지의 자의성 인정여부에 대한 논의

잠정적 중지의 자의성 인정여부에 대하여는 ① 기본적으로 이미 실행에 착수한 범죄의 결과발생을 방지하는 데에 중지미수의 취지가 있으므로 잠정적 중지도 중지미수라는 긍정설 ② 행위자가 합법의 세계로 돌아온 경우에만 중지미수의 의미가 있다고 보아 잠정적 중지는 중지미수가 아니라는 부정설이 대립하고 있다.

4. 예비의 중지 인정여부

예비죄에 대하여 중지미수규정을 유추적용할 수 있는가에 대하여는 ① 예비죄의 중지범은 성립할 수 없으므로 중지미수의 규정을 유추적용해서는 안 된다는 전면부정설 ② 원칙적으로 중지미수를 유추적용할 수는 없으나, 중지가 자수에 이른 정도의 경우에 한해 자수에 관한 필요적 감면 규정을 유추적용하자는 자수유추적용설 ③ 예비죄의 형이 기본범죄에 대하여 중지미수규정을 적용한 것보다 무거운 때에는 형의 불균형을 시정하기 위하여 중지미수의 규정을 유추적용하자는 제한적용설 ④ 예비의 중지에 있어서는 언제나 중지미수의 규정을 유추적용하여야 하며, 감경 또는 면제의 대상도 기수형이 아니라 예비·음모형이어야 한다는 전면긍정설이 대립하고 있다.

5. 사안의 해결

(1) 甲을 가장 가볍게 처벌할 수 있는 논리

甲을 가장 가볍게 처벌할 수 있는 논리는 ① 원인에 있어 자유로운 행위에서 실행의 착수를 객관설의 입장에 따라 파악하여 사안을 실행의 착수가 없는 예비에 그친다고 판단하고 ② 잠정적 중지의 자의성을 인정하고 ③ 예비의 중지를 인정하는 전면긍정설 입장에 따르면

甲을 가장 가볍게 처벌할 수 있다. 즉 이러한 논리에 따르면 甲은 살인예비죄에 중지미수를 유추적용하여 처벌하게 된다.

(2) 甲을 가장 무겁게 처벌할 수 있는 논리

甲을 가장 무겁게 처벌할 수 있는 논리는 ① 원인에 있어 자유로운 행위에서 실행의 착수를 주관설의 입장에 따라 파악하여 사안을 실행의 착수가 있는 미수로 파악하고 ② 잠정적 중지의 중지미수의 자의성을 부정하면 甲을 가장 무겁게 처벌하게 된다. 즉 이러한 논리에 따르면 甲은 살인죄의 장애미수죄로 처벌되게 된다.

관련판례

<예비·음모의 경우에는 중지범의 관념을 부정한 판례>

중지범은 범죄의 실행에 착수한 후 자의로 그 행위를 중지한 때를 말하는 것이고 실행의 착수가 있기 전인 예비·음모의 행위를 처벌하는 경우에 있어서 중지범의 관념은 이를 인정할 수 없다.(대판 1999.4.9. 99도424)

♣ **돌발퀴즈**

원인에 있어 자유로운 행위의 실행의 착수시기를 객관설인 법익침해행위시에 있다고 보면 행위·책임 동시 존재의 원칙을 지킬 수 있다.

정답 : X

해설 : 객관설인 법익침해행위설에 따를 경우 구성요건의 정형성은 지킬 수 있지만, 책임능력의 흠결로 인하여 행위·책임 동시 존재의 원칙을 유지할 수 없는 문제가 발생한다.

♣ **퀴즈!퀴즈!**

1. 원인에 있어 자유로운 행위를 규정하고 있는 조문은?

- ① 제9조
- ② 제10조 제1항
- ③ 제10조 제2항
- ④ 제10조 제3항
- ⑤ 제11조

정답 : ④

해설 : 현행법은 제10조 제3항에서 원인에 있어 자유로운 행위를 규정하고 있다.

2. 중지미수의 자의성을 판단하는 학설이 아닌 것은?

- ① 객관설
- ② 주관설
- ③ Frank의 공식
- ④ 절충설
- ⑤ 구체적 위험설

정답 : ⑤

해설 : 구체적 위험설은 불능미수의 위험성을 판단하는 학설이다.

3. 중지미수의 자의성에 대한 판례의 태도는?

- ① 객관설
- ② 주관설
- ③ Frank의 공식
- ④ 절충설
- ⑤ 구체적 위험설

정답 : ④

해설 : 다수설과 판례는 중지미수의 자의성에 대하여 절충설을 따르고 있다.

♣ 학습내용 정리

1. 원인에 있어 자유로운 행위의 실행의 착수시기에 대하여는 ① 원인설정행위시설 ② 법의 침해행위시설이 대립하고 있다.
2. 예비죄에 대하여 중지미수규정을 유추적용할 수 있는가에 대하여는 ① 전면부정설 ② 자수유추적용설 ③ 제한적용설 ④ 전면긍정설이 대립하고 있다.
3. 잠정적 중지의 자의성 인정여부에 대하여는 ① 기본적으로 이미 실행에 착수한 범죄의 결과발생을 방지하는 데에 중지미수의 취지가 있으므로 잠정적 중지도 중지미수라는 긍정설 ② 행위자가 합법의 세계로 돌아온 경우에만 중지미수의 의미가 있다고 보아 잠정적 중지는 중지미수가 아니라는 부정설이 대립하고 있다.

제3강 사실의 착오와 공범

♣ 학습목표

사실의 착오와 공범에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

사실의 착오의 한계로서의 부합설

간접교사의 교사범 인정 여부

제33조 규정이 반전된 경우의 공범과 신분

♣ 사전테스트

1. 구체적 부합설은 동가치를 강조하는 학설이다.

정답 : X

해설 : 구체적 부합설은 행위자가 인식한 부분까지의 사실을 강조하는 학설이므로 타당하지 않은 지문이다.

2. 구체적 사실의 착오 중 객체의 착오에 대한 해결은 구체적 부합설과 법정적 부합설의 결론이 동일하다.

정답 : O

해설 : 구체적 부합설과 법정적 부합설의 차이점은 구체적 사실의 착오 중 방법의 착오의 경우이므로 타당한 지문이다.

3. 현행법은 '교사자의 교사자를 처벌한다'는 규정을 두고 있다.

정답 : X

해설 : 현행법은 간접교사에 대한 처벌규정을 두고 있지 않으므로 타당하지 않은 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

甲은 자기의 養父 A로부터 빨리 상속을 받고 싶어서 친구인 乙에게 A를 살해해 줄 것을 부탁하였다. 乙은 이를 응낙하고 차일피일 미루다가 다시 친구인 丙에게 A의 살해를 부탁하였다. 丙은 A에게 총격을 가했으나 빗나가 행인 B에게 중상을 입게 하였다. 甲·乙·丙의 죄책은? (50점)

[해설]

I. 논점의 정리

사안에서 직접 실행행위를 한 자는 丙이므로 먼저 丙의 죄책을 검토한 다음 이에 가담한 직접가담자인 乙의 죄책, 간접적으로 가담한 甲의 죄책의 순서로 검토한다. 사안에서 ① 丙은 의도한 객체인 A가 아닌 B에게 중상을 입혔으므로 이에 대한 丙의 죄책이 문제되며 ② 정범인 丙의 착오가 교사범 乙에게는 어떠한 영향을 미치는지가 문제되며 ③ 丙의 행위에 간접적으로 가담한 甲에게 교사범이 성립하는지 그리고 존속을 살해하려고 한 부분에 대해서는 어떠한 죄책을 부담하는지가 문제된다.

II. 丙의 죄책

1. 논의점

사안에서 丙은 A를 살해할 의사로 총격을 가하였으나 빗나가 행인 B에게 중상을 입혔는바, 이는 구체적 사실의 착오로서 방법의 착오에 해당한다. 이와 같은 구성요건적 착오의 경우의 해결에 대하여 행위자에게 어느 정도의 범위에서 죄책을 물을 수 있는가에 대한 부합설의 논의가 있다.

2. 견해의 대립

(1) 구체적 부합설

구체적 부합설은 행위자가 구체적으로 인식한 사실의 범위까지 고의의 성립을 인정하는 견해이다. 이러한 견해에 따르면 사안의 경우에는 의도한 사실인 A에 대한 살인미수와 B에 대한 과실치상죄가 성립하며 이는 상상적 경합관계에 있게 된다.

(2) 법정적 부합설

법정적 부합설은 행위자가 인식한 사실과 동가치가 인정되는 범위까지 고의의 성립을 인정하는 견해이다. 이러한 견해에 의하면 사안의 경우에는 법정적 부합설에 의하면 A에 대한 살인고의가 B에게 전용될 수 있어 B에 대한 살인미수죄가 성립하게 된다.

3. 판례

판례는 이른바 ‘형수 조카 사건’에서 ‘소위 타격의 착오가 있는 경우라 할지라도 행위자의 살인의 범의성립에 방해가 되지 않는다’라고 하여 법정적 부합설의 입장을 따르고 있다.

4. 검토 및 사안의 해결

생각건대 고의는 사실적 기초가 중요하고 일반인의 법 감정이 형법 해석의 기준이 될 수 없다는 점에서 구체적 부합설이 타당하다. 이러한 구체적 부합설에 따르면 사안에서 丙은 인식한 사실인 A에 대한 살인미수와 B에 대한 과실치상죄의 상상적 경합이 된다.

III. 乙의 죄책

1. 논의점

사안과 같이 乙이 丙에게 A의 살해를 교사하였으나, 정범인 丙이 구체적 사실의 착오 중 방법의 착오를 범한 경우에 교사자인 乙의 죄책에 대하여 논의가 있다.

2. 견해의 대립

(1) 법정적 부합설의 입장

법정적 부합설에 의하면 구체적 사실의 착오인 한 교사자에게도 발생한 사실에 대한 고의범의 교사범이 성립한다고 본다. 따라서 사안의 경우에 乙은 발생사실인 B에 대한 살인미수의 교사범이 성립하게 된다.

(2) 구체적 부합설의 입장

- 1) 구체적 부합설에 의하면 견해가 나뉘어진다. 즉 ① 의도한 객체에 대한 고의미수범의 교사범과 발생사실에 대한 교사자 단독의 과실범의 상상적 경합을 인정하는 견해 ② 의도한 객체에 대한 고의미수범의 교사범만 인정하는 견해가 대립하고 있다.¹⁾
- 2) 乙이 丙을 교사하였다고 하더라도 丙이 범한 과실부분에 대하여는 특별한 사정이 없는 한 과실을 인정하기 어려우므로 乙에게는 교사한 부분인 A에 대한 살인미수죄의 교사범만 인정하는 견해가 타당하다.

3. 검토 및 사안의 해결

생각건대 고의는 사실적 기초가 중요하고 일반인의 법감정이 형법해석의 기준이 될 수 없다는 점에서 구체적 부합설이 타당하다. 구체적 부합설에 의할 경우 논의는 있지만 위에서 언급한 바와 같이 교사한 사실에 대하여만 교사범을 인정하여야 할 것이다. 따라서 사안에서 乙은 A에 대한 살인미수죄의 교사범만의 죄책을 진다.

IV. 甲의 죄책

1. 간접교사의 인정여부

(1) 논의점

사안에서 甲이 乙에게 A를 살해하도록 교사하였으나 乙이 직접 실행하지 않고 다시 丙에게 A를 살해하도록 교사한 경우로 甲의 교사행위는 간접교사에 해당한다. 이러한 간접교사의 경우에 교사범이 성립할 수 있는지에 대하여 논의가 있다.

(2) 견해의 대립

간접교사 내지는 재교사의 교사범 성립여부에 대하여는 ① 현행 형법에서는 구형법상의 '교사자의 교사자도 처벌한다'라는 제62조 제2항의 규정이 삭제되었으므로 간접교사의 가벌성을 부정하는 부정설과 ② 형법은 교사범의 요건으로 '타인을 교사하여 죄를 범한 자'라고만 규정하고 있을 뿐 그 방법에는 제한이 없으므로 피교사자가 반드시 정범이어야 하는 것은 아니므로 간접교사의 가벌성을 긍정하는 긍정설이 대립하고 있다.

(3) 판례의 태도

판례는 '甲이 乙에게 범죄를 저지르도록 요청한다 함을 알면서 甲의 부탁을 받고 甲의 요청을 乙에게 전달하여 乙로 하여금 범의를 야기케 하는 것은 교사에 해당한다'라고 하여 간접교사를 교사범으로 인정하고 있다.

1) 정범이 방법의 착오를 하고 있으므로, 정범이 객체의 착오의 경우에는 교사자도 객체의 착오로 본다는 견해는 나타날 수 없음도 주의하여야 한다.

(4) 검토 및 사안의 해결

생각건대 교사범이란 사람을 교사하여 범죄를 실행시킨다는 수정된 구성요건이므로 간접 교사도 교사범이라고 보는 긍정설이 타당하다. 사안에서 간접교사를 긍정하게 되면 甲은 乙과 동일한 교사범이 성립하므로, 위에서 검토했듯이 甲에게도 A에 대한 살인미수죄의 교사범이 성립할 수 있다.

2. 공범과 신분

(1) 논의점

사안은 존속살해죄의 직계비속이라는 가중적 신분을 가진 甲이 비신분자인 丙에게 가담한 경우이다. 현행법 제33조는 비신분자가 가중적 신분범에 가담한 경우를 규정하고 있으나, 사안처럼 가중적 신분을 가진 자가 비신분자에게 가담한 경우에는 규정을 두고 있지 않으므로 해석론상 논의가 있다.

(2) 견해의 대립

가중적 신분을 가진 자가 비신분자에게 가담한 경우에 대하여 ① 이론적으로 공범종속설에 충실하여야 하므로 정범보다 무거운 공범은 성립할 수 없으며, 실정법적으로도 제33조 단서의 취지에 따라 항상 경한 죄의 공범이 성립한다고 하는 보통살인죄의 교사범설 ② 제33조 단서는 책임의 개별화원칙을 규정한 것이므로 신분자는 언제나 신분범의 공범이 성립한다고 보는 존속살해죄의 교사범설이 대립하고 있다.

(3) 판례의 태도

판례는 소위 ‘모해위증사건’에서 목적을 신분으로 보면서 ‘신분관계로 인하여 형의 경중이 있는 경우에 신분이 있는 자가 신분이 없는 자를 교사하여 죄를 범하게 된 때에는 형법 제33조 단서가 위 제31조 제1항에 우선하여 적용됨으로써 신분이 있는 교사범이 신분이 없는 정범보다 중하게 처벌된다’고 하여 신분으로 인하여 형의 경중이 있는 경우에 교사자는 정범에 종속되지 않고 책임의 개별화에 따라 자신의 책임대로 처벌된다고 한다.

(4) 검토 및 사안의 해결

생각건대 자기책임의 원리에 따라 공범종속성보다는 책임의 개별화가 우선되어야 하므로 존속살해죄의 교사범설이 타당하다. 따라서 사안에서 甲은 A에 대한 존속살해미수죄의 교사범으로 처벌된다.

V. 사안의 해결

사안에서 ① 丙은 구체적 부합설에 의하는 한 A에 대한 살인미수죄와 B에 대한 과실치상죄의 상상적 경합이 되며 ② 乙은 교사범으로서 구체적 부합설에 의한다면 A에 대한 살인미수의 교사범이 성립하며 ③ 甲은 간접교사나 재교사를 긍정하게 되면 교사범이 성립할 수 있고, 특히 직계비속인 甲은 제33조 단서가 우선적용되어 책임개별화의 원칙에 따라 A에 대한 존속살해미수죄의 교사범이 성립한다.

관련판례

1. 형수 조카 사건

[사실관계] 甲은 그의 조카 乙을 업고 있는 형수 丙女를 살해하려고 몽둥이로 후려했다. 甲은 피를 흘리고 쓰러진 형수 丙女를 살해하려고 다시 한번 가격을 하였으나 형수의 등에 업힌 조카 乙의 머리에 맞아 乙이 현장에서 사망하였다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 소위 타격의 착오가 있는 경우라 할지라도 행위자의 살인의 범의성립에 방해가 되지 않는다.
(대판 1984.1.24. 83도2813)

2. 간접교사를 인정한 판례

갑이 을에게 범죄를 저지르도록 요청한다 함을 알면서 갑의 부탁을 받고 갑의 요청을 을에게 전달하여 을로 하여금 범의를 야기케 하는 것은 교사에 해당한다.(대판 1974.1.29. 73도3104)

3. 모해위증교사 사건

[사실관계] 甲은 A를 모해할 목적으로 A의 재판에서 증인으로 나설 乙에게 위증하도록 교사하여 乙이 기억에 반하는 증언을 하였다. 甲과 乙의 죄책은?

[판결요지] [1] 형법 제31조 제1항은 혐의의 공범의 일종인 교사범이 그 성립과 처벌에 있어서 정범에 종속한다는 일반적인 원칙을 선언한 것에 불과하고, 신분관계로 인하여 형의 경중이 있는 경우에 신분이 있는 자가 신분이 없는 자를 교사하여 죄를 범하게 한 때에는 형법 제33조 단서가 형법 제31조 제1항에 우선하여 적용됨으로써 신분이 있는 교사범이 신분이 없는 정범보다 중하게 처벌된다. [2] 형법 제152조 제1항과 제2항은 위증을 한 범인이 형사사건의 피고인 등을 '모해할 목적'을 가지고 있었는가 아니면 그러한 목적이 없었는가 하는 범인의 특수한 상태의 차이에 따라 범인에게 과할 형의 경중을 구별하고 있으므로, 이는 바로 형법 제33조 단서 소정의 '신분관계로 인하여 형의 경중이 있는 경우'에 해당한다고 봄이 타당하다. [3] 피고인이 갑을 모해할 목적으로 을에게 위증을 교사한 이상, 가사 정범인 을에게 모해의 목적이 없었다고 하더라도, 형법 제33조 단서의 규정에 의하여 피고인을 모해위증교사죄로 처단할 수 있다.(대판 1994.12.23. 93도1002)

♣ 돌발퀴즈

법정적 부합설은 동가치를 강조하는 학설이다.

정답 : ○

해설 : 법정적 부합설은 행위자가 인식한 부분과 동가치가 인정되는 부분까지 고의를 확정하는 견해이므로 타당한 지문이다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 다음 부합설 중 가장 주관적인 학설은?

- ① 구체적 부합설
- ② 법정적 부합설
- ③ 죄질 부합설
- ④ 구성요건적 부합설
- ⑤ 추상적 부합설

정답 : ⑤

해설 : 추상적 부합설이 가장 주관적인 학설이다.

2. 다음 부합설 중 가장 사실적 기초에 충실한 학설은?

- ① 구체적 부합설
- ② 법정적 부합설
- ③ 죄질 부합설
- ④ 구성요건적 부합설
- ⑤ 추상적 부합설

정답 : ①

해설 : 가장 사실적 기초에 충실한 학설은 구체적 부합설이다.

3. 공범과 신분을 규정한 조문은 몇 조인가?

- ① 제30조
- ② 제31조
- ③ 제32조
- ④ 제33조
- ⑤ 제34조

정답 : ④

해설 : 공범과 신분을 규정한 조문은 제33조이다.

♣ 학습내용 정리

1. 구체적 부합설은 행위자가 구체적으로 인식한 사실의 범위까지 고의의 성립을 인정하는 견해이다.
2. 법정적 부합설은 행위자가 인식한 사실과 동가치가 인정되는 범위까지 고의의 성립을 인정하는 견해이다.
3. 판례는 ‘甲이 乙에게 범죄를 저지르도록 요청한다 함을 알면서 甲의 부탁을 받고 甲의 요청을 乙에게 전달하여 乙로 하여금 범의를 야기케 하는 것은 교사에 해당한다’라고 하여 간접교사를 교사범으로 인정하고 있다.
4. 판례는 소위 ‘모해위증사건’에서 목적을 신분으로 보면서 ‘신분관계로 인하여 형의 경중이 있는 경우에 신분이 있는 자가 신분이 없는 자를 교사하여 죄를 범하게 된 때에는 형법 제33조 단서가 위 제31조 제1항에 우선하여 적용됨으로써 신분이 있는 교사범이 신분이 없는 정범보다 중하게 처벌된다’고 하여 신분으로 인하여 형의 경중이 있는 경우에 교사자는 정범에 종속되지 않고 책임의 개별화에 따라 자신의 책임대로 처벌된다고 한다.

제4강 개괄적 고의와 부작위범

♣ 학습목표

개괄적 고의와 부작위범에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

개괄적 고의 사례의 해결
부진정부작위범의 성립요건
정범과 공범의 구별

♣ 사전테스트

1. 인과관계의 착오 사례와 개괄적 고의 사례는 동일하다.

정답 : X

해설 : 인과관계의 착오 사례는 행위가 하나이지만, 개괄적 고의 사례는 행위가 둘 이상이라는 점에서 차이가 있다.

2. 부진정부작위범의 성립하기 위해서는 주체에게 보증인적 지위가 인정되어야 한다.

정답 : O

해설 : 보증인적 지위에 있는 자만이 부진정부작위범을 범할 수 있다.

3. 작위범에 의사의 연락없이 부작위로 가담한 자는 정범으로 보는 것이 판례이다.

정답 : X

해설 : 판례에 의하면 종범으로 파악하므로 타당하지 않은 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

대학생인 甲은 丙의 아들이다. 丙은 술주정뱅이에다 포악한 성격의 소유자로서 술만 먹으면 그의 부인 乙을 폭행, 학대하여 왔다. 이를 참다못한 乙은 丙에게 이혼해 줄 것을 수차 요구하였지만 丙은 그때마다 더욱 심하게 때렸다. 이에 甲은 丙을 살해하기로 결심하고 어느 날 丙이 술에 취하여 행패를 부리다가 잠을 자고 있는 사이에 甲은 丙의 목을 졸랐다. 丙이 의식을 잃자 甲은 丙이 죽은 것으로 생각하고 丙을 차에 싣고 가서 강에 버렸다. 乙은 甲이 丙을 살해하는 사실을 알고 있었음에도 불구하고 옆방에서 자는 척하고 있었다. 丙은 익사하였음이 밝혀졌다. 甲, 乙의 죄책은? (50점)

[해설]

I. 논점의 정리

- (1) 사안에서 직접 실행행위를 한 자는 甲이므로 먼저 甲의 죄책을 검토한 다음 이에 가담하고 있는 乙의 죄책을 검토하기로 한다.
- (2) 甲의 죄책과 관련하여 ① 전체적으로 존속살해죄의 기수의 구성요건에 해당하는지 미수의 구성요건에 해당하는지가 문제되고 ② 아버지가 평소에 폭행을 일삼아왔다는 점에서 위법성 또는 책임이 조각될 수 있는지가 문제된다.
- (3) 乙의 죄책과 관련하여 ① 甲의 범행을 알면서도 이를 방지하지 않은 행위가 부작위범에 해당할 수 있는지 ② 부작위범을 인정할 경우에도 정범인지 종범인지 ③ 신분 없는 자가 가중적 신분자의 범행에 가담한 경우이므로 제33조의 해석 등이 문제된다.

II. 甲의 죄책

1. 존속살해죄의 구성요건 해당성

(1) 논의점

사안에서 甲은 자신의 직계존속인 아버지 丙을 사망에 이르게 하고 있다. 문제는 丙의 사망이 甲이 丙의 목을 조른 행위에 의해 사망한 것이 아니라 사체유기의 고의로 강에 버린 행위에 의해 사망하였다는 점에 있다. 이러한 개괄적 고의 사례에서 甲에게 존속살해죄의 고의기수범을 인정할 수 있는지에 대하여 논의가 있다.

(2) 견해의 대립

개괄적 고의 사례의 해결에 대하여는 ① 제1행위와 제2행위를 하나의 행위로 보아 전체행위를 지배하는 개괄적 고의를 인정하여 고의기수범을 인정하자는 개괄적 고의설 ② 1행위와 제2행위를 분리하여 미수범과 과실범의 실체적 경합이 성립하는 것으로 보아야 한다는 미수와 과실의 경합설 ③ 객관적 귀속이론으로 해결하여 제2행위가 죄적인멸을 위한 전형적 행위인지 여부로 판단해야 한다는 객관적 귀속설 ④ 인과관계의 착오 문제로 보아 그 착오가 본질적인 것인지 비본질적인 것인지에 따라 구별하여 해결하는 인과관계착오설 등이 대립하고 있다.

(3) 판례의 태도

판례는 소위 '배우자 희롱 사건'에서 '피해자가 피고인들의 살해의 의도로 행한 구타행위에 의하여 직접 사망한 것이 아니라 죄적을 인멸할 목적으로 행한 매장행위에 의하여 사망하게 되었다 하더라도 전과정을 개괄적으로 보면 피해자의 살해라는 처음에 예견된 사실이

결국은 실현된 것으로서 피고인들은 살인죄의 죄책을 면할 수 없다'라고 하여 개괄적 고의를 인정하고 있다.

(4) 검토 및 사안의 해결

생각건대 개괄적 고의사례에서의 제2의 행위는 일반적으로 제1의 행위를 할 때 예견된 경우이므로 일반인의 법감정에 충실하기 위하여 개괄적 고의를 긍정하는 개괄적 고의설이 타당하다. 이러한 개괄적 고의설에 의하면 甲의 죄책은 존속살해죄의 기수범의 구성요건에 해당한다.

2. 위법성조각사유와 책임조각사유의 존부

(1) 정당방위의 인정 여부

- 1) 살해 당시 甲의 아버지 丙은 만취상태에 있어서 원칙적으로 침해의 현재성을 인정하기 어렵다. 그러나 아버지의 폭행·학대는 반복적이고 일상적이었으므로 장래의 폭행이 반복될 것이 예견되는바, 이에 대해 현재성을 인정하여 甲의 행위를 정당방위로 인정할 수 있는지가 문제된다.
- 2) 판례는 '의붓아버지 살해사건'에서 '침해행위가 그 후에도 반복하여 계속될 염려가 있었다면, 범행 당시 피고인의 신체나 자유 등에 대한 현재의 부당한 침해상태가 있었다고 볼 여지가 없는 것은 아니다'라고 판시하여 침해의 현재성을 인정하는 듯한 판시를 하고 있다.
- 3) 생각건대 정당방위는 긴급상태에서 국가에 의한 구제를 기대할 수 없는 예외적인 경우에 자기방어를 허용하는 것이므로 침해의 현재성을 확대할 수 없고, 계속적 침해는 장래의 침해에 불과하다는 점에서 현재성을 인정될 수 없다. 따라서 사안에 있어 甲의 행위는 정당방위에 해당하지 않는다.

(2) 긴급피난의 인정 여부

- 1) 긴급피난에서의 현재의 위난은 예측적 개념을 포함하므로 계속적 위난은 긴급피난에서 있어서 현재의 위난에 포함된다고 보는 것이 일반적이므로 사안에서는 긴급피난의 현재성은 인정될 수 있다.
- 2) 사안에서 긴급피난과 관련하여 문제되는 것은 상당성을 인정할 것인지가 문제되지만, 사안에서 甲의 행위는 보충성의 원칙과 균형성의 원칙이 인정되지 않는다. 따라서 사안에서 甲의 행위는 긴급피난에 해당하지 않는다.

(3) 책임조각사유의 존부

사안에서 아버지의 계속적인 폭행·학대에 시달려 온 甲이 아버지를 살해하는 행위가 기대가능성이 없는 행위로서 책임이 조각될 수 있는지가 문제된다. 그러나 사안에서는 甲이 특별히 적법행위에 대한 기대가능성이 없는 행위사정이 나타나 있지 않으므로 적법행위에 대한 기대불가능성에 의해서 책임이 조각될 수 없다.

3. 증거인멸죄의 성립여부

사안에서 甲은 丙이 죽은 것으로 생각하고 丙을 차에 싣고 가서 강에 버린 행위가 증거인멸죄에 해당하는지가 문제될 수 있으나, 증거인멸죄의 객체는 타인의 형사사건이나 징계사건에 관한 증거일 것을 요하므로 甲이 자기증거를 인멸하기 위해 丙을 강에 버린 행위는 증거인멸죄에 해당하지 않는다.

4. 甲의 죄책

사안에서 甲의 행위는 존속살해죄의 기수에 해당한다.

III. 乙의 죄책

1. 논의점

사안에서 甲의 어머니인 乙은 남편에 대한 甲의 살인행위를 공모하지 않았고, 다만 부작위로 가담하고 있다. 이러한 乙의 편면적 부작위가 ① 부작위에 의한 살인죄가 성립할 것인지 ② 부작위범이 성립한다면 乙의 가담형태가 정범인지 공범인지 ③ 乙은 신분 없는 자로서 가중적 신분자의 범행에 가담한 경우이므로 공범과 신분이 문제된다.

2. 부진정부작위범의 성립여부

(1) 부진정부작위범의 성립 요건

부진정부작위범이 성립하기 위하여는 乙에게 보증인적 지위가 인정되어야 한다. 보증인적 지위가 인정되기 위하여는 ① 구성요건적 상황 ② 작위의무 ③ 개별적인 행위가능성이 있어야 한다.

(2) 사안에의 적용

사안에서 ①과 ③의 요건은 이미 구비가 되어 있으므로 ②의 작위의무가 인정될 수 있는지가 문제된다. 그런데 乙의 작위의무는 부부간의 부양의무를 규정한 민법의 규정에서 발생하며, 그 기능은 생명과 신체를 보호하기 위한 가족관계에서의 보호의무이므로 乙은 丙의 생명에 대한 보증인지위가 인정된다. 따라서 사안에서 乙은 부진정부작위범이 성립한다.

3. 정범과 공범의 구별

(1) 논의점

사안에서 乙은 의사의 연락없는 甲이 자기의 남편인 丙을 살해하고 있음에도 불구하고 아무런 조치를 취하지 않았다. 이러한 경우에 甲의 작위에 의한 살인행위에 대하여 乙이 부작위로 가담한 행위가 정범인지 공범인지가 문제된다.

(2) 견해의 대립

이에 대하여는 ① 작위와 부작위를 구별할 필요없이 작위범에 있어서 구별기준을 그대로 적용하면 된다는 작위·부작위 구별 불요설 ② 작위와 부작위의 형태로 수인이 범행에 참가한 경우에 부작위에 의해 참가한 자는 원칙적으로 종범이 된다는 원칙적 종범설 ③ 원칙적으로 정범이 되지만 일정한 경우에는 제한적으로 종범이 성립한다는 원칙적 정범설 등이 대립하고 있다.

(3) 판례의 태도

판례는 ‘은행지점장 배임방조 사건’에서 ‘은행지점장이 정범인 부하직원들의 범행을 인식하면서도 그들의 은행에 대한 배임행위를 방치하였다면 업무상 배임죄의 방조범이 성립한다’라고 하여 작위의무 있는 자의 편면적 가담에 대하여 부작위에 의한 방조를 인정하고 있어 원칙적 종범설을 따르고 있다.

(4) 검토 및 사안의 해결

생각건대 ① 의사의 연락이 없는 동시범의 경우에는 작위의무자의 부작위라고 하더라도 적극적인 행위가 결여되어 있으므로 행위지배가 있다고 보기 어려워 정범성을 인정하기 어려우며 ② 부작위범에 대하여 임의적 감경을 하지 않는 현행법하에서는 부작위로 가담한 자에 대하여는 방조범을 인정함으로써 입법상의 불비를 해석론상 보완할 수 있기 때문에 원칙적 종범설이 타당하다. 이러한 원칙적 종범설에 의하면 乙은 부작위에 의한 방조범만이 성립할 수 있다.

4. 공범과 신분

(1) 논의점

사안에서 정범인 甲은 존속살해죄가 성립하고, 乙은 방조범이 성립한다. 이러한 경우에 신분 없는 乙에게 존속살해죄의 방조범을 인정할 것인지 아니면 보통살인죄의 방조범의 성립을 인정할 것인지에 대해 형법 제33조의 해석과 관련하여 논의가 있다.

(2) 제33조 본문과 단서의 적용범위

이에 대하여 ① 다수설은 제33조 본문은 진정신분범에 대한 공범성립과 과형을, 단서는 부진정신분범에 대한 공범성립과 과형을 규정한 것이라고 보고 있으며 ② 판례는 제33조 본문은 진정신분범과 부진정신분범에 대한 공범성립에 관한 규정이고, 단서는 부진정신분범의 과형에 관한 규정이라고 보고 있다.

(3) 검토 및 사안의 해결

생각건대 제33조 본문이 ‘신분관계로 인하여 성립될 범죄’라고 규정하고 있음에도 부진정신분범에 대해서 적용하는 것은 문언의 가능한 한계를 넘는 것이므로 다수설이 타당하다. 따라서 사안은 비신분자인 乙이 가중적 신분범의 신분자에게 가담한 경우로서 제33조 단서만 적용되어 乙은 부작위에 의한 보통살인죄의 방조범이 성립한다.

IV. 사안의 해결

(1) 甲은 직계존속인 아버지 丙을 살해하였으므로 존속살해죄의 기수범이 성립한다.

(2) 乙은 아들인 甲의 존속살해범행에 가담하였으나, 제33조 단서에 의해 乙은 보통살인죄의 방조범이 성립한다.

관련판례

1. 배우자 희롱 사건

[사실관계] 甲은 평소 乙이 약간 저능아인 자신의 처 丙에게 젖을 달라는 등의 희롱을 하는데 심한 불만을 품어오던 중 순간적으로 분노가 폭발하여 乙을 살해하기로 마음먹고 乙을 쓰러뜨리고 배 위에 올라타 머리와 가슴을 돌맹이로 내려쳤다. 乙이 뇌진탕 등으로 정신을 잃고 축 늘어지자 그가 죽은 것으로 오인하고 그 사체를 몰래 파묻어 증거를 인멸할 목적으로 乙을 그 곳에서 약 150m 떨어진 개울가로 끌고 가 웅덩이를 파고 매장하였으나 실제로 乙은 웅덩이 속에서 질식사하여 사망하였다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 피해자가 피고인들의 살해의 의도로 행한 구타행위에 의하여 직접 사망한 것은 아니라 죄적을 인멸할 목적으로 행한 매장행위에 의하여 사망하게 되었다 하더라도 전과정을 개괄적으로 보면 피해자의 살해라는 처음에 예견된 사실이 결국은 실현된 것으로서 피고인들은 살인죄의 죄책을 면할 수 없다.(대판 1988.6.28. 88도650)

2. 김보은양 사건

[사실관계] 甲은 약 12살 때부터 의붓아버지인 乙의 강간행위에 의하여 정조를 유린당한 후 계속적으로 乙과의 성관계를 강요받아 왔고, 생모조차 乙의 폭행·협박을 두려워하여 이에 응하도록 조장·방치하였다. 그러던 중 甲은 남자친구인 丙에게 乙과의 관계를 고백하고 같이 번민하다가 乙을 살해하고 강도로 위장하기로 공모한 후, 甲과 丙은 乙이 술에 취하여 잠들어 있는 방에 몰래 들어가 丙이 乙을 깨운 후 식칼로 乙의 심장을 1회 찔러 그 자리에서 살해하였다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 원심이 인정한 바와 같이, 피고인 김△은이 약 12살때부터 의붓아버지인 피해자의 강간행위에 의하여 정조를 유린당한 후 계속적으로 이 사건 범행 무렵까지 피해자와의 성관계를 강요 받아왔고, 그 밖에 피해자로부터 행동의 자유를 간섭받아 왔으며, 또한 그러한 침해행위가 그 후에도 반복하여 계속될 염려가 있었다면, 피고인들의 이 사건 범행당시 피고인 김△은의 신체나 자유 등에 대한 현재의 부당한 침해

상태가 있었다고 볼 여지가 없는 것은 아니나, 그렇다고 하여도 판시와 같은 경위로 이루어진 피고인들의 이 사건 살인행위가 형법 제21조 소정의 정당방위나 과잉방위에 해당한다고 하기는 어렵다. 정당방위가 성립하려면 침해행위에 의하여 침해되는 법익의 종류, 정도, 침해의 방법, 침해행위의 완급과 방위행위에 의하여 침해될 법익의 종류, 정도 등 일체의 구체적 사정들을 참작하여 방위행위가 사회적으로 상당한 것이었다고 인정할 수 있는 것이어야 할 것인데(당원 1966.3.15. 선고 66도63 판결; 1984.6.12. 선고 84도683 판결 각 참조), 피고인들이 사전에 판시와 같은 경위로 공모하여 범행을 준비하고, 술에 취하여 잠들어 있는 피해자의 양팔을 눌러 꼼짝 못하게 한 후 피해자를 깨워 피해자가 제대로 반항할 수 없는 상태에서 식칼로 피해자의 심장을 찔러 살해한다는 것은, 당시의 상황에 비추어도 사회통념상 상당성을 인정하기가 어렵다고 하지 않을 수 없고, 피고인들의 범행의 동기나 목적을 참작하여도 그러하므로, 원심이 피고인들의 판시 행위가 정당방위에 해당한다거나 야간 기타 불안스러운 상태 하에서 공포, 경악, 흥분 또는 당황으로 인하여 그 정도를 초과한 경우에 해당한다는 피고인들의 주장을 배척한 조치도 정당하고, 거기에 소론과 같은 법리를 오해하거나 채증법칙을 어긴 위법이 있다고 할 수 없다. 정당방위의 성립요건으로서의 방어행위에는 순수한 수비적 방어뿐 아니라 적극적 반격을 포함하는 반격방어의 형태도 포함됨은 소론과 같다고 하겠으나, 그 방어행위는 자기 또는 타인의 법익침해를 방위하기 위한 행위로서 상당한 이유가 있어야 하는 것인데, 피고인들의 판시 행위가 위에서 본 바와 같이 그 상당성을 결여한 것인 이상 정당방위행위로 평가될 수는 없는 것이므로, 원심이 피고인들의 이 사건 범행이 현재의 부당한 침해를 방위할 의사로 행하여졌다고보다는 공격의 의사로 행하여졌다고 인정한 것이 적절하지 못하다고 하더라도, 정당방위행위가 되지 않는다는 결론에 있어서는 정당하여, 이 사건 판결의 결과에 영향이 없는 것이다.(대판 1992.12.22. 92도2540)

3. 은행장이 부하직원의 배임행위 방치한 사건

[사실관계] 은행장 甲은 그의 부하직원 乙・丙이 부정한 방법으로 A주식회사에 대하여 자금유통의 편의를 봐주고 있는 사실을 발견하였음에도 불구하고 이를 방치하였다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 형법상 방조는 작위에 의하여 정범의 실행행위를 용이하게 하는 경우는 물론, 직무상의 의무가 있는 자가 정범의 범죄행위를 인식하면서도 그것을 방지하여야 할 제반조치를 취하지 아니하는 부작위로 인하여 정범의 실행행위를 용이하게 하는 경우에도 성립된다 할 것이므로 은행지점장이 정범인 부하직원들의 범행을 인식하면서도 그들의 은행에 대한 배임행위를 방치하였다면 배임죄의 방조범이 성립된다.(대판 1984.11.27. 84도1906)

4. 입점 점포 사건

바이어를 보조하여 특정매장에 관한 상품관리 및 고객들의 불만사항 확인 등의 업무를 담당하는 백화점 직원이 입점점포의 위조상표 부착 상품 판매사실을 알고도 방치한 경우에는 점주나 종업원에게 즉시 그 시정을 요구하고 바이어 등 상급자에게 보고하여 시정하도록 할 근로계약상 및 조리상 의무를 이행하지 않아 점주의 상표법위반 및 부정경쟁방지법 위반행위의 실행을 용이하게 한 경우와 동등한 형법적 가치가 있는 것으로 볼 수 있으므로 부작위에 의하여 점주의 상표법위반 및 부정경쟁방지법 위반행위를 방조한 것이다.(대판 1997.3.14. 96도1639)

5. 제33조의 해석에 대한 판례

신분관계가 없는 자가 그러한 신분관계에 있는 자와 공모하여 위 상호신용금고법위반죄를 저질렀다면, 그러한 신분관계가 없는 자에 대하여는 형법 제33조 단서에 의하여 형법 제355조 제2항에 따라 처단하여야 할 것인바, 그러한 경우에는 신분관계가 없는 자에게도 일단 업무상배임으로 인한 상호신용금고법 제39조 제1항 제2호 위반죄가 성립한 다음 형법 제33조 단서에 의하여 중한 형이 아닌 형법 제355조 제2항에 정한 형으로 처벌되는 것이다.(대판 1997.12.26. 97도2609)

♣ 돌발퀴즈

개괄적 고의와 개괄적 과실 사례는 제1행위의 고의의 내용에 따라 구별된다.

정답 : O

해설 : 제1행위가 살인의 고의이면 개괄적 고의사례가 되고, 제1행위가 상해의 고의이면 개괄적 과실사례가 된다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 다음 중 개괄적 고의사례에 관한 학설이 아닌 것은?

- ① 개괄적 고의설
- ② 미수설
- ③ 객관적 귀속설
- ④ 계획실현설
- ⑤ Frank의 공식

정답 : ⑤

해설 : Frank의 공식은 중지미수의 자의성에 대한 학설이다.

2. 다음 중 개괄적 고의사례에 관한 판례의 태도는?

- ① 기수설
- ② 미수설
- ③ 객관적 귀속설
- ④ 계획실현설
- ⑤ 인과관계착오의 특수유형설

정답 : ①

해설 : 판례는 개괄적 고의사례를 기수범으로 보고 있다.

3. 다음 정범과 공범의 구별에 대한 학설 중 조건설을 바탕으로 한 학설은?

- ① 형식적 객관설
- ② 실질적 객관설
- ③ 주관설
- ④ 목적적 행위지배설
- ⑤ 기능적 행위지배설

정답 : ③

해설 : 조건설의 입장에서는 객관적인 면은 모두 등가치이므로 주관적인 의사에 따라 정범과 공범을 구별하는 주관설을 따른다.

♣ 학습내용 정리

1. 개괄적 고의 사례의 해결에 대하여는 ① 개괄적 고의설 ② 미수와 과실의 경합설 ③ 객관적 귀속설 ④ 인과관계착오설 등이 대립하고 있다.
2. 판례는 소위 '배우자 희롱 사건'에서 '피해자가 피고인들의 살해의 의도로 행한 구타행위에 의하여 직접 사망한 것이 아니라 죄적을 인멸할 목적으로 행한 매장행위에 의하여 사망하게 되었다 하더라도 전과정을 개괄적으로 보면 피해자의 살해라는 처음에 예견된 사실이 결국은 실현된 것으로서 피고인들은 살인죄의 죄책을 면할 수 없다'라고 하여 개괄적 고의를 인정하고 있다.
3. 판례는 '의붓아버지 살해사건'에서 '침해행위가 그 후에도 반복하여 계속될 염려가 있었다면, 범행 당시 피고인의 신체나 자유 등에 대한 현재의 부당한 침해상대가 있었다고 볼 여지가 없는 것은 아니다'라고 판시하여 침해의 현재성을 인정하는 듯한 판시를 하고 있다.
4. 보증인적 지위가 인정되기 위하여는 ① 구성요건적 상황 ② 작위의무 ③ 개별적인 행위가 능성이 있어야 한다.
5. 판례는 '은행지점장 배임방조 사건'에서 '은행지점장이 정범인 부하직원들의 범행을 인식하면서도 그들의 은행에 대한 배임행위를 방치하였다면 업무상 배임죄의 방조범이 성립한다'라고 하여 작위의무 있는 자의 편면적 가담에 대하여 부작위에 의한 방조를 인정하고 있어 원칙적 종범설을 따르고 있다.

제5강 영아살해죄와 공범과 신분

♣ 학습목표

영아살해죄와 공범과 신분에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

간접정범 일반론

영아살해죄의 직계존속의 범위

감경적신분과 공범과 신분

♣ 사전테스트

1. 간접정범의 정범표지는 실행지배이다.

정답 : X

해설 : 간접정범의 정범표지는 우월적 의사지배이다.

2. 판례는 영아살해죄의 주체를 법률상의 직계존속으로 제한 해석하고 있다.

정답 : O

해설 : 타당한 지문이다.

3. 영아살해죄에 가담한 비신분자는 영아살해죄의 공범으로 처벌하는 것이 판례의 태도이다.

정답 : X

해설 : 판례의 논지에 따르면 영아살해죄에 가담한 비신분자의 책임개별화원칙에 따라 보통 살인죄의 공범으로 처벌되므로 타당하지 않은 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

甲男과 乙女는 사실혼 관계로 乙女가 출산한 직후 양육하기 어렵다고 판단하여 乙에게 애를 없애라고 지시하였고, 乙은 도저히 스스로 애를 살해할 수가 없어 자신의 동생인 丙에게 독이 든 우유를 주면서 먹이게 하여 丙이 이를 먹여 애를 사망하게 하였다. 甲, 乙, 丙의 죄책은? (30점)

[해설]

I. 논점의 정리

사안에서 甲, 乙, 丙의 죄책을 논리적 순서에 따라 ① 丙의 행위로 영아가 살해되었으므로 丙의 죄책을 검토하고 ② 丙을 이용하여 영아를 살해한 乙의 죄책을 검토하고 ③ 乙에게 영아를 없애라고 지시한 甲의 행위의 죄책의 순서로 검토한다.

II. 丙의 죄책

사안에서 乙과 丙사이에 공모가 있었다는 사정은 없고, 또한 丙에게 乙이 자신에게 건네준 우유에 독약이 들어있다는 것을 인식했다는 사정도 없어 丙에게는 살해의 고의를 인정하기 곤란하다. 또한 丙은 자신의 조카에게 우유를 먹이면서 영아의 친모인 乙이 그 안에 독약을 넣었으리라고는 통상 예상할 수 없는 일이므로 이를 확인하지 않았다고 하여 과실이 있다고 보기도 어렵다. 따라서 丙은 애를 살해한 행위에 대하여는 고의 또는 과실이 없으므로 죄가 성립하지 않으므로 무죄이다.

III. 乙의 죄책

1. 서 언

사안에서 乙은 양육이 불가능하다고 판단하여 자신의 영아를 살해하고 있으므로 형법 제 251조의 영아살해죄가 문제된다. 그런데 사안에서는 乙이 직접 살해하는 것이 아니라, 처벌받지 않는 丙의 행위를 이용하여 영아를 살해하고 있으므로 간접정범의 성립여부가 문제된다.

2. 간접정범 일반론

현행법 제34조 제1항에 의하면 ‘어느 행위로 인하여 처벌되지 아니하는 자 또는 과실범으로 처벌되는 자를 교사 또는 방조하여 범죄행위의 결과를 발생하게 한 자는 교사 또는 방조의 예에 의하여 처벌한다’라고 하여 간접정범을 규정하고 있다. 그리고 다수설은 행위지배설에 입각하여 간접정범이 성립하기 위하여는 행위자에 대한 우월적 의사지배가 있을 때에 간접정범을 인정한다.

3. 사안의 적용

사안에서 乙은 처벌되지 않는 丙을 이용하고, 丙은 단순한 도구로서 乙의 우월적 의사에 의해 지배·조종되었으므로 乙은 영아살해죄의 간접정범이 성립한다.

IV. 甲의 죄책

1. 서 언

甲은 乙과 사실혼 관계에 있으면서 乙이 출산한 직후 양육하기 어렵다고 판단하여 乙에게 애를 없애라고 지시하였으므로 사안에서 甲의 범죄형태는 교사범의 요건을 구비한 것으로 판단된다. 그런데 문제는 ① 사실상의 아버지인 甲도 영아살해죄의 주체가 될 수 있는지가 문제되고 ② 만약 甲에게 영아살해죄의 주체가 인정되지 않을 때 영아살해죄만 성립하는 乙에게 가담한 것이 어떠한 형법적 효과가 있는지가 문제된다.

2. 甲의 제251조 직계존속 해당여부

(1) 논의점

사안에서 甲은 사실혼관계에 있는 사실상의 아버지이므로 이러한 사실상의 아버지가 영아살해죄의 주체가 될 수 있는지에 대하여 논의가 있다. 즉 영아살해죄의 주체는 이론상으로는 산모에 한정하여야 하지만, 법조문에는 ‘직계존속’이라고 명시하고 있어 영아살해죄의 주체의 범위에 대하여 논의가 있다.

(2) 견해의 대립

이에 대하여는 ① 영아살해죄의 근본정신이 출산으로 인한 산모의 흥분상태 때문에 그 책임이 감경된다고 함에 있으므로 본죄의 주체는 산모에 제한하여야 한다는 산모한정설 ② 법률상의 직계존속만이 본죄의 직계존속이라는 법률상의 직계존속 한정설 ③ 입법론은 별문제로 하고 형법이 그 주체를 산모로 제한하지 않고 직계존속이라고 한 이상 법률상의 직계존속은 물론 사실상의 직계존속도 모두 본죄의 주체가 될 수 있다고 보는 견해인 사실상의 직계존속 포함설이 대립하고 있다.

(3) 판례의 태도

판례는 ‘사실상의 아버지가 영아 살해한 사건’에서 ‘남녀가 사실상 동거한 관계가 있고 그 사이에 영아가 분만되었다 하여도 그 남자와 영아와의 사이에 법률상 직계존속, 비속의 관계가 있다 할 수 없으므로 그 남자가 영아를 살해한 경우에는 보통살인죄에 해당한다’라고 하여 법률상의 직계존속 한정설을 따르고 있다.

(4) 결론 및 사안의 해결

생각건대 원칙적인 논리상 산모로 한정하는 것이 바람직하지만, 현행 형법이 직계존속이라고 명시하고 있으므로 법률상의 직계존속만으로 한정하는 것이 타당하다. 이러한 법률상의 직계존속 한정설에 따르면 사안에서 甲은 영아살해죄의 주체가 될 수 없다.

3. 공범과 신분

(1) 논의점

甲은 직계존속의 신분이 없음에도 직계존속인 乙을 교사하여 영아를 살해하였는바, 甲에게 영아살해죄의 교사범이 성립할 것인가 아니면 보통살인죄의 교사범이 성립할 것인가가 문제된다.

(2) 견해의 대립

비신분자가 감경적 신분범에 가담한 경우에 비신분자의 죄책에 대하여는 ① 이론적으로 공범종속설에 충실하여야 하므로 정범보다 무거운 공범은 성립할 수 없으며, 실정법적으로 제33조의 취지에 따라 항상 경한 죄의 공범이 성립한다고 하는 영아살해죄의 교사범설 ② 제33조 단서는 책임의 개별화원칙을 규정한 것이므로 가중사유와 마찬가지로 감경사유도 연

제나 신분자 자신에게 한하고 공범자에게는 미치지 않는다는 보통살인죄의 교사범설이 대립하고 있다.

(3) 판례의 태도

판례는 소위 ‘모해위증사건’에서 목적을 신분으로 보면서 ‘신분관계로 인하여 형의 경중이 있는 경우에 신분이 있는 자가 신분이 없는 자를 교사하여 죄를 범하게 된 때에는 형법 제33조 단서가 위 제31조 제1항에 우선하여 적용됨으로써 신분이 있는 교사범이 신분이 없는 정범보다 중하게 처벌된다’고 하여 신분으로 인하여 형의 경중이 있는 경우에 교사자는 정범에 종속되지 않고 책임의 개별화에 따라 자신의 책임대로 처벌된다고 한다. 이는 사안에서 보통살인죄의 교사범설을 따르는 것과 유사한 논리이다.

(4) 검토 및 사안의 해결

생각건대 자기책임의 원리에 따라 공범종속성보다는 책임의 개별화가 우선되어야 하므로 존속살해죄의 교사범설이 타당하다. 따라서 사안에서 甲에게는 보통살인죄의 교사범이 성립한다.

V. 사안의 해결

- (1) 丙은 영아살해에 대해 고의 및 과실이 없으므로 무죄가 된다.
- (2) 乙이 丙을 이용하여 영아를 살해한 행위는 영아살해죄의 간접정범에 해당한다.
- (3) 甲이 乙을 교사하여 영아를 살해한 행위는 형법 제33조 단서의 취지에 따라 보통살인죄의 교사범이 성립한다.

관련판례

1. 사실상의 아버지가 영아 살해한 사건

남녀가 사실상 동거한 관계가 있고 그 사이에 영아가 분만되었다 하여도 그 남자와 영아와의 사이에 법률상 직계존속, 비속의 관계가 있다 할 수 없으므로 그 남자가 영아를 살해한 경우에는 보통살인죄에 해당한다.(대판 1970.3.10. 69도2285)

2. 모해위증교사 사건

[사실관계] 甲은 A를 모해할 목적으로 A의 재판에서 증인으로 나설 乙에게 위증하도록 교사하여 乙이 기억에 반하는 증언을 하였다. 甲과 乙의 죄책은?

[판결요지] [1] 형법 제31조 제1항은 협의의 공범의 일종인 교사범이 그 성립과 처벌에 있어서 정범에 종속한다는 일반적인 원칙을 선언한 것에 불과하고, 신분관계로 인하여 형의 경중이 있는 경우에 신분이 있는 자가 신분이 없는 자를 교사하여 죄를 범하게 한 때에는 형법 제33조 단서가 형법 제31조 제1항에 우선하여 적용됨으로써 신분이 있는 교사범이 신분이 없는 정범보다 중하게 처벌된다. [2] 형법 제152조 제1항과 제2항은 위증을 한 범인이 형사사건의 피고인 등을 ‘모해할 목적’을 가지고 있었는가 아니면 그러한 목적이 없었는가 하는 범인의 특수한 상태의 차이에 따라 범인에게 과할 형의 경중을 구별하고 있으므로, 이는 바로 형법 제33조 단서 소정의 ‘신분관계로 인하여 형의 경중이 있는 경우’에 해당한다고 봄이 타당하다. [3] 피고인이 갑을 모해할 목적으로 을에게 위증을 교사한 이상, 가사 정범인 을에게 모해의 목적이 없었다고 하더라도, 형법 제33조 단서의 규정에 의하여 피고인을 모해위증교사죄로 처단할 수 있다.(대판 1994.12.23. 93도1002)

♣ 돌발퀴즈

공동정범의 정범표지는 기능적 행위지배이다.

정답 : ○

해설 : 타당한 지문이다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 간접정범의 정범표지는?

- ① 실행지배
- ② 기능적 행위지배
- ③ 목적적 행위지배
- ④ 우월적 의사지배
- ⑤ 전구성요건적 의무위반

정답 : ④

해설 : 간접정범의 정범표지는 우월적 의사지배이다.

2. 현행법상 간접정범의 처벌은?

- ① 정범으로 처벌한다.
- ② 교사범으로 처벌한다.
- ③ 방조범으로 처벌한다.
- ④ 교사 또는 방조의 예에 의하여 처벌한다.
- ⑤ 정범으로 처벌하되 임의적으로 감경한다.

정답 : ④

해설 : 제34조 제1항 참조

3. 다음 중 신분이 아닌 것은?

- ① 공무원
- ② 사람
- ③ 남자
- ④ 직계존속
- ⑤ 상습성

정답 : ②

해설 : 사람은 신분이 아니다.

♣ 학습내용 정리

1. 현행법 제34조 제1항에 의하면 ‘어느 행위로 인하여 처벌되지 아니하는 자 또는 과실범으로 처벌되는 자를 교사 또는 방조하여 범죄행위의 결과를 발생하게 한 자는 교사 또는 방조의 예에 의하여 처벌한다’라고 하여 간접정범을 규정하고 있다.
2. 판례는 ‘사실상의 아버지가 영아 살해한 사건’에서 ‘남녀가 사실상 동거한 관계가 있고 그 사이에 영아가 분만되었다 하여도 그 남자와 영아와의 사이에 법률상 직계존속, 비속의 관계가 있다 할 수 없으므로 그 남자가 영아를 살해한 경우에는 보통살인죄에 해당한다’라고 하여 법률상의 직계존속 한정설을 따르고 있다.
- 3 비신분자가 영아살해죄에 가담한 경우에 비신분자의 죄책에 대하여는 ① 이론적으로 공범 종속설에 충실하여야 하므로 정범보다 무거운 공범은 성립할 수 없으며, 실정법적으로 제33조의 취지에 따라 항상 경한 죄의 공범이 성립한다고 하는 영아살해죄의 교사범설 ② 제33조 단서는 책임의 개별화원칙을 규정한 것이므로 가중사유와 마찬가지로 감경사유도 언제나 신분자 자신에게 한하고 공범자에게는 미치지 않는다는 보통살인죄의 교사범설이 대립하고 있다.

제6강 미필적 고의와 특수상해죄

♣ 학습목표

미필적 고의와 특수상해죄에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

미필적고의와 인식있는 과실의 구별

특수폭행죄와 특수상해죄에 있어 위험한 물건의 휴대와 자동차

부진정부작위범의 성립요건과 중지미수

♣ 사전테스트

1. 미필적 고의와 인식있는 과실의 구별에 대하여 판례는 인용설을 따르고 있다.

정답 : ○

해설 : 판례는 인용설을 따르므로 타당한 지문이다.

2. 자동차는 항상 위험한 물건에 해당한다는 것이 판례이다.

정답 : X

해설 : 위험한 물건은 상대적 개념이며 판례도 자동차의 위험한 물건 해당 여부를 상대적으로 파악하므로 타당하지 않은 지문이다.

3. 보증인적 지위가 인정되기 위해서는 구성요건적 상황, 작위의무, 개별적 행위가능성이 있어야 한다.

정답 : ○

해설 : 부진정부작위범이 성립하기 위한 보증인적 지위의 성립요건으로 타당한 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

甲과 乙은 친구 A로부터 각 3천만 원을 빌렸으나 약속한 날짜에 돈을 갚지 못했다. 甲은 자기 집에 찾아 온 A가 채무변제를 독촉하자 이를 모면하려고 집에 차를 몰고 나갔다. 그 순간 A가 甲의 차 앞에 서서 빗을 갠다고 소리치자 甲은 A가 상처를 입어도 어쩔 수 없다고 생각하면서 차 앞 범퍼로 들이받아 A를 넘어뜨려 4주의 치료를 요하는 상처를 입혔다. 몇 개월 후 乙과 A는 단 둘이서 등산을 하여 산 중턱 절벽 위 큰 바위에 앉아 휴식을 취하다가 채무변제 문제로 언쟁을 벌이던 중 A가 화를 내면서 갑자기 일어나는 과정에서 미끄러져 절벽 아래로 떨어져 두 다리에 골절상을 입었다. 등산전문가인 乙은 A를 구조하지 않으면 A가 사망할 수 있다는 사실을 알고 있었고, A를 쉽게 구조할 수도 있었으나 이번 기회에 A를 죽이기로 마음먹고 A를 버려둔 채 하산해 버렸다. 그러나 乙은 귀가하던 중 자신의 잘못을 뉘우치고 A를 구조하러 사고 현장에 갔으나 A는 이미 사고현장을 지나던 등산객들에 의하여 구조되었다. 甲과 乙의 형사책임을 논하시오. (20점)

[해설]

1. 甲의 죄책

(1) 논의점

사안에서 甲은 자동차를 이용하여 A에게 상해를 입히고 있으므로 형법 제258조의2 제1항의 특수상해죄가 문제된다.²⁾ 이하 주관적 요건과 객관적 요건에 대하여 검토한다.

(2) 주관적 구성요건

- 1) 사안에서 A에게 상해를 입힌 甲의 행위에 상해의 미필적 고의가 있는지가 문제되는바, 미필적 고의와 인식있는 과실을 구별하는 기준에 대하여 논의가 있다.
- 2) 미필적 고의와 인식있는 과실과의 구별 기준에 대하여는 가능성설, 개연성설, 인용설 및 감수설 등이 대립하고 있으나, 판례는 ‘이른바 미필적 고의라 함은 결과의 발생이 불확실한 경우 즉 행위자에 있어서 그 결과발생에 대한 확실한 예견은 없었으나 그 가능성은 인정하는 것으로, 이러한 미필적 고의가 있었다고 하려면 결과발생의 가능성에 대한 인식이 있음은 물론 나아가 결과발생을 용인하는 내심의 의사가 있음을 요한다’라고 하여 인용설을 따르고 있다.

3) 사안의 적용

종래의 다수설이자 판례의 입장인 인용설에 따르면, 사안에서는 甲이 ‘A가 상처를 입어도 어쩔 수 없다’라고하여 그 결과발생을 인용하고 있으므로 甲에게는 상해의 고의가 인정된다.

(3) 객관적 구성요건

- 1) 사안에서 甲은 자동차를 이용하여 A에게 상해를 입히고 있으므로 이것이 형법 제258조의2 제1항의 특수상해죄가 성립하는지가 문제된다. 이와 관련하여 위 사안이 위험한 물건을 휴대한 것인지를 검토한다.

2) 종래 특수상해죄는 폭처법에 있었으나 2016.1.6. 해당 조문이 삭제되고, 2016.1.6. 형법에 특수상해죄가 신설되었다. <형법> 제258조의2 (특수상해) ① 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제257조제1항 또는 제2항의 죄를 범한 때에는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다. ② 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제258조의 죄를 범한 때에는 2년 이상 20년 이하의 징역에 처한다. ③ 제1항의 미수범은 처벌한다. [본조신설 2016.1.6]

2) 자동차가 제258조의2 제1항의 ‘위험한 물건’에 해당하는지에 대하여, 종래 폭처법과 관련된 판례에서는 ‘어떤 물건이 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 제3조 제1항에서 정한 위험한 물건에 해당하는지 여부는 구체적인 사안에서 사회통념에 비추어 그 물건을 사용하면 상대방이나 제3자가 생명 또는 신체에 위험을 느낄 수 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다’라고 하고 있다. 이러한 기준에 따르면 사안에서의 자동차는 위험한 물건에 해당한다.

3) 자동차를 이용한 경우가 ‘위험한 물건을 휴대’한 것인지에 대하여는 ① 휴대는 사전적 의미 그대로 몸에 지니는 것을 의미하므로 휴대에 포함되지 않는다는 부정설과 ② 휴대는 소지하는 것에 한정하지 않고 널리 ‘이용하여’와 같은 의미라고 해석하여 휴대에 포함된다는 긍정설인 판례의 태도가 대립하고 있다. 생각건대 자동차를 이용한 범죄를 억지하기 위한 형사정책적 측면을 고려하면 긍정설인 판례의 입장이 타당하다.

(4) 사안의 해결

휴대의 의미에 대하여 판례의 입장인 긍정설에 따르면 사안에서 甲은 제258조의2 제1항의 특수상해죄가 성립한다.

2. 乙의 죄책

(1) 논의점

乙의 A에 대한 죄책은 부작위에 의한 살인죄가 문제된다. 사안에서는 乙이 A를 죽이기로 마음먹고 있으므로 살인죄의 주관적 구성요건은 문제가 되지 아니한다. 다만 ① 부작위범의 성립요건인 보증인지위에 있는지와 ② 자신의 잘못을 뉘우치고 A를 구하려 갔으나 이미 구조된 경우에 중지미수의 성립여부가 문제된다.

(2) 부작위범의 성립요건

사안과 같은 부진정부작위범이 성립하기 위하여는 乙이 ① 구성요건적 상황 ② 작위의무 ③ 개별적인 행위가능성이 있어 보증인적 지위에 있어야 한다. 사안에서는 ① A가 스스로를 구조할 수 없는 구성요건적 상황이 있으며 ② 조리에 의한 작위의무가 인정되며 ③ 등산전문가인 乙이므로 개별적 행위가능성도 있었으므로 乙은 보증인적 지위에 있으며, 그럼에도 불구하고 부작위하였으므로 부작위범이 성립한다.

(3) 중지미수의 성립여부

- 1) 사안에서 A가 구조되었지만, 乙에게 중지미수가 인정될 수 있는가가 문제된다.
- 2) 먼저 주관적 요건으로서 자의성이 문제되지만, 사안에서 乙은 자신의 잘못을 뉘우치고 있으므로 자의성에 대한 어떠한 견해에 따르더라도 자의성이 인정된다.
- 3) 객관적 요건으로서 乙이 구하려 갔지만 이미 구조된 경우에 중지미수를 인정할 수 있는가에 대하여 ① 중지미수의 성립요건을 형식적으로 고찰하여 행위자의 방지행위에 의하여 결과가 발생하지 않은 것은 아니므로 중지미수가 성립할 여지가 없어 중지미수의 성립을 부정하는 부정설 ② 중지미수의 성립요건을 실질적으로 고찰하여 중지미수의 성립을 긍정하는 긍정설이 대립하고 있다.
- 4) 생각건대 중지미수에 대하여 감경사유로 인정하고 있는 현행법상으로 중지미수의 폭을 좁게 해석할 이유가 없으므로 중지미수 긍정설이 타당하다. 이러한 입장에 따르면 사안에서 乙은 살인죄의 중지미수가 인정된다.

관련판례

1. 미필적 고의에 대한 판례의 입장

이른바 미필적 고의라 함은 결과의 발생이 불확실한 경우 즉 행위자에 있어서 그 결과발생에 대한 확실한 예견은 없었으나 그 가능성은 인정하는 것으로, 이러한 미필적 고의가 있었다고 하려면 결과발생의 가능성에 대한 인식이 있음은 물론 나아가 결과발생을 용인하는 내심의 의사가 있음을 요한다.(대판 1987.2.10. 86도2338)

2. 자동차를 이용하여 다른 자동차를 충격한 사건

[사실관계] 甲은 배우자와 이혼분쟁을 하는 상태에 있었다. 그러던 어느 날 배우자 측의 사람들이 甲의 아들을 승낙없이 자동차에 태우고 떠나려고 하였다. 甲은 피해자들 일행을 상대로 급하게 추격 또는 제지하기 위해 자신의 소형승용차(라노스)로 피해자들의 중형승용차(쏘나타)를 충격하였다. 충격할 당시 두 차량 모두 정차하여 있다가 막 출발하는 상태에서 차량 속도가 빠르지 않았으며 상대방 차량의 손괴 정도가 그다지 심하지 않았고, 자동차의 충격으로 피해자들이 입은 상해의 정도도 비교적 경미하였다. 甲의 죄책은?

[판결요지] [1] 어떤 물건이 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 제3조 제1항에 정한 '위험한 물건'에 해당하는지 여부는 구체적인 사안에서 사회통념에 비추어 그 물건을 사용하면 상대방이나 제3자가 생명 또는 신체에 위험을 느낄 수 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다. 이러한 판단 기준은 자동차를 사용하여 사람의 생명 또는 신체에 위험을 가하거나 다른 사람의 재물을 손괴한 경우에도 마찬가지로 적용된다. [2] 자동차를 이용하여 다른 자동차를 충격한 사안에서, 충격 당시 차량의 크기, 속도, 손괴 정도 등 제반 사정에 비추어 위 자동차가 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 제3조 제1항에 정한 '위험한 물건'에 해당하지 않는다고 한 사례.(대판 2009.3.26. 2007도3520) ※ 본 판례는 형법 개정이전의 폭처법과 관련된 판례이지만, 개정형법상의 특수상해죄와 그 법리가 동일하므로 법리만을 참조하시기 바랍니다.

3. 승용차 앞 범퍼 사건

[사실관계] 甲은 교통관리직원인 乙이 견인료 납부를 요구하면서 자신의 승용차의 앞을 가로막자 승용차를 그대로 전진시켜 승용차 앞범퍼 부분으로 乙의 다리부분을 들이받고 약 1미터 정도 진행하여 乙을 땅바닥에 넘어뜨렸다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 폭력행위등처벌에관한법률 제3조 제1항에 있어서 '위험한 물건'이라 함은 흥기는 아니라고 하더라도 널리 사람의 생명, 신체에 해를 가하는 데 사용할 수 있는 일체의 물건을 포함한다고 풀이할 것이므로, 본래 살상용·파괴용으로 만들어진 것뿐만 아니라 다른 목적으로 만들어진 칼·가위·유리병·각종공구·자동차 등은 물론 화학약품 또는 사주된 동물 등도 그것이 사람의 생명·신체에 해를 가하는 데 사용되었다면 본조의 '위험한 물건'이라 할 것이며, 한편 이러한 물건을 '휴대하여'라는 말은 소지뿐만 아니라 널리 이용한다는 뜻도 포함하고 있다.(대판 1997.5.30. 97도597) ※ 본 판례는 형법 개정이전의 폭처법과 관련된 판례이지만, 개정형법상의 특수상해죄와 그 법리가 동일하므로 법리만을 참조하시기 바랍니다.

♣ 돌발퀴즈

판례는 위험한 물건의 '휴대'에서의 휴대의 의미를 '널리 이용하여' 라고 해석하고 있다.

정답 : O

해설 : 판례는 휴대의 의미를 가장 넓게 보고 있으므로 타당한 지문이다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 미필적 고의와 인식있는 과실의 구별에 대한 판례의 태도는?

- ① 가능성설
- ② 개연성설
- ③ 인용설
- ④ 의사설

⑤ 인식설

정답 : ③

해설 : 판례는 인용설의 태도를 취하고 있다.

2. 위험한 물건의 판단에 대한 판례의 태도는?

- ① 행위자의 주관적에 따라 판단한다.
- ② 행위의 태양에 따라 객관적으로 판단한다.
- ③ 주관과 객관을 절충하여 판단한다.
- ④ 구체적 사안에서 사회통념에 따라 판단한다.
- ⑤ 개별상황마다 법적으로 판단한다.

정답 : ④

해설 : 종래 폭처법과 관련된 판례는 ‘어떤 물건이 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 제3조 제1항에서 정한 위험한 물건에 해당하는지 여부는 구체적인 사안에서 사회통념에 비추어 그 물건을 사용하면 상대방이나 제3자가 생명 또는 신체에 위험을 느낄 수 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다’라고 하고 있다.

3. 부진정부작위범의 성립요건 중 행위론에 속하는 것은?

- ① 일반적 행위가능성
- ② 구성요건적 상황
- ③ 개별적 행위가능성
- ④ 작위의무
- ⑤ 보증인적 지위

정답 : ①

해설 : 일반적 행위가능성이 있어야 행위성을 인정받을 수 있다.

♣ 학습내용 정리

1. 미필적 고의와 인식있는 과실과의 구별 기준에 대하여는 가능성설, 개연성설, 인용설 및 감수설 등이 대립하고 있으나, 판례는 ‘이른바 미필적 고의라 함은 결과의 발생이 불확실한 경우 즉 행위자에 있어서 그 결과발생에 대한 확실한 예견은 없었으나 그 가능성은 인정하는 것으로, 이러한 미필적 고의가 있었다고 하려면 결과발생의 가능성에 대한 인식이 있음은 물론 나아가 결과발생을 용인하는 내심의 의사가 있음을 요한다’라고 하여 인용설을 따르고 있다.
2. 자동차가 ‘위험한 물건’에 해당하는지에 대하여, 종래 폭처법과 관련된 판례는 ‘어떤 물건이 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 제3조 제1항에서 정한 위험한 물건에 해당하는지 여부는 구체적인 사안에서 사회통념에 비추어 그 물건을 사용하면 상대방이나 제3자가 생명 또는 신체에 위험을 느낄 수 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다’라고 하고 있다.
3. 자동차를 이용한 경우가 ‘위험한 물건을 휴대’한 것인지에 대하여는 ① 휴대는 사전적 의미 그대로 몸에 지니는 것을 의미하므로 휴대에 포함되지 않는다는 부정설과 ② 휴대는 소지하는 것에 한정하지 않고 널리 ‘이용하여’와 같은 의미라고 해석하여 휴대에 포함된다는 긍정설인 판례의 태도가 대립하고 있다.

제7강 위법성조각사유의 전제사실의 착오

♣ 학습목표

위법성조각사유의 전제사실의 착오에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

상해치사죄의 성립요건

위법성조각사유의 전제사실의 착오

간접정범과 교사범의 구별

♣ 사전테스트

1. 엄격책임설은 위법성조각사유의 전제사실의 착오를 법률의 착오로 취급한다.

정답 : ○

해설 : 엄격책임설은 구성요건적 착오를 제외하고는 모두 법률의 착오로 보므로 타당한 지문이다.

2. 소극적 구성요건표지이론은 위법성조각사유의 전제사실의 착오를 사실의 착오로 해결한다.

정답 : ○

해설 : 소극적 구성요건표지이론은 위법성조각사유의 전제사실의 착오에 대해 사실을 착오를 직접 적용하여 고의를 조각시키므로 타당한 지문이다.

3. 간접정범의 정범표지는 우월적인 의사지배에 있다.

정답 : ○

해설 : 타당한 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

여대생 甲은 밤늦게 귀가하던 중 노숙자 A가 구걸하기 위해 따라오는 것을 추행범으로 착각하고 피하였다. 그러나 A가 계속하여 따라오자 甲은 도로변의 상점으로 들어가서 상점 주인 乙에게 A를 가리키면서 추행범이 따라오니 도와달라고 하였다. 이에 乙은 A가 구걸하는 노숙자인 것을 알았으나 평소 자기 상점 주위에서 어슬렁거리며 귀찮게 구는 것을 못마땅하게 생각하던 터라 이번 기회에 A를 혼내주었으면 좋겠다고 생각하고 甲에게 몽둥이를 건네주었다. 상점을 나선 甲에게 A가 접근하자 두려움을 느낀 甲은 乙로부터 건네받은 몽둥이로 A의 다리 부분을 가격하였다. A는 쓰러지면서 머리를 담에 부딪쳐 일어나지 못하였다.

甲이 떠난 후 아침 그곳을 지나던 丙은 A가 쓰러져 있는 것을 보고 전날 A로부터 아무런 이유 없이 폭행을 당한 것이 떠올라 넘어져 있는 A의 옆구리를 발로 차고 머리를 주먹으로 수회 가격하였다. 丙은 머리에 피를 흘리면서 쓰러져 있는 A를 그대로 두면 사망할 수도 있다고 생각했음에도 불구하고 그대로 둔 채 그곳을 떠났다. 즉시 구호조치를 취했더라면 A가 사망에 이르지 않았을 것이나 방치하여 결국 A는 뇌출혈로 사망하였다. 甲의 죄책을 논하시오. (20점)

[해설]

1. 사안의 정리

사안에서 甲은 노숙자 A가 다가오는 것을 추행범으로 오인하고 자기 방위의 의사로 몽둥이로 다리를 가격하고 있다. 이에 몽둥이에 맞은 A가 쓰러졌으며, 그 이후 丙의 행위에 의하여 사망에 이르게 된다. 이 경우의 甲의 죄책에 대하여는 ① 甲이 범한 범죄의 구성요건을 확정하여야 하며 ② 구성요건을 확정된 경우에 위법성이 조각되기 위한 전제상황이 없음에도 이를 있다고 생각하고 방위한 부분에 대한 죄책이 문제된다.

2. 구성요건의 확정

(1) 상해죄의 구성요건 해당성

사안의 경우에 몽둥이를 맞으면 일반적으로 멍이 들거나, 부러지거나 하는 점에 비추어 상해의 고의가 있다고 보는 것이 타당하다. 그리고 사안에서는 A가 기절하고 있으므로 상해의 결과도 실현되었다고 볼 수 있다. 따라서 甲의 행위는 상해죄의 구성요건에 해당한다.

(2) 丙의 행위의 개입으로 사망한 부분에 대한 평가

甲이 몽둥이로 A를 기절시킨 후에 丙의 행위가 개입되어 A가 사망에 이르고 있다. 결과적 가중범인 상해치사죄를 검토할 수 있으나 甲에게 상해치사죄의 죄책을 묻기 위해서는 추가적인 요건으로 인과관계와 예견가능성이 요구된다. 사안의 경우에는 몽둥이로 다리를 내리친 甲에게 A의 사망에 대한 인과관계와 객관적 귀속을 인정함에는 무리가 있고, 설령 인정된다 하더라도 甲에게는 A의 사망에 대한 예견가능성이 있었다고 평가하기 어려우므로 상해치사에 대한 죄책을 묻는 것은 무리가 있다. 따라서 甲에게는 A에 대한 상해죄의 구성요건에만 해당한다.

3. 위법성의 전제사실에 대한 착오의 해결

(1) 논의점

甲에게 상해죄의 구성요건을 확정한다고 하여도 甲은 위법성조각사유의 전제사실에 대한 착오에 빠져 있으므로 甲의 죄책범위에 대하여 논의가 있다.

(2) 견해의 대립

1) 엄격책임설의 입장

엄격책임설은 위법성조각사유의 전제사실의 착오는 법률의 착오로 보게 된다. 이러한 엄격책임설에 의하면 甲에게 상해의 고의가 인정되어 고의범의 성립여부를 논할 수 있지만, 법률의 착오로 보아 제16조가 적용되어 ‘정당한 이유’의 유무에 따라 고의범이 인정되거나 무죄가 된다. 사안의 경우에는 정당한 이유가 있다고 보기 어려워 상해죄의 죄책을 지게 될 것으로 평가된다.

2) 제한책임설

위법성조각사유의 전제사실에 대한 착오는 사실의 착오는 아니지만 사실적인 부분에 착오가 있으므로 사실의 착오와의 구조적 유사성을 근거로 사실의 착오가 유추적용 되어야 한다는 견해이다. 이러한 제한책임설에 의하면 사실의 착오의 유추적용으로 고의가 조각되어 과실범의 성립여부만이 문제되고, 사안에서는 과실치상죄를 인정하게 된다.

3) 소극적 구성요건표지이론

이단계범죄체계를 취하는 소극적 구성요건표지이론에 의하여 위법성조각사유의 전제사실은 소극적 구성요건요소가 되므로 이에 대한 착오는 사실의 착오로 취급하게 되어 고의가 조각된다는 견해이다. 이러한 소극적 구성요건표지이론에 의하면 사실의 착오의 직접적용으로 고의가 조각되어 과실범의 성립여부만이 문제되고, 사안에서는 과실치상죄를 인정하게 된다.

4) 법효과제한적 책임설

고의의 이중적 지위를 바탕으로 하여 위법성조각사유의 전제사실의 착오는 구성요건적 고의는 있지만 책임고의가 없어 전체적인 고의가 성립하지 않게 되어 고의범이 성립하지 않는다는 견해이다. 이러한 법효과제한적 책임설에 의하면 사안의 경우에는 책임고의가 탈락하여 고의범이 성립하지 않고 과실치상죄만을 인정하게 된다.

(3) 판례

위법성조각사유의 전제사실에 대한 착오에 관한 명시적인 판례는 아직은 없어 보인다. 다만 가정적으로 상정하여 판단한 사안을 비롯한 몇 개의 유사판례만이 있어 판례의 태도는 명확하지 않다.

(4) 결론과 사안의 해결

생각건대 현재 일반적으로 확립된 합일태적 범죄체계인 고의의 이중적 지위를 전제로 하고 있는 법효과제한적 책임설이 ① 구체적 타당성 ② 논리적 우수성 ③ 체계적합성 ④ 악의의 공범자의 처벌가능성을 모두 구비하고 있으므로 가장 타당하다. 이러한 법효과 제한적 책임설에 따르면 甲은 과실치상죄의 죄책을 지게 된다.

관련판례

주교사 사건

피해자를 아파트에 유인하여 양 손목과 발목을 노끈으로 묶고 입에 반창고를 두 겹으로 붙인 다음 양 손목을 묶은 노끈은 창틀에 박힌 시멘트 못에, 양 발목을 묶은 노끈은 방문손잡이에 각각 잡아매고 얼굴에 모포를 씌워 감금한 후 수차 아파트를 출입하다가 마지막 들어갔을 때 피해자가 이미 탈진 상태에 이르러 박카스를 마시지 못하고 그냥 흘러버릴 정도였고 피고인이 피해자의 얼굴에 모포를 덮어씌워 놓고 그냥 나오면서 피해자를 그대로 두면 죽을 것 같다는 생각이 들었다면, 피고인이 위와 같은 결과발생의 가능성을 인정하고 있으면서도 피해자를 병원에 옮기지 않고 사경에 이른 피해자를 그대로 방치한 소위는 피해자가 사망하는 결과에 이르더라도 용인할 수밖에 없다는 내심의 의사 즉 살인의 미필적 고의가 있다고 할 것이다. (대판 1982.11.23. 82도2024)

♣ 돌발퀴즈

제한 책임설은 위법성조각사유의 전제사실의 착오를 사실의 착오로 보지는 않지만 사실의 착오를 유추적용하여 불법고의를 조각시키는 견해이다.

정답 : ○

해설 : 타당한 지문이다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 상해치사죄의 성립요건이 아닌 것은?

- ① 고의에 의한 상해행위
- ② 사망의 결과 발생
- ③ 인과관계
- ④ 예견가능성
- ⑤ 중상해

정답 : ⑤

해설 : 중상해는 상해치사죄의 성립요건이 아니다.

2. 다음 중 오상방위의 해결에 대한 학설이 아닌 것은?

- ① 엄격책임설
- ② 제한책임설
- ③ 소극적 구성요건표지이론
- ④ 법효과제한적 책임설
- ⑤ 책임설

정답 : ⑤

해설 : 책임설은 위법성인식의 체계적 지위에 관한 학설이다.

3. 과실범으로 처벌되는 자를 교사한 자의 죄책은?

- ① 방조범
- ② 교사범
- ③ 간접정범
- ④ 공동정범
- ⑤ 결과적 가중범

정답 : ③

해설 : 제34조 제1항 참조

♣ 학습내용 정리

1. 제한책임설은 위법성조각사유의 전제사실에 대한 착오는 사실의 착오는 아니지만 사실적인 부분에 착오가 있으므로 사실의 착오와의 구조적 유사성을 근거로 사실의 착오가 유추적용되어야 한다는 견해이다.
2. 소극적 구성요건표지이론은 이단계범죄체계를 취하는 소극적 구성요건표지이론에 의하여 위법성조각사유의 전제사실은 소극적 구성요건요소가 되므로 이에 대한 착오는 사실의 착오로 취급하게 되어 고의가 조각된다는 견해이다.
3. 법효과제한적 책임설은 고의의 이중적 지위를 바탕으로 하여 위법성조각사유의 전제사실의 착오는 구성요건적 고의는 있지만 책임고의가 없어 전체적인 고의가 성립하지 않게 되어 고의범이 성립하지 않는다는 견해이다.

제8강 과실의 범위와 인과관계

♣ 학습목표

과실의 범위와 인과관계에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

신과실론과 신뢰의 원칙

적법한 대체행위 이론

규범의 보호범위 이론

♣ 사전테스트

1. 구과실론과 신과실론에서의 과실의 성립범위는 동일하다.

정답 : X

해설 : 신과실론에 의하면 과실의 성립범위가 좁아지므로 타당하지 않은 지문이다.

2. 사회적 상당성의 특칙이 허용된 위험의 이론이다.

정답 : O

해설 : 타당한 지문이다.

3. 허용된 위험이론이 도로교통상에서 발전된 특칙이 신뢰의 원칙이다.

정답 : O

해설 : 타당한 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

제한속도가 60km/h인 도로에서 자신의 승용차를 운전하던 甲은 녹색신호가 바뀌기 전에 ‘卜’형 삼거리를 통과하기 위하여 약 70km/h의 속도로 주행하던 중, 반대편에서 정지신호를 무시하고 중앙선을 넘어서 좌회전하는 A의 오토바이를 미처 보지 못하고 승용차의 앞 범퍼로 오토바이의 우측후미를 충격하였다. 이로 인해 A는 중상을 입고 구급차에 실려 인근 병원으로 후송되던 중 사망하였다. 업무상과실치사(형법 제268조)의 혐의로 기소된 甲이 자신의 무죄를 주장할 수 있는 근거를 설명하시오. (25점)

[해설]

1. 논점의 정리

사안에서 甲은 제한속도를 위반하여 운전한 행위에 의하여 A를 충격하여 사망에 이르게 하였는바, 甲의 무죄를 선고받도록 하기 위해서는 ① 신뢰의 원칙을 적용하여 甲의 과실을 인정하지 않거나 ② 甲의 과실이 인정된다 하더라도 A의 사망결과에 대한 인과관계가 없다는 점을 주장할 수 있다.

2. 과실을 부정하여 무죄를 주장

(1) 규칙위반행위와 신뢰의 원칙

사안과 같이 운전자 甲이 스스로 먼저 규칙위반을 한 경우에도 신뢰의 원칙이 적용될 수 있는가가 문제된다. 그러나 행위자의 규칙위반이 사고발생에 영향을 미친 경우에 한하여 신뢰의 원칙의 적용이 제한될 뿐, 그러한 규칙위반이 사고발생에 결정적인 원인이 아닌 경우에는 여전히 신뢰의 원칙이 적용되어야 한다.

(2) 판례의 태도

판례도 사안과 유사한 사안에서 ‘신호등에 의하여 교통정리가 행해지고 있는 삼거리의 교차로를 녹색등화에 따라 직진하는 차량의 운전자는 특별한 사정이 없는 한 다른 차량들도 교통법규를 준수하고 충돌을 피하기 위하여 적절한 조치를 취할 것으로 믿고 운전하면 족하고, 대향차선 위의 다른 차량이 신호를 위반하고 직진하는 자기 차량의 앞을 가로질러 좌회전할 경우까지 예상하여 그에 따른 사고발생을 미리 방지하기 위한 특별한 조치까지 강구하여야 할 업무상의 주의의무는 없다’라고 하여 과실을 부정하고 있다.

(3) 사안의 해결

甲이 제한속도를 위반한 규칙위반행위가 있었으나 사고발생의 결정적 원인은 甲의 행위로 인한 것이 아니라 A가 정지신호를 무시하고 중앙선을 침범하여 오토바이를 운전한 행위이므로 甲에게는 여전히 신뢰의 원칙이 적용되어 甲의 과실은 부정된다.

3. 적법한 대체행위이론으로 인과관계를 부정하여 무죄를 주장

(1) 적법한 대체행위 사례

사안에서 만약 甲이 제한속도를 위반한 행위에 대해 과실이 인정된다고 할 경우라도 발생한 결과인 A의 사망에 대한 인과관계가 인정되지 않는다면 甲은 무죄가 된다. 과실범의 미수는 처벌하지 않기 때문이다. 인과관계를 부정할 수 있는 이론 중 먼저 적법한 대체행위사례와 관련된 것을 먼저 검토한다.

(2) 견해의 대립

적법한 대체행위 사례의 해결에 대해서는 ① 행위자가 적법한 행위를 하였다면 결과가 발생하지 않았을 것이라는 것이 확실히 증명되는 경우에만 객관적 귀속을 인정하자는 무죄추정설(적법한 대체행위이론) ② 주의의무를 위반한 과실행위가 있으면 그 자체로서 과실범의 구성요건이 보호하려는 법익이 침해될 위험이 증가하였으므로 객관적 귀속을 긍정하자는 위험증대설 ③ 적법한 대체행위이론과 위험증대설을 결합하여 과실행위에 의하여 행위객체에 대하여 상당한 정도로 위험을 증대시켰을 때만 객관적 귀속을 인정하자는 절충설이 대립하고 있다.

(3) 판례의 태도

판례는 ‘운전자가 제한속도를 지키며 진행하였다면 피해자가 좌회전하여 진입하는 것을 발견한 후에 충돌을 피할 수 있었다는 등의 사정이 없는 한 운전자가 제한속도를 초과하여 과속으로 진행한 잘못이 있다 하더라도 그러한 잘못과 교통사고의 발생 사이에 상당인과관계가 있다고 볼 수는 없다’고 판시하여 상당인과관계설의 입장에 서면서도 적법한 대체행위이론과 동일한 결론에 이르고 있다.

(4) 사안의 해결

적법한 대체행위 이론에 의하면, 사안에서 발생한 결과를 甲에게 귀속시키기 위해서는 甲이 규정속도를 준수했더라도 A의 오토바이와의 충돌을 피할 수 있다는 것이 명백하거나 고도의 개연성이 있어야 하는데, 사안은 甲이 규정속도를 준수했더라도 사고발생을 피할 수 없었던 경우로서 동일한 결과가 발생하였을 것이기 때문에 객관적 귀속은 부정된다.

4. 규범의 보호범위 이론을 주장하여 인과관계를 부정하여 무죄를 주장

(1) 규범의 보호범위 이론의 의의

규범의 보호범위이론이란 행위자의 주의의무위반행위가 있더라도 결과가 행위를 통하여 침해되는 규범의 보호영역 밖에서 발생할 때 객관적 귀속을 부정하는 이론을 말한다.

(2) 도로교통법상 제한속도 규정의 목적

도로교통법상 제한속도 규정의 목적은 자동차운전자가 위험에 처했을 때 적시에 브레이크를 밟아 위험을 피하거나, 혹은 정지할 수 있도록 하는데 있는 것이지, 자동차를 특정한 지점에 보다 늦게 도착하도록 함으로써 교통사고를 방지하기 위하여 마련된 것은 아니다.

(3) 사안의 해결

甲은 제한속도규정에 위반하였지만 발생한 결과인 A의 오토바이와의 충돌은 도로교통법의 제한속도 규정의 보호범위를 벗어난 것으로서 甲의 행위에 객관적으로 귀속시킬 수 없다. 따라서 사안에서 규범의 보호범위이론에 따라 인과관계를 부정하여 甲의 무죄를 주장할 수 있다.

관련판례

1. 삼거리 사건

[사실관계] 甲은 녹색신호에 따라 ‘T’자형 삼거리의 교차로에서 제한속도를 위반하여 직진하였다. 그 무렵 반대차선에서 乙이 갑자기 신호를 위반하여 도로중앙선을 침범하면서 좌회전하던 도중 甲의 차량과 충돌하여 교통사고가 발생하였다. 甲은 이 교통사고에 대하여 책임을 지는가?

[판결요지] 신호등에 의하여 교통정리가 행해지고 있는 삼거리의 교차로를 녹색등화에 따라 직진하는 차량의 운전자는 특별한 사정이 없는 한 다른 차량들도 교통법규를 준수하고 충돌을 피하기 위하여 적절한 조치를 취할 것으로 믿고 운전하면 족하고, 대향차선 위의 다른 차량이 신호를 위반하고 직진하는 자기 차

량의 앞을 가로질러 좌회전할 경우까지 예상하여 그에 따른 사고발생을 미리 방지하기 위한 특별한 조치까지 강구하여야 할 업무상의 주의의무는 없고, 위 직진차량 운전자가 사고지점을 통과할 무렵 제한 속도를 위반하여 과속운전 한 잘못이 있었다 하더라도 그러한 잘못과 교통사고의 발생과의 사이에 상당인과관계가 있다고 볼 수 없다.(대판 1993.1.15. 92도2579)

♣ 돌발퀴즈

공동의료작업에서 수직적 분업관계에 해당하는 의사와 간호사 사이에서 의사에게는 원칙적으로 신뢰의 원칙이 적용되지 않는다.

정답 : ○

해설 : 지휘감독 관계에 있는 의사에게는 신뢰의 원칙이 적용되지 않으므로 타당한 지문이다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 다음 중 과실범을 처벌하지 않는 범죄는?

- ① 과실치상죄
- ② 과실장물취득죄
- ③ 실화죄
- ④ 과실일수죄
- ⑤ 과실교통방해죄

정답 : ②

해설 : 장물취득죄는 업무상 또는 중과실장물죄만 처벌하며, 단순과실장물취득죄는 벌하지 아니한다.

2. 다음 중 피고인에게 가장 불리한 학설은?

- ① 적법한 대체행위 이론
- ② 무죄추정설
- ③ 위험증대설
- ④ 절충설
- ⑤ 규범의 보호범위 이론

정답 : ③

해설 : 위의 학설 중 위험증대설의 입장이 피고인에게 가장 불리하다.

3. 다음 학설 중 성질이 다른 학설 하나는?

- ① 적법한 대체행위 이론
- ② 무죄추정설
- ③ 결과책임설
- ④ 절충설
- ⑤ 규범의 보호범위 이론

정답 : ③

해설 : 결과책임설은 고의, 과실과 관련없이 발생한 결과에 대하여 책임을 지는 것을 말하는 것으로서 과실을 전제로 인과관계를 논하는 다른 학설들과 차이가 있다.

♣ 학습내용 정리

1. 판례는 ‘신호등에 의하여 교통정리가 행해지고 있는 삼거리의 교차로를 녹색등화에 따라 직진하는 차량의 운전자는 특별한 사정이 없는 한 다른 차량들도 교통법규를 준수하고 충돌을 피하기 위하여 적절한 조치를 취할 것으로 믿고 운전하면 족하고, 대향차선 위의 다른 차량이 신호를 위반하고 직진하는 자기 차량의 앞을 가로질러 좌회전할 경우까지 예상하여 그에 따른 사고발생을 미리 방지하기 위한 특별한 조치까지 강구하여야 할 업무상의 주의의무는 없다’라고 하여 과실을 부정하고 있다.
2. 적법한 대체행위 사례의 해결에 대해서는 ① 행위자가 적법한 행위를 하였다면 결과가 발생하지 않았을 것이라는 것이 확실히 증명되는 경우에만 객관적 귀속을 인정하자는 무죄 추정설(적법한 대체행위이론) ② 주의의무를 위반한 과실행위가 있으면 그 자체로서 과실범의 구성요건이 보호하려는 법익이 침해될 위험이 증가하였으므로 객관적 귀속을 긍정하자는 위험증대설 ③ 적법한 대체행위이론과 위험증대설을 결합하여 과실행위에 의하여 행위객체에 대하여 상당한 정도로 위험을 증대시켰을 때만 객관적 귀속을 인정하자는 절충설이 대립하고 있다.

제9강 증뢰물전달죄와 불법원인급여

♣ 학습목표

증뢰물전달죄와 불법원인급여에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

증뢰물 전달죄의 성립요건

불법원인급여와 횡령죄

협박죄의 기수시기

♣ 사전테스트

1. 증뢰물전달죄가 성립하기 위해서는 전달자가 공무원에게 뇌물을 전달하여야 한다.

정답 : X

해설 : 증뢰물전달죄는 뇌물에 공할 물건임을 알고 교부받으면 바로 범죄가 성립하고 이를 공무원에게 전달할 필요는 없으므로 타당하지 않은 지문이다.

2. 판례는 원칙적으로 불법원인급여물에 대한 횡령죄를 부정한다.

정답 : O

해설 : 타당한 지문이다.

3. 현행법은 협박죄에 대한 미수규정을 두고 있다.

정답 : O

해설 : 타당한 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

세무사 甲은 건설회사 사장 A로부터 세무조사와 관련하여 담당공무원에게 1천만원을 전달해 달라는 부탁을 받았으나, 그 돈을 자신의 사무실 운영경비로 소비해 버렸다. 이 사실을 알게 된 A가 甲에게 돈을 돌려 줄 것을 요구하였으나, 甲은 돌려줄 수 없다고 하면서 계속해서 돈을 돌려달라고 요구하면 그 사실을 폭로하겠다고 협박하였다. 그러나 A는 돈이 전달되지 않은 이상 자신은 아무런 거리낄 것이 없다고 생각하고 甲을 경찰에 신고해 버렸다. 甲의 죄책을 논하시오. (25점)

[해설]

1. 쟁점의 정리

사안에서 甲의 죄책과 관련하여 ① A로부터 1천만원을 받은 행위가 증뢰물전달죄에 해당하는지 여부 ② 불법원인급여물인 1천만원을 전달하지 않고 영득한 행위가 횡령죄에 해당하는지 여부 ③ 乙을 협박한 행위가 기수인지 미수인지 여부가 문제된다.

2. A로부터 1천만원을 받은 행위

- (1) 증뢰물전달죄는 증뢰행위에 제공할 목적으로 제3자에게 금품을 교부하거나 제3자가 그 정을 알면서 교부받음으로써 성립하는 것이고, 제3자가 증뢰자로부터 교부받은 금품을 수뢰할 사람에게 전달하였는지는 범죄성립에 영향을 미치지 않는다.
- (2) 사안에서 甲은 A로부터 담당공무원에게 전달할 목적으로 그 정을 알면서 1천만원을 받은 것이므로 받은 즉시 증뢰물전달죄는 성립하고 이후 甲이 이를 소비하였다고 하더라도 증뢰물전달죄의 성립에 영향을 미치지 아니한다.

3. 1천만원을 임의로 소비한 행위

(1) 논의점

사안에서 1천만원은 뇌물에 공할 물건으로서 불법원인급여물이다. 이러한 불법원인급여물을 甲이 영득한 경우에 횡령죄가 성립할 수 있는가에 대하여 논의가 있다.

(2) 견해의 대립

이에 대하여는 ① 형법의 가벌성 여하는 형법의 독자적 입장에서 규율되어야 하므로 불법원인급여의 경우에도 횡령죄는 성립할 수 있다는 긍정설 ② 불법원인급여 물건의 소유권은 반사적으로 수탁자에게 귀속되므로 횡령죄가 성립할 수 없다는 부정설 ③ 불법원인급여를 다시 불법원인급여물과 불법원인위탁물로 구분한 후에 전자의 경우에는 횡령죄가 성립하지 않으나, 후자의 경우에는 횡령죄가 성립한다는 구별설이 대립하고 있다.

(3) 판례의 태도

판례는 불법원인급여물에 대한 횡령죄의 성립을 원칙적으로 부정한다. 즉 판례는 ‘불법원인급여물의 소유권은 급여를 받은 상대방에게 귀속된다’고 보아 타인의 재물이 아니므로 횡령죄가 성립할 수 없다고 본다. 그러나 예외적으로 ‘포주와 윤락녀 사건’에서는 ‘포주의 불법성이 윤락녀의 불법성보다 현저히 크므로 화대의 소유권이 여전히 윤락녀에게 속한다’는 이유로 횡령죄의 성립을 긍정하고 있다.

(4) 검토 및 사안의 해결

생각건대 긍정설에 따르면 국가기관이 불법행위를 조장하는 문제점이 있으므로 원칙적으로 부정설이 타당하다. 그러나 판례에서 보듯이 양자가 모두 불법을 범하고 있을 때에는 예외적으로 불법성을 비교하여 횡령죄의 성부를 구체적으로 판단하는 것이 타당하다. 사안의 경우 甲이 A로부터 받은 돈은 불법원인급여에 해당하고 甲의 불법성이 A의 불법성보다 현저히 크다고 할 수 없어 甲이 임의로 소비하였다고 할지라도 횡령죄는 성립하지 않는다.

4. 폭로하겠다고 협박한 행위

(1) 협박죄의 구성요건해당성

사안에서 甲이 A에게 사실을 폭로하겠다고 한 행위가 협박죄의 구성요건해당성이 인정됨은 의문의 여지가 없다. 그러나 사안에서 A는 현실적으로 공포심을 일으키지 않았으므로 협박죄가 기수인지 미수인지의 여부가 문제된다.

(2) 협박죄의 기수여부에 대한 견해의 대립

협박죄의 기수시기에 대하여는 ① 협박죄를 침해범으로 보아 해악의 고지로서 상대방이 현실적으로 공포심을 느꼈을 때 기수가 되고, 해악을 고지했으나 공포심을 느끼지 않은 경우 협박죄의 미수가 된다는 견해(전합의 반대의견) ② 협박죄를 위험범으로 보아 상대방이 현실적으로 공포심을 느끼지 않았더라도 해악의 고지를 인식하였다면 기수가 된다는 견해(전합의 다수의견)가 대립하고 있다.

(3) 검토 및 사안의 해결

생각건대 협박죄의 경우에는 외포된 상태가 극히 주관적이어서 입증하기 어려운 점이 있어 그 본질이 거동범에 가까우므로 이를 위험범으로 보는 것이 타당하다. 따라서 협박죄는 상대방이 해악의 고지내용을 인식하였다면 기수가 된다고 보아야 한다. 이러한 위험범설에 의하면 甲의 행위는 협박죄의 기수에 해당한다.

5. 甲의 죄책

甲은 증뢰물전달죄와 협박죄의 기수가 성립한다.

관련판례

1. 비위사실을 묵인해 준 사건

[사실관계] 甲은 乙로부터 공무원인 丙이 乙의 비위사실을 묵인해 준 데 대한 사례금으로 공여하는 뇌물이라는 정을 알면서도 금 200만원을 교부받은 다음 그 돈을 丙에게 교부하였다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 형법 제133조 제2항은 증뢰자가 뇌물에 공할 목적으로 금품을 제3자에게 교부하거나 또는 그 정을 알면서 교부받는 증뢰물전달행위를 독립한 구성요건으로 하여 이를 같은 조 제1항의 뇌물공여죄와 같은 형으로 처벌하는 규정으로서, 제3자의 증뢰물전달죄는 제3자가 증뢰자로부터 교부받은 금품을 수뢰할 사람에게 전달하였는지 여부에 관계없이 제3자가 그 정을 알면서 금품을 교부받음으로써 성립하는 것이며, 나아가 제3자가 그 교부받은 금품을 수뢰할 사람에게 전달하였다고 하여 증뢰물전달죄 외에 별도로 뇌물공여죄가 성립하는 것은 아니다.(대판 1997.9.5. 97도1572)

2. 도봉구청 뇌물 사건

[사실관계] 甲은 조합장 乙로부터 공무원에게 뇌물로 전달하여 달라고 금원을 교부받은 것을 뇌물로 전달하지 않고 자신이 소비하였다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 민법 제746조에 불법의 원인으로 인하여 재산을 급여하거나 노무를 제공한 때에는 그 이익의 반환을 청구하지 못한다고 규정한 뜻은 급여를 한 사람은 그 원인행위가 법률상 무효임을 내세워 상대방에게 부당이득반환청구권을 할 수 없고, 또 급여한 물건의 소유권이 자기에게 있다고 하여 소유권에 기한 반

환청구도 할 수 없어서 결국 급여한 물건의 소유권은 급여를 받은 상대방에게 귀속된다는 것이므로 조합장이 조합으로부터 공무원에게 뇌물로 전달하여 달라고 금원을 교부 받은 것은 불법원인으로 인하여 지급 받은 것으로서 이를 뇌물로 전달하지 않고 타에 소비하였다고 해서 타인의 재물을 보관 중 횡령하였다고 볼 수는 없다.(대판 1988.9.20. 86도628)

3. 포주와 윤락녀 사건

[사실관계] 전직경찰관인 윤락업소 포주 甲은 다방 종업원 乙女를 수차 찾아가 자신의 업소에서 윤락행위를 해 줄 것을 적극적으로 권유하였다. 이에 乙女는 혼인하여 남편과 두 아들이 있음에도 남편이 알코올 중독으로 생활능력이 없어 가족의 생계를 위하여 甲의 권유에 따라 윤락행위에 따르기로 하고, 甲과 화대를 절반씩 분배하기로 약정한 후 5개월간 甲의 업소에서 윤락행위를 하였다. 그런데 甲은 받은 화대 합계 2천7백만원을 보관하던 중 그 중 절반인 1,350만원을 乙女에게 지급하지 아니하였다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 포주가 윤락녀와 사이에 윤락녀가 받은 화대를 포주가 보관하였다가 절반씩 분배하기로 약정하고도 보관중인 화대를 임의로 소비한 경우, 포주와 윤락녀의 사회적 지위, 약정에 이르게 된 경우와 약정의 구체적 내용, 급여의 성격 등을 종합해 볼 때 포주의 불법성이 윤락녀의 불법성보다 현저히 크므로 화대의 소유권이 여전히 윤락녀에게 속한다는 이유로 횡령죄를 구성한다.(대판 1999.9.17. 98도2036)

4. 경찰관이 친구 채권 전화로 추심한 사건

[사실관계] 정보과 소속 경찰관 甲은 친구 乙을 만나 이야기 하던 중 A가 사업을 이유로 자신에게 돈을 빌려간 후 이를 갚지 않아 독촉을 하고 있지만 돈이 없다고 하면서 변제하지 않고 있다는 말을 듣고 그 자리에서 A에게 전화를 걸어 '나는 XX경찰서 정보과에 근무하는 형사다. B가 집안 동생인데 돈을 언제까지 해 줄 것이냐. 빨리 안 해주면 상부에 보고하여 문제를 삼겠다.'라고 말하였다. 하지만 A는 이를 무시하고 전화를 끊었다. 甲에게 협박죄의 기수범이 성립하는가?

[판결요지] [1] [다수의견] (가) 협박죄가 성립하려면 고지된 해악의 내용이 행위자와 상대방의 성향, 고지 당시의 주변 상황, 행위자와 상대방 사이의 친숙의 정도 및 지위 등의 상호관계, 제3자에 의한 해악을 고지한 경우에는 그에 포함되거나 암시된 제3자와 행위자 사이의 관계 등 행위 전후의 여러 사정을 종합하여 볼 때에 일반적으로 사람으로 하여금 공포심을 일으키게 하기에 충분한 것이어야 하지만, 상대방이 그에 의하여 현실적으로 공포심을 일으킬 것까지 요구하는 것은 아니며, 그와 같은 정도의 해악을 고지함으로써 상대방이 그 의미를 인식한 이상, 상대방이 현실적으로 공포심을 일으켰는지 여부와 관계없이 그로써 구성요건은 충족되어 협박죄의 기수에 이르는 것으로 해석하여야 한다. (나) 결국, 협박죄는 사람의 의사결정의 자유를 보호법익으로 하는 위헌범이라 봄이 상당하고, 협박죄의 미수범 처벌조항은 해악의 고지가 현실적으로 상대방에게 도달하지 아니한 경우나, 도달은 하였으나 상대방이 이를 지각하지 못하였거나 고지된 해악의 의미를 인식하지 못한 경우 등에 적용될 뿐이다. [대법관 김영란, 박일환의 반대의견] (가) 해악의 고지에 의해 현실적으로 공포심을 일으켰는지 여부나 그 정도는 사람마다 다를 수 있다고 하더라도 이를 판단할 수 없다거나 판단을 위한 객관적인 척도나 기준이 존재하지 않는다고 단정할 것은 아니며, 사람이 현실적으로 공포심을 일으켰는지 여부를 판단할 만한 객관적인 기준 및 개별 사건에서 쌍방의 입증과 그에 의하여 인정되는 구체적인 사정 등을 모두 종합하여, 당해 협박행위로 상대방이 현실적으로 공포심을 일으켰다는 점이 증명된다면 협박죄의 기수에 이르렀다고 인정하고, 이에 대한 증명이 부족하거나 오히려 상대방이 현실적으로 공포심을 일으키지 않았다는 점이 증명된다면 협박죄의 미수에 그친 것으로 인정하면 될 것이다. 기수에 이르렀는지에 대한 의문을 해결하기 어렵다고 하여 모든 경우에 기수범으로 처벌하는 것은 오히려 "의심스러울 때는 피고인의 이익으로"라는 법원칙 등 형사법의 일반원칙과도 부합하지 아니하며 형벌과잉의 우려를 낳을 뿐이다. (나) 결국, 현행 형법의 협박죄는 침해범으로서 일반적으로 사람으로 하여금 공포심을 일으킬 수 있는 정도의 해악의 고지가 상대방에게 도달하여 상대방이 그 의미를 인식하고 나아가 현실적으로 공포심을 일으켰을 때에 비로소 기수에 이르는 것으로 보아야 한다. [2] 정보보안과 소속 경찰관이 자신의 지위를 내세우면서 타인의 민사분쟁에 개입하여 빨리 채무를 변제하지 않으면 상부에 보고하여 문제를 삼겠다고 말한 사안에서, 객관적으로 상대방이 공포심을 일으키기에 충분한 정도의 해악의 고지에 해당하므로 현실적으로 피해자가 공포심을 일으키지 않았다 하더라도 협박죄의 기수에 이르렀다고 본 사례.(대판 2007.9.28. 2007도606 전합)

♣ 돌발퀴즈

판례는 협박죄를 위험범으로 보아 미수를 인정하지 않고 있다.

정답 : X

해설 : 판례는 협박죄를 위험범으로 보지만, 일정한 경우에는 미수범을 인정하고 있다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 다음 중 수뢰죄의 행위태양이 아닌 것은?

- ① 수수
- ② 요구
- ③ 약속
- ④ 알선
- ⑤ 공여

정답 : ⑤

해설 : 공여는 증뢰죄의 행위태양이다.

2. 불법원인급여에 대한 횡령죄성부에 대한 판례의 태도는?

- ① 긍정한다.
- ② 부정한다.
- ③ 원칙적으로 긍정한다.
- ④ 원칙적으로 부정한다.
- ⑤ 아직 판례가 없다.

정답 : ④

해설 : 판례는 원칙적으로 횡령죄의 성립을 부정하는 입장이지만, 예외적으로 긍정한다.

3. 판례에 의할 때 협박죄의 보호의 정도는?

- ① 침해범
- ② 위험범
- ③ 계속범
- ④ 상대범
- ⑤ 신분범

정답 : ②

해설 : 판례는 협박죄를 위험범으로 보고 있다.

♣ 학습내용 정리

1. 증뢰물전달죄는 증뢰행위에 제공할 목적으로 제3자에게 금품을 교부하거나 제3자가 그 정을 알면서 교부받음으로써 성립하는 것이고, 제3자가 증뢰자로부터 교부받은 금품을 수뢰할 사람에게 전달하였는지는 범죄성립에 영향을 미치지 않는다.
2. 판례는 불법원인급여물에 대한 횡령죄의 성립을 원칙적으로 부정한다. 즉 판례는 ‘불법원인급여물의 소유권은 급여를 받은 상대방에게 귀속된다’고 보아 타인의 재물이 아니므로 횡령죄가 성립할 수 없다고 본다. 그러나 예외적으로 ‘포주와 윤락녀 사건’에서는 ‘포주의 불법성이 윤락녀의 불법성보다 현저히 크므로 화대의 소유권이 여전히 윤락녀에게 속한다’는 이유로 횡령죄의 성립을 긍정하고 있다.
3. 협박죄의 기수시기에 대하여는 ① 협박죄를 침해범으로 보아 해약의 고지로서 상대방이 현실적으로 공포심을 느꼈을 때 기수가 되고, 해약을 고지했으나 공포심을 느끼지 않은 경우 협박죄의 미수가 된다는 견해(전합의 반대의견) ② 협박죄를 위험범으로 보아 상대방이 현실적으로 공포심을 느끼지 않았더라도 해약의 고지를 인식하였다면 기수가 된다는 견해(전합의 다수의견)가 대립하고 있다.

제10강 제310조의 진실성에 대한 착오

♣ 학습목표

제310조의 진실성에 대한 착오에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

출판물에 의한 명예훼손죄와 착오

제310조의 진실성에 대한 착오

출판물에 의한 명예훼손죄의 간접정범

♣ 사전테스트

1. 판례는 비방의 목적과 공공의 이익은 양립할 수 있다고 본다.

정답 : X

해설 : 판례에 의하면 비방의 목적과 공공의 이익은 양립할 수 없다고 본다.

2. 형법 제310조는 원칙적으로 제307조 제1항의 경우에만 적용된다.

정답 : O

해설 : 제310조는 제307조 제1항의 행위를 전제로 하므로 타당한 지문이다.

3. 판례는 제309조의 간접정범을 긍정하고 있다.

정답 : O

해설 : 판례는 제309조의 간접정범을 긍정하고 있다.

♣ 강의내용

[설문]

A맥주회사 직원이었다가 구조조정으로 퇴직한 甲은 기자인 친구 乙과 술집에서 맥주를 마시다가 “사실 A회사를 포함한 국내 5개의 맥주회사가 모여서 가격인상담합을 했다.”라고 말했다. 하지만 乙이 자신의 말을 믿으려 하지 않자, 甲은 재직시절 5개의 맥주회사 담당자가 가격인상담합을 모의하는 대화내용을 자신의 휴대전화로 녹음했다고 하면서 이를 들려주었다. 녹음된 파일을 넘겨받은 乙은 국민이 물가상승에 민감해져 있는 현시점에서 구독률을 올릴 좋은 기회라는 생각에 다음날 이를 기사화하였다. 乙의 입장에서는 당시 정황상 녹음내용이 진실이라고 믿을만한 상당한 이유가 존재하였고, 이 때문에 녹음내용을 진실로 확신하고 기사화하였던 것이다. 그러나 사실은 甲이 구조조정에 불만을 품고 A맥주회사를 비방할 목적으로 허위의 녹음파일을 제공한 것으로 밝혀졌다. 甲과 乙의 죄책을 논하시오. (30점)

[해설]

1. 乙의 죄책

1. 문제의 제기

사안에서 乙은 허위의 사실을 진실한 사실로 알고 기사화하고 있다. 이에 대하여는 ① 먼저 구성요건의 확정이 문제되고, ② 허위의 사실을 진실한 사실로 알고 기사화한 부분에 대한 착오가 문제된다.

2. 구성요건의 확정

(1) 출판물에 의한 명예훼손죄 해당여부

사안에서 乙은 신문을 통하여 사실을 적시하고 있으므로 제309조의 출판물의 의한 명예훼손죄의 성립여부가 문제되는데, 출판물에 의한 명예훼손죄가 성립하기 위하여는 비방할 목적이 있어야 한다. 그런데 비방할 목적은 공공의 이익을 위한 것과 양립할 수 없다는 것이 판례의 태도이다. 이러한 판례의 태도에 따르면 사안에서 乙은 가격담합으로 인한 피해를 기사화한 것은 공공의 이익을 위한 것이므로 비방의 목적은 인정되지 않는다. 따라서 甲에게는 제309조의 출판물에 의한 명예훼손죄가 성립하지 않는다.

(2) 제307조 제2항의 명예훼손죄 해당여부

사안에서 객관적으로 발생한 사실은 제307조 제2항의 허위사실명예훼손죄에 해당하지만, 乙이 주관적으로 인식한 사실은 제307조 제1항의 명예훼손죄에 해당한다. 이러한 착오의 경우에는 제15조 제1항이 적용되어 甲은 제307조 제2항의 허위사실명예훼손죄의 구성요건에는 해당하지 않는다.

(3) 제307조 제1항의 명예훼손죄 해당여부

사안에서 乙은 가격담합에 대한 의혹을 신문을 통하여 기사화한 경우이므로 공연히 사실을 적시하여 A의 명예를 훼손하였다. 따라서 甲에게는 제307조 제1항의 명예훼손죄의 구성요건해당성이 인정된다.

3. 제310조의 적용에 있어서의 진실성에 대한 착오

(1) 논의점

사안에서 乙의 행위는 제307조 제1항의 구성요건에 해당하므로 제310조의 위법조각사유의 해당여부를 검토할 수 있으나, 사안에서 乙은 객관적으로 허위의 사실을 적시하였으므로 원칙적

으로 제310조는 적용될 수 없다. 그런데 사안에서 甲은 객관적으로 허위인 사실을 진실한 사실로 오인하고 공익을 위하여 사실을 적시하고 있으므로 그 효과에 대하여 논의가 있다.

(2) 견해의 대립

이에 대하여는 ① 제310조를 위법성조각사유로 본다면 진실성에 대한 착오는 위법성조각사유의 전제사실의 착오문제로 해결하여야 한다는 위법성조각사유의 전제사실의 착오설 ② 허위의 사실을 진실한 사실로 착오한 경우에 행위자가 진실한 사실인가에 대해 신중한 검토의무를 이행하였다면 제310조가 적용된다는 의무합치적 심사설 ③ 허위의 사실을 진실한 사실로 착오한 경우에는 위법성을 조각시키는 것이 아니라 제15조 제1항에 따라 불법을 감경시켜 제307조 제1항의 죄가 성립하고, 다만 공익성이 있는 경우에는 법률의 착오로 보자는 위법성 착오설 등이 대립하고 있다.

(3) 판례의 태도

판례는 이와 유사한 사안에서 ‘기사작성의 목적이 공공의 이익에 관한 것이고 그 기사내용을 작성자가 진실하다고 믿었으며 그와 같이 믿은 데에 객관적인 상당한 이유가 있는 경우에는 진실한 것이라는 증명이 없다고 할지라도 위법성이 없다고 보아야 한다’라고 하여 상당한 이유가 있는 경우에는 위법성이 조각된다고 판시하고 있다.

(4) 결 언

생각건대 제310조는 사실의 진실성을 위법성조각사유의 전제사실로 하고 있으므로 사실의 진실성에 대한 착오는 위법성조각사유의 전제사실의 착오로 보고 다수설인 법효과제한적 책임설에 따라 해결하는 것이 타당하다. 이러한 경우에 고의가 조각되어 처벌이 되지 못하는 문제가 있을 수 있지만, 자유민주주의 보루인 언론의 자유라는 공익적인 목적을 고려한다면 경솔하게 진실성을 오신하여 타인의 명예를 훼손한 자를 처벌하지 못하는 처벌의 흠결은 크게 문제되지 않으리라 생각된다.

4. 사안의 해결

사안에서 乙의 행위는 법효과제한적 책임설에 의하면 고의책임이 조각되어 과실범이 문제될 수 있지만 명예훼손죄는 과실범 처벌 규정이 없으므로 처벌되지 않게 된다. 따라서 乙은 무죄가 된다.

II. 甲의 죄책

1. 출판물에 의한 명예훼손죄의 간접정범

사안에서 甲은 처벌되지 않는 乙을 이용하여 비방할 목적으로 A맥주회사 등에 대하여 출판물에 의한 명예훼손죄를 범하고 있다. 이러한 경우에 甲은 출판물에 의한 명예훼손죄에 대한 간접정범이 성립한다.

2. 판례의 태도

판례도 ‘타인을 비방할 목적으로 허위사실인 기사의 재료를 신문기자에게 제공한 경우에 기사를 신문지상에 게재하느냐의 여부는 신문 편집인의 권한에 속한다고 할 것이나 이를 편집인이 신문지상에 게재한 이상 기사의 게재는 기사재료를 제공한 자의 행위에 기인한 것이므로 기사재료의 제공행위는 형법 제309조 제2항 소정의 출판물에 의한 명예훼손죄의 죄책을 면할 수 없다’라고 하여 출판물에 의한 명예훼손죄의 간접정범을 인정하고 있다.

3. 결언

따라서 사안에서 甲에게는 출판물에 의한 명예훼손죄의 간접정범이 성립한다.

관련판례

1. 제309조와 제310조의 관계에 관한 판례

형법 제309조 제1항 소정의 '사람을 비방할 목적'이란 가해의 의사 내지 목적을 요하는 것으로서 공공의 이익을 위한 것과는 행위자의 주관적 의도의 방향에 있어 서로 상반되는 관계에 있다고 할 것이므로, 형법 제310조의 공공의 이익에 관한 때에는 처벌하지 아니한다는 규정은 사람을 비방할 목적이 있어야 하는 형법 제309조 제1항 소정의 행위에 대하여는 적용되지 아니하고 그 목적을 필요로 하지 않는 형법 제307조 제1항의 행위에 한하여 적용되는 것이고, 반면에 적시한 사실이 공공의 이익에 관한 것인 경우에는 특별한 사정이 없는 한 비방 목적은 부인된다고 봄이 상당하므로 이와 같은 경우에는 형법 제307조 제1항 소정의 명예훼손죄의 성립 여부가 문제될 수 있고 이에 대하여는 다시 형법 제310조에 의한 위법성 조각 여부가 문제로 될 수 있다.(대판 1998.10.9. 97도158)

2. 한겨레 신문 사건 - 진실성에 대한 착오

[사실관계] 甲은 H신문 민권사회부 기자로서 J대학 학생회장 乙의 사망사건을 보도하면서, 다방 종업원이던 丙女가 경찰에서 乙과 마지막으로 동행한 여자는 丁女였다는 진술을 기초로 乙과 동행한 여자는 丁女이고 丁女는 안기부에 근무하고 있다는 기사를 작성·보도하였다. 그러나 丁女가 안기부에 근무하고 있었던 것은 사실이지만, 丁女와 乙이 동행하지 않았음이 밝혀졌다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 내용 중에 일부 허위사실이 포함된 신문 기사를 보도한 사안에서 기사작성의 목적이 공공의 이익에 관한 것이고 그 기사내용을 작성자가 진실하다고 믿었으며 그와 같이 믿은 데에 객관적인 상당한 이유가 있는 경우에는 진실한 것이라는 증명이 없다고 할지라도 위법성이 없다고 보아야 한다.(대판 1996.8.23. 94도3191)

3. 집합적 명칭에 의한 명예훼손

[사실관계] 甲은 피해자의 이름을 직접적으로 적시하고 있지는 않으나, "K여상의 3.19동지회 소속교사들이 학생들을 선동하여 무단하교를 하게 하였다"고 적시한 허위의 보도자료를 작성하여 배포하였다. K여상의 교사는 총 66명으로서 그 중 약 37명이 3.19동지회 소속교사들이며, 위 학교의 학생이나 학부모, 교육청 관계자들은 3.19동지회 소속교사들이 누구인지 알고 있었다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 명예훼손죄는 어떤 특정한 사람 또는 인격을 보유하는 단체에 대하여 그 명예를 훼손함으로써 성립하는 것이므로 그 피해자는 특정한 것임을 요하고, 다만 서울시민 또는 경기도민이라 함과 같은 막연한 표시에 의해서는 명예훼손죄를 구성하지 아니한다 할 것이지만, 집합적 명사를 쓴 경우에도 그것에 의하여 그 범위에 속하는 특정인을 가리키는 것이 명백하면, 이를 각자의 명예를 훼손하는 행위라고 볼 수 있다.(대판 2000.10.10. 99도5407)

♣ 돌발퀴즈

판례는 제310조의 진실성을 착오한 경우에 그와 같이 믿은 데에 객관적인 상당한 이유가 있는 경우에는 진실한 것이라는 증명이 없다고 할지라도 위법성이 없다고 보고 있다.

정답 : O

해설 : 판례에 의하면 타당한 지문이다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 다음 중 친고죄인 것은?

- ① 사실적시 명예훼손죄
- ② 허위사실적시 명예훼손죄
- ③ 사자 명예훼손죄
- ④ 출판물에 의한 사실적시 명예훼손죄
- ⑤ 출판물에 의한 허위사실적시 명예훼손죄

정답 : ③

해설 : 제312조 제1항 참조

2. 310조의 법적 효과는?

- ① 구성요건 해당성이 배제된다.
- ② 위법성이 조각된다.
- ③ 책임이 조각된다.
- ④ 처벌이 조각된다.
- ⑤ 소추가 면제된다.

정답 : ②

해설 : 제310조는 명예훼손죄의 특유한 위법성조각사유이다.

3. 명예훼손죄와 관련하여 타당하지 않은 것은?

- ① 미수범을 처벌한다.
- ② 반의사불벌죄의 규정이 있다.
- ③ 친고죄의 규정이 있다.
- ④ 과실범을 처벌하는 규정은 없다.
- ⑤ 결과적가중범에 관한 규정은 없다.

정답 : ①

해설 : 미수범을 처벌하는 규정은 없다.

♣ 학습내용 정리

1. 판례는 제310조의 진실성을 착오한 사안에서 '기사작성의 목적이 공공의 이익에 관한 것이고 그 기사내용을 작성자가 진실하다고 믿었으며 그와 같이 믿은 데에 객관적인 상당한 이유가 있는 경우에는 진실한 것이라는 증명이 없다고 할지라도 위법성이 없다고 보아야 한다'라고 하여 상당한 이유가 있는 경우에는 위법성이 조각된다고 판시하고 있다.
2. 판례는 '타인을 비방할 목적으로 허위사실인 기사의 재료를 신문기자에게 제공한 경우에 기사를 신문지상에 게재하느냐의 여부는 신문 편집인의 권한에 속한다고 할 것이나 이를 편집인이 신문지상에 게재한 이상 기사의 게재는 기사재료를 제공한 자의 행위에 기인한 것으로 기사재료의 제공행위는 형법 제309조 제2항 소정의 출판물에 의한 명예훼손죄의 죄책을 면할 수 없다'라고 하여 출판물에 의한 명예훼손죄의 간접정범을 인정하고 있다.

제11강 교사범의 추상적사실의 착오

♣ 학습목표

교사범의 추상적 사실의 착오에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

출판물의 범위

무고죄의 성립요건

교사의 추상적 사실의 착오

♣ 사전테스트

1. 판례에 의하면 A4 용지 7장 정도는 제309조의 출판물이 될 수 없다.

정답 : O

해설 : 컴퓨터 워드프로세서로 작성되어 프린트된 A4 용지 7쪽 분량의 인쇄물이 형법 제 309조 제1항 소정의 '기타 출판물'에 해당하지 않는다고 본 사례.(대판 2000.2.11. 99도3048)

2. 무고죄는 '타인으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적'이 필요한 목적범이다.

정답 : O

해설 : 형법 제156조에 의하여 타당한 지문이다.

3. 교사범의 경우에는 기도된 교사를 처벌하는 규정이 있지만, 방조범의 경우에는 기도된 방조를 처벌하는 규정이 없다.

정답 : O

해설 : 형법 제31조와 제32조의 규정에 의하면 타당한 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

유명설령탕집과 경쟁 관계에 있는 원조설령탕집 업주 甲은 유명설령탕집에 대한 헛소문을 퍼뜨려 장사를 못하게 하기로 마음먹었다. 甲은 유명설령탕집 업주 A에게 전화하여 “당신네 설령탕에서 바퀴벌레가 나오고 중국산 김치의 원산지를 국내산으로 속여 영업을 하고 있다. 즉시 영업을 중단하지 않으면 당국에 신고해서 처벌을 받게 하겠다.”라고 말하였다. 그러나 A는 어떤 미친 사람이 전화했거니 생각하고 영업을 계속하였다.

한편, 甲은 컴퓨터 워드프로세서를 이용하여 ‘유명설령탕집 설령탕에서 바퀴벌레가 나왔는데 업주 A는 이를 숨기고 계속 장사를 하고 있다. 심지어 중국산 김치를 국내산으로 속이고 있으니 유명설령탕집에 가지 말자.’는 내용의 7쪽 분량 유인물을 작성한 후 유명설령탕집 주변의 행인 100여 명에게 배포하였다.

1. 甲의 죄책에 대하여 논하시오. (15점)
2. 위 사례에서 甲이 허위인 사실을 알고 있는 직원 乙에게 유인물을 배포하도록 시켰는데 乙이 유인물을 배포하는 대신 甲과 상의 없이 유인물을 첨부한 고발장을 경찰서에 제출한 경우 甲, 乙의 죄책을 논하시오. (10점)

[해설]

[1. 문 해설 (15점)]

I. A에게 전화로 협박한 행위에 대한 평가

1. 강요죄의 성립여부

사안에서 “영업을 중지하지 않으면 당국에 신고하여 처벌받게 하겠다”고 말한 것은 A의 의사결정의 활동에 영향을 미칠 정도로 겁을 먹게 할 만한 해악을 고지한 것으로 볼 수 있고, A의 설령탕 영업을 중단하게 하는 것은 권리행사의 방해로 볼 수 있다. 그러나 A는 甲의 협박에 의해 권리행사를 방해하는 결과가 발생하지 않았으므로 강요죄는 미수에 해당한다.

2. 업무방해죄의 성립여부

사안에서 甲의 전화내용은 A에게 위력을 행사한 것으로 평가할 수 있으므로 甲에게는 업무방해죄가 성립한다. 또한 업무방해죄는 추상적 위험범이므로 전화내용을 고지한 즉시 기수가 될 것이다.

3. 협박죄의 성립여부

사안에서 甲의 협박행위는 협박죄에 해당할 수 있으나, 甲에게 강요죄나 업무방해죄가 성립하게 되면 법조경합 중 보충관계에 있으므로 협박죄는 별도로 성립하지 않는다.

II. 유인물을 작성하여 배포한 행위

1. 명예훼손죄의 성립여부

(1) 출판물에 의한 명예훼손죄의 성립여부

형법 제309조 제1항 소정의 ‘기타 출판물’에 해당한다고 하기 위하여는 그것이 등록·출판된 제본인쇄물이나 제작물은 아니라고 할지라도 적어도 그와 같은 정도의 효용과 기능을 가

지고 사실상 출판물로 유통·통용될 수 있는 외관을 가진 인쇄물로 볼 수 있어야 한다. 사안에서 7쪽 분량의 유인물은 제309조 소정의 ‘기타 출판물’에 속하는 것을 볼 수 없다. 따라서 甲에게는 형법 제309조의 명예훼손죄가 성립하지 않는다. 그러므로 제307조의 명예훼손죄가 성립하는지를 검토해야 한다.

(2) 허위사실에 의한 명예훼손죄

사안에서 ① 행인 100명에게 유인물을 배포한 것은 공연성이 인정되며 ② 헛소문을 퍼뜨리기 위하여 설렁탕에서 바퀴벌레가 나오고 식품원료의 원산지를 속였다고 한 것은 허위사실의 적시라고 볼 수 있으며 ③ 음식에서 바퀴벌레가 나오고 원산지를 허위로 표시한다는 것은 A의 인격에 대한 사회적 평가를 저하시키는 것에 해당한다. 따라서 甲에게는 형법 제307조 제2항의 명예훼손죄가 성립한다.

2. 업무방해죄의 성립여부

사안에서 甲은 헛소문을 퍼뜨리기 위하여 유인물을 만들어 100명에게 배포한 것은 허위사실의 유포에 해당하고 이로 인해 A의 업무를 방해할 우려가 있으므로 업무방해죄가 성립한다.

III. 사안의 해결

전화협박한 甲의 행위는 강요죄의 미수(제324조, 제324조의5)와 업무방해죄(제314조 제1항)의 상상적 경합관계에 있으며, 유인물을 배포한 행위는 허위사실적시 명예훼손죄(제307조 제2항)과 업무방해죄(제314조 제1항)의 상상적 경합의 관계에 있다. 그리고 전화협박한 행위에 대한 죄와 유인물을 배포한 행위에 대한 죄는 각각 실체적 경합관계에 있다.

[2. 문 해설 (10점)]

1. 논의의 전제

사안에서 乙이 경찰서에 유인물을 첨부한 고발장을 제출한 것은 명예훼손죄의 점에 대하여는 공연성이 없고, 업무방해죄의 점에 대하여는 유포에 해당되지 않는다고 평가할 수 있으므로 이를 전제로 한다.

2. 乙의 죄책

(1) 무고죄의 의의

무고죄는 타인으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적으로 공무소 또는 공무원에 대하여 객관적 진실에 반하는 허위사실을 신고함으로써 성립하는 범죄이다. 따라서 무고죄가 성립하기 위해서는 ① 타인으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적 ② 공무원 또는 공무소에 대하여 ③ 허위사실을 신고하고 ④ 허위성에 대한 인식이 있어야 한다.

(2) 사안의 검토

사안에서 乙은 허위의 사실을 경찰서에 신고하였는바 ① 乙에게 A에 대한 형사처분 등을 받게 할 목적이 있음을 추지할 수 있고 ② 경찰서에 제출하였으므로 공무소에 대한 것이고 ③ 허위의 사실을 자발적으로 신고한 것이고 ④ 허위성에 대한 인식이 있으므로 乙에게는 무고죄가 성립한다.

3. 甲의 죄책

(1) 착오의 문제

甲은 乙에게 유인물을 작성하여 이를 배포하도록 하여 업무방해 및 명예훼손을 범하려고 하였는데 실제로 乙은 이를 배포하지 않고 경찰서에 제출하여 무고죄를 범하고 있다.

(2) 질적인 착오

이러한 경우 甲의 죄책에 대한 평가는 추상적 사실의 착오 중에서 질적인 착오에 해당한다. 따라서 乙이 전혀 이질적인 무고죄를 범하고 있으므로 甲은 이에 대하여는 책임지지 않는다 할 것이다.

(3) 효과없는 교사

乙이 승낙한 경우에 제31조 제2항에 따라서 업무방해죄 및 명예훼손죄의 예비·음모로 처벌하는 것을 생각할 수 있으나 두죄는 예비·음모를 처벌하는 규정이 없으므로 이를 처벌할 수 없다 할 것이다.

(4) 사안의 해결

따라서 사안의 경우에 甲은 아무런 형사상의 죄책을 지지 않는다.

관련판례

1. 최고서 사본 사건

[사실관계] 甲은 乙을 비방할 목적으로 '서명운동에 동참합시다'라는 제목으로 조합사옥 신축공사와 관련하여 乙에게 비리가 있다는 취지의 내용을 백지에 기재하고 최고서 사본을 첨부한 다음 이를 전자복사하여 조합원들에게 나누어주었다. 甲에게 출판물에 의한 명예훼손죄가 성립하는가?

[판결요지] [1] 형법이 출판물 등에 의한 명예훼손죄를 일반 명예훼손죄보다 중벌하는 이유는 사실적시의 방법으로서의 출판물 등의 이용이 그 성질상 다수인이 견문할 수 있는 높은 전파성과 신뢰성 및 장기간의 보존가능성 등 피해자에 대한 법익침해의 정도가 더욱 크다는 데 있다는 점에 비추어 보면, 형법 제309조 제1항 소정의 '기타 출판물'에 해당한다고 하기 위하여는 그것이 등록·출판된 제본인쇄물이나 제작물은 아니라고 할지라도 적어도 그와 같은 정도의 효용과 기능을 가지고 사실상 출판물로 유통·통용될 수 있는 외관을 가진 인쇄물로 볼 수 있어야 한다. [2] 장수가 2장에 불과하며 제본방법도 조잡한 것으로 보이는 최고서 사본이 출판물이라고 할 수 있을 정도의 외관과 기능을 가진 인쇄물에 해당한다고 보기는 어렵다.(대판 1997.8.26. 97도133)

2. A4 용지 7쪽 사건

[사실관계] 甲은 A대학교에서 학칙을 위반하며 진행되는 미술사학과 신입교수 임용절차의 부당함을 지적하고 관계자에게 이를 알려 그 시정을 구하기 위하여, 컴퓨터로 A4용지 7쪽 분량의 인쇄물을 작성하여 교육부에 편지봉투에 넣어 우송하거나 관계자들에게 교부하였다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 컴퓨터 워드프로세서로 작성되어 프린트된 A4 용지 7쪽 분량의 인쇄물이 형법 제309조 제1항 소정의 '기타 출판물'에 해당하지 않는다고 본 사례.(대판 2000.2.11. 99도3048)

♣ 돌발퀴즈

장수가 2장에 불과하며 제본방법도 조잡한 것으로 보이는 최고서 사본이 출판물이라고 할 수 있을 정도의 외관과 기능을 가진 인쇄물에 해당한다고 보기는 어렵다.

정답 : 0

해설 : 장수가 2장에 불과하며 제본방법도 조잡한 것으로 보이는 최고서 사본이 출판물이라고 할 수 있을 정도의 외관과 기능을 가진 인쇄물에 해당한다고 보기는 어렵다.(대판 1997.8.26. 97도133)

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 강요죄에 관한 규정은?

- ① 제323조
- ② 제324조
- ③ 제325조
- ④ 제326조
- ⑤ 제327조

정답 : ②

해설 : 자유에 관한 죄인 강요죄는 재산죄인 권리행사방해죄의 규정속에 있음을 주의하여야 한다.

2. 업무방해죄의 행위 태양은?

- ① 허위사실을 유포
- ② 허위사실을 유포하거나 기타 위계
- ③ 위계
- ④ 위력
- ⑤ 허위의 사실을 유포하거나 기타 위계 또는 위력

정답 : ⑤

해설 : 제314조 제1항 참조

3. 무고죄의 성립요건이 아닌 것은?

- ① 타인으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적
- ② 공무원 또는 공무소에 신고
- ③ 허위사실을 신고
- ④ 허위성에 대한 인식
- ⑤ 형사처분 또는 징계처분의 확정

정답 : ⑤

해설 : 무고죄가 성립하기 위해서는 ① 타인으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적 ② 공무원 또는 공무소에 대하여 ③ 허위사실을 신고하고 ④ 허위성에 대한 인식이 있어야 하지만, 형사처분 또는 징계처분의 확정是不요하다.

♣ 학습내용 정리

1. 형법 제309조 제1항 소정의 '기타 출판물'에 해당한다고 하기 위하여는 그것이 등록·출판된 제본인쇄물이나 제작물은 아니라고 할지라도 적어도 그와 같은 정도의 효용과 기능을 가지고 사실상 출판물로 유통·통용될 수 있는 외관을 가진 인쇄물로 볼 수 있어야 한다.
2. 무고죄는 타인으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적으로 공무소 또는 공무원에 대하여 객관적 진실에 반하는 허위사실을 신고함으로써 성립하는 범죄이다. 따라서 무고죄가 성립하기 위해서는 ① 타인으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적 ② 공무원 또는 공무소에 대하여 ③ 허위사실을 신고하고 ④ 허위성에 대한 인식이 있어야 한다.

제12강 절도죄의 기수시기와 친족상도례

♣ 학습목표

절도죄의 기수시기와 친족상도례에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

범죄목적의 주거침입에 대한 검토

절도죄의 기수시기에 대한 검토

친족상도례의 적용범위

♣ 사전테스트

1. 범죄 목적으로 타인의 주거에 들어가는 경우에는 항상 주거침입죄가 성립한다.

정답 : X

해설 : 뇌물을 주기 위하여 타인의 주거에 들어가는 경우에는 주거침입죄가 성립하지 아니하므로 타당하지 않은 지문이다.

2. 판례는 절도죄의 기수시기에 대하여 원칙적으로 취득설을 따르고 있다.

정답 : O

해설 : 타당한 지문이다.

3. 친족상도례의 규정인 제328조 제1항의 법적 효과는 '벌하지 아니한다'이다.

정답 : X

해설 : 제328조 제1항은 '그 형을 면제한다'라고 되어 있다.

♣ 강의내용

[설문]

경제적으로 어려워진 甲은 여러 가지 고민 끝에 자신의 할아버지가 계시는 시골 고향집 뒷마당의 오래된 소나무를 캐내어 팔기로 결심하였다. 차를 몰고 시골집으로 내려간 甲은 소나무를 캐내었으나, 크기가 너무 큰 까닭에 혼자서는 운반할 수 없어, 동네친구 乙에게 연락을 하여 자신의 사정을 말한 후 소나무를 차에 싣는 것을 도와 달라고 하였다. 잠시 후 도착한 乙은 甲과 함께 소나무를 甲의 차로 운반하였다. 이 모든 일이 주간에 행하여졌음을 전제로 할 때 甲과 乙의 책임은? (30점)

[해설]

I. 논점의 정리

사안에서 甲의 죄책을 ① 할아버지의 집에 들어간 행위가 주거침입죄에 해당하는지 ② 소나무를 캐내어 운반한 행위가 어떠한 절도죄에 해당하는지 ③ 이러한 절취행위가 친족상도령에 해당하여 처벌할 수 없는지의 순서로 살펴본다. 그리고 乙의 죄책은 甲의 절도행위가 기수에 이르렀는지에 따라 달라지므로 ① 기수인 경우와 ② 미수인 경우를 나누어서 살펴보기로 한다.

II. 甲의 죄책

1. 주거침입죄의 성부

(1) 주거의 범위

주거침입죄의 주거란 단순히 가옥 자체만을 말하는 것이 아니라 그 정원 등 위요지를 포함하므로 할아버지의 뒷마당에 들어갔더라도 주거에 출입한 것이 된다.

(2) 범죄목적의 출입

사안에서 甲의 출입이 할아버지의 의사에 반한 것인지 문제된다. 일반적으로 출입이 허용되어 있더라도 범죄목적으로 들어간 경우 주거권자의 의사에 반한다는 것이 판례와 다수설이며 타당하다. 따라서 사안의 경우에 절취목적으로 주거에 출입한 경우이므로 주거침입죄가 성립한다.

2. 절도죄의 구성요건의 특정

(1) 논의점

절도죄는 타인이 점유하는 타인 소유의 재물을 절취함으로써 성립한다. 사안에서 할아버지의 소나무는 타인 소유의 재물이고 甲이 이를 절취하였다는 점에는 의문이 없다. 그러나 문제가 되는 것은 단순절도인지 아니면 합동절도인지가 문제된다. 이와 관련되어 논의되어야 할 것이 절도죄의 기수시기이다.

(2) 절도죄의 기수시기에 대한 검토

절도죄의 기수시기에 대하여 취득설이 일반화되어 있다고 하더라도 사안과 같이 목적물이 커다란 수목인 경우에는 이를 언제 취득한 것으로 볼 것이냐에 대하여 논의가 있다. 이에 대하여는 ① 수목 등을 캐어내었을 때 기수가 된다는 견해와 ② 수목 등을 캐어낸 후 운반하거나 반출하였을 때 기수가 된다는 견해가 대립하고 있다.

(3) 판례의 입장

판례는 소위 ‘부부 영산홍 절취 사건’에서 ‘입목을 절취하기 위하여 이를 캐낸 때에는 그 시점에서 이미 소유자의 입목에 대한 점유가 침해되어 범인의 사실적 지배하에 놓이게 됨으로써 범인이 그 점유를 취득하게 되는 것이므로, 이때 절도죄는 기수에 이르렀다고 할 것이고, 이를 운반하거나 반출하는 등의 행위는 필요로 하지 않는다’라고 하여 수목 등을 캐어 내었을 때를 기수시기로 판단하고 있다.

(4) 검토 및 사안의 해결

생각건대 절도죄의 기수시기에 대하여 취득설을 기본으로 하는 한 수목 등의 절취행위의 기수시기는 캐어낸 때라고 보는 것이 타당하다. 수목 등을 캐어내었을 때는 이미 범인의 사실적 지배하에 놓이게 되기 때문이다.³⁾ 사안에서 甲이 소나무를 캐어내었을 때 기수가 된다면 이후 乙의 도움을 받았다고 하더라도 합동절도는 성립하지 않고 甲의 행위는 단순절도에 해당한다.⁴⁾ 그러나 운반 등의 행위를 했을 때를 기수시기로 보는 입장에서는 甲은 乙과 함께 합동절도죄의 죄책을 부담하게 될 것이다.

3. 친족상도례의 적용

甲과 할아버지는 직계혈족 관계에 있으므로 사안에서 단순절도가 성립하더라도 인적처벌 조각사유에 해당하여 甲은 그 형이 면제된다(제344조, 제328조 제1항).

III. 乙의 죄책

1. 논의점

사안에서 乙은 甲이 소나무를 캐낸 이후 운반전에 가담하여 甲의 절취행위를 완성시켜주고 있다. 이러한 경우에 乙의 죄책은 주거침입죄가 성립함은 이론이 없지만, 절취행위에 가담한 부분에 대하여는 甲의 절도의 기수시기를 언제로 볼 것인가에 따라 차이가 있을 수 있으므로 이를 나누어 검토한다.

2. 캐어내었을 때를 기수로 보는 경우

사안에서 甲이 소나무를 캐어내었을 때를 기수로 보는 경우에는 기수이후에 가담한 乙은 절취행위에 시간·장소적인 협동관계가 없으므로 합동절도는 성립하지 않고 다만 甲의 행위가 절도완료전이므로 단순절도죄에 대한 방조범만이 성립한다.⁵⁾

3. 반출했을 때를 기수로 보는 경우

사안에서 甲이 반출했을 때를 기수로 보는 입장에서는 乙의 가담시에 甲의 행위가 기수에 이르지 않았으므로 乙은 甲과 시간·장소적 협동관계를 이루어 절도범행을 한 것이므로 乙은 甲과 더불어 합동절도의 죄책을 지게 된다.

4. 사안의 해결

소나무절취의 기수시기를 캐어냈을 때라고 보는 입장에서 甲의 죄책이 단순절도에 그친다면, 乙은 단순절도의 방조범만이 성립한다. 그리고 甲과는 달리 친족관계 없는 乙에 대해서는 친족상도례는 적용되지 않는다.

3) 반대 결론 : 절취행위의 기수시기는 취득시 즉 새로운 점유의 취득은 재물에 대하여 방해받지 않는 사실상의 지배를 갖는 때이다. 크고 무거워 운반이 용이하지 않은 물건의 경우 그 물건의 소유자의 지배범위를 벗어나야 기수에 이른다고 볼 것이다.

4) 반대 결론에 따른 사안의 해결 : 사안에서 甲의 절취행위는 아직 기수에 이르지 않은 상태에서 乙과 시간·장소적으로 협동하여 절도를 완성했으므로 甲은 합동절도죄의 죄책을 진다.

5) 이 경우 장물운반죄의 성부에 대한 논의를 언급하면 가정을 받을 수 있을 것이다.

IV. 사안의 해결

1. 甲의 죄책

甲은 ① 주거침입죄 ② 단순절도죄가 성립하며, 양자는 실체적 경합관계에 있다. 그러나 단순절도에 대하여는 친족상도례의 적용으로 형이 면제된다.

2. 乙의 죄책

乙은 ① 주거침입죄 ② 단순절도의 방조범이 성립하며, 친족상도례는 적용되지 않는다. 그리고 ①과 ②의 죄는 실체적 경합관계에 있다.

관련판례

1. 절친한 옆집에 물건을 훔치러 들어간 사건

피고인이 피해자와 이웃 사이여서 평소 그 주거에 무상출입하던 관계에 있었다 하더라도 범죄의 목적으로 피해자의 승낙 없이 그 주거에 들어간 경우에는 주거침입죄가 성립한다.(대판 1983.7.12. 83도1394)

2. 입목절도 사건 (부부 영산홍 절취 사건)

[사실관계] 甲女는 모 연구소 마당에 쏘렌토 승용차를 두고 그 곳에서 약 20m 떨어진 丙 소유의 영산홍 1그루를 캐내었으나, 이 영산홍은 높이가 약1m 50cm 이상, 폭 약1m 정도로서 상당히 클 뿐만 아니라, 뿌리가 상하지 않도록 뿌리 부분의 흙까지 함께 캐내어져 甲女가 혼자서 이를 운반하기는 어려웠다. 이에 甲은 남편인 乙에게 전화를 걸어 영산홍을 차에 싣는 것을 도와 달라고 말하였고, 잠시 후 현장에 온 乙은 甲女와 함께 위 영산홍을 위 승용차까지 운반하였다. 甲女와 乙에게 2인 이상이 합동한 특수절도죄가 성립하는가?

[판결요지] [1] 입목을 절취하기 위하여 캐낸 때에 소유자의 입목에 대한 점유가 침해되어 범인의 사실적 지배하에 놓이게 되므로 범인이 그 점유를 취득하고 절도죄는 기수에 이른다. 이를 운반하거나 반출하는 등의 행위는 필요하지 않다. [2] 절도범인이 혼자 입목을 땅에서 완전히 캐낸 후에 비로소 제3자가 가담하여 함께 입목을 운반한 사안에서, 특수절도죄의 성립을 부정한 사례.(대판 2008.10.23. 2008도6080)

♣ 돌발퀴즈

제328조 제1항의 친족의 범위는 피해자와 직계혈족, 배우자, 동거친족, 동거가족 또는 그 배우자관계가 있는 경우에 적용된다.

정답 : O

해설 : 제328조 제1항의 규정에 따라 타당한 지문이다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 절도죄의 실행의 착수에 대한 판례의 태도는?

- ① 형식적 객관설
- ② 물색설
- ③ 절충설
- ④ 주관설
- ⑤ 취득설

정답 : ②

해설 : 일반적인 절도죄의 실행의 착수에 대한 판례의 태도는 물색설이다.

2. 제328조 제1항의 친족의 범위에 속하지 아니한 자는?

- ① 직계혈족
- ② 배우자
- ③ 호주
- ④ 동거친족
- ⑤ 동거가족

정답 : ③

해설 : 제328조 제1항 참조.

3. 친족상도례 규정인 제328조 제2항의 법적 효과는?

- ① 위법성을 조각한다.
- ② 책임을 조각한다.
- ③ 형을 면제한다.
- ④ 형을 감경 또는 면제한다.
- ⑤ 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다.

정답 : ⑤

해설 : 제328조 제2항 참조.

♣ 학습내용 정리

1. 주거침입죄의 주거란 단순히 가옥 자체만을 말하는 것이 아니라 그 정원 등 위요지를 포함하므로 피해자의 뒷마당에 들어갔더라도 주거에 출입한 것이 된다.
2. 절도죄의 기수시기에 대하여 취득설이 일반화되어 있다고 하더라도 목적물이 커다란 수목인 경우에는 이를 언제 취득한 것으로 볼 것이냐에 대하여 논의가 있다.
3. 판례는 소위 ‘부부 영산홍 절취 사건’에서 ‘입목을 절취하기 위하여 이를 캐낸 때에는 그 시점에서 이미 소유자의 입목에 대한 점유가 침해되어 범인의 사실적 지배하에 놓이게 됨으로써 범인이 그 점유를 취득하게 되는 것이므로, 이때 절도죄는 기수에 이르렀다고 할 것이고, 이를 운반하거나 반출하는 등의 행위는 필요로 하지 않는다’라고 하여 수목 등을 캐어 내었을 때를 기수시기로 판단하고 있다.

제13강 공모관계로부터의 이탈

♣ 학습목표

공모관계로부터의 이탈에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

공모공동정범의 성립요건

공모관계로부터의 이탈의 성립요건

합동범의 공동정범의 인정여부

♣ 사전테스트

1. 현재의 판례와 학설은 기능적 행위지배설에 따라 공모공동정범을 긍정하고 있다.

정답 : O

해설 : 2000년 이후의 학설과 판례의 태도에 따르면 타당한 지문이다.

2. 공모관계로 부터의 이탈이 인정되기 위해서는 다른 공모자가 실행의 착수하기 이전이어야 한다.

정답 : O

해설 : 실행의 착수전에 이탈하여야 공모관계로 부터의 이탈이 인정되므로 타당한 지문이다.

3. 판례는 합동범의 공동정범을 부정하고 있다.

정답 : X

해설 : 판례는 일정한 요건하에 합동범의 공동정범을 긍정하고 있으므로 타당하지 않은 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

교도소에서 만난 甲, 乙, 丙 세 사람은 출소 후 재회한 자리에서 甲이 근무한 적이 있는 A 산업 창고에 보관되어 있는 전자 부품을 절취하기로 결의하였다. 甲은 전자 제품에 대한 정보 및 침입 방법과 보안장치 해제 방법을 알려주는 등 주도적으로 구체적인 범행 계획을 수립하였다. 그런데 그 후 甲은 고향으로 돌아오라는 어머니의 전화를 받고서 마음의 동요를 일으키게 되어 스스로 범행을 포기하기로 하였다.

甲이 乙과 丙에게도 범행을 포기하도록 권유하였다면 그 권유 시점과 乙, 丙의 범행의 시간적 진행을 고려하여 판례에 따라 다음을 논하시오(단, 甲과 상관없이 乙과 丙이 스스로 범행을 포기하는 경우는 상정하지 않는다).

1. 甲이 무죄가 되는 경우 (10점)
2. 甲이 특수절도죄의 기수가 되는 경우 및 특수절도죄의 중지미수가 되는 경우 (20점)

[해설]

[1. 문 해설 (10점)]

1. 논의점

甲은 乙, 丙과 같이 범행을 주도적으로 모의하였으나 이후의 마음의 동요를 일으키어 범행을 포기하고 있다. 이러한 경우에 甲이 무죄가 되는 경우를 정리하면 다음과 같다.

2. 乙과 丙의 실행의 착수가 없는 경우

甲이 乙과 丙의 실행의 착수전의 권유로 인하여 乙과 丙이 합동절도죄의 실행의 착수가 없었던 경우에는 甲, 乙, 丙은 모두 절도죄의 예비에 해당하나 절도죄의 예비를 처벌하는 규정이 없으므로 甲은 무죄가 된다.

3. 乙과 丙의 실행의 착수가 있는 경우

(1) 판례에서의 공모공동정범의 인정과 공모관계로부터의 이탈

- 1) 최근의 판례는 기능적 행위지배설에 따라 공모공동정범을 인정하고 있다. 사안에서는 甲이 주도적인 역할을 하고 있으므로 기능적행위지배가 인정된다고 볼 수 있으므로 甲이 무죄가 되기 위해서는 공모관계에서의 이탈이 인정되어야 한다.
- 2) 기능적 행위지배설의 입장에 따라 공모관계에서의 이탈이 인정되기 위해서는 ① 이탈의 시기와 관련하여 乙과 丙이 실행의 착수가 있기 전에 이탈을 하고 ② 이탈행위와 관련해서는 기능적행위지배를 제거하여야 한다는 입장과 기능적 행위지배를 제거할 필요가 없다는 입장이 대립하고 있다. 판례는 기능적행위지배를 제거하여야 한다는 입장을 취하고 있다.

(2) 판례에 의한 사안의 해결

사안의 경우에 판례에 따라 甲이 무죄가 되기 위해서는 ① 乙과 丙의 실행의 착수이전에 범행포기를 권유하고 ② 기능적행위지배제거필요설에 따라 甲이 범행포기의 권유로 기능적 행위지배가 제거되었다고 평가된다면 甲은 무죄가 될 것이다.

[2. 문 해설 (20점)]

I. 甲이 특수절도죄의 기수나 중지미수가 되기 위한 공통적인 요건

1. 논의점

사안에서 甲이 특수절도의 기수나 중지미수가 성립하기 위한 공통적인 요건은 ① 甲에게 공모관계에서의 이탈이 인정되지 않아야 하고 ② 합동절도의 공동정범이 인정되어야 한다.

2. 공모관계에서의 이탈의 불인정

판례에 의하면 공모관계의 이탈을 인정하지만, 이탈이 인정되기 위해서는 ① 공모자들의 실행의 착수가 있기 전에 이탈을 하고 ② 기능적행위지배제거가 필요하다고 보고 있다. 따라서 사안에서 甲이 ① 공모자들의 실행의 착수 이후에 범행포기를 권유하거나 ② 공모자들의 실행의 착수 이전에 범행포기를 권유했더라도 기능적행위지배가 제거되지 않았다면 甲을 공동정범으로 처벌할 수 있게 된다.

3. 합동범의 공동정범의 인정

- (1) 사안은 일반절도가 아닌 합동절도이므로 합동범에 대한 공동정범을 인정할 수 있을 것인가가 논의되지만, 판례에 의하면 합동범의 공동정범을 긍정하고 있다. 이러한 판례에 의하면 현장에 없는 사람이 합동범의 공동정범이 성립되기 위해서는 ① 먼저 3인 이상이 모의가 있어야 하며 ② 2인 이상이 시간·장소적 협동관계가 있어 현장설에 입각한 합동범의 성립이 인정되어야 하며 ③ 현장에 참여하지 않은 사람에게 기능적행위지배설에 따른 정범표지가 인정되어야 한다.
- (2) 사안에서는 甲과 乙 및 丙이 모의하였으므로 ①요건은 구비되어 있으며, 甲은 범행을 주모하고 본질적인 기여를 하고 있어 기능적 행위지배를 인정할 수 있으므로 공동정범의 정범표지가 인정되므로 ③요건도 구비되어 있다. 따라서 사안에서는 乙과 丙이 현장설에 따라 합동절도를 범하게 되면 ②요건을 충족하여 甲이 합동절도의 공동정범이 성립할 수 있다.

II. 특수절도의 기수가 인정되는 경우

따라서 사안에서 甲이 특수절도의 기수가 인정되기 위해서는 위와 같은 요건을 구비하고 乙과 丙이 현장설에 따라 시간·장소적인 협동관계에 의한 합동절도의 기수가 성립하면 甲은 특수절도의 기수가 성립한다.

III. 특수절도의 중지미수가 인정되는 경우

1. 논의점

사안에서 甲에게 특수절도의 중지미수가 성립하기 위해서는 위의 공통적인 요건을 구비한 이외에 특수한 요건으로는 ① 주관적 요건으로서 자의성과 ② 乙과 丙의 범행결과발생의 방지 행위가 필요하다.

2. 甲에게 중지미수가 인정되기 위한 주관적 요건으로서 자의성

자의성에 대하여는 견해가 대립되고 있지만, 사회통념에 따른다는 절충설이 다수설과 판례이다. 이러한 절충설에 따르면 甲의 자율적 동기의 경우에는 자의성이 인정되고 타율적 동기의 경우에는 자의성이 부정된다. 사안의 경우에는 어머니로부터 전화를 받은 것만으로는 타율적 동기인 것으로 보아야 할 수 없어 자의성을 인정할 수 있다고 보아야 한다.

3. 甲에게 중지미수가 인정되기 위한 객관적 요건

- (1) 사안에서 甲에게 자의성이 인정된다고 하더라도 중지미수가 인정되기 위해서는 객관적 요건이 인정되어야 한다. 중지미수성립의 객관적 요건은 착수미수의 경우에는 행위계속을 포기하고, 실행미수의 경우에는 범행결과발생을 방지하기 위한 진지한 노력을 하고 이에 따라 결과발생이 방지되어야 한다.
- (2) 따라서 사안에서 乙과 丙의 행위가 실행에 착수한 이후에 甲이 乙과 丙에게 행위계속을 포기하게 하거나, 진지한 노력을 하여 결과발생을 방지하였다면 甲은 특수절도의 중지미수가 인정된다.

관련판례

1. ‘어?’라고만 하고 더 이상 만류하지 않은 사건

[1] 공모공동정범에 있어서 공모자 중의 1인이 다른 공모자가 실행행위에 이르기 전에 그 공모관계에서 이탈한 때에는 그 이후의 다른 공모자의 행위에 관하여는 공동정범으로서의 책임은 지지 않는다 할 것이나, 공모관계에서의 이탈은 공모자가 공모에 의하여 담당한 기능적 행위지배를 해소하는 것이 필요하므로 공모자가 공모에 주도적으로 참여하여 다른 공모자의 실행에 영향을 미친 때에는 범행을 저지하기 위하여 적극적으로 노력하는 등 실행에 미친 영향력을 제거하지 아니하는 한 공모관계에서 이탈하였다고 할 수 없다. [2] 다른 3명의 공모자들과 강도 모의를 하면서 삼을 들고 사람을 때리는 시늉을 하는 등 그 모의를 주도한 피고인이 함께 범행 대상을 물색하다가 다른 공모자들이 강도의 대상을 지목하고 뒤쫓아 가자 단지 "어?"라고만 하고 비대한 체격 때문에 뒤따라가지 못한 채 범행현장에서 200m 정도 떨어진 곳에 앉아 있었으나 위 공모자들이 피해자를 쫓아가 강도상해의 범행을 한 사안에서, 피고인에게 공동가공의 의사와 공동의사에 기한 기능적 행위지배를 통한 범죄의 실행사실이 인정되므로 강도상해죄의 공모관계에 있고, 다른 공모자가 강도상해죄의 실행에 착수하기까지 범행을 만류하는 등으로 그 공모관계에서 이탈하였다고 볼 수 없으므로 강도상해죄의 공동정범으로서의 죄책을 진다고 한 사례.(대판 2008.4.10. 2008도1274)

2. 공모이후 별건으로 체포된 사건

[1] 공모공동정범에 있어서 공모자 중의 1인이 다른 공모자가 실행행위에 이르기 전에 그 공모관계에서 이탈한 때에는 그 이후의 다른 공모자의 행위에 관하여는 공동정범으로서의 책임은 지지 않는다 할 것이나, 공모관계에서의 이탈은 공모자가 공모에 의하여 담당한 기능적 행위지배를 해소하는 것이 필요하므로 공모자가 공모에 주도적으로 참여하여 다른 공모자의 실행에 영향을 미친 때에는 범행을 저지하기 위하여 적극적으로 노력하는 등 실행에 미친 영향력을 제거하지 아니하는 한 공모자가 구속되었다는 등의 사유만으로 공모관계에서 이탈하였다고 할 수 없다. [2] 갑이 을과 공모하여 가출 청소년 병(여, 16세)에게 낙태수술비를 벌도록 해 주겠다고 유인하였고, 을로 하여금 병의 성매매 홍보용 나체사진을 찍도록 하였으며, 병이 중도에 약속을 어길 경우 민형사상 책임을 진다는 각서를 작성하도록 한 후, 자신이 별건으로 체포되어 구치소에 수감 중인 동안 병이 을의 관리 아래 12회에 걸쳐 불특정 다수 남성의 성매수 행위의 상대방이 된 대가로 받은 돈을 병, 을 및 갑의 처 등이 나누어 사용한 사안에서, 병의 성매매 기간 동안 갑이 수감되어 있었다 하더라도 위 갑은 을과 함께 미성년자유인죄, 구 청소년의 성보호에 관한 법률(2009. 6. 9. 법률 제9765호 아동·청소년의 성보호에 관한 법률로 전부 개정되기 전의 것) 위반죄의 책임을 진다고 한 원심판단을 수긍한 사례.(대판 2010.9.9. 2010도6924)

3. 빼끼 주점사건

[사실관계] 빼끼주점의 지배인인 甲은 술에 취한 피해자 A에게 술을 먹이고, 신용카드를 강취하여 비밀번호를 알아낸 후, 폭력배인 乙과 丙에게 위 신용카드를 이용하여 현금자동지급기에서 현금 500만원을 인출하도록 하였다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 3인 이상의 범인이 합동절도의 범행을 공모한 후 적어도 2인 이상의 범인이 범행 현장에서 시간적, 장소적으로 협동관계를 이루어 절도의 실행행위를 분담하여 절도 범행을 한 경우에는 공동정범의 일반이론에 비추어 그 공모에는 참여하였으나 현장에서 절도의 실행행위를 직접 분담하지 아니한 다른 범인에 대하여도 그가 현장에서 절도범행을 위 2인 이상의 범인의 행위를 자기 의사의 수단으로 하여 합동절도의 범행을 하였다고 평가할 수 있는 정범성의 표지를 갖추고 있다고 보여지는 한 그 다른 범인에 대하여 합

동절도의 공동정범의 성립을 부정할 이유가 없다고 할 것이다. 형법 제331조 제2항 후단의 규정이 위와 같이 3인 이상이 공모하고 적어도 2인 이상이 합동절도의 범행을 실행한 경우에 대하여 공동정범의 성립을 부정하는 취지라고 해석할 이유가 없을 뿐만 아니라, 만일 공동정범의 성립가능성을 제한한다면 직접 실행행위에 참여하지 아니하면서 배후에서 합동절도의 범행을 조종하는 수괴는 그 행위의 기여정도가 강력함에도 불구하고 공동정범으로 처벌받지 아니하는 불합리한 현상이 나타날 수 있다. 그러므로 합동절도에서도 공동정범과 교사범·종범의 구별기준은 일반원칙에 따라야 하고, 그 결과 범행현장에 존재하지 아니한 범인도 공동정범이 될 수 있으며, 반대로 상황에 따라서는 장소적으로 협동한 범인도 방조만 한 경우에는 종범으로 처벌될 수도 있다.(대판 1998.5.21. 98도321전합)

4. 판례에서의 중지미수

중지미수라 함은 범죄의 실행행위에 착수하고 그 범죄가 완수되기 전에 자기의 자유로운 의사에 따라 범죄의 실행행위를 중지하는 것으로서 장애미수와 대칭되는 개념이나 중지미수와 장애미수를 구분하는데 있어서는 범죄의 미수가 자의에 의한 중지이나 또는 어떤 장애에 의한 미수이냐에 따라 가려야 하고 특히 자의에 의한 중지중에서도 일반사회통념상 장애에 의한 미수라고 보여지는 경우를 제외한 것을 중지미수라고 풀이함이 일반이다.(대판 1985.11.12. 85도2002)

♣ 돌발퀴즈

공모관계로 부터의 이탈이 인정되기 위해서는 자기가 설정한 기능적 행위지배를 제거하여야 한다.

정답 : O

해설 : 공모관계에서의 이탈은 공모자가 공모에 의하여 담당한 기능적 행위지배를 해소하는 것이 필요하므로 공모자가 공모에 주도적으로 참여하여 다른 공모자의 실행에 영향을 미친 때에는 범행을 저지하기 위하여 적극적으로 노력하는 등 실행에 미친 영향력을 제거하지 아니하는 한 공모관계에서 이탈하였다고 할 수 없다. (대판 2008.4.10. 2008도1274)

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 합동범의 본질에 대한 학설이 아닌 것은?

- ① 공모공동정범설
- ② 가중된 공동정범설
- ③ 현장설
- ④ 현장적 공동정범설
- ⑤ 행위공동설

정답 : ⑤

해설 : 행위공동설은 공동정범의 본질에 관한 학설이다.

2. 공모공동정범에 대한 판례의 태도는?

- ① 긍정설
- ② 부정설
- ③ 기능적 행위지배설
- ④ 우월적 의사지배설
- ⑤ 목적적 행위지배설

정답 : ③

해설 : 2000년 이후의 판례는 기능적 행위지배설에 따라 공모공동정범을 긍정하고 있다.

3. 판례에 의할 때 합동범의 기수의 공동정범의 성립요건이 아닌 것은?

- ① 3인 이상의 범행의 모의
- ② 2인 이상의 현장설에 따른 실행의 착수
- ③ 범행의 결과 발생
- ④ 현장에 가지 않은 자에게 정범표지 인정
- ⑤ 공모관계에서의 이탈

정답 : ⑤

해설 : 공모관계에서의 이탈은 합동범의 공동정범과는 전혀 무관하다.

♣ 학습내용 정리

1. 최근의 판례는 기능적 행위지배설에 따라 공모공동정범을 인정하고 있다.
2. 기능적 행위지배설의 입장에 따라 공모관계에서의 이탈이 인정되기 위해서는 ① 이탈의 시기와 관련하여 乙과 丙이 실행의 착수가 있기 전에 이탈을 하고 ② 이탈행위와 관련해서는 기능적행위지배를 제거하여야 한다는 입장과 기능적 행위지배를 제거할 필요가 없다는 입장이 대립하고 있다.
3. 판례는 공모관계에서의 이탈이 인정되기 위해서는 기능적행위지배를 제거하여야 한다는 입장을 취하고 있다.
4. 판례에 의하면 현장에 없는 사람이 합동범의 공동정범이 성립되기 위해서는 ① 먼저 3인 이상이 모의가 있어야 하며 ② 2인 이상이 시간·장소적 협동관계가 있어 현장설에 입각한 합동범의 성립이 인정되어야 하며 ③ 현장에 참여하지 않은 사람에게 기능적행위지배설에 따른 정범표지가 인정되어야 한다.

제14강 합동범과 승계적 공동정범

♣ 학습목표

합동범과 승계적 공동정범에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

합동범의 성립요건

승계적 공동정범의 성립요건

공모공동정범과 기능적 행위지배설

♣ 사전테스트

1. 현재의 판례와 학설은 현장설에 따라 합동범의 성립을 긍정하고 있다.

정답 : O

해설 : 판례와 학설은 시간·장소적인 협동관계에 있는 경우에만 합동범의 성립을 인정하는 현장설을 따르고 있다고 보는 것이 일반적이다.

2. 판례는 포괄일죄의 일부에 가담한 자에 대하여 전체에 대하여 책임을 인정하고 있다.

정답 : X

해설 : 포괄일죄의 범행 도중에 공동정범으로 범행에 가담한 자는 비록 그가 그 범행에 가담할 때에 이미 이루어진 종전의 범행을 알았다 하더라도 그 가담 이후의 범행에 대하여만 공동정범으로 책임을 진다.(대판 1997.6.27. 97도163)

3. 판례는 공모공동정범을 전면적으로 긍정하고 있다.

정답 : X

해설 : 2000년 이후의 판례는 공모공동정범을 기능적행위지배가 인정되는 경우에만 인정하고 있으므로 타당하지 않은 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

甲, 乙, 丙은 A의 가전제품 창고의 물건을 강취하기로 공모하였다. 다만 甲은 현장에 가지 않고 범행이 성공하면 장물을 처분한 돈을 배분받기로 합의하였다. 범행 당일 乙과 丙이 A의 창고를 향해 가다가 갑자기 乙은 '그만 두겠다'고 말하고 귀가해 버렸다. 그러자 丙은 혼자 A의 창고로 들어가 A를 폭행한 후 기둥에 묶어 놓고 창고 앞 길가로 나와 지나가던 택시운전사 丁에게 지금까지의 사정을 설명하고 범행을 함께 할 것을 제안하자 이에 동의한 丁은 丙과 함께 A의 창고의 가전제품들을 자신의 차에 옮겨 싣고 범행 장소를 떠났다. 甲, 乙, 丙, 丁의 죄책을 논하시오. (30점)

[해설]

I. 사안의 정리

사안에서의 甲, 乙, 丙, 丁의 죄책을 논리적인 순서에 따라 ① 직접실행행위를 한 丙의 죄책 ② 丙의 범죄에 사후에 가담한 丁의 죄책 ③ 강도를 공모하였지만 실행행위를 하지 않은 甲과 乙의 죄책의 순서로 검토한다.

II. 丙의 죄책

1. 주거침입죄의 성부

사안에서 丙이 가전제품을 강취하기 위하여 A가 관리하는 창고에 들어간 행위는 주거침입죄에 해당한다.

2. 감금죄의 성부

사안에서 丙이 A를 기둥에 묶어 놓아 A의 장소적 이전의 자유를 일정시간 동안 제한하였으므로 감금죄에 해당한다.

3. 강도죄의 성부

사안에서 丙이 창고에 들어가 A를 폭행하고 폭행을 수단으로 하여 창고에 있는 가전제품을 탈취하였으므로 강도죄가 성립한다.

4. 丙의 죄책

丙은 기본적으로 주거침입죄와 감금죄, 강도죄가 성립한다. 그리고 A를 강도의 수단으로 창고의 기둥에 묶어둔 행위는 단순히 강도의 수단에 그치는 경우가 아니라 강도행위가 끝난 후에도 감금행위가 계속된 경우이므로 각각의 죄는 실체적 경합관계에 있다.

III. 丁의 죄책

1. 논의점

사안에서 丁은 丙이 강도의 고의로 A에게 폭행을 가한 행위 이후에 주거에 침입하여 재물 탈취행위에만 가담하였다. 주거침입에 대한 점은 차치하고 재물탈취행위에만 가담한 丁에게 강도죄 전체에 대한 책임을 물을 수 있는가가 문제된다. 즉 후행행위에 대하여 공동정범이 성립한다고 할 때 후행가담자에게 가담 이전의 행위에 대하여도 책임을 물을 수 있는지를 두고 논의가 있다.

2. 견해의 대립

이에 대하여는 ① 주관주의 입장에서 후행위자가 선행사실을 용인하고 이를 이용한 이상 선행행위 부분에 대하여도 책임을 져야 한다는 긍정설 ② 객관주의 입장에서 후행위자는 자기책임의 원칙상 가담이후의 부분에 대하여만 책임을 져야 한다는 부정설이 대립하고 있다.

3. 판례의 태도

판례는 ① 포괄일죄와 관련된 판례에서는 가담 이후의 범행에 대해서만 공동정범으로서의 책임을 진다고 하여 가담이전 부분에 대한 죄책을 부정하고 ② 결합범과 관련된 판례에서는 전체범죄에 대한 방조만을 인정함으로써 전체범죄에 대한 공동정범의 성립을 인정하지 않아 부정설의 입장이다.

4. 검토 및 사안의 해결

생각건대 승계적 공동정범의 경우에도 행위책임의 원칙이 실현되어야 하고, 가담이전에 행위에 대하여는 기능적행위지배를 인정할 수 없으므로 부정설이 타당하다. 이에 의하면 사안과 같이 불법이 분리될 수 있는 경우(범죄의 성립이 달라지는 경우)에는 가담 이전의 범죄에 대하여는 공동정범이 성립되지 않는다. 이러한 부정설에 따르면 사안에서 丁은 강도죄가 아닌 합동절도죄에 대한 죄책만 지게 된다.

5. 丁의 죄책

丁은 주거침입죄와 합동절도죄가 성립하며 양죄는 실체적 경합관계에 있다.

IV. 甲과 乙의 죄책

1. 논의점

甲과 乙은 강도죄를 공모하였지만 직접 실행행위를 하고 있지 않다. 이러한 甲과 乙을 丙의 범죄에 대한 공동정범으로 볼 수 있는지가 문제된다. 이것은 공모공동정범의 인정여부에 대한 문제이다.

2. 공모공동정범에 대한 논의

(1) 공모공동정범의 인정여부에 대하여는 종래에는 논의가 있었지만, 최근의 학설과 2000년 이후의 판례는 모두 기능적 행위지배설의 입장에서 실행행위를 하지 않은 자일지라도 기능적 행위지배가 인정되는 경우에는 공동정범이 성립할 수 있다고 보고 있다.

(2) 최근의 판례에서도 ‘형법 제30조의 공동정범은 공동가공의 의사와 그 공동의사에 기한 기능적 행위지배를 통한 범죄 실행이라는 주관적·객관적 요건을 충족함으로써 성립하는 바, 공모자 중 구성요건 행위 일부를 직접 분담하여 실행하지 않은 자라도 경우에 따라 이른바 공모공동정범으로서의 죄책을 질 수도 있는 것이기는 하나, 이를 위해서는 전체 범죄에 있어서 그가 차지하는 지위, 역할이나 범죄 경과에 대한 지배 내지 장악력 등을 종합해 볼 때, 단순한 공모자에 그치는 것이 아니라 범죄에 대한 본질적 기여를 통한 기능적 행위지배가 존재하는 것으로 인정되는 경우여야 한다’라고 하여 기능적 행위지배설을 따르고 있다.

(3) 사안의 적용

이러한 기능적 행위지배설을 사안에 적용하게 되면 사안에서 甲과 乙은 丙과 단순공모자로서 모의를 한 것에 불과하고 범죄에 본질적 기여를 한 표지가 나타나 있지 않다. 따라서 甲과 乙은 기능적 행위지배라는 정범표지를 구비하지 못하였으므로 丙의 범죄에 대한 공동정범은 성립하지 않는다.

3. 甲과 乙의 죄책

사안에서 甲과 乙은 단순공모자에 불과하므로 丙의 범죄에 공동정범이 인정될 수 없고, 사전에 강도죄를 음모한 부분에 대하여만 강도죄의 예비·음모죄로 처벌된다. 그리고 乙과 관련하여서는 예비의 중지가 문제될 수 있지만, 사안에서는 乙에게 자의성이 인정될 수 있는 표지가 없으므로 이는 논하지 않는다.

V. 사안의 해결

- (1) 丙이 A의 창고에 침입하여 가전제품을 취거한 행위는 기본적으로 주거침입죄, 감금죄, 단순강도죄에 해당하며, 이들 범죄는 실체적 경합범관계에 있다. 그러나 행위상황이 야간인 경우에는 특수강도인 야간주거침입강도죄와 감금죄가 성립하고 양자는 실체적 경합관계에 있게 된다.
- (2) 丁은 주거침입죄와 특수절도죄가 성립하며, 양자는 실체적 경합관계에 있다.
- (3) 甲과 乙은 단순공모자에 불과하므로 기능적 행위지배가 인정되지 않아 강도예비·음모죄만 성립한다.

관련판례

1. 강도상해후 계속 태우고 가다 잡힌 사건

감금행위가 단순히 강도상해 범행의 수단이 되는 데 그치지 아니하고 강도상해의 범행이 끝난 뒤에도 계속된 경우에는 1개의 행위가 감금죄와 강도상해죄에 해당하는 경우라고 볼 수 없고, 이 경우 감금죄와 강도상해죄는 형법 제37조의 경합범 관계에 있다.(대판 2003.1.10. 2002도4380)

2. 주거침입죄와 합동절도죄의 관계

[1] 형법 제331조 제2항의 특수절도에 있어서 주거침입은 그 구성요건이 아니므로, 절도범인이 그 범행 수단으로 주거침입을 한 경우에 그 주거침입행위는 절도죄에 흡수되지 아니하고 별개로 주거침입죄를 구성하여 절도죄와는 실체적 경합의 관계에 있게 된다(대법원 2008.11.27. 선고 2008도7820 판결 참조). [2] 2인 이상이 합동하여 야간이 아닌 주간에 절도의 목적으로 타인의 주거에 침입하였다 하여도 아직 절취할 물건의 물색행위를 시작하기 전이라면 특수절도죄의 실행에는 착수한 것으로 볼 수 없는 것이어서 그 미수죄가 성립하지 않는다(대법원 1992.9.8. 선고 92도1650, 92감도80 판결 참조). [3] 위 법리에 비추어 보면, 원심이 주간에 피해자의 아파트 출입문 시정장치를 손괴하다가 마침 귀가하던 피해자에게 발각되어 도주한 피고인들에 대하여 형법 제331조 제2항에 정한 특수절도죄의 실행의 착수가 없었다는 이유로 무죄를 선고한 조치는 옳고, 주장과 같은 법리오해의 위법이 없다.(대판 2009.12.24. 2009도9667)

3. 포괄일죄의 중간에 가담한 사건

[사실관계] 농업협동조합의 조합장인 甲과 전무인 乙은 공모하여 양곡업자에게 백미를 외상으로 판매함에 있어서 담보가치가 전혀 없는 담보물을 제공받는 방법으로 백미 합계 27억원 상당을 외상 판매하다 그 대금의 회수를 어렵게 하였는데, 판매부장 丙은 甲과 乙의 종전의 범행을 이미 알면서도 도중에 가담하였다. 丙은 가담이전의 범죄에 대하여도 책임을 지는가?

[판결요지] 포괄일죄의 범행 도중에 공동정범으로 범행에 가담한 자는 비록 그가 그 범행에 가담할 때에 이미 이루어진 종전의 범행을 알았다 하더라도 그 가담 이후의 범행에 대하여만 공동정범으로 책임을 진다.(대판 1997.6.27. 97도163)

4. 여고생 협박 전화 사건

[사실관계] 체육교사인 甲은 제자인 A를 자기의 아파트에 유인하여 포박·감금하였다. 甲은 약취 3일째 되던 날 아파트에 들어갔을 때에는 이미 A가 탈진상태에 있어 박카스를 먹여보려 했지만 A는 제대로 마시지도 못하였다. 그때 甲은 A를 그대로 두면 죽을 것 같은 생각이 들어 병원에 옮기고 자살할 것인가, 그대로 두어 A가 죽으면 시체를 처리하고 범행을 계속할 것인가 아니면 스스로 자살할 것인가 등 두루 고민하다가 결국 병원에 옮기고 자살할 용기가 생기지 않아 그대로 나와 학교에 갔다가 돌아와 보니 A는 이미 죽

어 있었다. 그리고 甲은 자기의 옛제자인 여고생 乙女를 불러내어 A의 유괴 및 사망사실을 말하고 A의 부모에게 거액의 금품을 요구하는 협박장을 써서 보내고 협박전화도 할 것을 부탁하였고, 이에 乙女는 이를 승낙한 후 시키는 대로 금품을 요구하는 협박전화 및 편지를 하였다. 甲과 乙女の 죄책은?

[판결요지] 특정범죄가중처벌등에관한법률 제5조의 2 제2항 제1호 소정의 죄는 형법 제287조의 미성년자 약취, 유인행위와 약취 또는 유인한 미성년자의 부모 기타 그 미성년자의 안전을 염려하는 자의 우려를 이용하여 재물이나 재산상의 이익을 취득하거나 이를 요구하는 행위가 결합된 단순일죄라고 봄이 상당하므로 비록 타인이 미성년자를 약취·유인한 행위에는 가담한 바가 없다 하더라도 사후에 그 사실을 알면서 약취·유인한 미성년자를 부모 기타 그 미성년자의 안전을 염려하는 자의 우려를 이용하여 재물이나 재산상의 이익을 취득하거나 요구하는 타인의 행위에 가담하여 이를 방조한 때에는 단순히 재물 등 요구행위의 종범이 되는데 그치는 것이 아니라 결합범인 위 특정범죄가중처벌등에관한법률 제5조의 2 제2항 제1호 위반죄의 종범에 해당한다.(대판 1982.11.23. 82도2024)

♣ 돌발퀴즈

판례는 감금행위가 강도상해의 범행이 끝난 뒤에도 계속되더라도 이를 상상적 경합으로 보고 있다.

정답 : X

해설 : 감금행위가 단순히 강도상해 범행의 수단이 되는 데 그치지 아니하고 강도상해의 범행이 끝난 뒤에도 계속된 경우에는 1개의 행위가 감금죄와 강도상해죄에 해당하는 경우라고 볼 수 없고, 이 경우 감금죄와 강도상해죄는 형법 제37조의 경합범 관계에 있다.(대판 2003.1.10. 2002도4380)

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 주거침입죄의 주거에 해당하지 않는 것은?

- ① 사람의 주거
- ② 관리하는 건조물
- ③ 위요지
- ④ 점유하는 방실
- ⑤ 아파트 지상주차장

정답 : ⑤

해설 : 아파트 지상주차장은 주거에 해당하지 않는다.

2. 주거침입죄에 관련하여 틀린 지문은?

- ① 퇴거불응죄는 진정부작위범이다.
- ② 특수주거침입죄가 있다.
- ③ 신체수색죄가 있다.
- ④ 미수를 처벌하는 규정은 없다.
- ⑤ 과실을 처벌하는 규정은 없다.

정답 : ④

해설 : 주거침입죄는 그 본질이 거동범임에도 현행법은 제322조에서 미수범을 처벌하는 규정을 두고 있어 논란이 되고 있다.

3. 공모관계에서의 이탈을 인정하기 위한 판례상의 요건이 아닌 것은?

- ① 2인 이상의 공모가 있어야 한다.
- ② 공모자 중 1인 이상의 자가 실행의 착수가 있어야 한다.
- ③ 이탈자는 실행의 착수가 있기 전에 이탈하여야 한다.
- ④ 이탈자에게 공모에서의 본질적 기여가 있어야 이탈이 의미가 있다.
- ⑤ 이탈이 인정되기 위해서는 본질적 기여를 제거할 필요는 없다.

정답 : ⑤

해설 : 이탈을 인정받기 위해서는 본질적 기여를 제거하여야 한다.

♣ 학습내용 정리

1. 승계적 공동정범의 죄책범위에 대하여는 ① 주관주의 입장에서 후행위자가 선행사실을 용인하고 이를 이용한 이상 선행행위 부분에 대하여도 책임을 져야 한다는 긍정설 ② 객관주의 입장에서 후행위자는 자기책임의 원칙상 가담이후의 부분에 대하여만 책임을 져야 한다는 부정설이 대립하고 있다.
2. 판례는 ① 포괄일죄와 관련된 판례에서는 가담 이후의 범행에 대해서만 공동정범으로서의 책임을 진다고 하여 가담이전 부분에 대한 죄책을 부정하고 ② 결합범과 관련된 판례에서는 전체범죄에 대한 방조만을 인정함으로써 전체범죄에 대한 공동정범의 성립을 인정하지 않아 부정설의 입장이다.
3. 최근의 판례는 공모공동정범의 성립범위에 대하여 ‘형법 제30조의 공동정범은 공동가공의 의사와 그 공동의사에 기한 기능적 행위지배를 통한 범죄 실행이라는 주관적·객관적 요건을 충족함으로써 성립하는바, 공모자 중 구성요건 행위 일부를 직접 분담하여 실행하지 않은 자라도 경우에 따라 이른바 공모공동정범으로서의 죄책을 질 수도 있는 것이기는 하나, 이를 위해서는 전체 범죄에 있어서 그가 차지하는 지위, 역할이나 범죄 경과에 대한 지배 내지 장악력 등을 종합해 볼 때, 단순한 공모자에 그치는 것이 아니라 범죄에 대한 본질적 기여를 통한 기능적 행위지배가 존재하는 것으로 인정되는 경우여야 한다’라고 하여 기능적 행위지배설을 따르고 있다.

제15강 우연방위와 필요적 공범

♣ 학습목표

우연방위와 필요적 공범에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

야간주거침입절도죄의 성립요건

우연방위의 해결

필요적 공범과 형법총칙의 적용여부

♣ 사전테스트

1. 정보는 절도죄의 객체가 될 수 없다는 것이 판례의 태도이다.

정답 : O

해설 : 컴퓨터에 저장되어 있는 ‘정보’ 그 자체는 유체물이라고 볼 수도 없고, 물질성을 가진 동력도 아니므로 재물이 될 수 없다 할 것이다.(대판 2002.7.12. 2002도745)

2. 판례는 주간에 주거에 침입하여 야간에 절도한 경우에 야간주거침입절도죄를 부정하고 있다.

정답 : O

해설 : 형법은 야간에 이루어지는 주거침입행위의 위험성에 주목하여 그러한 행위를 수반한 절도를 야간주거침입절도죄로 중하게 처벌하고 있는 것으로 보아야 하고, 따라서 주거침입이 주간에 이루어진 경우에는 야간주거침입절도죄가 성립하지 않는다고 해석하는 것이 타당하다.(대판 2011.4.14. 2011도300,2011감도5)

3. 우연방위의 해결에 대하여 결과반가치 일원론은 무죄설을 따르고 있다.

정답 : O

해설 : 고전적 범죄체계에서는 우연방위는 정당방위가 되므로 타당한 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

컴퓨터부품 전문업체 A회사의 대표이사인 丁은 경쟁사인 X회사의 신제품 개발을 막기 위해서 X회사의 신제품 정보관련 서류를 절취할 것을 계획하고, 이를 수행할 사람을 물색하던 중 甲을 소개 받았다. 甲은 컴퓨터 전문가인 乙에게 함께 일할 것을 요청하여 승낙을 받았다. 이에 丁은 甲과 乙이 X회사의 서류를 절취한 후 안전하게 도주할 수 있도록, 자신의 자가용 운전사인 丙에게 X회사 근처에서 대기하도록 지시하였다. 다만 丁은 丙에게 甲과 乙이 X회사에 간 이유에 대해서는 말해주지 않았다. 甲은 방문객을 가장하여 16:00경 X회사에 들어가 물품보관창고에 숨어있었다. 한편 乙은 X회사 인근에서 기다리면서, 甲이 서류들을 휴대전화 카메라로 촬영·전송하여 주면, 훔칠 가치가 있는 서류인지 여부를 판별하는 작업을 하기로 하였다. 甲은 훔칠 기회를 엿보다가 21:00경이 되어 직원들이 모두 퇴근하자, 사무실로 들어가 乙에게 서류들을 휴대전화 카메라로 촬영·전송하여 주고, 乙이 중요하다고 판단한 서류들을 들고 나와 乙과 함께 도주하던 중 이를 수상히 여긴 X회사 경비원 K가 "누구나"라고 소리치자 甲과 乙은 달아났고, K가 이들을 뒤쫓았다. (이하에서 특별법위반은 논외로 함)

1. 위 사례에서 쫓기던 甲이 더 이상 달릴 수 없어 주저앉은 상황에서, 마침 그곳을 지나던 친구 B를 발견하고 뒤쫓아 오는 사람을 제압해달라고 부탁하였다. 이에 영문도 모른 채 B는 경비원 K를 폭행하였다. 甲의 죄책을 논하시오. (20점)
2. 만약 甲이 창고에 숨어있던 도중에 X회사의 금고를 강취할 목적으로 침입한 C를 보고, 자신을 발견하고 체포하고자 하는 경비원으로 오인하여 C를 폭행하였다면, 이 폭행행위에 대한 甲의 죄책을 논하시오. (10점)

[해설]

[1. 문 해설 (20점)]

1. 논의점

사안에서의 甲의 죄책에 대한 쟁점은 ① 절도죄의 객체 ② 야간주거침입죄의 성부 ③ 합동절도죄의 성부 ④ 단순절도죄의 공동정범 ⑤ 준강도의 성부 ⑥ 주거침입죄를 인정할 경우의 죄수문제 등이 문제된다.

2. 절도죄의 객체성

(1) 정보의 객체여부(서류들을 촬영하여 전송해 준 부분)

정보의 절도죄의 객체성 인정 여부가 문제되지만 ① 절도죄의 객체는 물리적 관리 가능한 '재물'에 한하지만, 컴퓨터에 저장되어 있는 '정보' 그 자체는 물리적 관리가 가능한 재물이라고 볼 수 없으며 ② 절도죄가 성립하기 위해서는 그 재물의 소유자 기타 점유자의 점유 내지 이용가능성을 배제하고 이를 자신의 점유 하에 배타적으로 이전하는 행위가 있어야만 할 것인바, 정보의 경우에는 이에 대한 점유의 이전은 존재할 수 없으므로 절도죄의 객체가 되지 아니한다.

(2) 서류의 객체여부(서류를 들고 나온 부분)

서류는 물리적 관리가 가능한 유체물인바 절도죄의 객체가 될 수 있다.

3. 야간주거침입절도죄의 성부

(1) 논의점

사안에서 甲은 주간에 주거에 들어가 있다가 야간에 서류를 절취해 나오고 있는바 야간주거침입죄가 성립할 수 있는가에 대하여 논의가 있다.

(2) 견해의 대립

이에 대하여는 ① 절취행위만 야간에 있으면 족하다는 절취행위시기준설 ② 주거침입이 야간에 있으면 족하다는 주거침입기준설 ③ 주거침입 또는 절취행위 중 어느 하나라도 야간에 있으면 족하다는 주거침입 또는 절취행위기준설 ④ 주거침입과 절취행위 모두가 야간에 이루어진 경우에만 야간주거침입절도죄가 성립한다는 주거침입 및 절취행위기준설 등이 대립하고 있다.

(3) 판례의 태도

판례는 ‘형법은 야간에 이루어지는 주거침입행위의 위험성에 주목하여 그러한 행위를 수반한 절도를 야간주거침입절도죄로 중하게 처벌하고 있는 것으로 보아야 하고, 따라서 주거침입이 주간에 이루어진 경우에는 야간주거침입절도죄가 성립하지 않는다고 해석하는 것이 타당하다’라고 하여 일응 주거침입기준설을 따르고 있다.⁶⁾

(4) 결론과 사안의 해결

생각건대 ① 제330조의 ‘야간에’는 ‘침입하여’만을 수식한다고 보아야 하며 ② 따라서 본죄의 보호법익은 ‘야간주거의 사실상의 평온’과 ‘사실상의 소유상태’라고 보아야 하므로 야간에 주거에 침입한 경우에만 본죄가 성립한다고 보는 것이 타당하다. 이러한 결론에 의하면 사안에서의 甲은 야간주거침입절도죄는 성립하지 아니하며, 원칙적으로 주거침입죄와 절도죄의 경합범이 성립한다.

4. 합동절도의 성부

사안에서 甲은 乙과 긴밀하게 협조하여 서류를 절취하고 있는바 합동절도가 성립되는지에 대하여 논의가 있을 수 있다. 합동범의 본질에 대하여는 견해가 대립되지만, 형법이 합동범에 대하여 특별히 ‘2인 이상이 합동하여’라고 규정하여 무겁게 처벌하는 것은 시간적·장소적 협동에 의하여 다수인이 동시에 죄를 범할 때에는 구체적 위험성이 증가한다는데 그 이유가 있으므로 현장설이 타당하며, 다수설과 판례의 태도이다. 이러한 현장설의 입장에 따르면 사안에서의 乙은 장소적 협동관계가 있다고 보기 어려우므로 甲은 합동절도가 성립하지 않는다.

5. B로 하여금 K를 폭행하도록 한 부분의 죄책⁷⁾

(1) 간접정범 등에 대한 검토

사안에서 甲은 절도범행의 사실을 알지 못하는 B를 이용하여 K에게 폭행을 하도록 하여 체포를 면탈하고 있다. 이러한 甲의 행위에 대하여 폭행죄의 공동정범이나 폭행죄의 교사범이 논의될 수 있겠으나 준강도의 범의를 모르는 자를 이용한 준강도의 간접정범이 성립한다고 보는 것이 타당하다.

(2) 간접정범이 성립되는 논거

6) 단 판례의 해석에 대하여는 주거침입행위 및 절취행위기준설을 따랐다고 볼 여지도 있다.

7) 사안의 경우에 폭행을 이용한 부분에 대하여는 ① 공동정범으로 보는 입장 ② 교사범으로 보는 입장으로 설시할 수도 있을 것이다. 그러나 ① 공동정범으로 보기에는 기능적 행위지배적이 측면에서 어려움이 있고 ② 교사범으로 보는 경우에는 준강도를 인정할 수 없다는 점에서 어려움이 있다.

사안에서 甲은 준강도를 범하기 위하여 이러한 정을 모르는 B를 이용하고 있는바 ① 제34조 제1항의 해석론상 ‘어느행위로 처벌되지 않는 자’란 동일한 죄로 해석을 함이 타당하고 ② 준강도를 신분범으로 볼 경우 신분있는 자가 신분없는 자를 이용하고 있으며 ③ 준강도는 목적범이므로 목적있는 자가 목적 없는 자를 이용하였다는 점에서 준강도죄의 간접정범이 성립한다고 보는 것이 타당하다.

6. 죄수 및 甲의 죄책

사안에서 야간주거침입절도를 부정하면 주거침입죄를 별도로 인정하게 되는데 이러한 경우에 준강도죄와의 죄수 관계가 문제된다. 준강도의 주체는 주거침입죄와 단순절도의 불법보다 더 큰 야간주거침입절도를 포함하고 있으므로 준강도죄가 성립한다면 주거침입죄는 이에 흡수된다고 보아야 할 것이다. 따라서 사안에서의 甲은 준강도죄가 성립한다.

[2. 문 해설 (10점)]

1. 논의점

사안에서 甲은 C에게 체포를 면탈할 목적으로 폭행을 행사하였지만 C는 강도범으로 객관적인 면에서 정당방위가 되고 있다. 그러나 甲에게는 위법성이 조각되기 위한 주관적인 면이 결여되어 있는바 이러한 우연방위의 해결에 대하여 논의가 있다.⁸⁾

2. 견해의 대립

우연방위의 해결에 대하여는 ① 주관적 정당화요소는 필요없다는 입장에서 우연방위는 정당방위로 인정되어 무죄라는 무죄설 ② 주관적 정당화요소가 필요하다는 입장에서 우연방위는 정당방위가 성립하지 않고 기수가 된다는 기수설 ③ 주관적 정당화요소가 필요하다는 입장에서 우연방위는 정당방위가 성립될 수 없으나, 불법이원론에 의해 불능미수가 성립된다는 불능미수설이 대립하고 있다.

3. 결론 및 사안의 해결

생각건대 합일태적 범죄체계를 전제로 할 때 우연방위는 위법하지만 객관적 정당화상황의 존재로 인하여 결과반가치가 축소되므로 불능미수범만 인정하는 불능미수범설이 타당하다. 따라서 사안의 경우에는 甲은 이론상 폭행죄의 불능미수가 문제되지만 폭행죄의 미수를 처벌하는 규정이 없으므로 결국 무죄가 된다.

관련판례

1. 컴퓨터 속의 정보를 종이에 출력하여 가져간 사건

[사실관계] A주식회사는 직물원단고무코팅시스템을 독자적으로 개발하였는데, 동 회사의 직원 甲은 업무용으로 지급한 노트북 컴퓨터에 저장되어 있는 직물원단고무코팅시스템의 설계도면과 공정도를 A2용지에 2장을 출력하여 가지고 나왔다. 甲의 죄책은?

[판결요지] [1] 절도죄의 객체는 관리 가능한 동력을 포함한 ‘재물’에 한한다 할 것이고, 또 절도죄가 성립하기 위해서는 그 재물의 소유자 기타 점유자의 점유 내지 이용가능성을 배제하고 이를 자신의 점유 하에 배타적으로 이전하는 행위가 있어야만 할 것인바, 컴퓨터에 저장되어 있는 ‘정보’ 그 자체는 유체물이라고 볼 수도 없고, 물질성을 가진 동력도 아니므로 재물이 될 수 없다 할 것이며, 또 이를 복사하거나 출력하였다 할지라도 그 정보 자체가 감소하거나 피해자의 점유 및 이용가능성을 감소시키는 것이 아니므로 그 복

8) 사안의 경우에는 절도의 실행의 착수가 없으므로 준강도는 문제되지 아니한다.

사나 출력 행위를 가지고 절도죄를 구성한다고 볼 수도 없다. [2] 피고인이 컴퓨터에 저장된 정보를 출력하여 생성한 문서는 피해 회사의 업무를 위하여 생성되어 피해 회사에 의하여 보관되고 있던 문서가 아니라, 피고인이 가지고 갈 목적으로 피해 회사의 업무와 관계없이 새로이 생성시킨 문서라 할 것이므로, 이는 피해 회사 소유의 문서라고 볼 수는 없다 할 것이어서, 이를 가지고 간 행위를 들어 피해 회사 소유의 문서를 절취한 것으로 볼 수는 없다.(대판 2002.7.12. 2002도745)

2. 주간에 주거에 침입하여 야간에 절도한 사건

[사실관계] “甲은 2010. 6. 16. 15 : 40경 乙이 운영하는 서울 동대문구 장안동 (이하 생략) ○○○ 모텔에 이르러, 乙이 평소 비어 있는 객실의 문을 열어둔다는 사실을 알고 그곳 202호 안까지 들어가 침입한 다음, 같은 날 21 : 00경 그곳에 설치되어 있던 乙 소유의 LCD모니터 1대 시가 3만 원 상당을 가지고 나와 절취하였다. 甲에게 야간주거절도죄가 성립하는가?

[판결요지] 형법은 제329조에서 절도죄를 규정하고 곧바로 제330조에서 야간주거침입절도죄를 규정하고 있을 뿐, 야간절도죄에 관하여는 처벌규정을 별도로 두고 있지 아니하다. 이러한 형법 제330조의 규정형식과 그 구성요건의 문언에 비추어 보면, 형법은 야간에 이루어지는 주거침입행위의 위험성에 주목하여 그러한 행위를 수반한 절도를 야간주거침입절도죄로 중하게 처벌하고 있는 것으로 보아야 하고, 따라서 주거침입이 주간에 이루어진 경우에는 야간주거침입절도죄가 성립하지 않는다고 해석하는 것이 타당하다.(대판 2011.4.14. 2011도300,2011감도5)

3. 합동하여의 의미에 대한 판례

형법 제331조 제2항 후단의 ‘2인 이상이 합동하여’라 함은 주관적 요건으로서의 공모와 객관적 요건으로서의 실행행위의 분담이 있어야 하고 그 실행행위에 있어서는 시간적으로나 장소적으로 협동관계가 있음을 요한다.(대판 1988.1.3. 88도1197)

♣ 돌발퀴즈

주관적 정당화요소가 필요없다는 입장에서는 우연방위는 기수가 된다.

정답 : X

해설 : 주관적 정당화요소가 필요없다는 고전적 범죄체계입장에서는 우연방위는 정당방위로 인정되어 무죄가 된다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 다음 중 다른 넷과 차이가 있는 것은?

- ① 야간주거침입절도
- ② 흉기휴대절도
- ③ 합동절도
- ④ 특수절도
- ⑤ 손괴후 야간주거침입절도

정답 : ①

해설 : 나머지 넷은 모두 특수절도를 의미한다.

2. 우연방위에 대한 해결학설이 아닌 것은?

- ① 무죄설
- ② 기수설
- ③ 불능미수설

- ④ 불능미수유추적용설
- ⑤ 중지미수설

정답 : ⑤

해설 : 우연방위에 대한 해결 학설 중 중지미수설은 없다.

3. 다음 중 필요적 공범인 것은?

- ① 공동정범
- ② 교사범
- ③ 방조범
- ④ 간접정범
- ⑤ 대항범

정답 : ⑤

해설 : 대항범과 집합범을 필요적 공범이라고 한다.

♣ 학습내용 정리

1. 정보의 절도죄의 객체성 인정 여부가 문제되지만 ① 절도죄의 객체는 물리적 관리 가능한 '재물'에 한하지만, 컴퓨터에 저장되어 있는 '정보' 그 자체는 물리적 관리가 가능한 재물이라고 볼 수 없으며 ② 절도죄가 성립하기 위해서는 그 재물의 소유자 기타 점유자의 점유 내지 이용가능성을 배제하고 이를 자신의 점유 하에 배타적으로 이전하는 행위가 있어야만 할 것인바, 정보의 경우에는 이에 대한 점유의 이전은 존재할 수 없으므로 절도죄의 객체가 되지 아니한다.
2. 판례는 '형법은 야간에 이루어지는 주거침입행위의 위험성에 주목하여 그러한 행위를 수반한 절도를 야간주거침입절도죄로 중하게 처벌하고 있는 것으로 보아야 하고, 따라서 주거침입이 주간에 이루어진 경우에는 야간주거침입절도죄가 성립하지 않는다고 해석하는 것이 타당하다'라고 하여 일응 주거침입기준시설을 따르고 있다.
3. 우연방위의 해결에 대하여는 ① 주관적 정당화요소는 필요없다는 입장에서 우연방위는 정당방위로 인정되어 무죄라는 무죄설 ② 주관적 정당화요소가 필요하다는 입장에서 우연방위는 정당방위가 성립하지 않고 기수가 된다는 기수설 ③ 주관적 정당화요소가 필요하다는 입장에서 우연방위는 정당방위가 성립될 수 없으나, 불법이원론에 의해 불능미수가 성립된다는 불능미수설이 대립하고 있다.

제16강 결과적 가중범의 미수

♣ 학습목표

결과적 가중범의 미수에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

준강도죄의 기수시기

결과적가중범의 미수 인정여부

준강도죄의 공동정범 인정여부

♣ 사전테스트

1. 판례는 준강도의 기수시기에 대하여 절취행위기준설을 따르고 있다.

정답 : O

해설 : 판례는 종래 폭행·협박시설을 기준으로 준강도의 기수시기를 판단하였으나, 최근에 그 태도를 변경하여 절취행위기준설을 따르고 있다.

2. 판례는 결과적 가중범의 미수를 부정하고 있다.

정답 : O

해설 : 최근 대법원 판례는 ‘전자총격기로 강간한 사건’에서 결과적 가중범의 미수를 부정하고 있다.

3. 판례는 합동절도의 일방이 준강도죄를 범한 경우에 타방은 폭행·협박에 대한 의사의 연락이 없으므로 준강도죄의 성립을 부정하고 있다.

정답 : X

해설 : 판례는 다른 공범자에 의한 폭행과 협박에 대한 예견가능성 유무를 판단하여 예견가능성이 있으면 본죄의 공동정범이 성립한다는 긍정설의 입장이므로 타당하지 않은 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

甲은 야간에 A가 운영하는 주점 앞을 지나다가 A가 주점 문을 잠근 후 열쇠를 바닥에 떨어뜨린 사실을 모른 채 차를 몰고 퇴근하는 것을 목격한 후 열쇠를 주워서 영득하였다. 甲은 즉시 자신의 친구 乙을 불러내어 A의 주점에 몰래 들어가 양주를 절취하기로 모의하고, 乙이 주점 앞에서 망을 보는 동안에 甲은 열쇠를 이용하여 주점 안으로 들어가 미리 준비한 바구니에 양주를 담고 있었다. 그런데 몇 십분 후 A는 열쇠를 찾기 위해 되돌아 왔고, 주점 앞에서 서성거리는 乙을 수상히 여겨 무슨 일이냐고 묻자, 乙은 아무 말도 하지 않고 그냥 도주해 버렸다. 한편 바구니에 양주를 담고 있던 甲은 주점 안으로 들어오는 A를 발견하고는 바구니를 그대로 둔 채 체포를 면탈하기 위하여 A를 어깨로 밀어 넘어지게 하고 도주하였다. 그런데 A는 뒤로 넘어지면서 머리가 땅에 부딪혀 상해를 입게 되었다. 甲과 乙의 죄책은? (50점)

[해설]

I. 사안의 정리

사안에서 甲의 죄책을 시간진행에 따라 ① 甲이 A의 열쇠를 습득한 행위 ② A주점 안으로 들어가 절취하는 행위 ③ A를 폭행한 행위 ④ A에게 상해를 입힌 행위의 순서로 검토하고, 乙의 죄책에 대하여는 甲에게 성립한 범죄에 대해 어느 정도 범위까지 공동정범으로 책임을 지는지를 검토한다.

II. 甲의 죄책

1. 열쇠를 습득한 행위

사안에서는 명확하지 않지만 A의 주점은 불특정다수인이 통행하는 도로변에 있는 것으로 보이므로 A가 주점 앞에서 잃어버린 열쇠는 A의 의사에 반하여 점유를 이탈한 물건이다. 따라서 甲이 이를 영득한 것은 점유이탈물횡령죄에 해당한다.

2. A의 주점에 침입하여 절취하는 행위

(1) A의 주점에 침입하여 절취하는 행위에 대한 평가

甲이 절도를 위하여 A주점에 들어간 것은 주거침입죄에 해당하지만, 사안에서 甲이 야간에 절도 목적으로 타인의 건조물에 침입하였으므로 야간주거침입절도죄의 구성요건해당성이 인정된다. 그런데 사안에서는 甲은 乙과 시간·장소적인 협동관계를 이루어 절도를 하고 있으므로 甲은 합동절도가 성립한다. 이러한 경우 합동절도가 성립하게 되면 야간주거침입절도는 이에 흡수되어 합동절도만이 성립한다.

(2) 합동절도죄의 기수여부

절취행위의 기수시기는 원칙적으로 취득시 즉 새로운 점유의 취득은 재물에 대하여 방해받지 않는 사실상의 지배를 갖는 때이다. 다만 사안처럼 크고 무거워 운반이 용이하지 않은 물건의 경우 그 물건의 소유자의 지배범위를 벗어나야 기수에 이른다고 볼 것이다. 따라서 사안에서 甲은 바구니를 밖으로 운반하지 못하고 도주하였으므로 특수절도죄의 미수가 성립한다.

3. A를 폭행한 행위

(1) 논의점

사안에서 절도범인 甲이 절도의 기회에 체포면탈의 목적으로 A에게 폭행을 가하였으므로 준강도죄가 성립한다. 그런데 甲의 양주절취행위가 미수에 그쳤으므로 준강도죄의 기수인지 아니면 미수인지 여부가 문제된다.

(2) 견해의 대립

이에 대하여는 ① 강도죄가 재물탈취가 있어야 기수가 되므로 준강도죄의 경우도 강도죄와의 균형상 절취행위를 기준으로 해야 한다는 절취행위기준설 ② 절도는 행위주체일 뿐이고 그 구성요건적 행위는 폭행·협박이므로 폭행·협박을 기준으로 해야 한다는 폭행·협박기준설 ③ 양자 모두가 기수에 이르러야 준강도죄의 기수를 인정하는 종합설 등이 대립하고 있다.

(3) 판례

판례는 과거 폭행·협박행위기준설을 취했으나, 최근 전원합의체판결을 통하여 ‘준강도의 기수여부는 절도행위의 기수여부를 기준으로 하여 판단하여야 한다’고 판시하여 절취행위기준설의 입장으로 태도를 변경하였다.

(4) 검토 및 사안의 해결

생각건대 준강도죄와 강도죄는 재물탈취와 폭행·협박 사이에 시간적 순서상 차이만 있을 뿐 실질적 위법성은 동일하다는 점에서 처벌의 균형을 위해 절취행위기준설이 타당하다. 사안에서 甲의 양주절취행위는 미수에 그쳤으므로 甲은 준강도죄의 미수범이 성립한다.

4. A를 폭행하여 상해를 입힌 행위

(1) 강도치상죄의 성립여부

사안에서 준강도범인 甲이 A의 어깨를 넘어 밀어뜨려 상해를 입혔으므로 甲에게는 강도치상죄가 성립되지만, 제342조에서는 강도치상죄의 미수범을 처벌하고 있으므로 결과적가중범의 미수를 인정할 것인가에 대하여 논의가 있다.

(2) 결과적 가중범의 미수의 인정여부에 대한 견해의 대립

이에 대하여는 ① 결과적 가중범은 그 본질상 미수를 인정할 수 없으며, 결과적 가중범의 미수를 둔 조항은 입법의 과오이므로 결과적 가중범의 미수를 인정할 수 없다는 미수부정설 ② 현행법상 강요죄와 강도죄에서 미수처벌규정을 두고 있으며, 이러한 미수규정은 가벌성의 범위를 시정하여 책임원칙을 지키기 위한 입법적 개선이므로 결과적 가중범의 미수도 인정할 수 있다는 미수긍정설이 대립하고 있다.

(3) 판례의 태도

최근 대법원 판례는 ‘전자충격기로 강간한 사건’에서 ‘특수강간이 미수에 그쳤다고 하더라도 그로 인하여 피해자가 상해를 입었으면 특수강간치상죄가 성립하는 것이다’라고 하여 결과적 가중범의 미수를 부정하고 있다.

(4) 검토 및 사안의 해결

생각건대 부진정결과적가중범의 미수와는 달리 진정결과적가중범의 미수는 고의범과 과실범의 결합이므로 그 본질상 미수를 인정하기 곤란하고, 진정결과적가중범의 미수를 처벌하는 조문들은 형법 전체적인 조문들과 균형을 이룬 것이라고 보기는 어려우므로 부정설이 타당하다. 이러한 부정설에 따르면 甲은 강도치상죄의 기수범이 성립한다.

5. 甲의 죄책

사안에서 甲은 ① 열쇠에 대한 점유이탈물 횡령죄 ② 강도치상죄의 기수범이 성립하며, 양자는 실체적 경합관계에 있다.

III. 乙의 죄책

1. 합동절도에 대한 죄책

사안에서 乙은 甲과 더불어 합동절도를 모의하고 망을 보는 행위를 하였으므로 다수설과 판례의 태도인 현장설에 따라 시간·장소적인 협동관계가 있으므로 합동절도가 성립한다. 그런데 사안에서 甲은 양주절취에 기수에 이르지 못하였으므로 乙에게도 합동절도의 미수범이 성립한다.

2. 준강도죄의 공동정범의 성립여부

(1) 논의점

乙은 甲과 특수절도를 공모한 후 실행행위 중 도주하였는바 도주이후 甲이 범한 준강도죄나 강도치상행위에 대하여도 죄책을 부담할 것인지가 문제된다. 사안에서 乙이 준강도의 공동정범이 될 수 없다면 이를 전제로 하는 강도치상죄의 공동정범은 성립할 수 없기 때문에 먼저 乙에게 준강도죄의 공동정범이 인정되는지가 문제된다.

(2) 견해의 대립

이에 대하여는 ① 다른 공범자에 의한 폭행과 협박에 대한 예견가능성 유무를 판단하여 예견가능성이 있으면 본죄의 공동정범이 성립한다는 긍정설 ② 준강도는 공동의사의 범위를 초과한 것이므로 초과부분에 대해서는 단독범이 성립할 뿐이지 준강도죄의 공동정범을 인정할 수 없다는 부정설이 대립하고 있다.

(3) 판례

판례는 '2인 이상이 합동하여 절도를 한 경우 범인 중의 1인이 체포를 면탈할 목적으로 폭행을 하여 상해를 가한 때에는 나머지 범인도 이를 예기하지 못한 것으로 볼 수 없으면 강도상해죄의 죄책을 면할 수 없다'라고 하여 긍정설의 입장이다.

(4) 검토 및 사안의 해결

생각건대 ① 준강도는 독자적 범죄이지 절도죄에 대한 결과적 가중범이 아니고 ② 준강도는 절도와는 달리 행위객체가 사람이며 ③ 준강도가 성립하기 위해서는 일반적인 고의 이외에 초과주관적인 요소인 목적을 필요로 하므로 부정설이 타당하다. 따라서 이러한 부정설에 의하면 사안에서 甲과 乙은 특수절도만 공모하였을 뿐 준강도죄에 대해서는 공모가 없었으므로 乙은 공모의 범위인 특수절도의 범위내에서만 죄책을 부담하고 사안에서 절취행위는 미수에 그쳤으므로 합동절도의 미수범만 성립한다.

IV. 사안의 해결

甲은 A의 열쇠에 대한 점유이탈물횡령죄와 A에 대한 강도치상죄가 성립한다. 乙은 공동의사의 범위인 특수절도죄의 미수죄가 성립한다.

관련판례

1. 준강도의 기수시기를 절도행위의 기수 여부로 판단한다고 본 전합

[사실관계] 甲과 乙은 합동하여 양주를 절취할 목적으로 장소를 물색하던 중, 2003. 12. 9. 06 : 30경 부산 부산진구 부전2동 소재 5층 건물 중 2층 丙이 운영하는 주점에 이르러, 乙은 1층과 2층 계단 사이에서

甲과 무전기로 연락을 취하면서 망을 보고, 甲은 위 주점의 잠금장치를 뜯고 침입하여 위 주점 내 진열장에 있던 양주 45병 시가 1,622,000원 상당을 미리 준비한 바구니 3개에 담고 있던 중, 주점의 종업원 丁에게 발각되었다. 甲은 양주를 그대로 둔 채 출입문을 열고 나오다가 丁이 甲을 붙잡자, 체포를 면탈할 목적으로 丁에게 폭행을 하고 달아났다. 甲의 죄책은?

[판결요지] [1] [다수의견] 형법 제335조에서 절도가 재물의 탈환을 항거하거나 체포를 면탈하거나 죄적을 인멸할 목적으로 폭행 또는 협박을 가한 때에 준강도로서 강도죄의 예에 따라 처벌하는 취지는, 강도죄와 준강도죄의 구성요건인 재물탈취와 폭행·협박 사이에 시간적 순서상 전후의 차이가 있을 뿐 실질적으로 위법성이 같다고 보기 때문인바, 이와 같은 준강도죄의 입법 취지, 강도죄와의 균형 등을 종합적으로 고려해 보면, 준강도죄의 기수 여부는 절도행위의 기수 여부를 기준으로 하여 판단하여야 한다. [별개의견] 폭행·협박행위를 기준으로 하여 준강도죄의 미수범을 인정하는 외에 절취행위가 미수에 그친 경우에도 이를 준강도죄의 미수범이라고 보아 강도죄의 미수범과 사이의 균형을 유지함이 상당하다. [반대의견] 강도죄와 준강도죄는 그 취지와 본질을 달리한다고 보아야 하며, 준강도죄의 주체는 절도이고 여기에는 기수는 물론 형법상 처벌규정이 있는 미수도 포함되는 것이지만, 준강도죄의 기수·미수의 구별은 구성요건적 행위인 폭행 또는 협박이 종료되었는가 하는 점에 따라 결정된다고 해석하는 것이 법규정의 문언 및 미수론의 법리에 부합한다. [2] 절도미수범이 체포를 면탈할 목적으로 폭행한 행위에 대하여 준강도미수죄로 의율한 원심판결을 수긍한 사례.(대판 2004.11.18. 2004도5074 전합)

2. 전자충격기로 강간한 사건

[1] 성폭력범죄의 처벌 및 피해자보호 등에 관한 법률 제9조 제1항에 의하면 같은 법 제6조 제1항에서 규정하는 특수강간의 죄를 범한 자뿐만 아니라, 특수강간이 미수에 그쳤다고 하더라도 그로 인하여 피해자가 상해를 입었으면 특수강간치상죄가 성립하는 것이고, 같은 법 제12조에서 규정한 위 제9조 제1항에 대한 미수범 처벌규정은 제9조 제1항에서 특수강간치상죄와 함께 규정된 특수강간상해죄의 미수에 그친 경우, 즉 특수강간의 죄를 범하거나 미수에 그친 자가 피해자에 대하여 상해의 고의를 가지고 피해자에게 상해를 입히려다가 미수에 그친 경우 등에도 적용된다. [2] 위험한 물건인 전자충격기를 사용하여 강간을 시도하다가 미수에 그치고, 피해자에게 약 2주간의 치료를 요하는 안면부 좌상 등의 상해를 입힌 사안에서, 성폭력범죄의 처벌 및 피해자보호 등에 관한 법률에 의한 특수강간치상죄가 성립한다고 본 사례.(대판 2008.4.24. 2007도10058)

3. 합동범 중 일인이 준강도 상해를 범한 사건

2인 이상이 합동하여 절도를 한 경우 범인 중의 1인이 체포를 면탈할 목적으로 폭행을 하여 상해를 가한 때에는 나머지 범인도 이를 예기하지 못한 것으로 볼 수 없으면 강도상해죄의 죄책을 면할 수 없다.(대판 1988.2.9. 87도2460)

♣ 돌발퀴즈

현행 형법상 결과적 가중범의 미수를 규정하고 있는 조문은 제324조의5와 제342조이다.

정답 : O

해설 : 현행 형법상으로는 강요죄와 강도죄의 경우에만 결과적 가중범의 미수를 처벌하는 규정을 두고 있으므로 타당한 지문이다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 준강도죄의 객체는?

- ① 절도
- ② 재산상의 이익
- ③ 폭행
- ④ 협박
- ⑤ 사람

정답 : ⑤

해설 : 준강도죄의 객체는 폭행·협박의 대상인 사람이다.

2. 준강도죄에 대한 판례의 태도와 다른 것은?

- ① 목적범이다.
- ② 절도의 기수만이 주체가 된다.
- ③ 미수범을 처벌한다.
- ④ 준강도죄의 공동정범을 긍정한다.
- ⑤ 강도 내지 특수강도로 처벌된다.

정답 : ②

해설 : 판례와 다수설에 의하면 준강도죄의 주체인 절도는 기수뿐만 아니라 미수도 포함한다.

3. 합동절도의 일방이 준강도를 범한 경우에 타방에게 준강도죄의 공동정범을 인정하기 위하여 판례가 제시하는 근거는?

- ① 의사의 연락
- ② 예견가능성
- ③ 체포면탈의 목적
- ④ 재물탈환에 대한 항거목적
- ⑤ 죄증인멸 목적

정답 : ②

해설 : 판례는 예견하지 못한 경우가 아니면 폭행을 하지 않은 합동절도범에게 준강도죄의 성립을 긍정하고 있다.

♣ 학습내용 정리

1. 준강도죄의 기수시기에 대하여 판례는 과거 폭행·협박행위기준설을 취했으나, 최근 전원 합의체판결을 통하여 ‘준강도의 기수여부는 절도행위의 기수여부를 기준으로 하여 판단하여야 한다’고 판시하여 절취행위기준설의 입장으로 태도를 변경하였다.
2. 최근 대법원 판례는 ‘전자충격기로 강간한 사건’에서 ‘특수강간이 미수에 그쳤다고 하더라도 그로 인하여 피해자가 상해를 입었으면 특수강간치상죄가 성립하는 것이다’라고 하여 결과적 가중범의 미수를 부정하고 있다.
3. 판례는 ‘2인 이상이 합동하여 절도를 한 경우 범인 중의 1인이 체포를 면탈할 목적으로 폭행을 하여 상해를 가한 때에는 나머지 범인도 이를 예기하지 못한 것으로 볼 수 없으면 강도상해죄의 죄책을 면할 수 없다’라고 하여 합동절도의 일방이 준강도로 나아간 경우에도 타방도 예견가능성이 있으면 준강도죄의 공동정범이 성립될 수 있다고 보고 있다.

제17강 부작위범의 정범과 공범의 구별

♣ 학습목표

부작위범의 정범과 공범을 구별할 수 있다.

♣ 학습내용

준강도죄와 공무집행방해죄

부작위범의 정범과 공범의 구별

위법성조각사유의 전제사실의 착오의 해결

♣ 사전테스트

1. 절도범이 체포를 면탈할 목적으로 추격하는 경찰관을 폭행한 경우에 준강도죄와 공무집행 방해죄는 상상적 경합이 된다는 것이 판례의 태도이다.

정답 : O

해설 : 타당한 지문이다.

2. 판례는 작위와 부작위의 구별에 대하여 규범적인 방법론을 따르고 있다.

정답 : X

해설 : 판례는 소위 ‘보라매 병원 사건’에서 존재론적 방법론에 따라 작위와 부작위를 구별하고 있으므로 타당하지 않은 지문이다.

3. 위법성조각사유의 전제사실의 착오는 사실의 착오와 법률의 착오의 성질을 모두 가지고 있는 제3의 착오라고 할 수 있다.

정답 : O

해설 : 현재에 이르러서는 제3의 착오로 보는 것이 유력한 견해이므로 타당한 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

甲은 전에 다니던 공장 사무실의 금고에서 돈을 훔칠 생각으로 열쇠공인 乙에게 함께 범행을 하자고 제의하였고, 乙은 이를 승낙하였다. 범행 당일 밤 甲과 乙은 계획대로 공장의 담을 넘어 사무실로 들어갔다. 공장 안에 인기척이 있는 것을 수상히 여긴 경비원 丙은 공장 안을 돌아보다가, 사무실 창문 너머로 같은 동네에 살고 있는 乙이 甲과 함께 금고를 열고 있는 것을 보았다. 丙은 나중에 乙로부터 돈을 갈취할 생각으로 이를 못 본 척하고 경비실로 돌아왔다. 甲과 乙은 금고에서 현금 5,000만 원을 가지고 나오던 중 마침 순찰을 돌던 경찰관 A와 공장 앞에서 마주치게 되었다. 甲과 乙은 경찰관 A를 보자 서로 다른 방향으로 도주하였고, 이들을 절도범으로 판단한 A는 乙은 포기한 채 甲을 추격하였다. 甲은 막다른 골목에 이르자 붙잡히지 않기 위해 폭행의 의사를 가지고 항거가 불가능할 정도로 A를 강하게 밀치고 도주하였다. A는 甲의 폭행으로 넘어지면서 전치 4주의 상해를 입었지만, 사건의 경위를 알아보기 위해 공장으로 돌아왔다. 그런데 丙은 A를 또 다른 침입자로 오인하여 가스총을 쏘아 실신시켰다.

1. 甲의 죄책을 논하시오. (10점)
2. 乙의 변호인은 乙의 죄책을 가능한 한 가볍게 하려고 한다. 이를 위해서 주장할 수 있는 논거를 제시하시오. (15점)
3. 丙이 甲과 乙의 범행을 목인한 행위에 대한 죄책을 논하시오. (10점)
4. 丙이 A를 실신시킨 행위에 대해 과실범의 죄책을 묻는다면, 그 근거는 무엇인지 논하시오. (15점)

[해설]

[1. 문 해설 (10점)]

1. 강도상해죄 또는 강도치상죄의 성립여부

(1) 서 언

甲이 A를 밀어 4주간의 상해를 입힌 행위가 준강도죄 및 강도상해(치상)죄에 해당하는지를 단계별로 검토한다.

(2) 특수절도죄의 성립여부

2인 이상이 합동하여 절도죄를 범한 경우에는 합동범으로서 특수절도죄가 성립한다. 甲은 乙과 시간적·장소적으로 협동하여 공장 사무실 금고에서 5,000만 원을 절취하고 나왔으므로, 합동범의 본질에 대한 어떤 견해에 의하더라도 甲에게는 특수절도죄가 성립한다.

(3) 준강도죄의 성립여부

사안에서 甲은 특수절도의 기수범이고, 절도의 기회에 체포면탈의 목적으로 사람을 폭행한 것으로 보아야 하고, A에 대한 폭행의 정도는 그의 반항을 불가능하게 할 정도에 이르렀으므로 준강도에 해당한다.

(4) 강도상해죄 또는 강도치상죄의 성립여부

甲은 폭행의 의사를 가지고 항거가 불가능할 정도로 A를 강하게 밀치고 도주하였는바, 설문에서 폭행의 의사를 가지고 밀쳤다는 점이 명시된 점, 甲에게 생리적 기능의 훼손에 대한 고의까지 인정하기 어렵다는 점에서 상해가 아닌 폭행의 고의가 있었다고 보는 것이 타당하

다. 甲에게는 인과관계, 객관적 귀속, 상해에 대한 예견가능성 등도 인정될 수 있으므로, 결국 甲은 강도치상죄의 죄책을 진다.

2. 공무집행방해죄의 성립여부

사안에서 순찰을 돌던 경찰관은 직무를 집행중인 공무원이고, 甲은 직무를 집행중인 공무원 A에게 폭행을 가하였으므로, 甲에게는 공무집행방해죄가 성립한다. 기타 위법성이나 책임을 조각할만한 사유는 발견되지 않는다.

3. 甲의 죄책

甲에게 강도치상죄와 공무집행방해죄가 성립하고 양 죄는 행위동일성이 인정되므로 상사적 경합관계에 있다.

[2. 문 해설 (15점)]

1. 乙을 가볍게 처벌하기 위한 쟁점

사안에서 乙은 甲이 범한 강도치상죄와 공무집행방해죄에 대한 공동정범의 성립여부가 문제된다. 따라서 乙이 가장 가볍게 처벌받기 위해서 乙의 변호인은 ① 공무집행방해죄의 불성립 ② 강도치상죄의 불성립 ③ 준강도죄의 불성립을 주장할 수 있을 것이다. 아래에서는 이러한 쟁점들에 대한 논거를 제시한다.

2. 공무집행방해죄의 불성립

사안에서 甲은 경찰관 A를 폭행하여 공무집행방해죄를 범하고 있는바, 乙은 甲이 초과실행한 공무집행방해죄에 대해서는 책임을 지지 않는다고 보아야 한다. 왜냐하면 공무집행방해죄는 고의범이므로 직무를 집행하는 공무원에게 폭행 또는 협박한다는 고의가 없는 자에게는 공무집행방해죄는 성립할 수 없으며, 甲과 乙 사이에 의사의 연락도 없었기 때문이다.

3. 준강도 또는 강도치상죄의 불성립

(1) 사안에서 甲의 행위는 준강도에 해당하고 이에 A를 상처 입혀 강도치상죄의 죄책을 부담한다. 이러한 경우에 乙도 준강도죄에 해당하여 강도치상죄의 공동정범이 성립할 수 있는가가 문제된다.

(2) 강도치상죄의 불성립

1) 만약 乙에게 강도죄가 인정된다고 가정하더라도 강도치상죄의 공동정범이 성립될 수는 없다고 할 것이다. 왜냐하면 결과적 가중범의 공동정범은 성립할 수 없기 때문이다. 즉 ① 과실범의 공동정범 부정설의 입장에 따르면 결과적 가중범도 부정하는 것이 논리적이며 ② 결과적 가중범의 공동정범을 인정해야 할 특별한 실무상의 이유도 없으므로 결과적 가중범의 공동정범을 인정할 수 없다.

2) 따라서 사안에서 乙에게 준강도죄가 인정되더라도 강도치상죄의 죄책을 물을 수는 없다.

(3) 준강도죄의 불성립

1) 甲이 준강도에 해당하더라도 乙은 준강도죄의 공동정범이 성립할 수 없다. 왜냐하면 준강도는 고의범이며 乙은 甲과 준강도에 대한 의사의 연락이 없기 때문이다. 즉 준강도죄는 절도죄와 폭행·협박죄의 결합범이지 결과적 가중범이 아니므로 예견가능성만으로 그 결과에 대한 죄책을 지을 수 없으며, 공동정범은 공모의 범위내에서만 성립이 가능할 뿐이므로 의사의 연락이 없는 한 공동정범의 죄책을 물을 수 없다. 그러므로 합동절도범 중

일부의 자가 체포면탈 등의 목적으로 폭행을 가한 경우에는 그 부분은 단독정범이 될 뿐이고 다른 공범자에게 준강도죄의 성립을 인정할 수 없다.

2) 따라서 사안의 경우에는 폭행 등에 대한 의사의 연락이 없었으므로 乙은 준강도범이 성립하지 않는다.

4. 야간주거침입절도 등의 범죄의 합동절도예의 흡수

사안에서 상황이 야간이므로 야간주거침입절도 및 주거침입죄 등이 문제되지만 합동절도범이 성립한다면 이는 모두 흡수되어 별죄를 구성하지 않는다.

5. 결 언

이러한 변호인의 주장에 따르면 乙은 합동절도만이 성립하게 된다.

[3. 문 해설 (10점)]

1. 논의점

사안에서 丙은 甲과 乙의 특수절도를 못 본 척하고 경비실로 들어왔으므로 丙은 부작위로 甲과 乙의 범죄에 가담하고 있다. 이러한 경우 丙의 죄책에 대하여는 ① 부작위범이 성립할 수 있는지 ② 부작위범이 성립한다면 정범인지 공범인지 ③ 방조범이 인정된다면 성립범위가 문제된다.

2. 부작위범의 성립

사안에서 丙에게 부작위범이 성립되지 위해서는 丙이 보증인적 지위에 있으면서 부작위하여야 한다. 丙이 보증인적 지위를 인정하기 위해서는 ① 구성요건적 상황 ② 작위의무 ③ 개별적인 행위가능성이 있어야 하는바, 사안에서 이러한 요소들을 모두 구비하고 있으므로 丙에게는 보증인적 지위가 인정된다. 그리고 이러한 보증인적 지위가 있음에도 부작위 하였으므로 丙은 부작위범이 성립한다.

3. 병의 가담형태

(1) 사안과 같이 丙이 부작위로 甲과 乙의 범행에 의사의 연락없이 가담한 경우에 丙이 정범인지 공범인지가 문제된다. 사안과 같은 경우에 丙의 가담형태를 어떻게 볼 것이냐에 대하여는 논의는 있지만 현재의 다수설과 판례는 원칙적 중범설을 따르고 있다.

(2) 생각건대 ① 편면적인 작위의무자의 부작위는 행위지배를 인정하기 어려워 정범성을 인정할 수 없고 ② 부작위범에 대하여 임의적 감경을 하지 않는 현행법하에서는 부작위로 가담한 자를 방조범으로 처벌함으로써 입법상의 불비를 해석론상 보완할 수 있으므로 원칙적 중범설이 타당하다. 이러한 원칙적 중범설에 따르면 사안에서 丙에게는 기본적으로 특수절도의 방조범이 인정된다.

4. 방조범의 성립범위

사안에서 丙은 甲과 乙의 특수절도죄를 방조하였지만 甲은 준강도죄와 이에 이어 강도치상죄를 범하였는바, 丙의 책임범위에 대하여 논의가 있다. 생각건대 준강도는 고의범이라는 점을 고려하면 의사의 연락이 없는 丙에게 준강도의 방조범의 성립을 인정하는 것은 타당하지 않으므로 丙은 준강도 이후 부분의 행위에 대하여는 책임을 부담하지 않는다.

5. 사안의 해결

사안에서 丙은 특수절도의 방조범이 성립한다.

[4. 문 해설 (15점)]

1. 논의점

사안에서 丙이 경찰관인 A를 또 다른 침입자로 알고 가스총을 쏘아 실신시킨 행위는 정당방위의 의사로 행한 것이다. 그러나 실제로는 정당방위 상황이 없음에도 불구하고 정당방위 행위를 하고 있으므로 이는 위법성조각사유의 전제사실의 착오에 해당한다. 사안에 丙에게 과실범의 죄책을 묻기 위해서는 위법성조각사유의 전제사실의 착오에 관한 학설 중 고의를 조각시키는 학설이 그 근거가 될 수 있다. 먼저 고의를 조각시키는 학설들을 설명한 후 과실범이 성립함을 도출한다.

2. 고의를 조각시키는 학설

(1) 엄격고의설

고의의 성립에 사실의 인식이외에 위법성의 인식이 필요하다는 엄격고의설에 의하면 위법성조각사유의 전제사실의 착오가 있는 경우에는 고의가 성립하지 않으므로 고의가 조각되게 된다.

(2) 제한책임설

제한책임설에 의하면 위법성조각사유의 전제사실에 대한 착오는 사실의 착오는 아니지만 사실의 착오와는 사실적인 부분에 착오가 있다는 구조적 유사점을 근거로 하여 사실의 착오를 유추적용하여야 한다고 한다. 이러한 제한책임설에 의하면 고의가 조각되게 된다.

(3) 소극적 구성요건 표지이론

2단계 범죄체계를 취하는 소극적 구성요건표지이론에 의하면 위법성조각사유의 전제사실은 소극적 구성요건요소가 되므로 이에 대한 착오는 사실의 착오로 취급하게 되어 불법고의가 조각된다. 즉 이러한 소극적 구성요건표지이론에 의하면 사실의 착오에 대한 원칙적 조문인 제13조를 직접 적용하게 된다.

(4) 법효과제한적책임설

법효과제한적책임설에 의하면 고의의 이중적 지위를 바탕으로 하여 위법성조각사유의 전제사실의 착오는 구성요건적 고의는 인정되어 고의불법은 있지만 책임고의가 없으므로 고의범으로 처벌할 수 없게 된다.

3. 과실범으로 처벌할 수 있는 근거

丙이 위법성조각사유의 전제사실에 빠져 오상방위를 한 경우에 위의 학설들에 의하면 고의범이 성립하지 않게 된다. 그러나 사안에서 A가 실신한 것은 생리적 기능을 훼손한 상해이다. 그리고 丙이 통상의 주의를 기울였더라면 A가 경찰관이라는 것을 알 수 있었으므로 과실이 인정된다. 따라서 丙에게는 과실치상죄가 인정된다.

관련판례

1. 은행장이 부하직원의 배임행위 방치한 사건

[사실관계] 은행장 甲은 그의 부하직원 乙·丙이 부정한 방법으로 A주식회사에 대하여 자금융통의 편의를 봐주고 있는 사실을 발견하였음에도 불구하고 이를 방치하였다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 형법상 방조는 작위에 의하여 정범의 실행행위를 용이하게 하는 경우는 물론, 직무상의 의무가 있는 자가 정범의 범죄행위를 인식하면서도 그것을 방지하여야 할 제반조치를 취하지 아니하는 부작위로

인하여 정범의 실행행위를 용이하게 하는 경우에도 성립된다 할 것이므로 은행지점장이 정범인 부하직원들의 범행을 인식하면서도 그들의 은행에 대한 배임행위를 방치하였다면 배임죄의 방조범이 성립된다.(대판 1984.11.27. 84도1906)

♣ 돌발퀴즈

강도범이 체포를 면탈하기 위하여 경찰관을 폭행한 경우에는 상상적 경합이 된다는 것이 판례이다.

정답 : X

해설 : 판례에 의하면 강도죄와 공무집행면탈죄의 실체적 경합이 된다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 절도범이 체포를 면탈하기 위하여 경찰관을 폭행한 경우의 준강도죄와 공무집행방해죄와의 죄수관계는?

- ① 법조경합
- ② 포괄일죄
- ③ 상상적 경합
- ④ 동시적 경합
- ⑤ 사후적 경합

정답 : ③

해설 : 판례에 의하면 두 죄는 상상적 경합관계에 있다.

2. 강도가 체포를 면탈하기 위하여 경찰관을 폭행한 경우의 강도죄와 공무집행방해죄와의 죄수관계는?

- ① 법조경합
- ② 포괄일죄
- ③ 상상적 경합
- ④ 실체적 경합
- ⑤ 단순 일죄

정답 : ④

해설 : 판례에 의하면 두 죄는 실체적 경합관계에 있다.

3. 작위범에 대하여 의사의 연락없이 부작위로 가담한 자의 죄책에 대한 판례의 태도는?

- ① 원칙적 정범설
- ② 정범설
- ③ 교사범설
- ④ 원칙적 중범설
- ⑤ 무죄설

정답 : ④

해설 : 다수설과 판례는 원칙적 중범설의 입장이라고 볼 수 있다.

♣ 학습내용 정리

1. 현재의 다수설과 판례는 작위범에 대하여 의사의 연락없이 부작위로 가담한 자에 대하여
① 편면적인 작위의무자의 부작위는 행위지배를 인정하기 어려워 정범성을 인정할 수 없고 ② 부작위범에 대하여 임의적 감경을 하지 않는 현행법하에서는 부작위로 가담한 자를 방조범으로 처벌함으로써 입법상의 불비를 해석론상 보완할 수 있으므로 원칙적 종범설을 따르고 있다.
2. 제한책임설에 의하면 위법성조각사유의 전제사실에 대한 착오는 사실의 착오는 아니지만 사실의 착오와는 사실적인 부분에 착오가 있다는 구조적 유사점을 근거로 하여 사실의 착오를 유추적용하여야 한다고 한다.
3. 2단계 범죄체계를 취하는 소극적 구성요건표지이론에 의하면 위법성조각사유의 전제사실은 소극적 구성요건요소가 되므로 이에 대한 착오는 사실의 착오로 취급하게 되어 불법고의가 조각된다.
4. 법효과제한적책임설에 의하면 고의의 이중적 지위를 바탕으로 하여 위법성조각사유의 전제사실의 착오는 구성요건적 고의는 인정되어 고의불법은 있지만 책임고의가 없으므로 고의범으로 처벌할 수 없게 된다.

제18강 인질강도죄와 강도강간죄

♣ 학습목표

인질강도죄와 강도강간죄에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

인질강도죄의 실행의 착수시기

강도강간죄의 성립요건

책임배제사유로서의 기대가능성의 검토

♣ 사전테스트

1. 인질강도죄의 실행의 착수시기에 대하여는 아직 판례가 없다.

정답 : O

해설 : 인질강도죄의 실행의 착수시기에 대하여는 논의가 있지만 아직 판례는 없다.

2. 강간을 먼저하고 재물을 강취한 경우에도 강도강간죄가 성립한다.

정답 : X

해설 : 강간을 먼저하고 재물을 강취한 경우에는 강간죄와 강도죄의 경합범이 된다.

3. 기대가능성이란 적법행위에 대한 기대가능성을 의미하며, 면책사유로서의 성질을 지니고 있다.

정답 : O

해설 : 타당한 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

甲, 乙, 丙은 甲의 주도하에 유혹비를 마련하기 위하여 부유층을 납치하여 돈을 강취하기로 하였다. 뜻하지 않은 교통사고를 당하여 병원에 입원한 甲은 “고급아파트 주차장에서 외제승용차를 타는 사람을 붙잡아 몸값을 최대한 받아내라.”라는 범행지시를 하였다. 이에 乙, 丙은 범행대상을 물색하던 중 명품아파트 주차장으로 들어오는 A와 그의 여자친구 B를 발견하고, 미리 준비하여 가지고 간 쇠파이프로 A의 머리를 때려 실신시킨 다음 A와 B를 乙의 집으로 끌고 갔다.

乙, 丙은 범행발각이 두려워 범행계획과 달리 A를 살해하기로 결의한 다음, 겁에 질린 B에게 A를 목 졸라 살해하라고 하였다. B가 완강히 거부하자, 乙이 “말을 듣지 않으면 너도 죽여 버리겠다.”라고 하기에, 하는 수 없이 B는 A를 살해하였다. 이후 乙은 B의 어머니 C에게 전화를 걸어 “B를 살리고 싶으면 현금 1억 원을 가져오라.”고 말하였고, 다음날 강남고속버스터미널에서 C로부터 돈을 건네받기로 하였다.

丙은 乙이 잠시 외출한 틈에 B를 간음하고자 하였다. 공포심에 질려 있던 B는 반항해봤자 소용이 없다고 판단되어 丙의 요구에 순순히 응하였다.

다음날 乙, 丙은 C로부터 돈을 건네받기 위하여 강남고속버스터미널에 갔으나 범행일체가 발각될 것이 두려워 추후에 다시 협박하기로 마음먹고 乙의 집으로 되돌아 왔다.

1. 乙, 丙의 죄책을 논하시오. (20점)

2. B가 무죄가 될 수 있는 논거를 위법성과 책임 단계로 나누어 논하시오. (10점)

[해설]

[1. 문 해설 (20점)]

1. 서 언

乙과 丙은 전체적으로 강도살해를 범하고 있는바 이를 단계별로 고찰하면서 乙과 丙의 죄책을 검토하기로 한다.

2. A와 B를 乙의 집으로 끌고 간 행위의 평가

(1) 서 언

乙과 丙은 인질강도를 하기 위하여 A와 B를 乙의 집으로 끌고 가고 있다. 이러한 일련의 행위는 인질강도를 범하기 위한 것이므로 이러한 경우 인질강도의 실행의 착수시기를 언제로 볼 것인가에 따라 乙과 丙의 죄책이 달라진다고 할 수 있으므로 인질강도죄의 실행의 착수시기를 검토한다.

(2) 인질강도죄의 실행의 착수시기

인질강도죄의 실행의 착수시기에 대하여는 ① 인질로 삼기 위하여 체포·감금·약취·유인을 할 때라는 견해와 ② 인질의 석방이나 안전보장의 대가로 재물 또는 재산상의 이익을 요구한 때라는 견해가 대립하고 있다. 그러나 ① 인질로 삼기 위하여 체포·감금·약취·유인을 할 때 법익침해의 밀접한 행위가 있었으며 ② 결함범의 일반논리에 따르면 제1의 행위를 할 때 실행의 착수를 인정하는 것이 일반적이므로 체포·감금·약취·유인시설이 타당하다.

(3) 사안의 해결

실행의 착수시기에 대하여 체포·감금·약취·유인시설에 의하면 乙과 丙은 인질강도죄의 실행의 착수가 인정된다.

3. 특수강도(합동강도)의 문제

사안에서 乙과 丙은 2인이상이 합동하여 인질강도를 범하고 있으므로 이에 대하여 乙과 丙이 특수강도가 성립할 수 있는가가 문제된다. 그런데 인질강도의 경우에는 형량이 3년 이상이지만, 특수강도의 경우에는 형량이 5년 이상이므로 2인이상이 합동하여 인질강도를 범한 경우에는 양자 중 형이 중한 특수강도죄로 처벌하는 것이 타당하다. 따라서 乙과 丙은 특수강도죄가 성립한다.

4. 강도상해죄의 성립

사안에서는 합동강도인 乙과 丙이 A를 때려 상해를 입히고 있으므로 강도상해죄가 성립한다.

5. B로 하여금 A를 살해하도록 한 행위에 대한 평가

(1) 살인죄의 간접정범

사안에서 乙과 丙은 B로 하여금 A를 살해하도록 강요하고 이에 따라 B가 A를 살해하고 있다. 이러한 경우 B의 행위는 제12조의 강요된 행위이므로 책임이 조각되어 범죄가 성립하지 않으나, 이러한 B의 행위를 이용한 乙과 丙은 살인죄의 죄책을 지게 된다.

(2) 강도살인죄의 성립

乙과 丙은 인질강도의 기회에 살인죄를 범하고 있으므로 전체적으로 강도살인죄의 죄책을 지게 된다.

6. B를 간음한 부분의 죄책

(1) 丙이 B를 간음한 부분의 죄책

강간죄는 상대방의 저항을 불가능하게 할 정도의 폭행·협박을 사용하여 간음하는 죄이다. 사안에서 丙이 강간의 목적으로 직접적으로 폭행·협박을 행사한 것은 나타나있지 않지만, 인질강도를 범하는 와중에서 이미 B에게 반항이 불가능하게 할 정도의 폭행·협박이 있었다고 평가할 수 있으므로 丙이 이를 이용하여 간음하였다면 이는 강간죄에 해당한다. 특히 丙은 이미 강도를 범하고 있는 자이므로 이를 이용하여 강간을 범한 경우에는 강도강간죄의 죄책을 진다.

(2) 丙의 강도강간행위에 대한 乙의 죄책

丙은 乙과의 의사연락없이 강간을 단독으로 한 것이므로 이에 대한 고의가 없는 乙은 강도강간행위에 대하여는 책임을 부담하지 않는다.

7. 돈을 받지 못하고 되돌아 온 행위에 대한 평가

乙과 丙이 돈을 요구한 후 이를 취득하지 못하고 돌아 돈 부분은 합동강도의 미수에 해당하는 듯하다. 그러나 사안에서는 전체적으로 乙과 丙은 강도살인죄를 범하고 있으며 살인의 점에 대하여 이미 기수에 이른 상태이므로 강도살인죄가 성립한다.

8. 乙과 丙의 죄책

(1) 乙은 전체적으로 강도살인죄(제338조)의 죄책을 부담한다.

- (2) 丙은 乙과 같이 강도살인죄(제338조)의 죄책을 부담함과 동시에 강도강간죄(제339조)의 죄책을 부담하며 이는 실체적 경합관계에 있다.

[2. 문 해설 (10점)]

1. 서 언

B는 乙과 丙의 강요된 행위에 의하여 A를 살해하고 있는바 이러한 B의 행위는 구성요건에 해당한다. 그러나 B의 행위를 비난하기는 어려운 측면이 있다. 따라서 위법성과 책임론의 각 단계에 걸쳐 무죄가 될 수 있는가를 검토한다.

2. 위법성 단계에서의 검토

(1) 서 언

사안의 경우에는 위법성이 조각되기 어렵다. 아래에서는 개개의 위법성조각사유가 왜 인정되지 않는가를 간단히 검토한다.

(2) 개별적 검토

① 정당방위의 경우에는 제3자인 A에게 방위하므로 성립되지 않고 ② 긴급피난의 경우에는 법익균형성을 갖추어야 하는데 생명 대 생명은 우월적 법익균형이 인정되지 않고 ③ 의무의 충돌은 의무의 경합이 없으므로 인정되지 않고 ④ 피해자의 승낙은 승낙이 없으므로 인정되지 않고 ⑤ 추정적 승낙은 객관적 추정이 인정되기 어렵고 ⑥ 기타 사회상규에 어긋나지 않는 행위로도 평가하기 어렵다.

3. 책임 단계에서의 검토

(1) 서 언

사안에서 B의 행위는 책임이 조각되어 무죄가 된다. 그런데 책임이 인정되기 위해서는 ① 책임능력의 구비 ② 책임고의의 인정 ③ 위법성의 인식 ④ 적법행위의 기대가능성의 요건이 구비되어야 하는바 사안에서는 적법행위의 기대가능성이 문제되고 이러한 경우를 형법은 특히 제12조에서 강요된 행위로 규정하고 있다.

(2) 제12조 강요된 행위의 검토

제12조의 강요된 행위란 저항할 수 없는 폭력이나 자기 또는 친족의 생명·신체에 대한 위해를 방어할 방법이 없는 협박에 의하여 강요된 행위를 말한다. 사안에서 B는 자기의 생명에 대한 위해를 방어할 방법이 없는 협박에 의하여 A를 살해하고 있으므로 제12조의 요건을 구비하고 있으므로 책임이 조각되어 무죄가 된다.

♣ 돌발퀴즈

강간도중에 재물을 강취하고 이후 강간을 계속한 경우에는 강도강간죄가 성립한다.

정답 : O

해설 : 강간을 먼저하고 재물을 강취한 경우에는 원칙적으로 강간죄와 강도죄의 경합범이 되지만, 강간도중에 재물을 강취하고 이후 강간을 계속한 경우에는 강도강간죄가 성립한다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 인질강도죄에서 인질로 삼기 위한 행위태양이 아닌 것은?

- ① 협박
- ② 체포
- ③ 감금
- ④ 약취
- ⑤ 유인

정답 : ①

해설 : 제336조 참조

2. 다음 중 형법에 없는 구성요건은?

- ① 야간주거침입강도죄
- ② 해상강도살인죄
- ③ 강도치상죄
- ④ 강도강간죄
- ⑤ 강간강도죄

정답 : ⑤

해설 : 현행 형법상 강간강도죄는 없다.

3. 다음 중 기대가능성과 관련 없는 것은?

- ① 형사미성년자
- ② 과잉방위
- ③ 과잉피난
- ④ 강요된 행위
- ⑤ 도주죄

정답 : ①

해설 : 형사미성년자는 기대가능성과 관련 없는 책임배제사유이다.

♣ 학습내용 정리

1. 인질강도죄의 실행의 착수시기에 대하여는 ① 인질로 삼기 위하여 체포·감금·약취·유인을 할 때라는 견해와 ② 인질의 석방이나 안전보장의 대가로 재물 또는 재산상의 이익을 요구한 때라는 견해가 대립하고 있다.
2. 합동범의 공동정범이 인정될 수 있다면 ① 합동범에 대하여도 공동정범의 일반이론이 적용되어야 하며 ② 합동범의 가중요건은 위법요소이므로 이에 가담한 자는 합동범의 공동정범이 되어야 하며 ③ 합동범은 공동정범의 한 형태이고 단지 현장요소에 의해 제한될 따름이므로 기능적 행위지배가 있는 이상 공동정범으로 처벌해야 배후거물이나 수괴를 처벌할 수 있다는 점 등을 논거로 한다.

3. 합동범의 공동정범을 부정하는 입장에서는 ① 현장설의 입장에서 합동범은 공동정범에 대한 특별규정이므로 현장에서 시간적·장소적으로 협동한 자만이 합동범의 정범이 될 수 있으므로 합동범에 대하여는 공동정범의 규정이 적용될 수 없고 만일 합동범의 공동정범을 인정하게 되면 정범의 표지를 지나치게 확장하여 합동범을 현장설로 보는 취지가 무색해지며 ② 합동범은 필요적 공범이므로 이론적으로 공동정범을 인정할 여지가 없고 만일 필요적 공범에 대하여도 공동정범을 인정하면 유추해석이 되어 책임원칙에 반한다는 점 등을 논거로 한다.

제19강 준강도죄의 공동정범

♣ 학습목표

준강도죄의 공동정범에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

준강도와 표변강도

준강도죄의 공동정범 인정여부

결합범에서의 승계적 공동정범

♣ 사전테스트

1. 절도범이 발각되자 피해자를 폭행하고 재물을 탈취한 경우에도 준강도죄가 성립한다.

정답 : X

해설 : 절도범이 발각되자 피해자를 폭행하고 재물을 탈취한 경우에는 준강도가 아닌 표변강도가 된다.

2. 판례는 합동절도 중 일반이 준강도죄를 범한 경우에 타방이 예견가능성이 있으면, 준강도죄의 공동정범을 긍정하고 있다.

정답 : O

해설 : 판례의 입장으로서는 타당한 지문이다.

3. 판례는 결합범에서의 후행위의 가담자에 대하여 전체범죄에 대한 방조를 인정하고 있다.

정답 : O

해설 : 판례는 ‘여고생 협박 전화 사건’에서 후행 가담자인 여고생에게 전체범죄에 대한 방조를 인정하고 있으므로 타당한 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

甲과 乙은 야간에 A의 집에 들어가 절도를 할 것을 공모하고 甲은 A의 집안으로 들어가고, 乙은 트럭을 대문 앞에 대기한 채 망을 보았다. 甲이 A家에 들어가서 절취할 물건을 물색하던 중 A에게 발각되어 체포를 면하려고 격투 끝에 A를 포박하였다. 그런데 甲은 격투 중에 오른손에 부상을 입어 乙을 찾았으나 乙은 겁이 나서 이미 도망하고 없는 상태여서 친구 丙을 전화로 불러내어 지금까지의 사정을 털어 놓고 丙과 함께 피아노를 집밖으로 반출하였다. 甲, 乙, 丙의 형사책임은? (50점)

[해설]

I. 논점의 정리

- (1) 甲의 죄책과 관련하여 ① 乙과 특수절도를 공모한 후에 A의 집에 침입하여 절취한 물건을 물색한 행위가 합동절도에 해당하는지 ② A에게 발각되어 격투 끝에 A를 포박하고 丙을 불러내어 피아노를 집밖으로 반출한 행위가 어떤 유형의 강도죄에 해당하는지 ③ A를 포박한 행위가 감금죄에 해당한다면 이에 대한 죄수는 어떻게 평가해야하는지가 문제된다.
- (2) 乙의 죄책과 관련하여 ④ 특수절도죄의 기수인지 미수인지 ⑤ 乙에게 준강도의 공동정범이 성립하는지가 문제된다.
- (3) 丙의 죄책과 관련하여 ⑥ 합동절도 이외에 강도죄에 대한 죄책이 인정되는지가 문제된다.

II. 甲의 죄책

1. 합동절도의 실행의 착수 여부

사안에서 甲은 乙과 절도를 공모한 후에 야간에 乙은 망을 보고 甲은 A의 집에 침입하여 절취한 물건을 물색하였으므로 시간·장소적인 협동관계에 의한 합동절도의 실행에 착수하였다.

2. 준강도 또는 강도죄의 성립여부

(1) 논의점

사안에서 甲은 합동절도의 실행의 착수 이후 A에게 발각되어 체포를 면하려고 격투 끝에 A를 포박하고 이어서 丙과 함께 피아노를 탈취하고 있다. 그런데 폭행이후에 재물을 탈취하고 있으므로 甲의 행위가 준강도인지 아니면 강도죄인지가 문제된다.

(2) 준강도와 표변강도의 구별

사안과 같은 경우에 甲이 폭행 후 도망치지 않고 재물의 탈취를 완성한 경우에는 폭행 당시 새로운 강도의 범의가 있었다고 평가할 수 있으므로 소위 표변강도에 해당한다. 따라서 甲은 강도죄의 죄책을 진다. 강도죄와 준강도죄는 보충관계에 있으므로, 강도죄가 일단 성립하면 준강도죄는 별도로 성립하지 아니한다. 즉 절도가 체포를 면하고 동시에 재물을 강취하기 위하여 폭행·협박한 경우에는 강도죄만 성립한다.

(3) 특수강도의 해당여부

1) 논의점

사안에서 甲에게 강도죄가 성립한다는 것을 전제로 하는 경우에 행위상황이 야간이고 주거에 침입한 것으로 인해 특수강도의 한 유형인 야간주거침입강도죄가 되는지 또는 丙과 함께 재물을 탈취했으므로 특수절도의 한 유형인 합동강도가 성립할 수 있는지가 문제된다.

2) 야간주거침입강도죄의 성립여부

사안에서 甲은 이미 절도의 의사로 야간에 A의 집에 침입한 이후에 새로이 강도의 범의를 일으켜 강도행위를 하고 있다. 이러한 甲의 행위가 야간주거침입강도죄가 성립할 것인가가 문제된다. 그러나 형법은 야간에 이루어지는 주거침입행위의 위험성에 주목하여 야간주거침입강도를 규정하고 있다는 점을 고려하면 甲이 야간에 A의 주거에 침입할 때에는 절도의 범의만 있었기 때문에 야간주거침입강도를 인정하는 것은 사후고의를 인정하는 것이 되므로 이는 부당하다.

3) 합동강도의 성립여부

사안에서 甲은 이미 A를 체포한 이후에 丙과 더불어 피아노를 탈취하고 있는바, 이러한 행위가 합동강도에 해당하는지가 문제된다. 그러나 甲과 丙사이에 사전에 모의가 없는 이상 丙이 사후에 피아노를 탈취하는 데에만 가담한 것을 합동강도라고 평가할 수는 없다.

4) 결 언

甲은 단순강도죄만 성립한다.

3. 감금죄의 성립여부

사안에서 甲이 A를 포박한 부분에 대하여는 강도죄의 성립에 언제나 직접적으로 또 필요한 수단으로서 감금행위를 수반하는 것은 아니므로 감금행위에 대하여는 별죄가 성립한다. 그리고 피아노를 탈취한 이후에도 A를 감금한 것으로 추단되므로 강도죄와 감금죄는 실체적 경합관계에 있다.

4. 甲의 죄책

甲은 강도죄와 감금죄가 성립하고 양자는 실체적 경합관계에 있다.

III. 乙의 죄책

1. 특수절도죄의 성립여부

(1) 논의점

사안에서 乙은 야간에 A의 집에 들어가 절취할 것을 甲과 공모하고 甲이 A의 집안으로 들어가 물색을 하는 동안 트럭을 대문 앞에 대기한 채 망을 보았으므로 합동절도의 실행에 착수하였음에 의문이 없다. 그런데 사안에서 乙은 甲이 절취행위를 완성하기 이전에 겁을 먹고 도망하였으므로 이에 대한 죄책이 문제된다.

(2) 합동절도의 미수 여부

1) 사안에서 甲은 준강도가 되면서 새로이 강도의 범의를 일으켜 丙과 함께 피아노를 탈취하고 있다. 그러나 乙과는 강도에 대한 의사의 연락이 없었으므로 이는 甲의 독단적인 범죄가 되며 乙은 자기책임의 원칙상 합동절도 범행에 대하여만 책임을 진다.

2) 그런데 사안에서 피아노를 탈취하고 있으므로 甲만의 단독범행으로는 이를 완성할 수 없고 乙이 도움이 필연적인데, 乙이 도주한 이후 甲이 丙과 피아노를 탈취한 것은 乙의 절

도행위와는 인과관계가 단절된 것으로 보아야 한다. 따라서 乙은 특수절도의 미수의 죄책을 진다.

(3) 乙의 죄책

따라서 乙은 특수절도죄의 장애미수가 성립한다.

2. 준강도죄의 공동정범 성립여부

(1) 논의점

사안에서 甲은 체포를 면탈할 목적으로 A에게 폭행을 가하여 준강도의 태양도 지니고 있다. 이렇게 합동절도를 공모하여 실행 중 1인인 甲이 체포면탈 등의 목적으로 폭행을 가하여 준강도가 성립한 경우에 폭행에 가담하지 않은 乙에게도 준강도죄가 성립하는지가 문제된다.

(2) 견해의 대립

이에 대하여는 ① 다른 공범자에 의한 폭행과 협박에 대한 예견가능성 유무를 판단하여 예견가능성이 있으면 본죄의 공동정범이 성립한다는 긍정설 ② 준강도는 공동의사의 범위를 초과한 것이므로 초과부분에 대해서는 단독범이 성립할 뿐이지 준강도죄의 공동정범을 인정할 수 없다는 부정설이 대립하고 있다.

(3) 판례

판례는 '2인 이상이 합동하여 절도를 한 경우 범인 중의 1인이 체포를 면탈할 목적으로 폭행을 하여 상해를 가한 때에는 나머지 범인도 이를 예기하지 못한 것으로 볼 수 없으면 강도상해죄의 죄책을 면할 수 없다'라고 하여 긍정설의 입장이다.

(4) 검토 및 사안의 해결

생각건대 ① 준강도는 독자적 범죄이지 절도죄에 대한 결과적 가중범이 아니고 ② 준강도는 절도와는 달리 행위객체가 사람이며 ③ 준강도가 성립하기 위해서는 일반적인 고의 이외에 초과주관적인 요소인 목적을 필요로 하므로 부정설이 타당하다. 따라서 사안에서 乙은 공동의사의 범위인 합동절도의 미수범만 성립한다.

IV. 丙의 죄책

1. 논의점

사안에서 丙은 甲이 A를 포박한 이후에 재물인 피아노를 집밖으로 반출하는데만 관여하였는바 이는 합동절도에 해당한다. 그런데 가담이전의 甲의 행위를 丙이 인식하고 이를 이용하고 있으므로 丙의 죄책의 범위에 대하여 논의가 있다. 즉 후행행위에 대하여 공동정범이

성립한다고 할 때 후행가담자에게 가담 이전의 행위에 대하여도 책임을 물을 수 있는가를 두고 논의가 있다.

2. 견해의 대립

이에 대하여는 ① 주관주의 입장에서 후행위자가 선행사실을 용인하고 이를 이용한 이상 선행행위 부분에 대하여도 책임을 져야 한다는 긍정설 ② 객관주의 입장에서 후행위자는 자기책임의 원칙상 가담이후의 부분에 대하여만 책임을 져야 한다는 부정설이 대립하고 있다.

3. 판례의 태도

판례는 ① 포괄일죄와 관련된 판례에서는 가담 이후의 범행에 대해서만 공동정범으로서의 책임을 진다고 하여 가담이전 부분에 대한 죄책을 부정하고 ② 결합범과 관련된 판례에서는

전체범죄에 대한 방조만을 인정함으로써 전체범죄에 대한 공동정범의 성립을 인정하지 않아 부정설의 입장이다.

4. 결론 및 사안의 해결

승계적 공동정범의 경우에도 행위책임의 원칙이 실현되어야 하며, 선행행위에 대하여는 기능적 행위지배를 인정할 수 없으므로 부정설이 타당하다. 이러한 부정설에 따르면 사안에서 丙은 강도죄가 아닌 합동절도죄에 대한 죄책만 지게 된다. 丙의 주거침입죄와 야간주거침입죄는 합동절도가 성립하면 이들은 이에 흡수된다.

V. 사안의 해결

- (1) 甲에게는 강도죄와 감금죄가 성립한다. 그리고 양자는 실체적 경합관계에 있다.
- (2) 乙에게는 특수절도미수죄의 공동정범이 성립한다.
- (3) 丙은 특수절도죄의 죄책을 진다. 그리고 주거침입죄와 야간주거침입절도죄는 특수절도죄에 흡수된다.

관련판례

1. 강도상해후 계속 태우고 가다 잡힌 사건

감금행위가 단순히 강도상해 범행의 수단이 되는 데 그치지 아니하고 강도상해의 범행이 끝난 뒤에도 계속된 경우에는 1개의 행위가 감금죄와 강도상해죄에 해당하는 경우라고 볼 수 없고, 이 경우 감금죄와 강도상해죄는 형법 제37조의 경합범 관계에 있다.(대판 2003.1.10. 2002도4380)

2. 합동범 중 일인이 준강도 상해를 범한 사건

2인 이상이 합동하여 절도를 한 경우 범인 중의 1인이 체포를 면탈할 목적으로 폭행을 하여 상해를 가한 때에는 나머지 범인도 이를 예기하지 못한 것으로 볼 수 없으면 강도상해죄의 죄책을 면할 수 없다.(대판 1988.2.9. 87도2460)

3. 여고생 협박 전화 사건

[사실관계] 체육교사인 甲은 제자인 A를 자기의 아파트에 유인하여 포박·감금하였다. 甲은 약취 3일째 되던 날 아파트에 들어갔을 때에는 이미 A가 탈진상태에 있어 박카스를 먹여보려 했지만 A는 제대로 마시지도 못하였다. 그때 甲은 A를 그대로 두면 죽을 것 같은 생각이 들어 병원에 옮기고 자수할 것인가, 그대로 두어 A가 죽으면 시체를 처리하고 범행을 계속할 것인가 아니면 스스로 자살할 것인가 등 두루 고민하다가 결국 병원에 옮기고 자수할 용기가 생기지 않아 그대로 나와 학교에 갔다가 돌아와 보니 A는 이미 죽어 있었다. 그리고 甲은 자기의 옛제자인 여고생 乙女를 불러내어 A의 유괴 및 사망사실을 말하고 A의 부모에게 거액의 금품을 요구하는 협박장을 써서 보내고 협박전화도 할 것을 부탁하였고, 이에 乙女는 이를 승낙한 후 시키는 대로 금품을 요구하는 협박전화 및 편지를 하였다. 甲과 乙女の 죄책은?

[판결요지] 특정범죄가중처벌등에관한법률 제5조의 2 제2항 제1호 소정의 죄는 형법 제287조의 미성년자 약취, 유인행위와 약취 또는 유인한 미성년자의 부모 기타 그 미성년자의 안전을 염려하는 자의 우려를 이용하여 재물이나 재산상의 이익을 취득하거나 이를 요구하는 행위가 결합된 단순일죄라고 봄이 상당하므로 비록 타인이 미성년자를 약취·유인한 행위에는 가담한 바가 없다 하더라도 사후에 그 사실을 알면서 약취·유인한 미성년자를 부모 기타 그 미성년자의 안전을 염려하는 자의 우려를 이용하여 재물이나 재산상의 이익을 취득하거나 요구하는 타인의 행위에 가담하여 이를 방조한 때에는 단순히 재물 등 요구행위의 중범이 되는데 그치는 것이 아니라 결합범인 위 특정범죄가중처벌등에관한법률 제5조의 2 제2항 제1호 위반죄의 중범에 해당한다.(대판 1982.11.23. 82도2024)

♣ 돌발퀴즈

학설과 판례는 승계적 공동정범자의 죄책에 대하여 객관주의의 입장을 따르고 있으므로 전체범죄에 대한 공동정범을 인정하지 않고 있다.

정답 : 0

해설 : 판례는 ① 포괄일죄와 관련된 판례에서는 가담 이후의 범행에 대해서만 공동정범으로서의 책임을 진다고 하여 가담이전 부분에 대한 죄책을 부정하고 ② 결합범과 관련된 판례에서는 전체범죄에 대한 방조만을 인정함으로써 전체범죄에 대한 공동정범의 성립을 인정하지 않아 객관주의 입장을 따르고 있으므로 타당한 지문이다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 다음 준강도죄에 대한 기속 중 틀린 것은?

- ① 재물의 탈환에 항거할 목적
- ② 재물을 탈취할 목적
- ③ 체포를 면탈할 목적
- ④ 죄증을 인멸한 목적
- ⑤ 목적범

정답 : ②

해설 : 재물을 탈취할 목적은 준강도죄의 목적 태양이 아니다.

2. 일부의 자가 실행에 착수한 이후에 다른 일부의 자가 의사의 연락하에 후행행위를 공동으로 한 공동정범의 태양을 일컫는 표현은?

- ① 공모공동정범
- ② 예모공동정범
- ③ 우연공동정범
- ④ 승계적 공동정범
- ⑤ 과실의 공동정범

정답 : ④

해설 : 설문과 같은 공동정범을 승계적 공동정범이라고 한다.

3. 불법이 분리되는 범죄에서 후행가담자의 죄책에 대한 판례의 태도는?

- ① 가담이후의 범죄에 대한 방조범
- ② 가담이후의 범죄에 대한 공동정범
- ③ 전체범죄에 대한 방조범
- ④ 전체범죄에 대한 공동정범
- ⑤ 전체범죄에 대한 교사범

정답 : ③

해설 : 판례는 여고생협박전화 사건에서 전체범죄에 대한 방조범을 인정하고 있다.

♣ 학습내용 정리

1. 절도범이 범행발각 후 폭행하고 재물의 탈취를 완성한 경우에는 폭행 당시 새로운 강도의 범의가 있었다고 평가할 수 있으므로 소위 표변강도에 해당한다.
2. 판례는 '2인 이상이 합동하여 절도를 한 경우 범인 중의 1인이 체포를 면탈할 목적으로 폭행을 하여 상해를 가한 때에는 나머지 범인도 이를 예기하지 못한 것으로 볼 수 없으면 강도상해죄의 죄책을 면할 수 없다'라고 하여 합동절도의 일방이 준강도죄를 범한 경우에 타방에게 예견가능성이 없는 한 준강도죄의 공동정범을 긍정하고 있다.
3. 승계적 공동정범에서 후행가담자의 죄책에 대하여 판례는 ① 포괄일죄와 관련된 판례에서는 가담 이후의 범행에 대해서만 공동정범으로서의 책임을 진다고 하여 가담이전 부분에 대한 죄책을 부정하고 ② 결합범과 관련된 판례에서는 전체범죄에 대한 방조만을 인정함으로써 전체범죄에 대한 공동정범의 성립을 인정하지 않아 부정설의 입장이다.

제20강 합동범의 본질

♣ 학습목표

합동범의 본질에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

합동범의 본질

합동절도범의 준강도죄의 성립여부

정범과 공범의 구별과 행위지배설

♣ 사전테스트

1. 현행형법상 합동범은 절도, 강도, 도주의 경우에 인정되고 있다.

정답 : O

해설 : 타당한 지문이다.

2. 직접정범의 정범표지는 실행지배이다.

정답 : O

해설 : 타당한 지문이다.

3. 공동정범의 정범표지는 기능적 행위지배이다.

정답 : O

해설 : 타당한 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

甲과 乙은 A의 집에서 물건을 훔쳐 나오기로 공모하였고, 이 사실을 알게 된 甲의 친구 丙은 甲에게 가스총 1정을 건네주었다. 그날 밤 A의 집으로 들어가서 甲은 귀중품을 들고 밖으로 나왔으나, 가스총을 휴대한 乙은 그 집 가정부 B가 잠에서 깨어 거실로 나오자 가스총을 쏘아 실신시킨 뒤, 밖에 나와 있던 甲과 함께 도망하였다. 甲, 乙, 丙의 죄책은? (50점)

[해설]

I. 논점의 정리

- (1) 사안에서 甲, 乙, 丙의 죄책을 직접정범과 중한 범죄를 범한 논리적 순서대로 정리하여 乙의 죄책, 甲의 죄책, 丙의 죄책 순서로 검토한다.
- (2) 乙의 죄책과 관련하여 ① 甲과 함께 가스총을 휴대하고 A의 집에 들어가 절도한 행위가 특수절도죄에 해당하는지 ② 체포면탈의 목적으로 가정부 B를 가스총을 쏘아 실신시킨 행위가 준강도죄 또는 강도상해죄에 해당하는지가 문제된다.
- (3) 甲의 죄책과 관련하여 ③ 乙에게 성립한 강도상해죄에 대해 공동정범을 인정할 수 있는지가 문제된다.
- (4) 丙의 죄책과 관련하여 ④ 丙이 甲에게 가스총을 제공한 행위가 교사인지 방조인지를 검토하고 ⑤ 만일 방조에 해당한다면 어느 범위까지 방조범으로써 죄책을 지는지가 문제된다.

II. 乙의 죄책

1. 특수절도죄의 성립여부

(1) 논의점

乙은 야간에 A의 집에 들어가 절도를 하고 있으므로 야간주거침입절도죄가 성립하지만, 乙은 甲과 함께 가스총을 휴대하고 야간에 A의 집에 들어가 절도를 하였으므로 특수절도죄의 인정여부가 문제된다. 왜냐하면 야간주거침입절도죄와 특수절도죄가 중복될 때에는 불법이 무거운 특수절도죄의 성립을 인정하면 족하기 때문이다. 이와 관련하여 형법 제331조 제2항의 합동의 의미와 흉기의 의미를 검토해야 한다.

(2) 합동절도의 성립여부

1) 합동범의 본질에 대한 논의

합동범의 본질에 대하여는 ① 합동의 의미를 공모공동정범으로 해석하는 공모공동정범설 ② 합동의 의미를 공동으로 해석하여 그 본질은 공동정범이지만 집단범죄에 대한 대책상 형을 특별히 가중한 것이라고 보는 가중적 공동정범설 ③ 합동의 의미를 공동보다 좁게 해석하여 합동자들의 시간적·장소적 협동을 의미한다고 보는 현장설 등이 대립하고 있다.

2) 판례

판례는 기본적으로는 현장설을 바탕으로 하고 있다, 즉 판례는 형법 제331조 제2항 후단의 '2인 이상이 합동하여'의 의미에 대하여 '주관적 요건으로서의 공모와 객관적 요건으로서의 실행행위의 분담이 있어야 하고, 그 실행행위는 시간적으로나 장소적으로 협동관계에 있다고 볼 정도에 이르면 된다'라고 하여 현장설을 따르고 있다.

3) 검토 및 사안의 적용

생각건대 형법이 합동범에 대하여 특별히 ‘2인 이상이 합동하여’라고 규정하여 무겁게 처벌하는 것은 시간적·장소적 협동에 의하여 다수인이 동시에 죄를 범할 때에는 구체적 위험성이 증가한다는 데 그 이유가 있으므로 현장설이 타당하다. 사안에서 甲과 乙은 현장에서 시간적·장소적으로 협동하여 절취행위를 하였으므로 합동범으로서 특수절도죄가 성립한다.

(3) 흥기휴대절도

사안에서 乙이 휴대한 가스총은 흥기에 해당하고 乙은 사용할 의도를 가지고 소지하였으므로 흥기휴대절도에 해당한다.

(4) 사안의 해결

사안에서 乙은 특수절도의 두 유형인 합동절도와 흥기휴대절도를 모두 충족하고 있는바 이에 대한 죄수가 문제된다. 특수절도가 성립하는 이상 야간주거침입절도는 이에 흡수된다. 그리고 두 유형의 특수절도를 범했다고 하더라도 이는 포괄하여 하나의 특수절도죄로만 파악하여야 할 것이다. 따라서 乙은 특수절도죄 1죄만 성립한다.

2. 강도상해죄의 성립여부

사안에서 乙은 특수절도죄가 성립하며 체포를 면탈할 목적으로 B에게 가스총을 발사한바, 이는 준강도의 폭행에 해당하여 특수강도의 준강도죄가 성립한다. 그리고 乙이 가스총을 쏘아 B를 실신시킨 것은 상해에 해당하므로 乙은 강도상해죄가 성립한다.

3. 소 결

乙에게 강도상해죄가 성립한다. 강도상해죄가 성립한 이상 특수절도 및 특수강도의 준강도는 이에 흡수된다.

III. 甲의 죄책

1. 특수절도죄의 성립여부

甲은 乙과 함께 가스총을 휴대하고 A의 집에 들어가서 재물을 절취하였으므로 특수절도죄가 성립한다.

2. 준강도죄의 성립여부

(1) 논의점

사안에서 甲은 귀중품을 들고 밖으로 나왔지만, 아직 방에 있던 乙이 B에게 가스총을 쏘아 준강도가 성립된 경우에 폭행행위를 하지 않은 甲에게도 준강도죄가 성립하는지가 문제된다.

(2) 견해의 대립

이에 대하여는 ① 다른 공범자에 의한 폭행과 협박에 대한 예견가능성 유무를 판단하여 예견가능성이 있으면 본죄의 공동정범이 성립한다는 긍정설 ② 준강도는 공동의사의 범위를 초과한 것이므로 초과부분에 대해서는 단독범이 성립할 뿐이지 준강도죄의 공동정범을 인정할 수 없다는 부정설이 대립하고 있다.

(3) 판 례

판례는 ‘2인 이상이 합동하여 절도를 한 경우 범인 중의 1인이 체포를 면탈할 목적으로 폭행을 하여 상해를 가한 때에는 나머지 범인도 이를 예기하지 못한 것으로 볼 수 없으면 강도상해죄의 죄책을 면할 수 없다’라고 하여 긍정설의 입장이다.

(4) 검토 및 사안의 해결

생각건대 합동절도의 경우에 공범 중 1인이 체포를 면탈하기 위하여 폭행을 가한다는 점은 일반적으로 쉽게 예견할 수 있으므로 예견가능성을 기준으로 판단하는 것이 타당하다. 따라서 예견가능성이 없는 특이한 경우를 제외하고는 준강도죄의 공동정범이 성립하는 것으로 보는 것이 타당하다. 사안에서 甲과 乙은 가스총을 휴대하고 주거에 침입하고 있으므로 그 중 일방이 이를 사용할 것이라는 것은 충분히 예견할 수 있으므로 甲도 특수강도의 준강도의 죄책을 진다.

3. 강도상해죄 또는 강도치상죄의 성립여부

乙에게 성립한 강도상해죄에 대해 甲도 강도상해죄의 공동정범을 인정할 수 있는지가 문제된다. 사안에서 甲에게 특수강도의 준강도의 공동정범이 인정된다면 甲에게도 강도상해의 공동정범을 인정하여야 할 것이다. 특히 사안에서는 이미 가스총을 휴대했다는 점에서 상해에 대한 미필적 고의도 인정할 수 있기 때문이다.

4. 甲의 죄책

甲은 乙과 더불어 강도상해죄의 공동정범이 성립한다. 그리고 甲이 범한 특수절도 등의 행위는 이에 흡수되어 별죄로 논하지 않는다.

IV. 丙의 죄책

1. 丙의 가담형태

사안에서 丙은 甲과 乙이 합동절도를 결의하고 있는 것을 알고 이에 대하여 가스총을 건네 준 행위가 정범인지 공범인지가 문제된다. 정범과 공범의 구별에 대하여는 논의가 있었지만, 현재는 행위지배설로 확립되어 있다. 사안에서 丙의 행위는 공동가공의 의사와 기능적 행위지배라는 정범표지를 인정하기 어렵다. 따라서 丙의 행위는 공범만이 될 수 있다.

2. 특수절도죄의 공범

사안에서 丙은 甲과 乙이 특수절도를 하려는 사실을 알면서 甲에게 가스총을 제공하고 있는바 이는 합동절도에 대하여 흥기휴대절도를 새로이 결의시키는 것으로 볼 여지가 있다. 그러나 합동절도와 흥기휴대절도는 동일한 조문에 포괄일죄의 관계에 있으므로 이를 교사라고 평가할 수 없고, 특수절도의 방조범만 성립한다고 보아야 할 것이다. 따라서 丙은 기본적으로 특수절도죄의 방조범이 성립한다.

3. 강도상해죄 또는 강도치상죄의 방조범 성립여부

사안에서 甲이 가스총을 사용하여 가정부를 실신시키고 있는 바, 이에 대한 丙의 죄책범위가 문제된다. 丙이 乙에게 가스총 1정을 건네줄 당시 甲이나 乙이 절도의 기회에 가스총을 사용할 것이라는 점에 대해 미필적 고의가 있는 경우이므로 丙은 甲과 乙의 강도상해죄에 대해 방조범이 성립할 수 있다.

4. 丙의 죄책

丙에게는 강도상해죄의 방조범이 성립한다.

V. 사안의 해결

甲과 乙은 강도상해죄의 공동정범이 성립하고, 丙에게는 강도상해죄의 방조범이 성립한다.

관련판례

1. 합동하여의 의미에 대한 판례

형법 제331조 제2항 후단의 '2인 이상이 합동하여'라 함은 주관적 요건으로서의 공모와 객관적 요건으로서의 실행행위의 분담이 있어야 하고 그 실행행위에 있어서는 시간적으로나 장소적으로 협동관계가 있음을 요한다.(대판 1988.1.3. 88도1197)

2. 100미터 이내의 거리에서 각자 강간한 사건

[1] 성폭력범죄의처벌및피해자보호등에관한법률 제6조 제1항의 2인 이상이 합동하여 형법 제297조의 죄를 범함으로써 특수강간죄가 성립하기 위하여는 주관적 요건으로서의 공모와 객관적 요건으로서의 실행행위의 분담이 있어야 하고, 그 실행행위는 시간적으로나 장소적으로 협동관계에 있다고 볼 정도에 이르면 된다. [2] 피고인 등이 비록 특정한 1명씩의 피해자만 강간하거나 강간하려고 하였다 하더라도, 사전의 모의에 따라 강간할 목적으로 심야에 인가에서 멀리 떨어져 있어 쉽게 도망할 수 없는 야산으로 피해자들을 유인한 다음 곧바로 암묵적인 합의에 따라 각자 마음에 드는 피해자들을 데리고 불과 100m 이내의 거리에 있는 곳으로 흩어져 동시 또는 순차적으로 피해자들을 각각 강간하였다면, 그 각 강간의 실행행위도 시간적으로나 장소적으로 협동관계에 있었다고 보아야 할 것이므로, 피해자 3명 모두에 대한 특수강간죄 등이 성립된다고 한 사례.(대판 2004.8.20. 2004도2870)

3. 합동범 중 일인이 준강도 상해를 범한 사건

2인 이상이 합동하여 절도를 한 경우 범인 중의 1인이 체포를 면탈할 목적으로 폭행을 하여 상해를 가한 때에는 나머지 범인도 이를 예기하지 못한 것으로 볼 수 없으면 강도상해죄의 죄책을 면할 수 없다.(대판 1988.2.9. 87도2460)

♣ 돌발퀴즈

행위지배는 모든 범죄에 통용되는 정범표지이다.

정답 : X

해설 : 행위지배는 일반범(지배범)의 경우에만 적용되는 정범표지이다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 다음 중 합동범이 아닌 것은?

- ① 합동절도
- ② 합동강도
- ③ 합동도주
- ④ 성폭법상 합동강간
- ⑤ 내란죄

정답 : ⑤

해설 : 내란죄는 집합범이기는 하지만, 합동범은 아니다.

2. 의무범의 정범표지는?

- ① 실행지배
- ② 의사지배
- ③ 기능적 행위지배
- ④ 전구성요건적 의무위반

⑤ 자수성

정답 : ④

해설 : 의무범(신분범)의 정범표지는 전구성요건적 의무위반이다.

3. 자수범의 정범표지는?

① 실행지배

② 의사지배

③ 기능적 행위지배

④ 전구성요건적 의무위반

⑤ 자수성

정답 : ⑤

해설 : 자수범의 정범표지는 자수성이다.

♣ 학습내용 정리

1. 판례는 합동범의 본질에 대하여 기본적으로는 현장설을 바탕으로 하고 있다, 즉 판례는 형법 제331조 제2항 후단의 '2인 이상이 합동하여'의 의미에 대하여 '주관적 요건으로서의 공모와 객관적 요건으로서의 실행행위의 분담이 있어야 하고, 그 실행행위는 시간적으로나 장소적으로 협동관계에 있다고 볼 정도에 이르면 된다'라고 하여 현장설을 따르고 있다.
2. 합동절도 중 일방이 준강도가 된 경우에 타방의 죄책에 대하여는 ① 다른 공범자에 의한 폭행과 협박에 대한 예견가능성 유무를 판단하여 예견가능성이 있으면 본죄의 공동정범이 성립한다는 긍정설 ② 준강도는 공동의사의 범위를 초과한 것이므로 초과부분에 대해서는 단독범이 성립할 뿐이지 준강도죄의 공동정범을 인정할 수 없다는 부정설이 대립하고 있다.

제21강 준강도죄의 요건과 장물죄의 본질

♣ 학습목표

준강도죄의 요건과 장물죄의 본질에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

준강도죄의 성립요건

절도죄와 자동차등불법사용죄의 관계

장물죄의 본질

♣ 사전테스트

1. 준강도죄의 주체인 절도에는 미수범이 포함된다.

정답 : O

해설 : 종래에는 논의가 있었지만, 현재의 다수설과 판례는 절도미수범을 포함하는 것이 일반적이므로 타당한 지문이다.

2. 자동차등불법사용죄의 객체에는 자전거도 포함된다.

정답 : X

해설 : 장도차등불법사용죄는 연료사용을 처벌하기 위한 조문이므로 연료를 사용하지 않는 자전거는 객체가 아니다.

3. 판례는 장물죄의 본질에 대하여 추구권설과 유지설을 결합한 결합설을 따르고 있다.

정답 : O

해설 : 판례는 ‘장물인 정을 모르고 보관하던 중 장물인 정을 알게 되었고, 위 장물을 반환하는 것이 불가능하지 않음에도 불구하고 계속 보관함으로써 피해자의 정당한 반환 청구권 행사를 어렵게 하여 위법한 재산상태를 유지시킨 경우에는 장물보관죄에 해당한다.’라고 하여 결합설을 따르고 있다.

♣ 강의내용

[설문]

甲과 乙은 잠겨있지 않은 채 아파트 주차장에 정차되어 있는 피해자 A의 승용차를 훔치기로 하고, 甲은 망을 보고 乙은 위 승용차에 시동을 거는 순간 경비원 B가 나타나자 乙은 위 승용차를 운전하여 도주하고, 甲은 B에게 붙잡혀 인근 파출소로 인도되던 중 파출소 앞에서 갑자기 양손으로 B를 떠밀고 도주하였다. 그 후 위 승용차가 절취되었다는 정을 알고 있는 丙은 乙이 알지 못하는 사이에 위 승용차를 일시 사용한 후 제자리에 가져다 놓았다. 甲·乙·丙의 죄책은? (50점)

[해설]

I. 논점의 정리

- (1) 甲의 죄책과 관련하여 ① 乙과 함께 A의 승용차를 절취하기로 공모한 후 乙이 절취행위를 하는 동안 망을 본 행위에 대한 죄책 ② B에게 체포되어 파출소로 가던 중 B를 양손으로 떠밀고 도주한 행위에 대한 죄책이 문제된다.
- (2) 乙의 죄책과 관련하여 ③ 합동절도의 성립여부 ④ 준강도죄의 공동정범의 성립여부가 문제된다.
- (3) 丙의 죄책과 관련하여 ⑤ 乙이 훔쳐온 자동차인 줄 알고 일시 사용하고 제자리에 갖다 둔 행위에 대하여 절도죄의 성부, 자동차등불법사용죄의 성부, 장물죄의 성부 등이 문제된다.

II. 甲의 죄책

1. 특수절도죄의 성립여부

(1) 논의점

사안에서 甲은 乙과 함께 A의 승용차를 훔쳤으므로 합동범인 특수절도죄의 죄책을 지는지가 문제된다. 형법 제331조 제2항의 합동의 의미를 어떻게 해석하느냐에 따라 甲에게 특수절도죄가 성립하는지 여부를 판단함에 있어 검토해야 할 요건이 달라질 수 있으므로 합동의 의미를 검토해야 한다.

(2) 합동범의 본질에 대한 논의

합동범의 본질에 대하여는 ① 공모공동정범설 ② 가중적 공동정범설 ③ 현장설 ④ 현장적 공동정범설이 대립하고 있으나, 합동범의 성립에는 현장에서의 시간적·장소적 협동이 필요하다는 견해인 현장설이 다수설의 태도이다.

(3) 판례

판례는 ‘형법 제331조 제2항 후단의 “2인 이상이 합동하여”라 함은 주관적 요건으로서의 공모와 객관적 요건으로서의 실행행위의 분담이 있어야 하고 그 실행행위에 있어서는 시간적으로나 장소적으로 협동관계가 있음을 요한다’고 판시하여 현장설의 입장이다.

(4) 검토 및 사안의 해결

생각건대 법률 문언상 합동과 공동은 구별될 뿐 아니라 합동범을 특별 취급하는 근거 등을 고려하면 현장설이 타당하다. 사안에서 甲은 乙과 절도를 공모하고, 甲은 망을 보고 乙은 승용차를 절취하였으므로 甲과 乙은 현장에서 시간적·장소적으로 협동하여 절취행위를 하였으므로 합동범으로서 특수절도죄가 성립한다.

2. 준강도죄의 성립여부

(1) 준강도죄의 성립요건

준강도죄는 ① 절도가 ② 절도의 기회에 ③ 재물의 탈환을 항거하거나 체포를 면탈하거나 죄적을 인멸할 목적으로 ④ 폭행 또는 협박한 때에 성립한다.

(2) 준강도죄의 성립요건의 검토

- 1) 절도에는 단순절도와 가중절도, 절도죄의 기수와 미수를 불문한다. 사안에서 甲은 합동절도범으로 준강도의 주체인 절도에 해당한다는 점은 의문이 없다.
- 2) 절도의 기회란 절도와 시간적·장소적 근접성이 인정될 것을 요구하며, 절취의 직후 또는 그 부근에서 폭행·협박한 때에 인정된다. 사안에서 甲은 절도행위 직후 경비원 B에 의해 체포되어 파출소로 연행되는 도중에 B를 폭행한 경우이므로, 아직 신병확보가 확실하지 않은 단계에서 체포 상태를 면하기 위해 폭행한 것으로 평가할 수 있다.
- 3) 체포를 면탈하는 등의 목적이 있어야 하는데 사안에서는 이러한 목적이 있음에 의문의 여지가 없다.
- 4) 폭행·협박은 절도의 기회에 행하여져야 할 뿐만 아니라 그것은 강도죄에 경우와 같은 정도, 즉 상대방의 의사를 억압할 정도에 이를 것을 요한다. 사안에서 甲이 B를 양손으로 밀고 있는 바 이는 그의 반항을 불가능하게 할 정도에 이르렀다고 보아야 한다.⁹⁾

(3) 사안의 해결

사안에서 甲은 준강도의 성립요건을 모두 구비하였으므로 준강도죄가 성립한다. 甲에게 준강도죄가 성립하면 합동절도죄는 이에 흡수된다.

3. 도주죄의 성립여부

도주죄는 법률에 의하여 체포 또는 구금된 자가 도주한 때에 성립하는 범죄이다. 사인에 의하여 현행범으로 체포된 자는 국가기관에 현실로 인계될 때까지는 국가의 구금권이 침해된다고 할 수 없으므로 본죄의 주체가 될 수 없다. 사안에서 甲은 국가기관에 인도되기 이전에 도주하였으므로 甲에게는 도주죄가 성립하지 않는다.

III. 乙의 죄책

1. 특수절도죄의 성립여부

乙은 甲과 A의 승용차를 절취하기로 공모하고 甲이 망을 보는 사이에 승용차를 몰고 도주하였으므로 특수절도죄가 성립한다.

2. 준강도죄의 공동정범의 성립여부

(1) 논의점

사안처럼 합동절도를 공모하여 실행 중 1인이 체포면탈 등의 목적으로 폭행을 가한 경우, 폭행에 가담하지 않은 乙에게도 준강도죄가 성립하는지가 문제된다.

(2) 견해의 대립

이에 대하여는 ① 다른 공범자에 의한 폭행과 협박에 대한 예견가능성 유무를 판단하여 예견가능성이 있으면 본죄의 공동정범이 성립한다는 긍정설 ② 준강도는 공동의사의 범위를 초과한 것이므로 초과부분에 대해서는 단독범이 성립할 뿐이지 준강도죄의 공동정범을 인정할 수 없다는 부정설이 대립하고 있다.

9) 그러나 최협의의 폭행에 이르지 않았다고 평가하여 답안을 작성할 수도 있다.

(3) 판례의 태도

판례는 '2인 이상이 합동하여 절도를 한 경우 범인 중의 1인이 체포를 면탈할 목적으로 폭행을 하여 상해를 가한 때에는 나머지 범인도 이를 예기하지 못한 것으로 볼 수 없으면 강도상해죄의 죄책을 면할 수 없다'라고 하여 긍정설의 입장이다.

(4) 검토 및 사안의 해결

생각건대 ① 준강도는 독자적 범죄이지 절도죄에 대한 결과적 가중범이 아니고 ② 준강도는 절도와는 달리 행위객체가 사람이며 ③ 준강도가 성립하기 위해서는 일반적인 고의 이외에 초과주관적인 요소인 목적을 필요로 하므로 부정설이 타당하다. 따라서 사안의 경우에 乙은 합동절도죄만 성립한다.

IV. 丙의 죄책

1. 절도죄의 성립여부

(1) 논의점

사안에서 丙이 승용차를 일시 사용한 후 제자리에 가져다 놓은 행위가 절도죄에 해당하는지가 문제된다. 특히 절도죄의 성립에 불법영득의사가 필요한지에 대하여 논의가 있다.

(2) 불법영득의사의 요부

형법은 불법영득의사에 관한 명문의 규정을 두고 있지 않지만 ① 절도죄의 보호법익은 소유권이므로 소유권침해의사가 필요하고 ② 절도죄를 손괴죄에 비하여 무겁게 벌하는 취지도 절도죄가 영득의 의사로 점유를 침해한다는 점에 있고 ③ 형법에 자동차불법사용죄를 신설한 취지도 절도죄의 성립에 불법영득의사가 필요하다는 취지라고 할 것이므로 다수설과 판례의 태도인 필요설이 타당하다.

(3) 사안의 해결

사안의 경우 丙은 승용차를 일시 사용한 후 제자리에 가져다 놓았으므로 관리자를 영구적으로 배제하려는 의사 즉 불법영득의사가 없다. 따라서 丙은 승용차에 대한 불법영득의사가 없으므로 승용차에 대한 절도죄는 성립하지 않는다.

2. 자동차등불법사용죄의 성립여부

자동차등불법사용죄는 관리자의 동의 없이 타인의 자동차 등을 일시 사용한 경우에 성립한다. 여기서의 사용이란 통행수단으로 이용하는 것을 말한다. 사안의 경우 丙은 관리자인 A의 동의 없이 자동차를 그 본래 용도인 통행수단으로 사용하였다는 점에서 丙은 자동차등불법사용죄의 죄책을 진다.

3. 장물죄의 성립여부

(1) 논의점

사안에서의 승용차는 재산범죄로 취득한 재물이므로 장물에 해당한다. 그런데 丙이 사안의 승용차가 장물인 정을 알면서도 이를 乙과 합의없이 사용한 행위가 장물운반죄에 해당하는지가 문제되는데 이에 대하여 논의가 있다.

(2) 장물죄의 본질 관련 논의

장물죄가 성립하기 위한 요건으로 본범과의 합의가 필요한가에 대하여는 ① 장물죄의 본질에 대한 추구권설의 입장에서 피해자의 사법상의 추구권의 행사를 방해하면 족하므로 합의는 필요없다는 견해 ② 장물죄의 본질에 대하여 유지설이나 결합설의 입장에서 본범과의

합의가 필요하다는 견해가 대립하고 있다. 이에 대하여 ③ 판례는 결합설의 입장을 따르고 있으면서 '타인이 갈취한 재물을 그 타인의 의사에 반하여 절취하였다면 절도죄를 구성하고 장물취득죄가 되지 않는다'라고 판시하여 합의가 필요하다는 입장이다.

(3) 결언 및 사안의 해결

생각건대 장물죄는 위법한 재산상태를 유지하는 사회적 측면과 피해자의 추구권을 곤란하게 함으로써 재산상 손해를 심화시키는 개인적 측면을 공유하고 있으므로 결합설이 타당하다. 따라서 장물죄가 성립하기 위해서는 본범과의 합의가 필요하다고 해야 한다. 이러한 입장에 따르면 사안에서 丙은 본범인 乙과의 합의가 없었으므로 장물죄는 성립하지 않게 된다.

V. 사안의 해결

- (1) 甲은 특수절도행위 직후 신병확보가 확실하지 않은 단계에서 체포를 면탈할 목적으로 경비원 B를 폭행하였으므로 준강도죄의 죄책을 진다.
- (2) 乙은 특수절도죄의 죄책을 진다. 만일 판례의 논리에 따르면 乙은 甲의 체포면탈목적을 위한 폭행을 예견할 수 있었으므로 준강도죄의 공동정범의 죄책을 진다.
- (3) 丙은 자동차불법사용죄의 죄책을 진다. 승용차를 일시 사용한 후 제자리에 갖다 놓았으므로 불법영득의사가 부정되어 절도죄가 성립하지 않고, 본범인 乙과의 합의가 없으므로 장물운반죄도 성립하지 않는다.

관련판례

1. 합동하여의 의미에 대한 판례

형법 제331조 제2항 후단의 '2인 이상이 합동하여'라 함은 주관적 요건으로서의 공모와 객관적 요건으로서의 실행행위의 분담이 있어야 하고 그 실행행위에 있어서는 시간적으로나 장소적으로 협동관계가 있음을 요한다.(대판 1988.1.3. 88도1197)

2. 신병확보가 확실치 되지 않은 사건

[사실관계] 甲은 지하철에서 소매치기를 하다가 발각되어 도주하던 중 곧 바로 뒤쫓아 온 보안요원 A에게 붙잡혔다. 그런데 甲은 보안사무실에서 A로부터 그 경위를 확인 받던 중, 체포된 상태를 벗어나기 위해서 A의 안면을 주먹으로 구타하여 상해를 입혔다. 甲의 죄책은?

[판결요지] [1] 준강도는 절도범인이 절도의 기회에 재물탈환의 항거 등의 목적으로 폭행 또는 협박을 가함으로써 성립되는 것으로서, 여기서 절도의 기회라고 함은 절도범인과 피해자측이 절도의 현장에 있는 경우와 절도에 잇달아 또는 절도의 시간·장소에 접촉하여 피해자측이 범인을 체포할 수 있는 상황, 범인이 죄적인멸에 나을 가능성이 높은 상황에 있는 경우를 말하고, 그러한 의미에서 피해자측이 추적대세에 있는 경우나 범인이 일단 체포되어 아직 신병확보가 확실하다고 할 수 없는 경우에는 절도의 기회에 해당한다. [2] 절도범인이 일단 체포되었으나 아직 신병확보가 확실하지 않은 단계에서 체포 상태를 면하기 위해 폭행하여 상해를 가한 경우, 그 행위는 절도의 기회에 체포를 면탈할 목적으로 폭행하여 상해를 가한 것으로서 강도상해죄에 해당한다.(대판 2001.10.23. 2001도4142)

3. 합동범 중 일인이 준강도 상해를 범한 사건

2인 이상이 합동하여 절도를 한 경우 범인 중의 1인이 체포를 면탈할 목적으로 폭행을 하여 상해를 가한 때에는 나머지 범인도 이를 예기하지 못한 것으로 볼 수 없으면 강도상해죄의 죄책을 면할 수 없다.(대판 1988.2.9. 87도2460)

4. 결합설을 따른 판례

장물인 정을 모르고 보관하던 중 장물인 정을 알게 되었고, 위 장물을 반환하는 것이 불가능하지 않음에도 불구하고 계속 보관함으로써 피해자의 정당한 반환청구권 행사를 어렵게 하여 위법한 재산상태를 유지시킨 경우에는 장물보관죄에 해당한다.(대판 1987.10.13. 87도1633)

5. 갈취한 재물에 대한 절도

타인이 갈취한 재물을 그 타인의 의사에 반하여 절취하였다면 절도죄를 구성하고 장물취득죄가 되지 않는다.(대판 1966.12.20. 66도1437)

♣ 돌발퀴즈

장물죄의 본질에 대하여 추구권설을 따를 경우에는 불법원인급여물은 장물이 될 수 없다.

정답 : O

해설 : 추구권설을 따를 경우에는 불법원인급여물은 사법상의 추구권이 없으므로 장물이 될 수 없다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 자동차등불법사용죄의 객체가 아닌 것은?

- ① 자동차
- ② 선박
- ③ 항공기
- ④ 원동기장치자전거
- ⑤ 자전거

정답 : ⑤

해설 : 자전거를 자동차등불법사용죄의 객체가 아니다.

2. 장물죄의 본질에 대한 학설이 아닌 것은?

- ① 추구권설
- ② 유지설
- ③ 공범설
- ④ 결합설
- ⑤ 사후종범설

정답 : ⑤

해설 : 사후종범설은 장물죄의 본질에 대한 학설이 아니다.

3. 장물죄에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 미수범을 처벌하지 않는다.
- ② 과실범을 처벌하지 않는다.
- ③ 친족상도례를 수정하여 적용한다.
- ④ 상습장물죄를 처벌한다.
- ⑤ 예비·음모를 처벌하지 않는다.

정답 : ②

해설 : 장물죄는 재산죄에서 유일하게 과실범을 처벌하는 규정을 두고 있다.

♣ 학습내용 정리

1. 합동범의 본질에 대하여는 ① 공모공동정범설 ② 가중적 공동정범설 ③ 현장설 ④ 현장적 공동정범설이 대립하고 있으나, 합동범의 성립에는 현장에서의 시간적·장소적 협동이 필요하다는 견해인 현장설이 다수설의 태도이다.
2. 준강도죄는 ① 절도가 ② 절도의 기회에 ③ 재물의 탈환을 항거하거나 체포를 면탈하거나 죄적을 인멸할 목적으로 ④ 폭행 또는 협박한 때에 성립한다.
3. 절도의 기회란 절도와 시간적·장소적 근접성이 인정될 것을 요구하며, 절취의 직후 또는 그 부근에서 폭행·협박한 때에 인정된다.
4. 형법은 불법영득의사에 관한 명문의 규정을 두고 있지 않지만 ① 절도죄의 보호법익은 소유권이므로 소유권침해의사가 필요하고 ② 절도죄를 손괴죄에 비하여 무겁게 벌하는 취지도 절도죄가 영득의 의사로 점유를 침해한다는 점에 있고 ③ 형법에 자동차불법사용죄를 신설한 취지도 절도죄의 성립에 불법영득의사가 필요하다는 취지라고 할 것이므로 다수설과 판례의 태도인 필요설이 타당하다.
5. 장물죄가 성립하기 위한 요건으로 본범과의 합의가 필요한가에 대하여는 ① 장물죄의 본질에 대한 추구권설의 입장에서 피해자의 사법상의 추구권의 행사를 방해하면 족하므로 합의는 필요없다는 견해 ② 장물죄의 본질에 대하여 유지설이나 결합설의 입장에서 본범과의 합의가 필요하다는 견해가 대립하고 있다.

제23강 강도살인죄와 인과관계

♣ 학습목표

강도살인죄와 인과관계에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

강도살인죄와 비유형적 인과관계
강도치사와 강도치상죄의 성립요건
사용절도의 성립요건

♣ 사전테스트

1. 판례는 비유형적 인과관계에 대하여 인과관계를 원칙적으로 긍정하고 있다.

정답 : O

해설 : 타당한 지문이다.

2. 현행법상 강도상해와 강도치상죄의 형량은 다르게 규정되어 있다.

정답 : X

해설 : 현행 형법 제337조에서는 강도상해죄와 강도치상죄의 형량을 동일하게 규정하고 있다.

3. 자동차등불법사용죄는 사용절도의 일부분을 처벌하는 죄이다.

정답 : O

해설 : 타당한 지문이다. 따라서 자동차등불법사용죄로 처벌하기 위해서는 사용절도의 요건을 먼저 구비하여야 한다.

♣ 강의내용

[설문]

甲은 乙에게 야간에 A의 집에 침입하여 물건을 훔치라고 시키면서, A의 집에 들어갈 때 사용하도록 A의 집 열쇠를 제공하였다. 그러나 乙은 丙과 공모하여 야간에 칼을 휴대하고 A를 강도하기로 하되 사람의 생명이나 신체를 해치지 않는기로 약속하였다. 그러나 丙은 乙이 칼을 휴대하였으므로 A의 생명이나 신체를 해칠 수 있을 것이라고 생각하였다. 乙과 丙은 A의 집 문이 이미 열려 있어서 甲이 준 열쇠를 사용하지 않고 A의 집에 침입하였다. 丙은 일층에서 물건을 챙기고, 乙은 이층으로 올라가 물건을 물색하는 과정에 자고 있던 A가 일어나려고 하자 당황하여 베개로 A의 머리부분을 누르고 소지한 칼로 복부를 찔렀는데 A가 저항을 멈추고 사지가 축 늘어지자 이미 사망한 것으로 생각하였다. 乙은 A의 지갑과 통장을 챙긴 후 일층으로 내려와 A의 살해사실을 숨긴 채 丙과 함께 훔친 물건을 가지고 그 집을 빠져 나왔다.

이러한 상황을 모른 채 새벽에 집에 돌아온 A의 아들 丁은 A가 침대에서 피를 흘리며 쓰러져 있는 것을 발견하고 병원으로 이송하지 않으면 A가 사망할 것이라는 사실을 알았으나, 이 기회에 상속을 받으려고 A를 구조하지 아니한 채 그대로 집에서 나와 버렸다. 그 결과 A는 과다출혈로 사망하였다. 丁이 A를 발견하였을 당시 병원에 옮겼더라면 생명을 구할 수 있는 상황이었다. A가 사망한지 일주일이 지난 후, 丁은 사용하고 갖다놓을 생각으로 집에 있던 A의 인감도장을 동사무소로 가지고 가서 인감증명 위임장을 작성하여 이를 직원에게 제출한 후, 도장을 다시 제자리에 갖다 놓았다. 직원은 A가 이미 사망하였음을 알고 수사기관에 신고하였다.

甲, 乙, 丙, 丁의 죄책은? (60점)

[해설]

I. 서 언

사안을 먼저 甲, 乙, 丙의 죄책을 정범에서 공범 순서로 검토하고, 이후 丁의 죄책을 검토한다.

II. 乙의 죄책

1. 특수강도의 성립

乙은 丙과 흉기를 휴대한 특수강도를 모의한 후 흉기를 휴대하고 A의 집에 침입하여 A의 머리를 베개로 누르는 폭행을 행사하고 재물을 탈취하고 있는바 이는 특수강도죄가 성립한다.

2. 강도살인죄의 성부

(1) 사안에서 乙은 丙과 ‘사람의 생명이나 신체를 해치지 않는기로 약속’하였지만, 강도의 기회인 범행현장에서는 乙은 A의 배를 찔르고 있는바 이러한 행위가 강도살인죄에 해당하는가가 문제된다.

(2) 살인고의의 검토

강도살인죄가 성립하기 위해서는 살인의 고의가 있어야 하는바 사안에서 乙의 행위에 살인의 고의가 있는지가 문제된다. 사안에서 乙은 A를 베개로 제압한 후 당황하여 A의 배를 찔르고 있는 바 이는 우연적이지만 미필적인 살인의 고의가 있는 행위라고 평가할 수 있다.

(3) 인과관계의 검토 및 사안의 해결

사안에서 A는 결국 사망하였지만, 乙의 행위와 사망의 결과 사이에 丁의 행위가 개입되어 있다. 이러한 제3자의 부작위에 의한 개입이 있는 경우에 A의 사망을 乙에게 귀속시킬 수

있는가가 문제되지만, 제3자인 丁의 자유로운 행위가 개입된 경우에는 그 인과관계가 단절된다고 보아야 할 것이다. 따라서 사안에서는 乙은 강도살인죄의 미수의 죄책을 진다.

III. 丙의 죄책

1. 특수강도죄의 성립

丙은 乙과 흥기휴대강도를 모의하고 A의 집에 침입하여 乙은 A에게 폭행을 행사하고 丙은 재물을 취득하였으므로 특수강도죄가 성립한다.

2. 강도치사상죄의 성립여부

(1) 사안에서 공범인 乙이 강도살인의 미수를 범하고 있는바 이에 대한 丙의 죄책이 문제된다.

(2) 강도살인미수죄의 공동정범의 성부

丙에게 강도살인미수죄의 공동정범이 성립하기 위해서는 乙과 丙사이에 살인에 대한 의사의 합치가 있어야 하지만 사안에서는 사람의 생명을 해치지 않기로 약속하고 있으므로 살인에 대한 의사의 합치가 있었다고 보기 어려워 강도살인미수죄는 성립하지 않는다.

(3) 강도치사죄 또는 강도치상죄의 성립여부 및 사안의 해결

1) 사안에서 丙에게 강도치사죄가 성립하기 위해서는 乙의 행위와 A의 사망사이에 인과관계가 있어야 하지만, 사안에서는 이에 대한 인과관계가 없으므로 丙에게 강도치사죄가 성립하지는 않는다.

2) 사안에서 丙에게 강도치상죄가 성립하기 위해서는 상해에 대한 예견가능성이 있어야 하는데 사안에서는 丙이 이를 예견하고 있으므로 丙에게는 강도치상죄가 성립한다.

IV. 甲의 죄책

1. 야간주거침입 절도죄의 교사

사안에서 甲은 乙에게 야간에 A의 집에 침입하여 물건을 훔치라고 시키고 있는바 이는 제 330조 소정의 야간주거침입절도죄의 교사에 해당한다.

2. 열쇠를 제공한 행위에 대한 평가

甲은 乙에게 A의 집 열쇠를 제공하고 있는바 이는 야간주거침입절도죄의 방조행위에 해당한다. 그러나 이러한 방조행위는 교사범과 보충관계에 있으므로 甲에게 교사범이 성립하는 한 이에 흡수된다.

3. 강도살인미수죄의 교사범의 성립여부 및 사안의 해결

(1) 사안에서는 乙은 실제로 강도살인의 미수를 범하고 있는바, 야간주거침입절도를 교사한 甲이 이에 대하여도 교사범으로서의 책임을 지는가가 문제된다.

(2) 먼저 특수강도를 범한 부분에 대하여는 교사의 착오 중 추상적 사실의 착오 중 양적 착오에 해당하므로 중첩되는 부분인 야간주거침입절도의 교사범으로서의 책임을 진다.

(3) 그러나 (강도)살인을 한 부분에 대하여는 추상적 사실의 착오 중 질적 착오에 해당하므로 이에 대하여는 책임을 부담하지 않는다.

(4) 따라서 甲은 야간주거침입절도죄의 교사범으로서의 죄책을 부담한다.

V. 丁의 죄책

1. 사안의 정리

사안에서 丁의 죄책을 ① 아버지의 사망을 방치한 행위 ② 아버지 명의의 인감증명 위임장을 작성한 행위 ③ 인감도장을 사용하고 돌려 준 행위 순서로 검토한다.

2. 부작위에 의한 존속살해죄의 성부

- (1) 사안에서 丁은 아버지 A의 위급한 상황을 알면서도 이를 구제하지 않고 방치하여 사망에 이르게 하고 있다. 이러한 丁의 행위는 부작위범의 성립이 문제되느냐 부작위범이 성립하기 위해서는 ① 구성요건적 상황 ② 작위의무 ③ 행위가능성이 있어 보충인적 지위에 있는 사람이 ④ 부작위를 하여 ⑤ 결과를 창출시켜야 한다.
- (2) 사안에서는 ① 피해자가 스스로를 돌볼 수 없는 상황이 있고 ② 丁과 A는 부자지간이므로 작위의무가 인정되고 ③ A를 살리기 위하여 丁이 작위를 할 가능성이 있었으므로 丁은 보충인적 지위에 있었으나 부작위를 하여 A를 사망에 이르게 하였으므로 丁에게는 부작위에 의한 존속살해죄가 성립한다.

3. 사문서 위조 및 동행사죄의 성부

사안에서 丁은 이미 사망한 A의 명의의 인감증명 위임장을 작성하고 이를 동직원에게 제출하고 있는바, 이에 대하여 사문서위조죄가 성립할 수 있는가가 문제된다. 사자명의로 사문서를 위조한 경우에 대하여는 ① 종래의 판례는 이를 부정하였으나 ② 현재의 다수설과 판례는 사문서위조죄를 인정하고 있다. 따라서 사문서위조죄와 동행사죄가 성립하고 이는 실체적 경합관계에 있다.

4. 인감도장을 사용하고 이를 제자리에 갖다 놓은 행위에 대한 평가

(1) 절도죄의 성부

사안에서 丁이 사망한 A의 인감도장을 사용하고 제자리에 돌려놓은 행위가 절도죄 혹은 점유이탈물횡령죄에 해당하는지가 문제되지만, 두죄는 모두 불법영득의사가 있어야 성립되는바, 인감도장을 사용하는 것은 그 사용으로 인한 경제적 가치의 소모가 무시할 수 있을 정도로 경미하므로 불법영득의사는 인정되지 않는다. 따라서 丁의 행위는 사용절도에 해당하여 절도죄나 점유이탈물횡령죄는 성립하지 아니한다.

(2) 인장위조죄 및 동행사죄의 성립여부

사안에서 丁이 A의 인감도장을 사용한 부분에 대하여 인장위조죄 등이 문제되지만 문서위조죄가 성립하는 경우에는 인장위조죄는 문서위조죄에 흡수되므로 독립된 죄를 구성하지 아니한다.

5. 丁의 죄책

따라서 丁은 존속살해죄, 사문서위조죄 및 동행사죄가 성립하며 이는 실체적 경합관계에 있다.

관련판례

1. 사자 또는 허위인 문서 사건

[사실관계] 甲이 중국 중의사 및 침구사 시험에 응시할 사람을 모집한 후 그들을 중국에 데려가 응시원서의 제출을 대행하면서 응시생의 임상경력증명서가 필요하게 되자, 임상경력증명서 양식에 응시생의 이름과 생년월일 및 학습기간 등을 기재한 다음 의원직인란에 강남한의원이라고 기재하고 그 옆에 임의로 새긴 강남한의원의 직인을 날인하여 강남한의원 명의의 임상경력증명서를 위조한 것을 비롯하여, 동일한의

원과 일심한의원 명의의 임상경력증명서를 같은 방법으로 각 위조하여 행사하였다. 그런데 위 각 임상경력 증명서의 명의인인 한의원이 실재하지 않는다고 할 경우 甲의 죄책은?

[판결요지] 문서위조죄는 문서의 진정에 대한 공공의 신용을 그 보호법익으로 하는 것이므로 행사할 목적으로 작성된 문서가 일반인으로 하여금 당해 명의인의 권한 내에서 작성된 문서라고 믿게 할 수 있는 정도의 형식과 외관을 갖추고 있으면 문서위조죄가 성립하는 것이고, 위와 같은 요건을 구비한 이상 그 명의인이 실재하지 않는 허무인이거나 또는 문서의 작성일자 전에 이미 사망하였다고 하더라도 그러한 문서 역시 공공의 신용을 해할 위험성이 있으므로 문서위조죄가 성립한다고 봄이 상당하며, 이는 공문서뿐만 아니라 사문서의 경우에도 마찬가지라고 보아야 한다.(대판 2005.2.24. 2002도18 전합)

♣ 돌발퀴즈

현행법상 강도살인죄와 강도치사죄는 형량이 동일하다.

정답 : X

해설 : 제338조에 따르면 강도살인죄는 사형 또는 무기징역이지만, 강도치사죄는 무기 또는 10년 이상의 징역으로 형량이 동일하지 않다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 다음 중 인과관계에 관한 학설이 아닌 것은?

- ① 조건설
- ② 원인설
- ③ 중요설
- ④ 상당인과관계설
- ⑤ 비유형적 인과관계설

정답 : ⑤

해설 : 비유형적 인과관계를 인과관계의 태양을 의미하며 인과관계에 대한 학설은 아니다.

2. 갑과 을이 병을 살해하기 위하여 각각 치사량을 독약을 먹여 병이 사망한 경우의 인과관계의 태양은?

- ① 추월적 인과관계
- ② 가정적 인과관계
- ③ 단절적 인과관계
- ④ 택일적 인과관계
- ⑤ 중첩적 인과관계

정답 : ④

해설 : 사안과 같은 인과관계의 태양을 택일적 인과관계라고 한다.

3. 갑이 을을 살해하기 위하여 치사량의 독약을 먹였으나, 병이 을을 총으로 사격하여 사망한 경우에 갑의 인과관계의 태양은?

- ① 추월적 인과관계
- ② 가정적 인과관계
- ③ 단절적 인과관계
- ④ 택일적 인과관계

⑤ 중첩적 인과관계

정답 : ③

해설 : 사안과 같은 인과관계의 태양을 갑에 대하여는 단절적 인과관계, 병에 대하여는 추월적 인과관계라고 한다.

♣ 학습내용 정리

1. 부작위범이 성립하기 위해서는 ① 구성요건적 상황 ② 작위의무 ③ 행위가능성이 있어 보증인적 지위에 있는 사람이 ④ 부작위를 하여 ⑤ 결과를 창출시켜야 한다.
2. 사자명의의 사문서를 위조한 경우에 대하여는 ① 종래의 판례는 이를 부정하였으나 ② 현재의 다수설과 판례는 사문서위조죄를 인정하고 있다.

제24강 불법영득의사에서의 불법의 의미

♣ 학습목표

불법영득의사에서의 불법의 의미에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

사회상규에 어긋난 협박과 공갈죄의 성립여부
강도강간도중의 상해발생의 처리
긴급피난의 성립요건

♣ 사전테스트

1. 판례는 사회상규에 어긋난 협박으로 자신의 채권을 회수한 경우에 공갈죄의 성립을 인정하고 있다.

정답 : O

해설 : 판례는 갈취의 불법설에 따라 공갈죄의 성립을 인정하므로 타당한 지문이다.

2. 강도강간중에 상해를 입혔다면 강도강간치상죄가 성립한다.

정답 : X

해설 : 현행 형법상 강도강간치상죄라는 구성요건은 없다.

3. 긴급피난의 상당성은 정당방위의 상당성보다 그 범위가 넓다.

정답 : X

해설 : 긴급피난은 정당한 제3자의 법익을 침해하는 경우이므로 정당방위의 상당성보다 그 범위가 좁은 것이 일반적이다.

♣ 강의내용

[설문]

사채업자 甲은 채무자 A에게 빌려준 5,000만 원을 받지 못하게 되자 평소 동업자로 일해오던 불법 채권추심 전문업자 乙, 丙과 함께 해결방안을 논의한 끝에, A를 협박하여 돈을 받아내기로 하였다. 甲으로부터 A의 사진과 집주소를 받아든 乙과 丙은 A의 집 근처 골목에서 기다리다가 퇴근하던 A의 앞을 막아서면서 “내일 밤 10시경 집으로 찾아갈 것이니, 그때까지 빌린돈 5,000만 원을 준비해놔라. 그렇지 않으면 너와 네 가족까지도 험한 꼴을 당할 것이다.”라고 위협한 후 사라졌다. 그런데 건강해 보이던 A는 사실 평소 지병인 심장질환을 앓고 있었고, 乙과 丙의 협박에 놀란 나머지 그 자리에 쓰러져 병원 응급실에 실려가게 되었다.

다음날 밤 10시경 A의 집을 방문한 乙과 丙은 A가 집에 없자 A가 일부로 자신들을 피한 것이라고 생각하여 격분해 있던 중, 마침 집에 돌아오던 A의 대학생 딸 B를 발견하고 B를 이용해 A를 협박하여 돈을 받아낼 생각으로 B를 납치하여 야산의 창고로 데려갔다. 그러나 丙이 잠시 자리를 비운 사이 B를 감시하고 있던 乙은 마음이 바뀌어 B를 강간하려고 했고, 강제로 키스하려던 순간 B가 乙의 정강이를 걷어차고 도망쳤다. “잡히면 죽여버리겠다.”고 소리치며 무섭게 뒤쫓아 오던 乙을 피해 도망치던 B는 어두운 산길을 정신없이 달리다가 낭떠러지고 떨어져 중상을 입었다.

한편, 병원의 연락을 받고 달려온 A의 아내 丁은 미동도 없이 누워있는 남편 A를 보면서, 지난 10여 년간 평소 술만 마시면 자신에게 마구 폭력을 행사하고 변태적 성행위까지 요구해왔던 A가 이대로 죽었으면 좋겠다는 생각으로 A에게 부착되어 있던 인공호흡기와 수혈바늘을 뽑아버렸다. 하지만 인공호흡기와 수혈바늘을 제거하더라도 의학적으로 A의 생명에는 지장이 없는 상황이었고, A는 사망하지 않았다.

1. 甲, 乙, 丙의 죄책을 논하시오(특별범위반은 논외로 함) (35점)
2. 丁의 죄책과 관련하여 변호인은 살인죄의 불능범과 긴급피난을 주장하고 있다. 그 타당성을 논하시오. (15점)

[해설]

[1. 문 해설(35점)]

I. 乙과 丙에 대한 죄책

1. A에게 협박한 행위에 대한 죄책

(1) 논의점

사안에서 乙과 丙은 甲의 채권을 추심하는 과정에서 사회상규에 어긋나는 협박을 하고 있다. 이와 같이 권리행사를 위한 협박이 사회상규에 어긋나는 경우에 어떤 죄가 성립하는지에 대하여 논의가 있다.

(2) 견해의 대립

이에 대하여는 ① 영득의 불법이 없어 불법영득의사가 인정하기 어려우므로 협박죄만 성립한다는 협박죄설(다수설) ② 갈취의 불법이 있어 불법영득의사를 인정할 수 있으므로 공갈죄가 성립한다는 공갈죄설(판례)이 대립하고 있다.

(3) 판례의 태도

판례는 '피고인이 피해자에 대하여 채권이 있다고 하더라도 그 권리행사를 빙자하여 사회통념상 용인되기 어려운 정도를 넘는 협박을 수단으로 상대방을 외포케 하여 재물의 교부 또는 재산상의 이익을 받았다면 공갈죄가 되는 것이다(99도4305)'라고 하여 공갈죄설의 입장이다.

(4) 검토 및 사안의 해결

생각건대 재산죄에서의 불법영득의 의사는 타인의 재산을 불법하게 자기의 재산으로 한다는 영득의 불법으로 보아야 하므로 협박죄만 성립한다고 보는 것이 타당하다. 따라서 乙과 丙은 협박죄가 성립한다.

2. A를 쓰러지게 한 행위에 대한 죄책

(1) 논의점

사안에서 乙과 丙의 협박으로 A가 쓰러진 경우에 乙과 丙에게 상해죄나 과실치상죄의 성립을 인정할 수 있는지가 문제된다.

(2) 상해죄의 성립 여부

乙과 丙에게 상해죄의 성립을 인정하기 위해서는 먼저 乙과 丙에게 상해죄의 고의가 인정되어야 한다. 그런데 사안에서의 乙과 丙은 채권을 추심하기 위한 방편으로 협박을 한 것이지 상해를 입힐 의도는 없었다고 보여지므로 상해의 고의는 인정할 수 없어 乙과 丙에게 상해죄는 성립하지 않는다.

(3) 과실치상죄의 성립 여부

사안에서 乙과 丙에게 A가 상해를 입은 부분에 대하여 과실을 인정할 수 있는지가 문제되지만, 사안의 경우에 乙과 丙에게 A의 상해에 대한 예견가능성은 없었다고 평가할 수 있으므로 乙과 丙에게 과실치상죄는 성립하지 않는다.¹⁰⁾

(4) 사안의 해결

따라서 乙과 丙은 A가 쓰러진 부분에 대하여는 무죄가 된다.

3. B를 납치한 행위에 대한 평가

(1) 논의점

사안에서 乙과 丙이 B를 납치하여 인질의 석방을 조건으로 돈을 요구하려고 한 경우이므로 인질강도죄에 해당할 수 있다. 그런데 문제가 되는 것은 인질강도죄의 실행의 착수시기가 문제된다.

(2) 인질강도죄의 실행의 착수시기

실행의 착수시기에 대하여는 ① 인질로 삼기 위하여 체포·감금·약취·유인을 할 때라는 견해와 ② 인질의 석방이나 안전보장의 대가로 재물 또는 재산상의 이익을 요구한 때라는 견해가 대립하고 있다.

(3) 검토 및 사안의 해결

10) 만약 예견가능성을 인정하여 과실치상죄를 긍정한다면 과실의 공동정범을 더 논할 수 있을 것이다.

생각건대 ① 인질로 삼기 위하여 체포·감금·약취·유인을 할 때 법익침해의 밀접한 행위가 있었으며 ② 결합범의 일반논리에 따르면 제1의 행위를 할 때 실행의 착수를 인정하는 것이 일반적이므로 체포·감금·약취·유인시설이 타당하다. 따라서 사안에서 乙과 丙은 인질강도죄의 미수에 해당한다.

4. B를 상해입힌 행위에 대한 평가

(1) 논의점

사안에서 乙은 B를 강간하려고 하였으나 강간에는 성공하지 못하고 B에게 중상을 입히고 있다. 乙은 이미 강도의 신분을 취득하고 있는 자이므로 강도강간죄의 미수범이 성립하지만, 상해를 입힌 부분에 대하여 어떠한 평가를 할 것인가가 문제된다.

(2) 견해의 대립

이에 대하여는 ① 강도강간죄는 강도죄가 기본이므로 강도강간죄와 강도치상죄의 상상적 경합으로 처벌해야 한다는 강도강간죄와 강도치상죄의 상상적 경합범설 ② 상해의 결과가 강도로 인한 경우에는 강도강간죄와 강도치상죄의 상상적 경합으로 처벌하고, 상해의 결과가 강간으로 인한 경우에는 강도강간죄와 강간치상죄의 상상적 경합으로 처벌하자는 이분설이 대립하고 있다.

(3) 판례의 태도

판례는 '강도강간범이 강간의 미수에 그쳤지만 피해자에게 상해를 입힌 경우에는 강도강간미수죄와 강도치상죄가 성립되고, 이는 1개의 행위가 2개의 죄명에 해당되어 상상적 경합관계가 성립된다(88도820)'라고 하여 강도강간죄와 강도치상죄의 상상적 경합범설을 따르고 있다.

(4) 검토 및 사안의 해결

생각건대 강도강간죄는 강도의 기회에 이루어지는 것이므로 기본적으로는 강도죄가 범죄의 핵심이 되므로 강도강간죄와 강도치상죄의 상상적 경합설이 타당하다. 따라서 乙은 강도강간미수죄와 강도치상죄의 상상적 경합이 성립한다.¹¹⁾

5. 乙과 丙의 죄책 정리

(1) 乙의 죄책 정리

乙은 협박죄와 인질강도죄의 미수와 강도강간죄 및 강도치상죄가 성립한다. 죄수판단은 강도강간죄와 강도치상죄는 상상적 경합관계에 있으며 인질강도죄의 미수는 이에 흡수되고, 협박죄와는 실체적 경합관계에 있다.

(2) 丙의 죄책의 정리

丙은 협박죄와 인질강도죄의 미수범이 성립하며, 양자는 실체적 경합관계에 있다.

II. 甲의 죄책

1. 乙과 丙이 A를 협박한 부분의 죄책

(1) 논의점

사안에서 甲은 乙, 丙과 모의를 하고, 乙, 丙으로 하여금 A를 협박하도록 하고 있다. 이러한 경우에 협박행위를 하지 않는 甲이 공동정범이 될 수 있는지가 문제된다.

(2) 논의 상황

종래 이러한 공모공동정범은 인정할 것인지에 대하여 논의가 있었지만, 최근의 다수설과 판례는 기능적 행위지배설에 따라 공모공동정범을 인정하고 있다.

11) 이 경우 시간과 답안 공간이 허용된다면 강도치상죄와 관련하여 결과적가중범의 미수를 언급할 수 있을 것이다.

(3) 사안의 해결

사안에서 甲은 채권자이며, 乙과 丙에게 A의 집주소와 사진 등을 준 것은 乙과 丙의 협박행위에 대한 본질적 기여를 하고 있는 것으로 평가될 수 있으므로 甲은 乙 및 丙과 함께 협박죄의 공동정범의 죄책은 부담한다.

2. A를 쓰러지게 한 부분의 죄책

위에서 검토하였듯이 乙과 丙의 행위가 무죄가 된다면 이에 가담한 甲의 행위도 무죄가 된다.

3. B에 대한 죄책

사안에서 甲은 乙 및 丙과 함께 A를 협박하여 돈을 받아내려고 하였으나 B를 납치한 부분에 대하여는 공모를 한 바 없다. 따라서 乙과 丙이 甲과 모의없이 인질강도를 범하려고 한 부분 이후에 대하여 甲은 책임을 부담하지 않는다.

4. 甲의 죄책 정리

甲은 협박죄의 공동정범이 성립한다.

[2. 문 해설 (15점)]

1. 불능범 주장에 대하여

1. 논의점

사안에서 丁은 A를 살해할 의도로 인공호흡기와 수혈바늘을 제거하고 있다. 그러나 이러한 행위는 丁이 수단을 착오한 것으로 A의 사망의 결과발생은 불가능하였다. 이러한 경우 丁의 행위에 위험성이 인정된다면 살인죄의 불능미수범이 성립할 수 있는바, 위험성의 판단기준에 대하여 논의가 있다.

2. 견해의 대립

이에 대하여는 ① 절대적 불능은 불능범, 상대적 불능은 불능미수로 보자는 구객관설 ② 행위당시에 행위자가 인식한 사정 및 일반인이 인식할 수 있었던 사정을 판단의 기초로 하여 일반인의 기준으로 판단하자는 구체적 위험설 ③ 행위당시에 행위자가 인식한 사정을 판단의 기초로 하여 일반인의 기준으로 판단하자는 추상적 위험설 ④ 범죄실현의사를 표현하는 행위가 있으면 불능미수가 된다는 주관설이 대립하고 있다.

3. 판례의 태도

판례의 태도는 일정하지 않다. 다수의 판례에서는 '결과가 발생할 위험성' 내지는 '결과가 발생할 가능성'을 기준으로 하고 있어 구객관설을 따르고 있는 듯하지만, 일부판례에서는 '불능범의 판단기준으로서 위험성의 판단은 피고인이 행위당시에 인식한 사정을 놓고 이것이 객관적으로 일반인의 판단으로 보아 결과발생의 가능성이 있느냐를 따져야 한다'라고 하여 추상적 위험설을 따른 듯한 판시를 하고 있다.

4. 검토 및 사안의 해결

생각건대 불능미수의 위험성은 기본적으로 행위자가 인식한 사정을 바탕으로 하면서도 행위자가 경솔한 경우까지 처벌하는 것은 불합리하므로 일반인이 인식할 수 있었던 사정도 고려하여 일반인의 입장에서 판단하는 구체적 위험설이 타당하다. 이러한 구체적 위험설에 따르면 사

안에서 丁의 행위는 일반인의 입장에서 위험성이 있으므로 불능미수범이 인정되므로 丁의 변호인의 주장은 타당하지 않다.

II. 긴급피난 주장에 대하여

1. 논의점

사안에서 丁의 행위가 불능미수의 구성요건에 해당한다고 하는 경우에 丁의 행위가 긴급피난에 해당할 수 있는지가 문제된다.

2. 긴급피난의 해당 여부

- (1) 긴급피난은 ① 피난상황 ② 피난행위 ③ 상당성 ④ 주관적 정당화요소를 구비하여야 한다. 특히 사안과 관련하여서는 상당성요건의 충족여부가 문제된다.
- (2) 긴급피난은 정대정의 관계에 있으므로 엄격한 상당성이 요구된다. 따라서 ① 최후수단성 ② 법익균형성 ③ 수단의 적합성이 요구되는데, 사안에서 丁이 A를 살해하려는 행위는 이러한 상당성의 요건을 충족시킬 수 없으므로 긴급피난은 성립할 수 없다.

3. 결론

따라서 사안에서 丁의 변호인의 긴급피난의 주장은 타당하지 않다.

♣ 돌발퀴즈

위난을 가하는 자가 아닌 제3자에 대한 긴급피난을 적극적 긴급피난이라고 한다.

정답 : O

해설 : 타당한 지문이다. 이에 대해 적극적 정당방위는 부당한 침해를 가하는 자에 대한 공격적인 정당방위를 의미한다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 다음 중 형법에 없는 구성요건은?

- ① 강도치상죄
- ② 강간치상죄
- ③ 강도치사죄
- ④ 강간치사죄
- ⑤ 강도강간치상죄

정답 : ⑤

해설 : 형법상 강도강간치상죄라는 구성요건은 없다.

2. 긴급피난의 설명 중 타당하지 않은 것은?

- ① 정대 정의 관계이다.
- ② 과잉긴급피난에 대한 규정이 없다.
- ③ 현재의 위난이 있어야 한다.
- ④ 법익균형성을 구비하여야 한다.
- ⑤ 수단의 적합성을 구비하여야 한다.

정답 : ②

해설 : 제22조 제3항에서 과잉긴급피난규정을 두고 있다.

3. 다음 중 위법조각사유가 아닌 것은?

- ① 정당방위
- ② 긴급피난
- ③ 자구행위
- ④ 피해자의 승낙
- ⑤ 강요된 행위

정답 : ⑤

해설 : 강요된 행위는 책임조각사유이다.

♣ 학습내용 정리

1. 판례는 '피고인이 피해자에 대하여 채권이 있다고 하더라도 그 권리행사를 빙자하여 사회통념상 용인되기 어려운 정도를 넘는 협박을 수단으로 상대방을 외포케 하여 재물의 교부 또는 재산상의 이익을 받았다면 공갈죄가 되는 것이다'라고 하여 공갈죄설의 입장이다.
2. 인질강도죄의 실행의 착수시기에 대하여는 ① 인질로 삼기 위하여 체포·감금·약취·유인을 할 때라는 견해와 ② 인질의 석방이나 안전보장의 대가로 재물 또는 재산상의 이익을 요구한 때라는 견해가 대립하고 있다.
3. 판례는 '강도강간범이 강간의 미수에 그쳤지만 피해자에게 상해를 입힌 경우에는 강도강간미수죄와 강도치상죄가 성립되고, 이는 1개의 행위가 2개의 죄명에 해당되어 상상적 경합관계가 성립된다'라고 하여 강도강간죄와 강도치상죄의 상상적 경합범설을 따르고 있다.
4. 긴급피난은 ① 피난상황 ② 피난행위 ③ 상당성 ④ 주관적 정당화요소를 구비하여야 한다.

제25강 강도강간죄의 성립요건

♣ 학습목표

강도강간죄의 성립요건에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

강간도중의 재물탈취행위에 대한 평가

직불카드부정사용죄의 성립요건

장물보관죄의 성립요건

♣ 사전테스트

1. 판례는 강간한 이후에 재물을 탈취한 경우에 강간죄와 강도죄의 실체적 경합을 인정하고 있다.

정답 : O

해설 : 타당한 지문이다.

2. 타인의 신용카드를 절취하여 예금을 인출한 경우에도 신용카드부정사용죄가 성립한다.

정답 : X

해설 : 신용카드의 본래적 기능을 사용한 것이 아니므로 신용카드부정사용죄는 성립하지 아니한다.

3. 장물인 정을 모르고 장물을 보관한 자가 후에 장물인 정을 알면서도 계속 장물을 보관하게 되면 항상 장물보관죄가 성립한다.

정답 : X

해설 : 후에 장물인 정을 알았더라도 반환하기 불가능하거나 곤란한 사정이 있는 경우에는 장물보관죄가 성립하지 않으므로 타당하지 않은 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

甲은 밤 11:00경 택시에서 내려 귀가하는 여성 A(만 21세)를 강간할 목적으로 뒤 따라가, A가 자신의 아파트 내부 엘리베이터를 타자 甲도 함께 탄 다음 A의 머리채를 잡고 반항을 억압한 후 12층 복도로 끌고 나와 간음하였다. 甲은 간음행위 도중 A가 손가락에 끼고 있던 다이아반지가 탐이 나서 강제로 빼앗은 후 간음행위를 계속하였다. 이 과정에서 A의 손가락에 멍이 들었으나, 3일 후 자연적으로 치유되었다. 甲은 간음행위 후에 범죄현장에 떨어져 있는 A의 핸드백에서 현금 50만 원과 직불카드 1매를 꺼내 자신의 주머니에 넣은 후 도주했다.

甲은 범죄현장에서 1km 정도 떨어진 ○○은행 현금자동지급기에서 A의 직불카드를 사용해 현금 200만 원을 인출한 후 카드는 쓰레기통에 버렸다.

이튿날 甲은 A에게서 빼앗은 반지를 처리하기 위해 자신의 친구인 보석상 乙을 찾아가 반지를 빼앗은 전후사정을 말한 후, “잘 보관하다가 적절한 사람이 나타나면 매각해 줘.”라고 부탁했다. 며칠 후 乙은 그 정을 모르는 B에게 그 반지를 200만 원에 매각하였음에도 甲에게는 100만 원에 매각했다고 속이고 100만 원만 전해 준 후, 나머지 100만 원은 개인적 용도로 소비하였다.

1. 甲의 죄책을 논하시오. (20점)
2. 乙의 죄책을 논하시오. (10점)

[해설]

[1. 문 해설 (20점)]

1. 논의점

사안에서 甲의 죄책을 ① 엘리베이터를 탄 행위의 주거침입죄 성부 ② 강간도중에 다이아반지를 탈취한 행위의 강도죄 성부 ③ 강간을 계속한 행위의 강도강간죄 성부 ④ 상해의 인정여부 ⑤ 현금 50만원과 직불카드 1매를 영득한 행위의 절도죄의 성부 ⑥ 현금인출행위의 절도죄와 직불카드부정사용죄의 성부 ⑦ 반지의 매각한 부분에 대한 사기죄의 교사 성부 등의 순서로 검토한다.

2. 주거침입죄의 성부

사안에서 甲은 A를 강간하기 위하여 엘리베이터를 타고 있는바, 아파트 등 공동주택의 내부에 있는 엘리베이터, 공용 계단과 복도는 특별한 사정이 없는 한 주거침입죄의 객체인 ‘사람의 주거’에 해당하므로 甲은 주거침입죄가 성립한다.

3. 강간도중에 다이아반지의 탈취에 대한 평가

사안에서 甲이 A에 대한 강간의 실행에 착수한 이후에 다이아반지를 탈취한 부분에 대하여 판례는 강도죄의 성립을 인정하고 있지만, 학설은 폭행·협박과 인과관계가 없으므로 절도죄만을 인정하고 있다. 그러나 사안과 같은 폭행은 상대방의 저항을 불가능하게 할 정도이므로 강도죄의 성립을 인정하는 것이 타당하다.

4. 강도강간죄의 성부

강간범이 강간행위 후에 강도의 범의를 일으켜 그 부녀의 재물을 강취하는 경우에는 강도강간죄가 아니라 강간죄와 강도죄의 경합범이 성립될 수 있을 뿐이지만, 사안과 같이 강간행

위의 종료 전 즉 그 실행행위의 계속 중에 강도의 행위를 할 경우에는 이때에 바로 강도의 신분을 취득하는 것이므로 이후에 그 자리에서 강간행위를 계속하는 때에는 강도가 부녀를 강간한 때에 해당하여 형법 제339조에 정한 강도강간죄를 구성한다.

5. 상해의 인정여부

사안에서 A는 손가락에 멍이 들었으나 3일후 자연 치유되었다. 이러한 상해를 강도치상이나 강간치상에서 말하는 상해라고 볼 수 있는가에 대하여 논의가 있다. 그러나 판례는 일반적으로 상해로 인해 일상생활에 지장이 없고, 자연치유가능성이 있는 경우에는 상해로 인정하지 않고 있다. 이러한 판례의 입장에 따르면 사안의 A의 상해는 강도치상이나 강간치상의 상해로는 인정될 수 없다.

6. 현금 50만 원과 직불카드 1매에 대한 죄책

사안에서 A가 떨어뜨리고 간 지갑에서 현금 50만 원과 직불카드 1매를 영득한 것은 규범적 요소에 의하여 A의 점유가 인정되어 절도죄에 해당할 수 있지만, 사안에서는 강도죄가 성립하고 있으므로 시간·장소적인 접촉관계에 있는 절도죄는 이에 흡수된다.

7. 직불카드 1매로 현금을 찾은 부분

직불카드로 현금을 찾은 부분은 판례에 의하면 별도의 절도죄가 성립한다. 그리고 직불카드의 고유한 기능을 사용한 것이 아니므로 직불카드부정사용죄는 성립하지 않는다.

8. 사기의 교사부분

甲은 乙에게 강취한 반지의 매각을 교사하고 있으며, 乙이 선의의 B에게 반지를 매각하였으므로 사기죄의 교사범이 성립한다.

9. 甲의 죄책

甲은 주거침입죄, 강도강간죄, 절도죄가 성립하고 이와 별도로 사기죄의 교사범이 성립하며, 이들은 실제적 경합관계에 있다.

[2. 문 해설 (10점)]

1. 논의점

乙의 죄책과 관련하여서는 ① 장물보관죄의 성부 ② 사기죄의 성부 ③ 횡령죄의 성부 등이 문제된다.

2. 장물보관죄의 성부

乙은 강취한 반지인 정을 알면서 이를 보관하고 있으므로 장물보관죄가 성립한다. 그리고 장물양도죄는 장물인 정을 모르고 취득한 후 그 정을 알면서 제3자에게 수여하는 것을 말하므로 장물양도죄는 성립하지 아니한다.

3. 사기죄의 성부

乙이 B에게 강취한 반지인 丁을 숨기고 이를 매각한 경우에 B는 민법 제250조의 규정에 의하여 선의취득을 하지 못하므로 B에 대한 사기죄가 성립한다.

4. 횡령죄의 성부

(1) 문제의 제기

사안에서 乙은 B에게 반지를 200만원에 팔았음에도 불구하고 甲에게는 100만원에 팔았고 거짓말을 하여 100만원을 영득하고 있다. 이러한 경우에 乙에게 횡령죄가 성립할 것인가에 대하여 논의가 있다.

(2) A에 대한 횡령죄의 성립여부

사안에서 반지의 소유권은 피해자 A에게 있으며, 乙에게 장물보관죄가 성립한다면 이에 대한 소유권을 충분히 침해하였으므로 별도로 횡령죄는 성립하지 않는다.

(3) 甲에 대한 횡령죄의 성립여부

1) 논의점

사안에서 甲은 乙에게 사기죄를 교사하고 있다. 이러한 甲의 행위는 민법 제103조에 위배되며, 반지는 불법원인급여물이 된다. 이러한 불법원인급여물에 대한 횡령죄가 성립할 수 있는가에 대하여 논의가 있다.

2) 견해의 대립과 판례의 태도

이에 대하여는 횡령죄 긍정설과 부정설 등이 대립하고 있으나, 판례는 ‘불법원인급여물의 소유권은 급여를 받은 상대방에게 귀속된다’라고 보아 타인의 재물이 아니므로 횡령죄가 성립할 수 없다고 본다.

3) 결론 및 사안의 해결

생각건대 긍정설에 따르면 국가기관이 불법행위를 조장하는 문제점이 있으므로 원칙적으로 부정설이 타당하다. 따라서 사안의 경우에 부정설에 따르면 乙의 행위는 횡령죄가 성립하지 않는다.

(4) 乙의 죄책

乙은 장물보관죄, 사기죄가 성립하며 양자는 실체적 경합관계에 있다.

관련판례

1. 엘리베이터 안에서 폭행하고 계단에서 강간한 사건

[1] 주거침입죄에 있어서 주거란 단순히 가옥 자체만을 말하는 것이 아니라 그 정원 등 위요지를 포함한 다. 따라서 다가구용 단독주택이나 다세대주택·연립주택·아파트 등 공동주택 안에서 공용으로 사용하는 엘리베이터, 계단과 복도는 주거로 사용하는 각 가구 또는 세대의 전용 부분에 필수적으로 부속하는 부분으로서 그 거주자들에 의하여 일상생활에서 감시·관리가 예정되어 있고 사실상의 주거의 평온을 보호할 필요성이 있는 부분이므로, 다가구용 단독주택이나 다세대주택·연립주택·아파트 등 공동주택의 내부에 있는 엘리베이터, 공용 계단과 복도는 특별한 사정이 없는 한 주거침입죄의 객체인 ‘사람의 주거’에 해당하고, 위 장소에 거주자의 명시적, 묵시적 의사에 반하여 침입하는 행위는 주거침입죄를 구성한다. [2] 피고인이 강간할 목적으로 피해자를 따라 피해자가 거주하는 아파트 내부의 엘리베이터에 탄 다음 그 안에서 폭행을 가하여 반항을 억압한 후 계단으로 끌고 가 피해자를 강간하고 상해를 입힌 사안에서, 피고인이 성폭력범죄의 처벌 및 피해자보호 등에 관한 법률 제5조 제1항에 정한 주거침입범의 신분을 가지게 되었다는 이유로, 주거침입을 인정하지 않고 강간상해죄만을 선고한 원심판결을 파기한 사례.(대판 2009.9.10. 2009도4335)

2. 강간범이 재물 탈취한 사건

[1] 강간범이 강간행위 후에 강도의 범의를 일으켜 그 부녀의 재물을 강취하는 경우에는 강도강간죄가 아니라 강간죄와 강도죄의 경합범이 성립될 수 있을 뿐이지만, 강간행위의 종료 전 즉 그 실행행위의 계속 중에 강도의 행위를 할 경우에는 이때에 바로 강도의 신분을 취득하는 것이므로 이후에 그 자리에서 강간

행위를 계속하는 때에는 강도가 부녀를 강간한 때에 해당하여 형법 제339조에 정한 강도강간죄를 구성하고, 구 성폭력범죄의 처벌 및 피해자보호 등에 관한 법률(2010. 4. 15. 법률 제10258호 성폭력범죄의 피해자보호 등에 관한 법률로 개정되기 전의 것) 제5조 제2항은 형법 제334조(특수강도) 등의 죄를 범한 자가 형법 제297조(강간) 등의 죄를 범한 경우에 이를 특수강도강간 등의 죄로 가중하여 처벌하는 것이므로, 다른 특별한 사정이 없는 한 특수강간범이 강간행위 종료 전에 특수강도의 행위를 한 이후에 그 자리에서 강간행위를 계속하는 때에도 특수강도가 부녀를 강간한 때에 해당하여 구 성폭력범죄의 처벌 및 피해자보호 등에 관한 법률 제5조 제2항에 정한 특수강도강간죄로 의율할 수 있다. [2] 강도죄는 재물탈취의 방법으로 폭행, 협박을 사용하는 행위를 처벌하는 것이므로 폭행, 협박으로 타인의 재물을 탈취한 이상 피해자가 우연히 재물탈취 사실을 알지 못하였다고 하더라도 강도죄는 성립하고, 폭행, 협박당한 자가 탈취당한 재물의 소유자 또는 점유자일 것을 요하지도 아니하며, 강간범인이 부녀를 강간할 목적으로 폭행, 협박에 의하여 반항을 억압한 후 반항억압 상태가 계속 중임을 이용하여 재물을 탈취하는 경우에는 재물탈취를 위한 새로운 폭행, 협박이 없더라도 강도죄가 성립한다. [3] 야간에 갑의 주거에 침입하여 드라이버를 들이대며 협박하여 갑의 반항을 억압한 상태에서 강간행위의 실행 도중 범행현장에 있던 을 소유의 핸드백을 가져간 피고인의 행위를 포괄하여 구 성폭력범죄의 처벌 및 피해자보호 등에 관한 법률(2010. 4. 15. 법률 제10258호 성폭력범죄의 피해자보호 등에 관한 법률로 개정되기 전의 것) 위반(특수강도강간등)죄에 해당한다고 판단한 원심의 조치를 수긍한 사례.(대판 2010.12.9. 2010도9630)

3. 7일 가료 상해 사건

[사실관계] 甲은 나이트클럽에서 乙女와 동석하여 술을 마신 후 집까지 데려다 주겠다고 하여 자신의 승용차에 태워가던 중 갑자가 욕정을 일으켜 강간하려 하였으나 미수에 그쳤다. 이 과정에서 乙女는 전치 1주의 동전크기만한 경부타박상을 입게 되었다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 피해자를 강간하려다가 미수에 그치고 그 과정에서 피해자에게 경부 및 전흉부 피하출혈, 통증으로 약 7일간의 가료를 요하는 상처가 발생하였으나 그 상처가 굳이 치료를 받지 않더라도 일상생활을 하는데 아무런 지장이 없고 시일이 경과함에 따라 자연적으로 치유될 수 있는 정도라면 그로 인하여 신체의 완전성이 손상되고 생활기능에 장애가 왔다거나 건강상태가 불량하게 변경되었다고 보기는 어려워 강간치상죄의 상해에 해당되지 아니한다.(대판 1994.11.4. 94도1311)

4. 어깨에 동전크기의 반상출혈상 사건

강간도중 흥분하여 피해자의 왼쪽 어깨를 입으로 빨아서 생긴 동전크기 정도의 반상출혈상은 별다른 통증이나 자각증상도 없어 피해자는 그 상처를 알아차릴 수도 없었는데 의사가 진찰을 하던 과정에서 우연히 발견한 것이고 의학상 치료를 받지 아니하더라도 자연흡수되어 보통 1주 정도가 지나면 자연치유되는 것으로서 인체의 생활기능에 장애를 주고 건강상태를 불량하게 변경하는 것이 아니어서 강간치상죄의 상해에 해당한다 할 수 없다.(대판 1986.7.8. 85도2042)

5. 코피가 이불에 손바닥 만큼의 넓이로 묻은 사건

피고인이 강간하려고 피해자의 반항을 억압하는 과정에서 주먹으로 피해자의 얼굴과 머리를 몇 차례 때려 피해자가 코피를 흘리고(흘린 코피가 이불에 손바닥 만큼의 넓이로 묻었음) 콧등이 부었다면 비록 병원에서 치료를 받지 않더라도 일상생활에 지장이 없고 또 자연적으로 치료될 수 있는 것이라 하더라도 강간치상죄에 있어서의 상해에 해당한다.(대판 1991.10.22. 91도1832)

6. 강간 등의 상해의 정도 (여중생 강간 미수 사건)

[1] 강간행위에 수반하여 생긴 상해가 극히 경미한 것으로서 굳이 치료할 필요가 없어서 자연적으로 치유되며 일상생활을 하는 데 아무런 지장이 없는 경우에는 강간치상죄의 상해에 해당되지 아니한다고 할 수 있을 터이나, 그러한 논거는 피해자의 반항을 억압할 만한 폭행 또는 협박이 없어도 일상생활 중 발생할 수 있는 것이거나 합의에 따른 성교행위에서도 통상 발생할 수 있는 상해와 같은 정도임을 전제로 하는 것이므로 그러한 정도를 넘는 상해가 그 폭행 또는 협박에 의하여 생긴 경우라면 상해에 해당된다고 할 것이며, 피해자의 건강상태가 나쁘게 변경되고 생활기능에 장애가 초래된 것인지는 객관적, 일률적으로 판단될 것이 아니라 피해자의 연령, 성별, 체격 등 신체, 정신상의 구체적 상태를 기준으로 판단되어야 한다. [2] 피해자(여자 중학생)가 소형승용차 안에서 강간범행을 모면하려고 저항하는 과정에서 피고인과의 물리적 충돌로 인하여 입은 ‘우측 슬관절 부위 찰과상’ 등이 강간치상죄의 상해에 해당하지 않는다고 본 원심판결을 파기한 사례.(대판 2005.5.26. 2005도1039)

7. 절취한 직불카드로 예금인출한 사건

[사실관계] 甲은 乙의 직불카드를 절취한 후 그 직불카드를 이용하여 현금자동지급기로부터 乙의 예금을 인출하였다. 이 경우 甲의 죄책은? (단, 카드에 대한 절도는 논외로 한다)

[판결요지] 여신전문금융업법 제70조 제1항 소정의 부정사용이라 함은 위조·변조 또는 도난·분실된 신용카드나 직불카드를 진정한 카드로서 신용카드나 직불카드의 본래의 용법에 따라 사용하는 경우를 말하는 것이므로, 절취한 직불카드를 온라인 현금자동지급기에 넣고 비밀번호 등을 입력하여 피해자의 예금을 인출한 행위는 여신전문금융업법 제70조 제1항 소정의 부정사용의 개념에 포함될 수 없다.(대판 2003.11.14. 2003도3977)

8. 장물보관죄와 횡령죄와의 관계

절도범으로부터 장물보관의뢰를 받은 자가 그 정을 알면서 이를 인도받아 보관하고 있다가 임의처분하였다 하여도 장물보관죄가 성립되는 때에는 이미 그 소유자의 소유물추구권을 침해하였으므로 그 후의 횡령행위는 불가벌적 사후행위에 불과하여 별도로 횡령죄가 성립하지 않는다.(대판 1976.11.23. 76도3067)

9. 도봉구청 뇌물 사건

[사실관계] 甲은 조합장 乙로부터 공무원에게 뇌물로 전달하여 달라고 금원을 교부받은 것을 뇌물로 전달하지 않고 자신이 소비하였다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 민법 제746조에 불법의 원인으로 인하여 재산을 급여하거나 노무를 제공한 때에는 그 이익의 반환을 청구하지 못한다고 규정한 뜻은 급여를 한 사람은 그 원인행위가 법률상 무효임을 내세워 상대방에게 부당이득반환청구권을 할 수 없고, 또 급여한 물건의 소유권이 자기에게 있다고 하여 소유권에 기한 반환청구도 할 수 없어서 결국 급여한 물건의 소유권은 급여를 받은 상대방에게 귀속된다는 것이므로 조합장이 조합으로부터 공무원에게 뇌물로 전달하여 달라고 금원을 교부 받은 것은 불법원인으로 인하여 지급 받은 것으로서 이를 뇌물로 전달하지 않고 타에 소비하였다고 해서 타인의 재물을 보관 중 횡령하였다고 볼 수는 없다.(대판 1988.9.20. 86도628)

♣ 돌발퀴즈

판례는 상해여부를 판단함에 있어 일상생활에 지장이 없고, 자연치유가능성이 있는 경우에는 항상 상해를 부정하고 있다.

정답 : X

해설 : 판례는 상해여부를 판단함에 있어 일상생활성과 자연치유가능성을 일응의 기준으로 삼고 있지만 항상 그런 것은 아니므로 타당하지 않은 지문이다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 갑은 을녀를 강간한 후에 을녀를 시계를 탈취하였다. 판례에 따를 때 갑의 죄책은?

- ① 강간죄와 절도죄
- ② 강간절도죄
- ③ 강간죄와 강도죄
- ④ 강간강도죄
- ⑤ 강도강간죄

정답 : ③

해설 : 판례에 따르면 갑은 강간죄와 강도죄의 실체적 경합범이 된다.

2. 갑은 강취한 을의 신용카드를 현금자동지급기에서 30만원을 현금서비스 받고 50만원짜리 카메라를 구입하였다. 이에 대해 판례에 따른 갑의 죄책과 관련없는 것은?

- ① 강도죄
- ② 절도죄
- ③ 신용카드부정사용죄
- ④ 사기죄
- ⑤ 컴퓨터사용사기죄

정답 : ⑤

해설 : 판례에 의하면 컴퓨터사용사기죄는 성립하지 않는다.

3. 장물죄의 행위태양이 아닌 것은?

- ① 취득
- ② 양도
- ③ 보관
- ④ 알선
- ⑤ 공여

정답 : ⑤

해설 : 장물공여죄라는 죄는 없다.

♣ 학습내용 정리

1. 강간범이 강간행위 후에 강도의 범의를 일으켜 그 부녀의 재물을 강취하는 경우에는 강도강간죄가 아니라 강간죄와 강도죄의 경합범이 성립될 수 있을 뿐이지만, 강간행위의 종료 전 즉 그 실행행위의 계속 중에 강도의 행위를 할 경우에는 이때에 바로 강도의 신분을 취득하는 것이므로 이후에 그 자리에서 강간행위를 계속하는 때에는 강도가 부녀를 강간한 때에 해당하여 형법 제339조에 정한 강도강간죄를 구성한다.
2. 판례는 일반적으로 상해로 인해 일상생활에 지장이 없고, 자연치유가능성이 있는 경우에는 상해로 인정하지 않고 있다. 하지만 개별적인 경우에는 달리 판단한 판례도 있다.

제26강 불법원인급여와 사기죄

♣ 학습목표

불법원인급여와 사기죄에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

불법원인급여의 재물성

사기죄와 횡령죄의 구별

불법원인급여와 사기죄의 성부

♣ 사전테스트

1. 판례는 불법원인급여물에 대한 재산죄를 항상 긍정하고 있다.

정답 : X

해설 : 판례는 불법원인급여물에 대한 횡령죄는 원칙적으로 부정하고 있으므로 타당하지 않은 지문이다.

2. 사기죄와 횡령죄의 구별은 타인의 점유하에 있는 재물인지에 따라 결정된다.

정답 : O

해설 : 타당한 지문이다.

3. 판례는 불법원인급여물에 대한 사기죄를 긍정하고 있다.

정답 : O

해설 : 민법 제746조의 불법원인급여에 해당하여 급여자가 수익자에 대한 반환청구권을 행사할 수 없다고 하더라도, 수익자가 기망을 통하여 급여자로 하여금 불법원인급여에 해당하는 재물을 제공하도록 하였다면 사기죄가 성립한다.(대판 2006.11.23. 2006도 6795)

♣ 강의내용

[설문]

조직폭력배 甲은 마약사범 A가 새로운 방법으로 메스암페타민(속칭 ‘히로뽕’)을 제조했다는 정보를 입수하고 A의 히로뽕을 가로채기로 마음먹었다. 甲은 A에게 전화를 걸어 히로뽕을 팔아 주겠다고 제안하였다. 甲을 신뢰하지 못한 A는 평소 친분이 있던 乙에게 “甲이 믿을 만한 사람인지 알아봐 달라”고 부탁하였다. 甲을 각별한 선배로 여기고 있던 乙은 이 사실을 甲에게 알렸다. 甲은 乙에게 “이 기회에 A의 히로뽕을 가로채서 팔아 돈을 절반씩 나눠 갖자. A가 나를 신뢰하고 히로뽕을 맡길 수 있게끔 만들어라”라고 제안했다. 乙은 甲의 제안을 받아들인 다음, A에게 전화를 걸어 “꼼꼼하게 알아보니 甲이 신용할 만한 사람이다. 히로뽕을 맡겨도 괜찮을 것 같다”고 말해 주었다. 이에 A는 甲에게 히로뽕 1킬로그램을 건네주면서 빠른 시일 안에 매각하도록 의뢰하였다. 甲은 그 히로뽕을 마약상 B에게 1억 원을 받고 매각하였다.

그로부터 1주일이 지나도록 甲에게서 아무런 연락을 받지 못한 A는 甲에게 전화를 걸어 “당장 히로뽕을 돌려주지 않으면 가만두지 않겠다”며 협박하였다. 甲이 乙에게 “A를 살려 두면 골치 아플 것 같으니 네가 처치해라”라고 지시하였다. 乙이 그렇게 하겠다고 하자 甲은 히로뽕 매각 대금 중 5천만 원을 乙에게 주었다. 그날 밤 乙이 A를 살해할 범행 장소를 사전 답사할 생각으로 A의 집 근처를 살펴보고 있는데, A가 갑자기 어둠 속에서 야구방망이를 들고 乙쪽으로 달려왔다. 자기를 해치려는 것으로 착각한 乙은 방어 의사로 A를 공격하여 상해를 입혔다(그런데 사실은 A는 공원에서 야구방망이로 스윙 연습을 마친 후 집까지 뛰어서 돌아오는 중이었다). 한편 우연히 현장을 지나던 丙이 지난날 마약거래와 관련하여 원한관계에 있는 A가 공격당하는 것을 목격하게 되자, A를 구조하려는 행인을 제지하는 방법으로 乙의 범행을 도와주었다. 乙은 丙의 존재를 알지 못했다.

1. 甲의 죄책을 논하시오.(특별법 위반의 점은 논외로 함) (20점)
2. A의 메스암페타민을 가로챈 甲의 범행에 관여한 부분에 대하여 乙에게 공동정범의 죄책을 묻는다면 그 근거를 제시하시오. (10점)
3. 만약 丙이 A가 실제로 乙을 공격하는 것이 아님을 알면서도 위와 같이 乙의 행위를 도와주었다고 가정할 경우, 丙에게 상해죄의 간접정범 및 방조범의 성립 가능성을 각각 검토한 후 丙의 죄책에 대한 자신의 견해를 제시하시오. (20점)

[해설]

[1. 문 해설 (20점)]

1. A로부터 히로뽕을 가로챈 행위

(1) 논점의 정리

사안에서 甲은 乙을 이용하여 A를 기망하였고 기망당한 A가 착오에 의하여 甲에게 히로뽕 1킬로그램을 건네주었으므로 사기죄의 성립이 가능하지만, 甲에게 사기죄의 성립을 인정하기 위해서는 ① 금제품인 히로뽕이 사기죄의 객체인 재물에 해당하는지 ② 반사회질서에 어긋나는 마약판매를 위해서 제공된 불법원인급여물이 사기죄의 객체가 될 수 있는지에 대하여 논의가 있다.

(2) 히로뽕의 재물성

1) 논의점

사안에서 논의되는 히로뽕은 원칙적으로 일반인들이 소유 또는 점유할 수 없는 금제품이다. 이러한 금제품이 재산죄의 객체가 될 수 있는가에 대하여 논의가 있다.

2) 견해의 대립

이에 대하여는 ① 형법의 독자성을 강조하는 입장에서 금제품일지라도 재물성을 인정하는 긍정설 ② 법질서의 통일을 강조하는 입장에서 금제품은 소유권의 목적이 될 수 없으므로 재물성을 인정할 수 없다는 부정설 ③ 금제품 가운데 상대적 금제품은 재물성이 인정되지만, 절대적 금제품은 재물성이 인정되지 않는다는 절충설이 대립하고 있다.

3) 판례의 태도

판례는 ‘리프트 탑승권 사건’에서 ‘위조된 유가증권이라고 하더라도 절차에 따라 몰수되기까지는 그 소지자의 점유를 보호하여야 한다는 점에서 형법상 재물로서 절도죄의 객체가 된다’라고 하여 긍정설의 입장이다.

4) 검토 및 사안의 해결

생각건대 법에서 보호하는 소유권은 형식적 소유권이며, 사인의 소유 또는 점유가 금지된 물건도 궁극적으로는 국가가 소유권을 가진다는 점에서 긍정설이 타당하다. 따라서 사안의 히로뽕은 재산범죄에 있어 재물성이 인정된다.

(3) 불법원인급여와 사기죄의 성부

1) 논의점

사안에서 A는 마약판매를 위해서 甲에게 마약을 건네고 있으므로 이는 불법원인급여물이다. 이러한 불법원인급여물이 사기죄의 객체가 될 수 있는지에 대하여 논의가 있다.

2) 견해의 대립

이에 대하여는 ① 반사회질서행위를 한 피해자를 형법이 보호해 줄 필요가 없으므로 불법원인급여물에 대하여 사기죄의 성립을 부정하는 부정설 ② 사법상의 반환청구권보다는 형법의 독자성이 강조되어야 하므로 불법원인급여물에 대하여도 사기죄의 성립을 긍정하는 긍정설이 대립하고 있다.

3) 판례의 태도

판례는 피해자로부터 도박자금으로 사용하기 위하여 금원을 차용한 사건에서 ‘민법 제746조의 불법원인급여에 해당하여 급여자가 수익자에 대한 반환청구권을 행사할 수 없다고 하더라도, 수익자가 기망을 통하여 급여자로 하여금 불법원인급여에 해당하는 재물을 제공하도록 하였다면 사기죄가 성립한다’라고 하여 긍정설의 입장이다.

4) 검토 및 사안의 해결

생각건대 ① 사기죄의 성립 여부는 사법상의 반환청구권과는 관계없이 형법독자적인 입장에서 판단하여야 하고 ② 사기죄의 객체인 재산상의 이익을 경제적 재산설에 입각하는 한 불법원인급여물에 대하여도 사기죄의 성립을 긍정하여야 할 것이다. 이러한 긍정설의 입장에 의하면 甲은 사기죄의 죄책을 진다.

2. 히로뽕판매대금을 A에게 돌려주지 아니한 행위

사안에서 甲에게 히로뽕을 편취한 것이 사기죄가 성립한다면 타인의 신임을 바탕으로 한 횡령죄나 배임죄는 별도로 성립하지 않는다.

3. 乙에게 A를 처단하라고 지시한 행위

(1) 乙에게 살인행위를 교사한 부분에 대한 죄책

사안에서 甲이 살인을 교사하여 乙이 범죄의 실행을 승낙하였지만 乙이 살인의 실행의 착수로 나가지 않았으므로 효과 없는 교사에 해당한다. 따라서 甲과 乙은 살인죄의 예비 음모에 준하여 처벌받는다(제31조 제2항).

(2) 乙이 오상방위로 A에게 상해를 입힌 행위에 대한 죄책

甲이 乙에게 A를 살해하라고 교사하였지만, 사안에서 乙은 A를 살해한다는 의사가 없이 A가 자기를 공격한다고 착각을 하고 방위행위를 하고 있다. 이러한 乙의 방위행위는 乙의 독자적인 행위로서 甲의 교사행위와의 인과관계를 인정할 수 없기 때문에 甲은 이에 대하여는 책임을 지지 아니한다.

4. 甲의 죄책

甲에게는 사기죄와 살인예비·음모죄가 성립하며 양자는 실체적 경합관계에 있다.

[2. 문 해설 (10점)]

1. 乙의 가담형태

甲이 사기범행을 한다는 것을 알면서 乙은 이에 가담하고 있는바 乙에게 공범이 성립한다는 것은 의문의 여지가 없다. 다만 乙이 공동정범인가 아니면 협의의 공범인가를 구별할 필요가 있다.

2. 정범과 공범의 구별학설

종래 정범과 공범의 구별에 대한 견해는 ① 조건설을 바탕으로 한 주관설 ② 원인설을 바탕으로 한 실질적 객관설 ③ 구성요건해당행위를 기준으로 하는 형식적 객관설 ④ 목적적 행위지배를 기준으로 하는 목적적 행위지배설 등이 대립하고 있었다. 그러나 현재의 다수설과 판례는 주관적인 면과 객관적인 면을 모두 참조하여 행위지배가 있으면 정범이고, 행위지배가 없으면 공범이라고 하는 Roxin의 행위지배설을 따르고 있다.

3. 乙에게 공동정범이 성립되는 근거

(1) Roxin의 행위지배설에 의할 경우 특히 당 사안에서 문제가 되고 있는 공동정범의 경우에는 공동의 결의에 의하여 분업적 협력으로 전체적 범행계획을 실현함에 있어 불가결한 행위기여를 하는 기능적 행위지배가 정범표지가 된다.

(2) 사안에서 乙은 甲의 사기의 실행행위 도중에 공동가공의 의사를 가지고 가담하여 甲이 신뢰할 수 있는 사람이라고 A가 믿게 만들어서 히로뽕을 교부하게 하는데 결정적인 기여를 하였는바, 이는 공동정범의 구성표지인 기능적 행위지배를 모두 충족하는 것이라고 평가된다. 따라서 乙은 사기죄의 공동정범의 죄책을 진다고 할 것이다.

[3. 문 해설 (20점)]

1. 논의점

사안에서 丙은 乙이 A에 대하여 오상방위한다는 점을 알면서도 A를 구조하려는 행인을 제지하는 방법으로 乙의 범행을 도와주고 있는데 丙이 간접정범 또는 방조범이 성립가능한가는 위법성조각사유의 전제사실의 착오에 대한 법효과에 따라 달라질 수 있다. 먼저 위법성조각사유의 전제사실의 착오에 대한 일반론을 정리한 후 사안에 대한 의견을 개진한다.

2. 위법성조각사유의 전제사실의 착오에 대한 견해의 대립

(1) 엄격책임설

엄격책임설은 위법성조각사유의 전제사실의 착오의 경우 행위자가 구성요건적 사실에 대한 인식은 있으나 자기 행위의 위법성을 인식하지 못한 경우이므로 위법성의 착오 문제로 보아야 한다는 견해이다. 이러한 입장에 따르면 사안의 丙에게는 간접정범이나 방조범이 모두 성립할 수 있다.

(2) 제한책임설 (구성요건적 착오의 유추적용설)

위법성조각사유의 전제사실에 대한 착오는 사실의 착오는 아니지만 사실의 착오와의 구조적 유사성(사실적인 부분에 착오가 있다는 점)을 근거로 하여 사실의 착오를 유추적용하여야 한다는 견해이다. 이러한 입장에 따르면 사안의 丙은 제한종속을 구비하지 못하여 방조범은 성립할 수 없고, 간접정범만이 성립가능하다.

(3) 소극적 구성요건표지이론 (구성요건적 착오 직접 적용설)

2단계 범죄체계를 취하는 소극적 구성요건표지이론에 의하여 위법성조각사유의 전제사실은 소극적 구성요건요소가 되므로 이에 대한 착오는 사실의 착오로 취급하게 되어 불법고의가 조각된다는 견해이다. 이러한 입장에 따르면 사안의 丙은 제한종속을 구비하지 못하여 방조범은 성립할 수 없고, 간접정범만이 성립가능하다.

(4) 법효과제한적 책임설 : 고의의 이중적 지위의 입장

고의의 이중적 지위를 바탕으로 하여 위법성조각사유의 전제사실의 착오는 구성요건적 고의는 인정되므로 고의불법은 있지만 책임고의가 없으므로 법효과만을 제한하여 고의책임은 부정되고 과실책임 여부만이 문제된다는 견해이다. 이러한 입장에 따르면 사안의 丙은 제한종속을 구비하였으므로 간접정범은 물론 방조범이 성립할 가능성이 있다.

3. 검 토

생각건대 현재 일반적으로 확립된 합일대적 범죄체계인 고의의 이중적 지위를 전제로 하고 있는 법효과제한적 책임설이 ① 구체적 타당성 ② 논리적 우수성 ③ 체계적합성 ④ 악의의 공범자의 처벌가능성을 모두 구비하고 있으므로 가장 타당하다.

4. 사안의 해결

법효과제한적 책임설의 입장에 의할 경우에 丙은 간접정범과 방조범의 성립이 모두 가능하다. 정범개념의 우위성에 따라 간접정범여부를 먼저 판단하면 사안에서 丙이 간접정범이 성립하기 위해서는 행위지배설의 입장에 따르면 우월적 의사지배가 있어야 하지만, 사안에서 丙은 행위자인 乙에 대하여 우월적 의사지배를 할 수 있다고 보기 어렵다. 따라서 丙은 간접정범이 성립하지 않고 방조범만 성립한다. 사안에서는 乙과의 의사연락이 없는 편면적 방조이지만 공동정범과는 달리 편면적 방조를 인정하는 것이 일반적이므로 丙을 방조범으로 처벌하는 것에는 아무런 문제가 없다.

관련판례

1. 스키장 리프트 탑승권 사건

[사실관계] 甲은 A리조트 스키장의 리프트탑승권 발매기를 권한 없이 조작하여 리프트 탑승권을 발행하였다. 그리고 그 정을 알고 있는 乙에게 5회에 걸쳐 1,700여장을 4,700만원에 판매하였다. 甲과 乙의 죄책은?

[판결요지] [1] 유가증권도 그것이 정상적으로 발행된 것은 물론 비록 작성권한 없는 자에 의하여 위조된 것이라고 하더라도 절차에 따라 몰수되기까지는 그 소지자의 점유를 보호하여야 한다는 점에서 형법상 재물로서 절도죄의 객체가 된다. [2] 리프트탑승권 발매기를 전산조작하여 위조한 탑승권을 발매기에서 뜯어 간 행위는 탑승권 위조행위와 위조탑승권 절취행위가 결합된 것이라는 이유로, 위조탑승권의 장물성을 인정한 사례.(대판 1998.11.24. 98도2967)

2. 도박자금 차용 사기 사건

[1] 민법 제746조의 불법원인급여에 해당하여 급여자가 수익자에 대한 반환청구권을 행사할 수 없다고 하더라도, 수익자가 기망을 통하여 급여자로 하여금 불법원인급여에 해당하는 재물을 제공하도록 하였다면 사기죄가 성립한다. [2] 피고인이 피해자로부터 도박자금으로 사용하기 위하여 금원을 차용하였더라도 사기죄의 성립에는 영향이 없다고 한 사례.(대판 2006.11.23. 2006도6795)

♣ 돌발퀴즈

판례는 금제품을 형법상 재물로서 절도죄의 객체로 보고 있다.

정답 : O

해설 : 유가증권도 그것이 정상적으로 발행된 것은 물론 비록 작성권한 없는 자에 의하여 위조된 것이라고 하더라도 절차에 따라 몰수되기까지는 그 소지자의 점유를 보호하여야 한다는 점에서 형법상 재물로서 절도죄의 객체가 된다.(대판 1998.11.24. 98도2967)

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 판례가 불법원인급여물에 대한 재산범을 인정하지 않는 범죄는?

- ① 절도죄
- ② 강도죄
- ③ 사기죄
- ④ 공갈죄
- ⑤ 횡령죄

정답 : ⑤

해설 : 판례는 불법원인급여물에 대한 횡령죄를 원칙적으로 인정하지 않고 있다.

2. 기망으로 타인의 재물을 영득한 경우에 사기죄와 횡령죄의 구별방법은?

- ① 재물여부
- ② 기망행위
- ③ 보관여부
- ④ 가액여부
- ⑤ 처벌여부

정답 : ③

해설 : 자신이 보관하는 물건을 기망하여 영득하면 횡령죄, 타인이 보관하는 물건을 기망하여 영득하면 사기죄가 된다.

3. 다음 중 판례에 의하면 사기죄의 구성요건이 아닌 것은?

- ① 기망
- ② 착오
- ③ 처분행위
- ④ 이익의 취득
- ⑤ 손해의 발생

정답 : ⑤

해설 : 판례는 학설과 달리 손해의 발생을 사기죄의 구성요건으로 보고 있지 않다.

♣ 학습내용 정리

1. 판례는 ‘리프트 탑승권 사건’에서 ‘위조된 유가증권이라고 하더라도 절차에 따라 몰수되기까지는 그 소지자의 점유를 보호하여야 한다는 점에서 형법상 재물로서 절도죄의 객체가 된다’라고 하여 긍정설의 입장이다.
2. 판례는 피해자로부터 도박자금으로 사용하기 위하여 금원을 차용한 사건에서 ‘민법 제746조의 불법원인급여에 해당하여 급여자가 수익자에 대한 반환청구권을 행사할 수 없다고 하더라도, 수익자가 기망을 통하여 급여자로 하여금 불법원인급여에 해당하는 재물을 제공하도록 하였다면 사기죄가 성립한다’라고 하여 긍정설의 입장이다.
3. 종래 정범과 공범의 구별에 대한 견해는 ① 조건설을 바탕으로 한 주관설 ② 원인설을 바탕으로 한 실질적 객관설 ③ 구성요건해당행위를 기준으로 하는 형식적 객관설 ④ 목적적 행위지배를 기준으로 하는 목적적 행위지배설 등이 대립하고 있었다. 그러나 현재의 다수설과 판례는 주관적인 면과 객관적인 면을 모두 참조하여 행위지배가 있으면 정범이고, 행위지배가 없으면 공범이라고 하는 Roxin의 행위지배설을 따르고 있다.

제27강 사자명의 사문서 위조

♣ 학습목표

사자명의 사문서 위조에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

공동정범과 동시범의 구별

사자명의 사문서위조죄의 성부

신용카드의 갈취와 강취의 구별

♣ 사전테스트

1. 공동정범과 동시범을 구별하는 실익은 인과관계의 판단에 있다.

정답 : O

해설 : 공동정범은 인과관계의 판단에 대하여 일부실행 전부책임의 원리를 적용하지만, 동시범은 인과관계의 판단에 대하여 개인책임의 원리를 적용하므로 이에 차이점이 발생한다.

2. 현재 판례는 사자명의 사문서위조죄의 성립을 부정하고 있다.

정답 : X

해설 : 종래 판례는 사자명의 사문서위조죄의 성립을 부정하였으나, 전합에 의하여 종래 판례를 변경하여 사문서위조죄의 성립을 긍정하고 있다.

3. 타인의 신용카드를 절취한 자가 그 카드로 예금을 인출한 경우에는 카드에 대한 절도죄 이외에 예금에 대한 절도죄가 성립한다.

정답 : O

해설 : 판례에 의하면 예금에 대한 절도죄가 별도로 성립한다.

♣ 강의내용

[설문]

甲과 乙은 후배인 V를 지속적으로 괴롭혀 왔다. 1) 2008. 3. 5. 甲과 乙은 함께 V의 자취방에서 V를 구타하다가 사망에 이르게 하였다. V가 사망하자 乙은 당황하여 도주하였는데, 甲은 V의 자취방을 뒤져 V명의로 A은행 통장과 V의 주민등록증 및 도장을 훔친 후 도주하였다. 2) 다음 날인 3. 6. 12 : 00경 甲은 V의 주민등록증 사진을 자신의 사진으로 바꾸고, 같은 날 15 : 00경 A은행에 가서 V명의로 예금청구서를 작성하고 V의 도장을 찍어 V의 주민등록증을 제시한 후 V의 통장에서 현금 1,000만 원을 인출하였다. 같은 해 3. 8. 甲과 甲의 친구인 丙은 乙에게 찾아가 A은행에서 찾은 현금 1,000만 원을 주면서 乙 혼자 경찰에 자수하여 乙이 단독으로 V를 때려 사망에 이르게 한 것이라고 진술하라고 하였다. 만약 그렇게만 해주면 乙의 가족들에게도 상당한 금액으로 보상하고 乙이 출소하더라도 끝까지 뒤를 봐주겠다고 회유하였다.

고민하던 乙은 2008. 3. 11. 15 : 00경 경찰에 찾아가 자수하면서 자신이 혼자 V를 때려 사망에 이르게 한 것이라고 진술하였고, 이에 따라 2008. 4. 9. 乙만 상해치사죄로 구속 기소되었다. 하지만 乙은 제1심 공판과정에서 심경의 변화를 일으켜 사건의 진상을 털어놓았고, 검찰이 재수사에 착수하여 2008. 6. 16. 甲을 긴급체포하였다. 긴급체포 과정에서 검찰수사관은 甲의 소지품을 압수하였는데, 그 중에 V 명의로 직불카드가 있는 것을 발견하고 甲을 추궁하자 3) 甲은 乙과 함께 2008. 2. 중순 경 V를 폭행하여 V 명의로 B은행 직불카드를 빼앗은 후 비밀번호를 알아내고 현금자동지급기에서 현금 50만 원을 인출하여 유혹비로 사용한 사실을 털어놓았다.

甲은 2008. 7. 4. 구속 기소되어 같은 해 9. 3. 제1심 법원으로부터 유죄를 선고받고 그날 항소를 포기하여 그대로 판결이 확정되었다. 한편 丙은 甲이 체포된 후 숨어 지내다가 2013. 4. 29. 체포되었고, 같은 해 5. 15. 검사는 丙에 대해 공소를 제기하였다.

1. 1)의 범죄사실에 대해 甲의 변호인은 상해치사의 공동정범의 성립을 부정하고, 상해의 죄책만을 인정하려 한다. 甲의 변호인의 입장에서 그 논거를 서술하시오. (10점)
2. 2)의 범죄사실에 대한 甲의 죄책을 논하시오. (20점)
3. 3)의 범죄사실에 대한 甲과 乙의 죄책을 폭행의 정도를 구별하여 논하시오. (20점)

[해설]

[1. 문 해설 (10점)]

1. 결과적 가중범의 성립요건

사안에서 甲이 공소제기된 상해치사죄는 결과적가중범으로서 ① 고의의 기본범죄 ② 중한 결과의 발생 ③ 인과관계 ④ 예견가능성을 요건이 구비되었을 때 성립하게 됩니다.

2. 결과적 가중범의 공동정범의 인정실익

여기에서 결과적 가중범의 성립요건과 관련하여 가장 문제가 되는 것은 인과관계입니다. 그리고 결과적 가중범의 공동정범을 논하는 실익은 인과관계의 확정에 있습니다. 결과적 가중범의 공동정범을 인정하게 되면 일부실행전부책임의 원리가 적용되어 甲에게 치사부분에 대한 인과관계가 인정될 수 있지만, 이를 부정하게 되면 동시범의 원리가 적용되어 甲의 행위와 V의 사망

사이의 인과관계를 검사가 입증해야 합니다. 그러나 사안에서 주어진 사실관계만으로는 입증하기가 용이하지 않으므로 변호인은 상해죄만 주장할 수 있습니다.

3. 변호인의 주장 논거

따라서 변호인은 공동정범은 심리적 사실인 의사의 연락이 있는 경우에만 성립한다거나 규범적 요소인 과실에 대하여는 기능적 행위지배를 인정할 수 없다는 점을 들어 결과적 가중범의 공동정범을 부정하는 주장을 하고, 甲의 행위와 V의 사망사이에는 인과관계가 인정되지 않으므로 甲에게는 상해죄만 성립한다고 주장할 수 있습니다.

[2. 문 해설 (20점)]

1. 주민등록증의 사진을 바꾸고 이를 제시한 행위에 대한 평가

사안에서 甲은 행사할 목적으로 V의 주민등록증에 붙어 있는 사진을 떼어내고 甲의 사진을 붙였다면 이는 기존 공문서의 본질적 또는 중요부분에 변경을 가하여 새로운 증명력을 가지는 별개의 공문서를 작성한 경우에 해당하므로 공문서위조죄를 구성한다. 그리고 이를 은행직원에게 제시한 행위는 행사에 해당하므로 甲에게는 공문서위조죄와 위조공문서행사죄가 성립한다.

2. V명의를 예금청구서를 작성하고 이를 제시한 행위에 대한 평가

- (1) 사안에서 甲은 이미 사망한 V명의를 예금청구서를 작성한 행위에 대하여는 사망자명의를 사문서위조죄가 성립할 수 있는지가 문제된다.
- (2) 종래 판례는 원칙적으로 사망자 명의의 사문서위조죄의 성립을 인정하지 않지만, 생존일자로 소급작성된 경우에는 예외적으로 사문서위조죄의 성립을 인정하였다. 그러나 최근 전합판례에 의하면, 사망자 명의의 문서도 공공의 신용을 해할 위험성이 있으므로 문서위조죄가 성립한다고 보아 종래의 판례는 변경하였다.
- (3) 사망자 명의의 문서라도 공공의 신용을 해할 수 있으므로 문서위조죄가 성립한다고 보는 것이 타당하다. 따라서 사안의 경우에 甲의 행위는 문서위조죄가 성립하며, 이를 은행직원에게 제시하는 것은 위조사문서의 행사죄에 해당한다.

3. V의 인장을 예금청구서에 찍은 행위

甲이 V의 인장을 예금청구서에 찍어 예금청구서를 완성한 후에 이를 은행직원에게 제시한 것은 사인부정사용죄 및 동행사죄가 성립할 수 있지만, 인장에 관한 죄는 문서죄와 보충관계에 있으므로 위에서 본바와 같이 사문서위조죄 및 동행사죄가 성립하는 한 이에 흡수되어 별죄를 구성하지 않는다.

4. 은행직원을 기망한 행위

사안에서 甲은 V가 아님에도 V인 것처럼 행세하며 V의 예금잔고 중 1,000만원을 인출하고 있다. 이러한 甲의 행위는 사기죄의 성립요건인 ① 기망 ② 착오 ③ 처분행위 ④ 이익의 취득 및 ⑤ 손해의 발생을 모두 충족하고 있으므로 사기죄가 성립한다.

5. 죄수 문제

사안에서 甲에게는 공문서위조죄와 동행사죄, 사문서위조죄와 동행사죄, 사기죄가 성립하며 원칙적으로 이들은 모두 실체적 경합관계에 있다.

[3. 문 해설 (20점)]

1. 논의점

사안에서 甲과 乙은 공동하여 폭행하여 V의 직불카드를 빼앗고 이를 이용하여 현금자동지급기에서 50만원을 인출하여 이를 영득하고 있다. 이러한 경우에 甲과 乙의 폭행의 정도에 따라 甲과 乙의 죄책이 달라지고 후행행위들에 대한 범죄성립이 달라지므로 이를 검토한다.

2. 폭행이 갈취의 정도인 경우

甲과 乙의 폭행이 최협의의 폭행인 상대방의 저항을 억압할 정도가 아닌 폭행을 행사하여 V의 직불카드를 빼앗은 경우에는 甲과 乙의 행위는 공갈죄를 구성하게 된다. 그리고 이러한 공갈행위로 취득한 직불카드를 사용한 부분에 대하여는 절도죄와 직불카드부정사용죄 등이 논의될 수 있으나, 판례에 의하면 V의 승낙에 따른 행위이므로 포괄하여 하나의 공갈죄만이 성립한다고 본다. 따라서 甲과 乙은 공갈죄만이 성립하고, 특히 2인 이상이 공동으로 하였으므로 폭처법 제3조에 의하여 가중처벌된다.

3. 폭행이 강취의 정도인 경우

(1) 직불카드에 대한 범죄

甲과 乙의 폭행이 최협의의 폭행인 상대방의 저항을 억압할 정도의 폭행을 행사하여 V의 직불카드를 빼앗은 경우에는 甲과 乙의 행위는 강도죄가 성립하지만 2인이상이 합동하여 강도하고 있으므로 제334조 제2항의 합동강도죄가 성립한다.

(2) 후행행위에 대한 범죄

그리고 이러한 직불카드에 대한 강도행위는 피해자의 의사에 반한 경우이므로 후행행위의 범죄가 문제된다.

(3) 현금을 인출한 부분의 죄책

타인의 직불카드를 이용하여 현금을 인출한 행위에 대하여는 ① 컴퓨터사용사기죄설 ② 절도죄설 ③ 무죄설 등이 대립하고 있으나, 판례는 현금자동지급기 관리자의 의사에 반하여 그의 지배를 배제하고 그 현금을 자기의 지배하에 옮겨 놓는 것이 되어서 강도죄와는 별도로 절도죄를 구성한다고 보고 있다. 이러한 판례의 입장에 따르면 사안에서 甲은 절도죄가 성립한다.

(4) 직불카드부정사용죄의 죄책

사안에서는 직불카드를 이용하여 현금을 인출한 것은 직불카드의 본래적 기능을 사용하였다고 볼 수 없으므로 甲에게는 직불카드부정사용죄는 성립하지 아니한다.

♣ 돌발퀴즈

판례는 결과적가중범의 공동정범을 긍정하고 있다.

정답 : O

해설 : 판례는 결과적 가중범의 공동정범을 긍정하고 있으므로 타당한 지문이다.

제28강 용도가 특정된 금전과 횡령죄

♣ 학습목표

용도가 특정된 금전과 횡령죄에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

업무상횡령죄에서의 업무의 범위

용도가 특정된 금전과 횡령죄

이중신분범과 공범과 신분

♣ 사전테스트

1. 업무란 사회생활상의 지위에 기하여 계속·반복할 의사로서 행하는 사무를 말한다.

정답 : O

해설 : 타당한 지문이다.

2. 판례는 용도가 특정된 타인의 금전을 보관하는 자가 이를 영득한 경우에 배임죄의 성립을 인정하고 있다.

정답 : X

해설 : 판례는 용도가 특정된 타인의 금전을 보관하는 자가 영득한 경우에 횡령죄로 보고 있으므로 타당하지 않은 지문이다.

3. 업무상횡령죄는 진정신분범적인 요소와 부진정신분범적인 요소를 모두 가지고 있는 이중신분범이다.

정답 : O

해설 : 업무상 횡령죄와 업무상 배임죄는 가장 대표적인 이중신분범이다.

♣ 강의내용

[설문]

甲은 A학교법인 이사장으로서 A학교법인이 설치·운영하는 사립학교 B대학 및 별개 법인인 B대학 산학협력단의 운영에 직·간접적으로 영향력을 행사하였고, B대학 산학협력단 자금에 관하여 입출금을 지시하기도 하였다. 甲은 동창회 모임에서 증권회사에 근무하고 있는 친구 乙을 만나 그로부터 주식투자를 권유받게 되었다. 甲과 乙은 그 자리에서 B대학 산학협력단에서 교부받은 국가 보조금을 빼내어 그 돈을 주식에 투자하여 수익을 분배하기로 합의하였다. 위 보조금은 B대학 산학협력단이 국가로부터 용도를 특정하여 교부받은 것으로, 보조금 관리에 관한 법률에 의하여 다른 용도에 사용하는 것이 금지되어 있다. 그 후 甲은 위 보조금 중 2억 원을 빼내어 乙에게 전달하였고, 乙은 그러한 사정을 잘 알고 이를 건네받아 주식에 투자하였다.

1. 甲의 행위가 업무상횡령죄에 해당되는지 여부를 논하시오. (10점)
2. 甲의 행위가 업무상횡령죄에 해당된다고 가정하고, 乙의 죄책을 논하시오. (15점)

[해설]

[1. 문 해설 (10점)]

1. 업무상 횡령죄의 성립요건

甲의 행위가 업무상횡령죄가 성립하기 위해서는 ① 업무성의 인정 ② 보관자의 지위 ③ 타인의 재물성의 인정 ④ 불법영득의사에 의한 횡령행위 등이 인정되어야 할 것이다.

2. 업무성의 인정

업무상횡령죄에서 ‘업무’는 법령, 계약에 의한 것뿐만 아니라 관례를 따르거나 사실상의 것이거나를 묻지 않고 같은 행위를 반복할 지위에 따른 사무를 가리킨다. 사안에서 甲은 학교법인의 이사장으로서 계속인 학교법인의 일을 처리하는 자이므로 업무성을 인정할 수 있다.

3. 위탁받아 보관하는 자의 지위

횡령죄에서 재물 보관에 관한 위탁관계는 사실상의 관계에 있으면 충분하다. 甲은 대학과 산학협력단 운영에 직·간접적으로 영향력을 행사하였고, 대학 교비나 산학협력단 자금에 관하여 입출금을 지시하기도 하였던 점 등을 종합할 때 자금에 관하여 사실상 보관자의 지위에 있었다고 인정할 수 있다.

4. 용도가 특정된 금전의 성격

금전은 그 성격상 점유가 있는 곳에 소유가 있다는 것이 일반적이다. 그러나 용도가 특정된 금전의 경우에는 ① 금전이 갖는 고도의 유통성과 대체성을 고려하여 용도를 특정한 위탁의 경우에도 점유이전과 함께 수탁자에게 소유권도 이전하므로 횡령죄는 성립할 수 없고, 배임죄가 성립할 수 있다고 보는 견해도 있지만 ② 금전 기타의 대체물도 재물이며 목적·용도를 정하여 위탁한 금전은 정해진 목적·용도에 사용할 때까지는 이에 대한 소유권이 위

탁자에게 유보되어 있다는 점에서 타인의 재물로서의 성격을 지니므로 횡령죄의 객체가 된다는 보는 것이 타당하다.

5. 용도가 특정된 금전을 유용한 행위

국고보조금으로 교부된 산학협력단 자금을 지정된 용도 외의 용도에 사용한 것으로서 이는 불법영득의사에 기한 횡령행위이므로 甲에게는 업무상횡령죄가 성립한다.

[2. 문 해설 (15점)]

1. 乙은 정범인가 공범인가

甲의 업무상횡령죄에 가담한 乙의 행위가 정범인가 공범인가가 문제된다. 정범과 공범의 구별에 대하여는 ① 주관설 ② 실질적 객관설 ③ 형식적 객관설 ④ 행위지배설의 견해가 대립되지만 현재는 행위지배설을 따르는 것이 일반적이다. 사안의 경우에 있어 乙은 甲과 주관적으로 횡령행위에 대한 합의가 있었고, 이후 이를 넘겨받고 후에 이득을 분배하기로 하였다는 점에서 기능적 행위지배도 인정된다고 하겠다. 따라서 乙은 공동정범의 태양을 구비하였다고 보아야 하고, 甲이 신분범이라는 점을 감안하더라도 규범적 행위지배가 있다고 보이므로 공동정범이 성립한다.

2. 공범과 신분

(1) 논의점

비신분자인 乙은 이중신분범인 업무상배임죄를 범한 甲의 행위에 공동정범으로 가담하고 있다. 이러한 경우 乙의 성립과 처벌에 대하여 논의가 있다.

(2) 견해의 대립

제33조의 해석에 대하여는 ① 제33조 본문은 구성적 신분인 진정신분범의 공범의 성립과 과형 문제를 규정한 것으로 보고, 제33조 단서는 가감적 신분인 부진정신분범의 공범의 성립과 과형 문제를 규정한 것으로 보는 다수설과 ② 제33조 본문은 진정신분범과 부진정신분범에 대한 공범의 성립 및 진정신분범에 대한 처벌을 규정한 것으로 보고, 제33조 단서는 부진정신분범의 과형 문제를 규정한 것으로 보는 판례의 입장이 대립하고 있다.

(3) 결론 및 사안의 해결

생각건대 33조는 신분 없는 자가 신분 있는 자에게 가담한 경우에 그 처벌을 확장하기 위하여 규정된 것이다. 따라서 본문에 의하여 처벌을 확장하되 그 범위가 너무 확장되는 것을 막기 위하여 단서를 둔 것이다. 그렇다면 제33조 본문은 진정신분범에게 적용되고, 제33조 단서는 부진정신분범에게 적용된다고 보는 다수설의 입장이 타당하다. 또한 원칙적으로 범죄의 성립과 처벌은 일치하여야 하지만, 소수설과 판례에 의하면 부진정신분범의 성립과 처벌이 분리되게 되므로 타당하지 않다. 따라서 사안에서의 乙은 다수설에 따르면 횡령죄의 공동정범(제355조 제1항, 제33조, 제30조)이 성립하게 된다.

3. 장물죄의 성부

사안에서 乙이 횡령죄의 공동정범이 성립하지 않는다면 장물죄가 논의될 수 있을 것이다. 그러나 사안에서는 乙이 횡령죄의 공동정범이 성립하므로 장물죄는 성립하지 않는다.

관련판례

1. 업무의 개념

[1] 형법 제356조 소정의 ‘업무’는 직업 혹은 직무라는 말과 같아 법령, 계약에 의한 것뿐만 아니라, 관례를 쫓거나 사실상이거나를 묻지 않고 같은 행위를 반복할 지위에 따른 사무를 가리킨다. [2] 피고인이 등기부상으로 공소외 회사의 대표이사를 사임한 후에도 계속하여 사실상 대표이사 업무를 행하여 왔고 회사원들도 피고인을 대표이사의 일을 하는 사람으로 상대해 왔다면 피고인은 위 회사 소유 금전을 보관할 업무상의 지위에 있었다고 할 것이다.(대판 1982.1.12. 80도1970)

2. 원료구입대금 사건

[사실관계] 甲은 乙과 공모하여 乙이 丙으로부터 근관충전제 원료구입대금으로 교부받아 보관 중이던 금 600만원을 甲이 사용할 근관충전제 원료대금으로 지급하였다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 목적, 용도를 정하여 위탁한 금전은 정해진 목적, 용도에 사용할 때까지는 이에 대한 소유권이 위탁자에게 유보되어 있는 것으로서, 특히 그 금전의 특정성이 요구되지 않는 경우 수탁자가 위탁의 취지에 반하지 않고 필요한 시기에 다른 금전으로 대체시킬 수 있는 상태에 있는 한 이를 일시 사용하더라도 횡령죄를 구성한다고 할 수 없고, 수탁자가 그 위탁의 취지에 반하여 다른 용도에 소비할 때 비로소 횡령죄를 구성한다.(대판 1995.10.12. 94도2076)

3. 위임자를 위하여 제3자로부터 수령한 금전 사건

[사실관계] 甲은 아파트에 대한 사실상의 처분권을 가진 乙로부터 아파트를 타에 매도하여 달라는 요청을 받고 이에 따라 위 아파트를 매도한 다음 그 대금을 수령한 후 그 매도대금을 임의로 소비하였다. 그 후 그 매도대금에 상응하는 금액을 乙에게 지급하였다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 금전의 수수를 수반하는 사무처리를 위임받은 자가 그 행위에 기하여 위임자를 위하여 제3자로부터 수령한 금전은, 목적이나 용도를 한정하여 위탁된 금전과 마찬가지로, 달리 특별한 사정이 없는 한 그 수령과 동시에 위임자의 소유에 속하고, 위임을 받은 자는 이를 위임자를 위하여 보관하는 관계에 있다고 보아야 한다.(대판 2003.9.26, 2003도3394)

4. 대학 산학협력단이 용도를 특정하여 교부받은 보조금 중 일부를 대학 교비계좌로 송금하여 교직원 급여 등으로 사용한 사건

학교법인 이사장인 피고인이, 학교법인이 설치·운영하는 대학 산학협력단이 용도를 특정하여 교부받은 보조금 중 3억 원을 대학 교비계좌로 송금하여 교직원 급여 등으로 사용한 사안에서, 위 행위는 국고보조금으로 교부된 산학협력단 자금을 지정된 용도 외의 용도에 사용한 것으로서 업무상횡령죄에 해당한다고 본 원심판단을 수긍한 사례.(대판 2011.10.13. 2009도13751)

5. 제33조의 해석에 대한 판례

신분관계가 없는 자가 그러한 신분관계에 있는 자와 공모하여 위 상호신용금고법위반죄를 저질렀다면, 그러한 신분관계가 없는 자에 대하여는 형법 제33조 단서에 의하여 형법 제355조 제2항에 따라 처단하여야 할 것인바, 그러한 경우에는 신분관계가 없는 자에게도 일단 업무상배임으로 인한 상호신용금고법 제39조 제1항 제2호 위반죄가 성립한 다음 형법 제33조 단서에 의하여 중한 형이 아닌 형법 제355조 제2항에 정한 형으로 처벌되는 것이다.(대판 1997.12.26. 97도2609)

6. 은행원 아닌 자가 은행원들과 공모한 사건

은행원이 아닌 자가 은행원들과 공모하여 업무상 배임죄를 저질렀다 하여도, 이는 업무상 타인의 사무를 처리하는 신분관계로 인하여 형의 경중이 있는 경우이므로, 그러한 신분관계가 없는 자에 대하여서는 형법 제33조 단서에 의하여 형법 제355조 제2항에 따라 처단하여야 한다.(대판 1986.10.28. 86도1517)

♣ 돌발퀴즈

은행원이 아닌 자가 은행원들과 공모하여 업무상 배임죄를 범한 경우에는 학설과 판례에 따르면 달리 처벌된다.

정답 : X

해설 : 학설과 판례는 죄의 성립은 다르지만 처벌은 동일하게 되므로 타당하지 않은 지문이다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 다음 중 업무가 가중적 신분요소가 아닌 범죄는?

- ① 업무상 과실치상죄
- ② 업무상 비밀누설죄
- ③ 업무상 횡령죄
- ④ 업무상 배임죄
- ⑤ 업무상 동의낙태죄

정답 : ②

해설 : 업무상 비밀누설죄는 진정신분범이다.

2. 판례에 의할 때 용도가 특정된 금전을 영득한 경우의 죄책은?

- ① 사기죄
- ② 공갈죄
- ③ 횡령죄
- ④ 배임죄
- ⑤ 권리행사방해죄

정답 : ③

해설 : 판례에 의하면 횡령죄가 성립한다.

3. 무면허의료행위죄에서 의사라는 신분은?

- ① 적극적 신분
- ② 가감적 신분
- ③ 불구성적 신분
- ④ 책임조각적 신분
- ⑤ 처벌조각적 신분

정답 : ③

해설 : 의사라는 신분은 불구성적 신분 내지 위법조각적 신분이 된다.

♣ 학습내용 정리

1. 업무상횡령죄가 성립하기 위해서는 ① 업무성의 인정 ② 보관자의 지위 ③ 타인의 재물성의 인정 ④ 불법영득의사에 의한 횡령행위 등이 인정되어야 한다.
2. 업무상횡령죄에서 ‘업무’는 법령, 계약에 의한 것뿐만 아니라 관례를 따르거나 사실상의 것이거나를 묻지 않고 같은 행위를 반복할 지위에 따른 사무를 가리킨다.
3. 용도가 특정된 금전의 경우에는 ① 금전이 갖는 고도의 유통성과 대체성을 고려하여 용도를 특정한 위탁의 경우에도 점유이전과 함께 수탁자에게 소유권도 이전하므로 횡령죄는 성립할 수 없고, 배임죄가 성립할 수 있다고 보는 견해도 있지만 ② 금전 기타의 대체물도 재물이며 목적·용도를 정하여 위탁한 금전은 정해진 목적·용도에 사용할 때까지는 이에 대한 소유권이 위탁자에게 유보되어 있다는 점에서 타인의 재물로서의 성격을 지니므로 횡령죄의 객체가 된다는 보는 것이 타당하다.
4. 제33조의 해석에 대하여는 ① 제33조 본문은 구성적 신분인 진정신분범의 공범의 성립과 과형 문제를 규정한 것으로 보고, 제33조 단서는 가감적 신분인 부진정신분범의 공범의 성립과 과형 문제를 규정한 것으로 보는 다수설과 ② 제33조 본문은 진정신분범과 부진정신분범에 대한 공범의 성립 및 진정신분범에 대한 처벌을 규정한 것으로 보고, 제33조 단서는 부진정신분범의 과형 문제를 규정한 것으로 보는 판례의 입장이 대립하고 있다.

제29강 명의신탁과 이중매매

♣ 학습목표

명의신탁과 이중매매에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

2자간 명의신탁과 횡령죄

이중매매의 성립요건

횡령죄와 배임죄의 장물죄와의 관계

♣ 사전테스트

1. 판례는 2자간 명의신탁의 경우에 명의수탁자가 신탁물을 영득하면 횡령죄의 성립을 인정하고 있다.

정답 : O

해설 : 타당하다.

2. 이중매매의 경우에 현행 민법은 의사주의를 취하므로 횡령죄가 문제된다.

정답 : X

해설 : 이중매매의 경우에 현행 민법은 형식주의를 취하므로 배임죄만 문제된다.

3. 명의신탁된 물건임을 알면서 이를 매매로 취득한 자에게는 장물죄가 성립한다.

정답 : X

해설 : 명의신탁된 물건은 제3자와의 관계에서는 수탁자가 소유자가 되므로 이러한 정을 알고 취득한 제3자에게 장물취득죄는 성립하지 않는다.

♣ 강의내용

[설문]

甲과 A는 명의신탁을 목적으로 실소유자 A 명의의 토지를 甲의 명의로 이전등기해 놓았다. 얼마 후 돈이 급히 필요하게 된 甲은 A의 승낙을 받지 않고, B와 토지의 매매계약을 체결하고 계약금과 중도금을 받았다. 다음날 乙이 “내가 B보다 20% 비싸게 사겠으니 나에게 그 토지를 팔아라.”라고 하자, 甲은 乙과 매매계약을 체결하고 계약금을 받았다. 한편 그 토지가 곧 크게 오를 것이라고 생각한 丙은 甲에게 “내가 乙보다 두 배 주겠으니 그 토지를 나에게 팔아라.”라고 하였다. 甲은 매매대금을 모두 받고 丙에게 소유권이전등기를 하여 주었다.

위 사례를 읽고 물음에 답하시오(특별법 위반의 점은 논외로 함).

1. 甲의 죄책을 논하시오. (10점)
2. 甲이 명의신탁받은 토지를 B에게 임의로 처분한다는 사실을 알고 乙이 매매계약을 체결한 경우, 乙의 죄책을 논하시오. (10점)
3. 丙이 토지가 명의신탁된 사실은 모르지만 甲이 B로부터 중도금까지 받았다는 사실은 알고 매매계약을 체결한 경우, 丙의 죄책을 논하시오. (10점)

[해설]

[1. 문 해설 (10점)]

1. 논의점

사안에서 甲은 A에게서 명의신탁 받은 부동산을 B와 乙에게 양도하려고 하였고, 丙에게 최종적으로 양도하였다. 이 경우에 甲의 죄책에 대하여는 ① 명의신탁자인 A에 대한 횡령죄의 성립 여부 ② B에 대한 배임죄의 성립 여부 ③ 乙에 대한 배임죄의 성립 여부 ④ 丙에 대한 사기죄의 성립 여부 등이 문제된다.

2. A에 대한 횡령죄의 성립 여부

사안처럼 2자간 명의신탁의 경우에 횡령죄가 성립할 수 있는가에 대하여는 긍정설과 부정설이 대립하고 있으며, 판례는 ‘신탁자가 그 소유 명의로 되어 있던 부동산을 수탁자에게 명의신탁하였는데 수탁자가 임의로 그 부동산에 관하여 근저당권을 설정하였다면 신탁자에 대한 횡령죄가 성립한다’라고 하여 횡령죄 성립설의 입장이다. 생각건대 명의신탁물은 불법원인급여물은 아니므로 횡령죄 성립설이 타당하다. 이러한 횡령죄성립설에 의하면 甲은 횡령죄가 성립한다.

3. B에 대한 배임죄의 성립 여부

사안과 같이 B에게 매매를 한 이후에 丙에게 이중매매의 경우에 형식주의를 따르는 현행 민법하에서는 배임죄만이 문제되며, 다수설과 판례에 따르면 B에게 중도금 수령 이후에는 타인의 사무처리자로서의 지위가 발생한다. 따라서 甲은 선매수인인 B에게 중도금을 받았으므로 타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있으며 이후 丙에게 부동산을 이중매매한 후에 등기까지 마쳤으므로 배임죄가 성립한다.

4. 乙에 대한 죄책

사안에서 乙은 甲과 매매계약을 체결하는 정도에 그쳤으므로 甲은 乙에 대한 타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있지 않으므로 乙에 대한 배임죄는 성립하지 않게 된다.

5. 丙에 대한 죄책

사안에서 甲이 명의신탁물이라는 사정을 알리지 않고 丙에게 매매를 하고 소유권을 이전하였다면 丙에 대한 사기죄의 성부가 문제되지만, 명의신탁물은 대외적으로는 甲의 소유이어서 丙은 완벽한 소유권을 취득하므로 丙에 대한 사기죄는 성립하지 않는다.

6. 죄수관계

甲의 A에 대한 횡령죄(제355조 제1항)와 B에 대한 배임죄(제355조 제2항)는 실체적 경합관계에 있게 된다.

[2. 문 해설 (10점)]

1. 논의점

甲이 명의신탁받은 토지를 B에게 임의처분한다는 것을 알고 다시 자신과 매매계약을 체결하도록 한 乙의 죄책에 대하여는 ① A에 대한 甲의 횡령행위에 가담한 죄책여부 ② B에 대한 배임죄의 방조여부 ③ 장물범의 성립여부 등이 문제된다.

2. A에 대한 甲의 횡령행위에 가담한 죄책

- (1) 사안에서 乙이 甲의 횡령행위에 대한 가담부분에 대한 죄책을 논하기 위해서는 甲의 횡령행위의 죄수관계가 문제되지만, 설혹 불가벌적 사후행위에 해당한다고 하더라도 이에 가담자는 횡령죄의 공범이 성립한다.
- (2) 사안에서 乙의 가담형태가 문제되지만, 제2의 횡령행위에 대하여 乙은 수탁자인 甲과 짜고 불법영득할 것을 공모하고 있으므로 횡령죄의 공동정범이 성립한다.
- (3) 그리고 명의신탁물에 대한 횡령죄의 기수시기에 대하여는 논의가 있지만, 최근 판례에 따르면 등기를 이전하는 등의 행위를 하기 전까지는 횡령죄의 미수범만이 성립한다. 따라서 사안에서 乙은 횡령죄의 미수의 공동정범이 성립한다.

3. B에 대한 배임행위에 가담한 죄책여부

사안에서 乙은 甲이 B에게 토지를 매도하여 중도금까지 받은 것을 알고 이중매매를 권유하였지만 계약금을 받은 단계에 그치고 있다. 이러한 이중매매의 경우의 배임죄에 대한 실행의 착수는 다수설과 판례에 의하는 한 계약금을 받는 것만으로는 부족하고 중도금을 받아야 하므로 아직까지 甲이 배임죄의 실행의 착수에 있었다고 보기 어렵다. 따라서 甲의 배임죄는 죄가 되지 않으므로 乙도 죄가 성립하지 않는다.

4. 장물죄의 성립여부

횡령죄의 방조와 관련하여 토지를 매입하려던 행위에 대하여 장물죄의 성립을 문제 삼을 수 있으나 명의신탁의 경우에는 수탁자가 외부관계에 대하여 소유자로 간주되므로 이를 취득한 제3자는 수탁자가 신탁자의 승낙없이 매각하는 정을 알고 있는 여부에 불구하고 완벽한 소유권을 취득하므로 장물에 관한 죄는 논할 여지가 없다.

5. 乙의 죄책

따라서 乙에게는 횡령죄의 미수에 대한 공동정범이 성립한다.

[3. 문 해설 (10점)]

1. 논의점

이미 타인에게 매도되어 중도금을 받았다는 사실을 알면서도 이에 가담한 丙에게 어떠한 책임을 물을 수 있는가에 대하여 ① 배임죄에 대한 죄책을 물을 수 있는지 ② 배임죄가 성립할 수 있다면 배임죄의 가담형태는 무엇인지 ③ 누구에 대한 배임죄인지 ④ 토지의 취득이 장물죄가 성립될 수 있는지 등이 논의될 수 있다.

2. 배임죄의 죄책여부

(1) 배임죄의 죄책여부

다수설과 판례에 의하면 후매수인이 악의인 경우에는 원칙적으로 배임죄에 대한 죄책을 지지 아니하나, 후매수인의 행위가 전매수인을 해할 목적으로 양도를 교사하거나 기타 방법으로 양도행위에 적극 가담한 경우에는 배임죄의 공범이 성립된다.

(2) 사안의 해결

사안에서 丙은 그 토지가 곧 크게 오를 것이라고 생각하고 甲에게 “내가 乙보다 두 배 주겠으니 그 토지를 나에게 팔아라.”라고 하고 있다. 따라서 이러한 丙의 행위는 단순한 악의가 아니라 양도를 교사하거나 양도행위에 적극 가담한 경우라고 보아야 할 것이므로 丙은 배임죄의 죄책을 진다.

3. 가담형태

丙의 경우에 배임죄의 죄책을 진다고 하여도 甲의 배임행위에 대한 공동정범인지 아니면 교사범인지가 문제된다. 사안에서 丙은 甲과 의사의 연락을 하고 매매라는 행위를 통하여 기능적 행위지배를 하고 있으므로 공동정범으로 보아야 할 것이다. 단 이 경우 丙은 신분관계가 없지만, 제33조의 적용으로 배임죄의 대한 공동정범이 성립한다.

4. 배임죄의 피해자

사안에서 丙은 그 토지가 곧 크게 오를 것이라고 생각하고 甲에게 “내가 乙보다 두 배 주겠으니 그 토지를 나에게 팔아라.”라고 하고 있다. 그러나 乙은 실제로 계약단계에 그치고 있으므로 甲이 乙에 대하여 타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다고 볼 수 없다. 따라서 이미 중도금을 받은 B에 대한 배임죄의 공동정범이 성립한다.

5. 장물죄의 성립여부

丙이 배임죄의 공동정범이 성립한다고 하더라도 그 토지는 재산범죄로 인해 영득한 재물이 아니라 배임행위에 제공된 물건에 지나지 않으므로 丙이 그 토지를 취득한다고 하더라도 장물죄는 성립되지 아니한다.

6. 丙의 죄책

丙은 B를 피해자로 하는 甲의 배임죄의 공동정범이 성립한다.

관련판례

1. 부실법이후에도 횡령인정 사건

신탁자가 그 소유 명의로 되어 있던 부동산을 수탁자에게 명의신탁하였는데 수탁자가 임의로 그 부동산에 관하여 근저당권을 설정하였다면 신탁자에 대한 횡령죄가 성립하고, 그 명의신탁이 부동산실권리자명의등기에관한법을 시행 이후에 이루어진 것이라고 하여 달리 볼 것은 아니다.(대판 1999.10.12. 99도3170)

2. 명의신탁물의 매수인의 책임과 장물

[1] 부동산의 수탁자가 신탁자의 승낙없이 매각처분함으로써 횡령죄가 성립하는 경우에 매수인이 그 정을 알고 있었다 하더라도 수탁자와 짜고 불법영득할 것을 공모한 것이 아닌 한 그 횡령죄의 공동정범이 되지 아니한다. [2] 신탁행위에 있어서는 수탁자가 외부관계에 대하여 소유자로 간주되므로 이를 취득한 제3자는 수탁자가 신탁자의 승낙없이 매각하는 정을 알고 있는 여부에 불구하고 장물취득죄가 성립하지 아니한다.(대판 1979.11.27. 79도2410)

3. 이중매매로 배임죄의 주체가 되기 위한 요건

이중매매에 있어서 매도인이 매수인의 사무를 처리하는 자로서 배임죄의 주체가 되기 위하여는 매도인이 계약금을 받은 것만으로는 부족하고 적어도 중도금을 받는 등 매도인이 더 이상 임의로 계약을 해제할 수 없는 상태에 이르러야 한다.(대판 1986.7.8. 85도1873)

4. 계약금만 수령한 사건

매도인이 매수인에게 부동산을 매도하고 계약금만을 수수한 상태에서 매수인이 잔대금의 지급을 거절한 이상 매도인으로서의 이행을 최고할 필요없이 매매계약을 해제할 수 있는 지위에 있었으므로 위 매도인을 타인의 사무를 처리하는 자라고 볼 수 없다.(대판 1984.5.15. 84도315)

5. 표현설을 따른 판례

횡령죄의 구성요건으로서의 횡령행위란 불법영득의사를 실현하는 일체의 행위를 말하고, 횡령죄에 있어서의 행위자는 이미 타인의 재물을 점유하고 있으므로 점유를 자기를 위한 점유로 변경하는 의사를 일으키면 곧 영득의 의사가 있었다고 할 수 있지만, 단순한 내심의 의사만으로는 횡령행위가 있었다고 할 수 없고 영득의 의사가 외부에 인식될 수 있는 객관적 행위가 있을 때 횡령죄가 성립한다.(대판 1993.3.9. 92도2999)

6. 이중매매의 후매수인에게 배임죄를 묻기 위한 요건

이미 타인에게 매도되었으나 소유권이전등기가 경료되지 아니하고 있는 부동산을 이중으로 매수 기타 양수하는 자에 대하여 배임죄의 죄책을 묻기 위해서는 이중으로 양수하는 자가 단지 그 부동산이 이미 타인에게 매도되었음을 알고 이중으로 양수하는 것만으로는 부족하고 먼저 매수한 자를 해할 목적으로 양도를 교사하거나 기타 방법으로 양도행위에 적극 가담한 경우에 한하여 양도인의 배임행위에 대한 공범이 성립된다.(대판 1975.6.10. 74도2455)

7. 이중매매의 후매수인의 책임

부동산을 타인이 매수한 사실을 알면서 그 매수인을 배제하고 이를 취득할 목적으로 그 매도인과 공모하여 이중으로 매수하여 그 소유권이전등기를 경료하였다면 피고인은 매도인의 배임범죄행위에 가공하였다 할 것이므로 본법 제33조와 제30조에 의하여 배임죄의 공모관계가 성립된다.(대판 1966.1.31. 65도1095)

♣ 돌발퀴즈

명의신탁된 부동산임을 알면서 이를 취득한 자에게는 항상 횡령죄의 공범이 성립한다.

정답 : X

해설 : 부동산의 수탁자가 신탁자의 승락없이 매각처분함으로써 횡령죄가 성립하는 경우에 매수인이 그 정을 알고 있었다 하더라도 수탁자와 짜고 불법영득할 것을 공모한 것이 아닌 한 그 횡령죄의 공동정범이 되지 아니한다.(대판 1979.11.27. 79도2410)

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 다음 중 형법상 분류되는 명의신탁이 아닌 것은?

- ① 2자간 명의신탁
- ② 매도인이 악의인 2자간 명의신탁
- ③ 중간생략등기형 명의신탁
- ④ 3자간 명의신탁
- ⑤ 계약명의신탁

정답 : ②

해설 : 매도인이 악의인 2자간 명의신탁이라는 분류는 없다.

2. 갑이 을에게 가옥을 매도하여 중도금을 받은 후에 병에게 다시 매도하고 등기를 이전해 준 경우에 갑의 죄책은?

- ① 무죄
- ② 사기죄
- ③ 횡령죄
- ④ 배임죄
- ⑤ 장물죄

정답 : ④

해설 : 현행법상 이중매매는 배임죄가 성립하게 된다.

3. 다음 중 재물이 객체가 아닌 범죄는?

- ① 절도죄
- ② 강도죄
- ③ 사기죄
- ④ 횡령죄
- ⑤ 배임죄

정답 : ⑤

해설 : 배임죄는 객체가 재물이 아닌 재산상의 이익이다.

♣ 학습내용 정리

1. 2자간 명의신탁의 경우에 횡령죄가 성립할 수 있는가에 대하여는 긍정설과 부정설이 대립하고 있으며, 판례는 '신탁자가 그 소유 명의로 되어 있던 부동산을 수탁자에게 명의신탁하였는데 수탁자가 임의로 그 부동산에 관하여 근저당권을 설정하였다면 신탁자에 대한 횡령죄가 성립한다'라고 하여 횡령죄 성립설의 입장이다.
2. 이중매매의 경우에 형식주의를 따르는 현행 민법하에서는 배임죄만이 문제되며, 다수설과 판례에 따르면 중도금 수령 이후에는 타인의 사무처리자로서의 지위가 발생한다.
3. 판례에 의하면 이중매매에서 후매수인이 악의인 경우라도 원칙적으로 배임죄에 대한 죄책을 지지 아니하나, 후매수인의 행위가 전매수인을 해할 목적으로 양도를 교사하거나 기타 방법으로 양도행위에 적극 가담한 경우에는 배임죄의 공범이 성립된다.

제30강 잔전사기와 횡령죄의 죄수판단

♣ 학습목표

잔전사기와 횡령죄의 죄수판단에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

잔전사기의 인정여부

명의신탁물의 횡령죄의 죄수판단

횡령죄의 기수시기

♣ 사전테스트

1. 판례는 잔전사기에 대해 사기죄의 성립을 부정하고 있다.

정답 : X

해설 : 판례는 잔전사기의 경우에 사기죄의 성립을 긍정하고 있으므로 타당하지 않은 지문이다.

2. 판례는 횡령죄를 위험범으로 파악하여 횡령죄의 미수를 인정하지 않고 있다.

정답 : X

해설 : 판례는 횡령죄를 위험범으로 파악하면서도 횡령죄의 미수범을 인정하고 있다.

3. 일부 판례는 횡령죄를 구체적위범범으로 파악하면서도 미수를 인정하고 있다.

정답 : O

해설 : 최신 판례 중 일부 판례는 횡령죄를 단순한 위험범이 아니라 구체적 위험범으로 파악하면서 횡령죄의 미수범을 인정하고 있으므로 타당한 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

甲은 자기 소유의 아파트를 A에게 6억 원에 매도하기로 하고 계약금으로 6,000만 원을 받았다. 그 후 A는 甲에게 잔금을 지급하면서 수표를 잘못 세어 1억 원권 자기앞수표 5장과 1,000만 원권 자기앞수표 5장을 교부하였다. 甲은 그 현장에서 A가 준 수표를 세어보고 1,000만 원이 더 지급된 것임을 알았음에도 이를 A에게 돌려주지 않았다.

甲은 친구 乙과 명의신탁약정을 한 후 위 아파트 매각대금 중 4억 원으로 B 소유의 X건물에 관하여 B와 매매계약을 체결하고 X건물에 대한 소유권이전등기는 B에서 바로 乙 명의로 경료하였다. 그런데 乙은 사업자금이 부족하게 되자 X건물이 자기명의로 등기되어 있는 것을 기회로 甲의 동의를 받지 않고 X건물에 관하여 채권최고액 1억 5,000만 원의 근저당권을 설정하고 은행으로부터 1억 원을 대출받았다. 그로부터 한 달 후 乙은 사업자금이 더 필요하여 X건물을 임의로 매도하기로 마음먹고 C와 매매계약을 체결하여 계약금과 중도금을 받았다. 그런데 乙과 C 간의 위 매매계약 체결 및 중도금 지급 사실을 알고 있던 丙은 乙에게 X건물을 자신에게 매도할 것을 수차례 요청하면서 만약 문제가 발생하면 모든 책임을 지겠다고 적극적으로 매도를 권유하였고, 이에 乙은 丙으로부터 매매대금 3억 원 전액을 받고 임의로 X건물의 소유권이전등기를 경료해주었다.

甲, 乙, 丙의 죄책을 논하시오 (부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 위반의 점은 논외로 함). (60점)

[해설]

1. 甲의 죄책 - 사기죄의 성부

1. 논의점

사안에서 甲은 A가 잔금 1,000만원을 더 주고 있음을 알면서도 이를 영득하였으므로 이에 대한 사기죄가 성립할 것인지에 대하여 논의가 있다.

2. 견해의 대립

이에 대하여는 ① 신의칙상의 작위의무를 인정할 수 있다는 점을 논거로 사기죄의 성립을 긍정하는 사기죄설 ② 과다한 잔금을 수령하는 경우에는 적극적인 기망행위가 존재하지 않으며, 신의칙상 고지해야 할 의무가 있는 것은 아니라는 점을 논거로 하는 무죄설이 대립하고 있으나, ③ 이와 유사한 사례에서 판례는 '매도인이 사실대로 고지하였다면 매수인이 그와 같이 초과하여 교부하지 아니하였을 것임은 경험칙상 명백하므로, 특별한 사정이 없는 한 신의칙상 고지의무를 지므로 사기죄에 해당한다'라고 하여 사기죄 긍정설의 입장이다.

3. 결론 및 사안의 해결

거래는 신의칙에 의하여 이루어져야 하므로 거래대금을 교부하는 경우에도 각 당사자는 신의칙에 따라 행동해야 할 의무가 있다고 보아야 한다. 따라서 과다한 잔금을 알면서 교부받은 경우에는 신의칙에 기한 작위의무가 인정되어 부작위에 의한 사기죄가 성립된다고 보는 것이 타당하므로 甲에게는 사기죄가 성립한다.

II. 乙의 죄책

1. X건물에 대하여 근저당권을 설정한 행위의 죄책

사안에서 乙은 3자간 명의신탁에 의한 수탁부동산 X건물에 관하여 채권최고액 1억 5,000만원의 근저당권을 설정하고 은행으로부터 1억 원을 대출받고 있는바, 이러한 경우에 횡령죄의 성립여부가 문제되지만, 학설과 판례는 모두 횡령죄의 성립을 긍정하고 있으므로 乙에게는 횡령죄가 성립한다.

2. C에게 매도하려고 하고, 丙에게 매도한 행위

(1) 논의점

사안에서 乙은 X건물에 대하여 근저당을 설정한 이후에 다시 이를 매도하고 있다. 이러한 경우에 후행행위가 불가벌적인 사후행위가 되는지 별개의 횡령죄가 되는지에 대하여 논의가 있다.

(2) 견해의 대립

이에 대하여는 ① 종래 판례와 전합의 소수의견은 횡령죄는 재물죄라는 점을 중시하여 후행 처분행위는 불가벌적 사후행위에 불과하다고 보고 있지만 ② 최근 전합의 다수의견은 후행 처분행위에 의해 새로운 위험을 추가하는 것이 아니라면 후행 처분행위는 이른바 불가벌적 사후행위에 해당하지만, 후행 처분행위가 새로운 위험을 추가하거나 선행 처분행위와는 무관한 방법으로 법익침해의 결과를 발생시키는 경우에는 별도로 횡령죄가 성립한다고 보고 있다.

(3) 결론 및 사안의 해결

생각건대 횡령죄가 재물죄임은 명백하지만, 하나의 재물도 경제적 가치를 바탕으로 하고 있으므로 선행행위로 침해한 경제적 가치보다 후행행위가 침해한 경제적 가치가 더 큰 경우에는 새로운 횡령죄를 구성한다고 보는 것이 타당하다. 따라서 사안에서 乙은 후행 처분행위에서 새로운 위험을 추가하였으므로 별도의 횡령죄가 성립한다.

3. C에게 매도하려 한 행위에 대한 죄책

(1) 논의점

C에게 매도하려 하였으나 중도금만 받고 그친 경우에 횡령죄의 기수가 성립할 것인지에 대하여 횡령죄의 기수시기에 대하여 논의가 있다.

(2) 견해의 대립

이에 대하여는 ① 행위자의 불법영득의사가 외부에 인식될 수 있도록 객관적으로 표현되었을 때 기수가 된다는 표현설 ② 행위자의 불법영득의사가 객관적으로 실현된 때에 기수가 된다는 실현설이 대립하고 있다.

(3) 판례의 태도

종래의 판례는 일반적으로 표현설을 따르고 있다고 평가하지만, 최근의 판례는 횡령죄를 구체적 위험범으로 보면서 추상적 위험의 발생에 그친 경우에는 미수를 인정하고 있어 새로운 논의를 불러 일으키고 있다.

(4) 검토 및 사안의 해결

생각건대 현행법상 횡령죄도 미수처벌규정이 있으므로 미수의 여지를 남겨두기 위해서라도 기수시기가 늦춰지는 실현설이 타당하다. 따라서 사안에서 乙이 C에게 아직 등기를 이전하지 않은 경우에는 횡령죄는 미수에 그친다고 보아야 한다.

4. 丙에게 등기를 이전한 경우의 죄책 및 죄수판단

사안에서 乙은 丙에게 X건물의 등기를 이전하여 주었으므로 이에 대한 횡령죄는 기수가 된다. 이러한 경우에 C에게 매도하려고 한 부분에 대한 횡령죄의 미수부분과의 죄수판단이 문제가 되

나, 이는 동일한 객체에 대해 법익침해이므로 미수는 이에 흡수되어 횡령죄 1죄만이 성립한다고 보아야 할 것이다.

5. C에 대한 죄책

사안에서 乙은 X건물을 매도하려고 중도금까지 받았으나 丙에게 다시 이중으로 매매하고 등기까지 이전하였으므로 乙은 C에 대한 배임죄가 성립한다.

III. 丙의 죄책

사안에서 丙은 乙의 배임행위에 적극가담하고 있는바, 丙에게 배임죄의 공범이 성립할 수 있는지가 문제된다. 이에 대하여 판례는 단순히 이중매매라는 사실을 알고 있는 것만으로는 부족하고, 제1매수인을 해할 목적으로 매도인을 교사하거나 기타 방법으로 양도행위에 적극 가담한 경우에 한하여 배임행위에 대한 공범이 성립한다고 보고 있다.

사안의 경우에는 丙이 乙의 배임행위에 적극 가담한 경우이므로 배임죄의 공동정범이 성립한다.

♣ 돌발퀴즈

횡령죄의 기수시기에 대하여 종래 판례는 실현설을 취하고 있다.

정답 : X

해설 : 횡령죄의 기수시기에 대하여 종래 판례는 표현설을 취하고 있으므로 타당하지 않은 지문이다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 과도한 거스름돈을 주는 것을 현장에서 알면서 받아 영득한 경우의 죄책은?

- ① 절도죄
- ② 사기죄
- ③ 횡령죄
- ④ 점유이탈물 횡령죄
- ⑤ 배임죄

정답 : ②

해설 : 판례에 의하면 사기죄가 성립하게 된다.

2. 판례에 의할 때 3자간 명의신탁에 의해 위탁받은 재물을 수탁자가 영득한 경우의 죄책은?

- ① 무죄
- ② 사기죄
- ③ 횡령죄
- ④ 점유이탈물 횡령죄
- ⑤ 배임죄

정답 : ③

해설 : 판례에 의하면 횡령죄가 된다.

3. 판례에 의할 때 계약명의신탁에 의해 위탁받은 재물을 수탁자가 영득한 경우의 죄책은?

- ① 무죄
- ② 사기죄
- ③ 횡령죄
- ④ 점유이탈물 횡령죄
- ⑤ 배임죄

정답 : ①

해설 : 판례에 의하면 무죄가 된다.

♣ 학습내용 정리

1. 판례는 잔전사기에 관하여 '매도인이 사실대로 고지하였다면 매수인이 그와 같이 초과하여 교부하지 아니하였을 것임은 경험칙상 명백하므로, 특별한 사정이 없는 한 신의칙상 고지의무를 지므로 사기죄에 해당한다'라고 하여 사기죄 긍정설의 입장이다.
2. 횡령행위 이후에 동일 재물에 대한 또다른 후행 횡령행위가 불가벌적인 사후행위가 되는지 별개의 횡령죄가 되는지에 대하여 논의가 있다. 이에 대하여는 ① 종래 판례와 전합의 소수의견은 횡령죄는 재물죄라는 점을 중시하여 후행 처분행위는 불가벌적 사후행위에 불과하다고 보고 있지만 ② 최근 전합의 다수의견은 후행 처분행위에 의해 새로운 위험을 추가하는 것이 아니라면 후행 처분행위는 이른바 불가벌적 사후행위에 해당하지만, 후행 처분행위가 새로운 위험을 추가하거나 선행 처분행위와는 무관한 방법으로 법익침해의 결과를 발생시키는 경우에는 별도로 횡령죄가 성립한다고 보고 있다.
3. 횡령죄의 기수시기에 대하여 종래의 판례는 일반적으로 표현설을 따르고 있다고 평가하지만, 최근의 판례는 횡령죄를 구체적 위험범으로 보면서 추상적 위험의 발생에 그친 경우에는 미수를 인정하고 있어 새로운 논의를 불러 일으키고 있다.

제31강 위탁매매와 횡령죄

♣ 학습목표

위탁매매와 횡령죄에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

위탁매매의 법적 성질

위탁매매와 횡령죄 및 배임죄

횡령죄의 공동정범의 요건과 장물죄의 성부

♣ 사전테스트

1. 위탁매매물의 판매대금 중 일부를 기망으로 영득한 경우에는 횡령죄가 성립한다.

정답 : O

해설 : 자신이 보관하고 있는 물건에 대한 것이므로 횡령죄가 성립한다.

2. 위탁매매물의 소유권과 판매대금의 소유권은 수탁자에게 있다.

정답 : X

해설 : 위탁매매물의 소유권과 판매대금의 소유권은 위탁자에게 있으므로 타당하지 않은 지문이다.

3. 횡령죄의 공동정범이 그 횡령물을 취득한다고 하여도 장물죄는 성립하지 않는다.

정답 : O

해설 : 재산죄 본범의 정범은 장물죄의 주체가 될 수 없으므로 타당한 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

甲은 乙로부터 고가의 의료기기 한 대를 팔아달라는 부탁을 받고 그 물건을 보관하던 중, 중개상 丙으로부터 매수인을 소개해 줄 테니 판매대금에 대하여 乙을 속이고 그 대금의 일부를 나누어 갖자는 제안을 받았다. 甲은 이를 수락하였고, 丙의 소개로 그 의료기기를 丁에게 1억원을 받고 팔았다. 甲은 丙과 모의한 대로 乙에게 판매대금으로 8천만원만 건네주었다. 그리고 甲과 丙은 남은 판매대금 2천만원을 각각 반씩 나누어 가졌다. 甲과 丙의 죄책은? (30점)

[해설]

I. 논점의 정리

사안에서 甲의 죄책과 관련하여 의료기기의 판매대금 중 2천만원을 영득한 행위에 대한 횡령죄와 배임죄 및 사기죄의 성부를 검토하고, 丙의 죄책과 관련하여 丙의 甲의 범죄에 대한 가담형태와 장물취득죄의 성부를 검토한다.

II. 甲의 죄책

1. 횡령죄와 배임죄의 성부

(1) 위탁매매의 처리

사안은 甲이 乙로부터 위탁판매를 의뢰받은 의료기기의 판매대금을 임의로 영득한 경우이다. 甲은 의료기기 판매대금이라는 금전수수를 수반하는 사무의 처리를 위임받은 자인데, 그가 사무처리 과정에서 취득한 금전을 누구의 소유로 볼 것인지에 따라 횡령죄 혹은 배임죄가 성립한다.

(2) 판례의 태도

판례는 '위탁매매에 있어서는 위탁품의 소유권은 위임자에게 속하고 그 판매대금은 다른 특약이나 특단의 사정이 없는 한 이를 수령함과 동시에 위탁자에게 귀속한다 할 것이므로 이를 사용 소비한 때에는 횡령죄가 구성된다'라고 하여 횡령죄설의 입장이다.

(3) 검토 및 사안의 해결

생각건대 위탁매매의 경우 상법 제103조에 따라 위탁매매인이 위탁자로부터 받은 물건은 물론이고 위탁매매로 인해 취득한 물건 등도 위탁자의 소유로 보아야 하므로 사안에서 위탁매매로 인하여 취득한 금전은 위탁자 乙의 소유라고 보아야 한다. 따라서 甲이 판매대금을 영득한 때에는 횡령죄가 성립한다.

2. 사기죄의 성립여부

사안에서 甲이 판매대금 1억원을 받고도 8천만원만 받은 것으로 기망하여 2천만원을 가진 것이 사기죄에 해당하는지 문제된다. 그러나 사기죄의 객체는 타인소유·타인점유물이므로 甲이 乙에게 건네주지 않은 2천만원은 甲이 보관한 것이므로 乙의 점유물이 아니고, 乙이 처분행위를 했다고 평가하기도 어려우므로 사기죄는 성립하지 않는다.

III. 丙의 죄책

1. 丙의 가담형태

(1) 정범과 공범의 구별

사안에서 甲의 횡령죄에 가담한 丙의 가담형태를 정범으로 보아야 하는지 공범으로 보아야 하는지 문제된다. 정범과 공범의 구별기준과 관련하여 종래 논의가 있었으나, 현재의 다수설과 판례는 행위지배설에 따라 이를 판단하고 있다.

(2) 검토 및 사안의 해결

사안에서 丙은 甲과 주관적으로 범행을 공모하고, 객관적으로 기능적인 역할분담을 하고 있으므로 기능적행위지배가 인정된다. 따라서 丙의 가담형태는 공동정범이다.

2. 횡령죄의 공동정범의 성립여부

(1) 甲에게 성립하는 횡령죄는 '위탁관계에 의하여 타인의 재물을 보관하는 자'가 주체가 되는 진정신분범이다. 그러나 丙에게는 그러한 신분이 없다. 여기서 丙에게 횡령죄의 공동정범이 성립할 수 있는지 문제된다.

(2) 형법 제33조 본문은 '비신분자가 신분자의 범죄에 가공한 경우에는 비신분자도 신분범의 공동정범, 교사범, 종범이 될 수 있다'고 함으로써 신분의 연대성을 규정하고 있다. 사안은 비신분자인 丙이 신분자인 甲의 범죄에 가담한 경우인바, 이 경우에는 제33조 본문에 의해 비신분자에게도 가담형태에 따라 신분범의 공범이 성립한다. 따라서 丙은 횡령죄의 공동정범의 죄책을 진다.

3. 장물취득죄의 성립여부

장물죄의 주체는 본범을 제외한 모든 자이고 정범에는 공동정범까지 포함된다. 따라서 丙은 횡령죄의 공동정범으로서 장물죄의 주체가 될 수 없으므로 甲으로부터 1천만원을 받을지라도 구성요건에 해당하지 않아 장물취득죄가 성립하지 않는다.

IV. 사안의 해결

(1) 甲은 위탁판매대금 중 2천만원을 영득하였는데 이는 위탁관계에 의하여 보관하는 乙의 재물을 영득한 것이므로 횡령죄가 성립한다. 그러나 2천만원은 乙의 점유물이 아니고 乙의 처분행위도 인정되지 않으므로 사기죄는 성립하지 않는다.

(2) 丙은 甲과 공모하고 실행행위를 분담하였으므로 공동정범이 된다. 그리고 제33조 본문에 의하여 비신분자인 丙에게도 횡령죄의 공동정범이 성립한다. 한편 丙은 횡령죄의 정범이므로 1천만원에 대해서는 장물취득죄가 성립하지 않는다.

관련판례

1. 위탁매매에서 판매대금을 소비한 사건

위탁매매에 있어서는 위탁품의 소유권은 위임자에게 속하고 그 판매대금은 다른 특약이나 특단의 사정이 없는 한 이를 수령함과 동시에 위탁자에게 귀속한다 할 것이므로 이를 사용 소비한 때에는 횡령죄가 구성된다.(대판 1986.6.24. 86도1000)

2. 위탁매매에 특약이 있는 사건

통상 위탁판매의 경우에 위탁판매인이 위탁물을 매매하고 수령한 금원은 위탁자의 소유에 속하여 위탁판매인이 함부로 이를 소비하거나 인도를 거부하는 때에는 횡령죄가 성립한다고 할 것이나, 위탁판매인과 위탁자간에 판매대금에서 각종 비용이나 수수료 등을 공제한 이익을 분배하기로 하는 등 그 대금처분에 관

하여 특별한 약정이 있는 경우에는 이에 관한 정산관계가 밝혀지지 않는 한 위탁물을 판매하여 이를 소비하거나 인도를 거부하였다 하여 곧바로 횡령죄가 성립한다고는 할 수 없다.(대판 1990.3.27. 89도813)

♣ 돌발퀴즈

위탁판매의 경우에 위탁판매인이 위탁물을 매매하고 수령한 금원은 위탁자의 소유에 속하여 위탁판매인이 함부로 이를 소비하거나 인도를 거부하는 때에는 항상 횡령죄가 성립한다.

정답 : X

해설 : 통상 위탁판매의 경우에 위탁판매인이 위탁물을 매매하고 수령한 금원은 위탁자의 소유에 속하여 위탁판매인이 함부로 이를 소비하거나 인도를 거부하는 때에는 횡령죄가 성립한다고 할 것이나, 위탁판매인과 위탁자간에 판매대금에서 각종 비용이나 수수료 등을 공제한 이익을 분배하기로 하는 등 그 대금처분에 관하여 특별한 약정이 있는 경우에는 이에 관한 정산관계가 밝혀지지 않는 한 위탁물을 판매하여 이를 소비하거나 인도를 거부하였다 하여 곧바로 횡령죄가 성립한다고는 할 수 없다.(대판 1990.3.27. 89도813)

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 위탁매매인이 판매대금을 영득한 경우의 죄책은?

- ① 사기죄
- ② 횡령죄
- ③ 배임죄
- ④ 점유이탈물횡령죄
- ⑤ 장물죄

정답 : ②

해설 : 판례에 의하면 횡령죄가 성립한다.

2. 정범과 공범의 구별학설 중 제한적 정범개념을 전제로 하는 학설은?

- ① 이익설
- ② 의사설
- ③ 동시설
- ④ 형식적 객관설
- ⑤ 행위지배설

정답 : ④

해설 : 제한적 정범개념을 전제로 하는 학설은 형식적 객관설이다.

3. 다음 중 장물죄의 주체가 될 수 있는 사람은?

- ① 합동절도범
- ② 절도죄의 공동정범
- ③ 절도죄의 직접정범
- ④ 절도죄의 교사범
- ⑤ 절도죄의 간접정범

정답 : ④

해설 : 절도죄의 교사범은 장물죄의 주체가 될 수 있다.

♣ 학습내용 정리

1. 판례는 '위탁매매에 있어서는 위탁품의 소유권은 위임자에게 속하고 그 판매대금은 다른 특약이나 특단의 사정이 없는 한 이를 수령함과 동시에 위탁자에게 귀속한다 할 것이므로 이를 사용 소비한 때에는 횡령죄가 구성된다'라고 하여 횡령죄설의 입장이다.
2. 정범과 공범의 구별기준과 관련하여 종래 논의가 있었으나, 현재의 다수설과 판례는 행위 지배설에 따라 이를 판단하고 있다.
3. 형법 제33조 본문은 '비신분자가 신분자의 범죄에 가공한 경우에는 비신분자도 신분범의 공동정범, 교사범, 종범이 될 수 있다'고 함으로써 신분의 연대성을 규정하고 있다.

제32강 명의신탁물의 횡령과 공범

♣ 학습목표

명의신탁물의 횡령과 공범에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

절도죄와 강도죄의 구별

명의신탁물의 횡령죄와 공범의 성립요건

강요죄의 성립요건

♣ 사전테스트

1. 절도죄와 강도죄의 구별은 폭행·협박의 사용여부에 있다.

정답 : O

해설 : 절도죄와 강도죄는 탈취죄라는 점에서는 동일하지만, 폭행·협박의 사용여부에 따라 구별되므로 타당한 지문이다.

2. 판례에 의하면 계약명의신탁의 경우에 수탁자가 신탁물을 영득하더라도 횡령죄나 배임죄는 성립하지 않는다.

정답 : O

해설 : 판례에 의하면 계약명의신탁의 경우에는 횡령죄나 배임죄가 성립하지 않으므로 타당한 지문이다.

3. 강요죄의 객체에는 법인이나 국가기관은 포함되지 않는다.

정답 : O

해설 : 강요죄의 객체는 폭행·협박의 대상인 자연인만으로 제한되므로 타당한 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

甲은 친구인 乙로부터 “丙이 송년회라도 하자며 술을 사겠다고 하니 같이 가자.”라는 전화를 받고, 자신의 승용차에 乙을 태우고 약 5킬로미터 가량 떨어진 노원역 교차로 부근으로 가서 丙을 만났다. 그러자 丙은, “사실 돈이 없다. 취객을 상대로 돈을 훔쳐 술 먹자.”라고 제의하였다. 甲은 농담을 하는 줄 알았으나, 乙과 丙이 그동안 몇 차례 취객을 상대로 절취행각을 한 사실을 알게 되었다. 甲은 “나는 그렇게까지 해서 술 마실 생각이 없다.”라고 거절하자, 乙과 丙은 “그럼 너는 승용차에 그냥 있어라.” 하고 떠났다.

乙과 丙은 마침 길바닥에 가방을 떨어뜨린 채 2~3미터 전방에서 구토하고 있는 취객을 발견하고, 乙은 그 취객을 발로 차 하수구로 넘어지게 하고 丙은 길에 떨어져 있던 가방에서 돈을 꺼냈다.

이를 지켜보던 사법경찰관 P1과 P2가 다가와 乙과 丙을 현행범으로 체포하려 하자 이 두 사람이 甲이 있는 승용차로 도망가다가 붙잡혔다. 경찰관들은 승용차 운전석에 있던 甲도 체포하여 신원을 조회한 결과 甲이 자동차 운전면허 정지기간 중인 자임을 알게 되었다.

당시 P1과 P2는 강절도범특별검거지시가 있어 순찰하다가 그 취객을 발견하고도 구호조치를 하지 않은 채 잠복근무 중, 乙과 丙이 범행하는 것을 기다렸다가 때마침 체포한 것이었다.

甲과 乙은 경찰에서 “우리들은 골프장을 건설하기 위해 수십억 원이 넘는 임야를 소유하고 있는데 왜 그런 짓을 하겠느냐.”라고 하면서 등기부와 매매가격 10억 원의 매매계약을 제시하였고, 丙은 “떨어진 지갑을 주웠을 뿐이다.”라고 변명하였다.

이에 P1은 임야의 매수 과정을 확인하기 위해 매도인 丁을 불러 조사한 결과, 丁의 이름으로 명의 신탁된 A의 임야를 甲과 乙에게 매도한 사실을 확인하고, 丁으로부터 매도 경위에 관한 자술서를 제출받았다.

계속해서 丁은, 甲과 乙이 자신을 설득하면서 ‘고위공직자 A가 부정 축재한 사실을 들어서 잘 알고 있다. 고소하지 못하도록 알아서 처리하겠다’고 말한 취지의 3자 간 대화를 녹음한 녹음테이프를 제출하였다.

뒤늦게 매도 사실을 안 A가 丁을 고소하려 하자, 甲은 A에게 휴대전화로 “고소를 포기해라. 부정 축재한 사실을 폭로할 수도 있다.”라는 문자메시지를 수회 반복하여 발송하였다. A는 이에 대해 별로 개의치 않았으나, 丁이 다칠 것을 염려하여 고소를 하지 않았다.

甲과 乙은 공판정에 제출된 녹음테이프에 관하여 “우리들은 녹음에 동의한 적도 없고, 성립의 진정도 부정한다.”라고 진술하자, 丁은 “내가 직접 녹음한 그 테이프가 맞다. 그러나 위 임야는 원래 내 땅이었다.”라고 범행을 부인하면서 A를 증인신청하였다.

한편, 증인 A는 경찰에서 한 1차 진술과는 달리 “그 땅은 내 땅이 아니고, 丁의 땅이다.”라고 허위의 진술을 하였다. 그러자 검사는 A를 불러 재번복하는 취지의 2차 진술조서를 작성하였다.

甲, 丙, 丁의 형사책임을 논하라.(부동산 관련 특별법 위반의 점은 제외함) (55점)

[해설]

1. 사안의 정리

甲, 丙 및 丁의 죄책을 사안에서 주어진 사건별 순서와 논리적 순서에 따라 먼저 丙의 죄책을 검토하고, 그 다음 丁의 죄책을 검토한 후 마지막으로 甲의 죄책을 검토한다.

2. 丙의 죄책

(1) 사안에서 丙은 乙과 함께 절도를 모의하고, 취객의 가방에서 돈을 탈취하였다. 일반적인 경우에는 丙은 乙과 함께 합동절도가 성립하겠지만, 사안의 경우에는 乙이 취객을 발로 차 하수구에 넣어뜨리고 있으므로 이에 대한 평가가 선행되어야 한다.

(2) 乙의 행위에 대한 평가

乙은 취객을 발로 차 하수구에 넣어지게 하고 있으므로 이러한 행위의 평가가 문제된다. 특히 폭행의 정도가 상대방의 저항을 불가능하게 할 정도라면 乙은 강도죄의 죄책을 질 수 있기 때문이다. 그러나 사안에서 취객은 이미 가방을 길바닥에 떨어뜨린 채 2~3미터 전방에서 구토하고 있었으므로 이러한 乙의 폭행이 가방을 강취하기 위한 직접적인 원인이 되었다고도 보기 어렵다. 따라서 乙은 폭행죄와 합동절도의 죄책을 진다.

(3) 丙의 행위에 대한 평가

사안에서 丙은 乙과 함께 절도를 모의하였지만, 취객에게 폭행을 할 것인가에 대한 의사적 연락은 나와 있지 않다. 따라서 丙은 자기가 모의한 합동절도로서의 책임만 진다.

3. 丁의 죄책

(1) 사안에서 丁은 A로부터 명의신탁 받은 임야를 甲과 乙에게 매도하고 있다. 이러한 경우에 丁의 죄책이 문제된다.

(2) 2자간 명의신탁의 경우에 수탁자의 임의처분에 대해서는 ① 부동산실명법 위반은 민법 제103조에 준하는 불법이 아니어서 수탁자는 보관자의 지위에 있으므로 횡령죄가 성립한다는 횡령죄설 ② 부동산실명법 위반은 민법 제103조에 준하므로 불법원인급여물에 대하여는 횡령죄가 성립할 수 없다는 무죄설 등이 대립하고 있으며, ③ 판례는 수탁자가 명의신탁물을 임의로 처분한 경우에는 횡령죄의 성립을 긍정하는 횡령죄설의 입장이다.

(3) 검토 및 사안의 해결

생각건대 부동산실명법을 위반한 명의신탁물은 불법원인급여물이 아니므로 횡령죄설이 타당하다. 따라서 사안에서 丁은 횡령죄가 성립한다. 그리고 시가가 10억원이 넘으므로 이는 특정경제범죄가중처벌등에관한법 제3조 1항 2호에 의하여 가중처벌된다.

4. 甲의 죄책

(1) 무면허운전행위에 대한 죄책

사안에서 甲은 운전면허 정지 중임에도 운전을 하였으므로 이는 도로교통법 제152조위반(무면허운전)죄에 해당된다.

(2) 乙과 丙이 취객에게 수표를 절취한 행위에 대한 甲의 죄책

1) 사안에서 甲은 乙과 丙이 절취범행을 하려 한다는 것을 알고 이에서 이탈하고 있다. 이러한 경우에 甲에게 공모공동정범으로서 죄책을 물을 수 있는가가 문제된다.

2) 공모공동정범이론을 논하기 위해서는 먼저 공모관계가 성립되어야 할 것이다. 그런데 사안에서 甲은 乙과 丙의 절도공모를 농담으로 알았으므로 이에 대한 공모가 있었다고 보기 어려워 공동정범이나 예비, 음모는 성립하지 않는다고 보아야 한다. 만약 사안에서 공모관계가 인정된다는 것을 전제로 甲의 죄책을 검토하면 아래와 같다.

3) 최근의 판례와 다수설은 공모공동정범을 인정함에 있어서 기능적 행위지배설을 따르고 있다. 따라서 모의와 실행과정에서 주모자나 본질적인 기여를 한 자만을 공동정범으로 파악하고 있다.

- 4) 사안에서 甲은 乙과 丙이 절도를 공모하는 부분에 대하여 주모자 역할이나 본질적인 기여를 하지 않았다. 따라서 甲은 乙과 丙의 합동절도에 대한 기능적 행위지배가 없으므로 甲의 절도 모의부분은 무죄가 된다.

(3) 丁의 횡령행위에 가담한 행위에 대한 죄책

- 1) 丁이 A의 임야를 매도한 행위는 위에서 살펴본 바와 같이 횡령죄에 해당한다. 이러한 횡령행위에 甲은 乙과 같이 ‘고위공직자 A가 부정 축재한 사실을 들어서 잘 알고 있다. 고소하지 못하도록 알아서 처리하겠다’라고 하면서 이에 가담하고 있다. 이러한 경우에 甲에게 횡령죄의 공동정범이 성립할 수 있는지가 문제된다.
- 2) 이에 대하여 판례는 ‘명의신탁물을 양수하거나 담보제공받는 자는 비록 그와 같은 사정을 알고 있다 하더라도 처음부터 수탁자와 짜고 이를 불법영득하기로 공모하지 아니한 이상 그 횡령죄의 공동정범이 될 수 없다’라고 하여 제한적으로 공동정범을 인정하고 있다. 사안에서는 甲과 乙은 丁과 짜고 임야를 영득하고 있으므로 甲은 횡령죄의 공동정범이 성립한다.

(4) 甲이 A에게 문자메세지를 보낸 행위에 대한 평가

- 1) 사안에서 甲은 A에게 “고소를 포기해라. 부정 축재한 사실을 폭로할 수도 있다.”라고 하면서 협박을 수단으로 권리행사를 방해하고 있다. 이러한 경우에 甲의 죄책에 대하여 강요죄와 협박죄가 문제된다.
- 2) 甲에게 강요죄의 성립여부가 문제되는 바 甲에게 강요죄가 성립하기 위해서는 ① 폭행 또는 협박을 수단으로 하여 ② 의무없는 일을 행하게 하거나 권리행사를 방해하고 ③ 양자 사이에 인과관계가 있어야 한다. 사안에서 甲과 乙이 협박을 하였지만 A는 이에 외포된 것이 아니라 丁이 처벌받을 것을 우려하여 고소를 하지 않고 있다. 따라서 강요죄의 기수가 되기 위해서는 폭행 또는 협박과 권리행사방해사이에 인과관계가 필요하지만, 사안에서는 인과관계가 인정되지 않으므로 甲은 강요죄의 미수범만 성립하게 된다.
- 3) 甲은 A를 협박하고 있는바 이러한 행위는 협박죄에 해당할 수 있다. 그런데 사안에서는 A가 외포되지 않았기 때문에 협박죄의 기수에 달했는지가 문제된다. 이에 대하여는 ① 협박죄를 위험범으로 보아 기수로 보자는 기수범설과 ② 협박죄를 침해범으로 보아 미수로만 보아야 한다는 미수범설이 대립하고 있지만, ③ 판례는 위험범설을 전제로 해악의 고지가 상대방에게 도달한 이상 기수범이 성립한다고 보고 있다. 따라서 협박죄는 그 본질이 위험범에 부합되므로 기수범설이 타당하며 이에 의하면 甲은 협박죄의 기수범에 해당한다.
- 4) 甲이 강요죄의 미수와 협박죄의 기수범이 성립한다고 할 때 양자의 죄수관계가 문제된다. 그러나 강요죄가 성립하는 한 협박죄는 이에 흡수된다고 보아야 하므로 甲에게는 강요죄의 미수범만이 성립한다.

5. 결 론

사안에서 ① 丙은 합동절도죄가 성립하고 ② 丁은 특경법위반(횡령)죄가 성립한다. 그리고 ③ 甲의 죄책은 도로교통법 제152조위반(무면허운전)죄, 특경법위반(횡령)죄의 공동정범, 강요죄의 미수범이 성립하고 각각의 범죄는 실체적 경합관계에 있다.

관련판례

1. 2자간 명의신탁 사건

[사실관계] 甲은 건물을 신축하여 원시취득한 후 乙 명의로 신탁하여 소유권보존등기를 경료하였는데, 丙은 명의신탁사실을 알고도 乙의 처분행위에 적극 가담하여 매매계약을 체결하고 丙의 처 丁 명의로 소유

권이전등기를 경료하였다. 그러나 이러한 처분행위는 부동산실권리자명의등기에관한법률에 의하여 명의신탁약정 및 이에 따라 행하여진 등기에 의한 물권변동이 무효로 된 후에 이루어졌다. 乙과 丙의 죄책은? [판결요지] 부동산을 소유자로부터 명의수탁받은 자가 이를 임의로 처분하였다면 명의신탁자에 대한 횡령죄가 성립하며, 그 명의신탁이 부동산실권리자명의등기에관한법률 시행 전에 이루어졌고 같은 법이 정한 유예기간 이내에 실명등기를 하지 아니함으로써 그 명의신탁약정 및 이에 따라 행하여진 등기에 의한 물권변동이 무효로 된 후에 처분행위가 이루어졌다고 하여 달리 볼 것이 아니다.(대판 2000.2.22. 99도5227)

2. 기능적 행위지배설 입장에서의 판례

[1] 형법 제30조의 공동정범은 공동가공의 의사와 그 공동의사에 기한 기능적 행위지배를 통한 범죄 실행이라는 주관적·객관적 요건을 충족함으로써 성립하는바, 공모자 중 구성요건 행위 일부를 직접 담당하여 실행하지 않은 자라도 경우에 따라 이른바 공모공동정범으로서의 죄책을 질 수도 있는 것이기는 하나, 이를 위해서는 전체 범죄에 있어서 그가 차지하는 지위, 역할이나 범죄 경과에 대한 지배 내지 장악력 등을 종합해 볼 때, 단순한 공모자에 그치는 것이 아니라 범죄에 대한 본질적 기여를 통한 기능적 행위지배가 존재하는 것으로 인정되는 경우여야 한다. [2] 그리고 이 경우, 범죄의 수단과 태양, 가담하는 인원과 그 성향, 범행 시간과 장소의 특성, 범행과정에서 타인과의 접촉 가능성과 예상되는 반응 등 제반 상황에 비추어, 공모자들이 그 공모한 범행을 수행하거나 목적 달성을 위해 나아가는 도중에 부수적인 다른 범죄가 파생되리라고 예상하거나 충분히 예상할 수 있는데도 그러한 가능성을 외면한 채 이를 방지하기에 족한 합리적인 조치를 취하지 아니하고 공모한 범행에 나아갔다가 결국 그와 같이 예상되던 범행들이 발생하였다면, 비록 그 파생적인 범행 하나하나에 대하여 개별적인 의사의 연락이 없었다 하더라도 당초의 공모자들 사이에 그 범행 전부에 대하여 암묵적인 공모는 물론 그에 대한 기능적 행위지배가 존재한다고 보아야 할 것이다. [3] 피고인이 노조원들의 폭행, 상해, 특수공무집행방해치상 등 범행들에 대하여 구체적으로 모의하거나 이를 직접 담당·실행한 바 없었더라도, 피고인이 파업투쟁에 가담하게 된 경위, 위 파업투쟁 및 폭력사태의 경위와 진행 과정, 그 과정에서 피고인의 지위 및 역할, 피고인이 작성한 문건의 내용 및 성격 등을 종합할 때, 위 각 범행에 대하여 암묵적인 공모는 물론 본질적 기여를 통한 기능적 행위지배가 있었다고 보아 그 공동정범으로 의율한 원심판단을 수긍한 사례.(대판 2010.12.23. 2010도7412)

3. 명의신탁물을 양수한 자의 책임

부동산의 등기명의수탁자가 명의신탁자의 승낙없이 이를 제3자에게 양도 또는 담보제공함으로써 횡령죄가 성립하는 경우에 그것을 양수하거나 담보제공받는 자는 비록 그와 같은 사정을 알고 있다 하더라도 처음부터 수탁자와 짜고 이를 불법영득하기로 공모하지 아니한 이상 그 횡령죄의 공동정범이 될 수 없다.(대판 1985.6.25. 85도1077)

4. 경찰관이 친구 채권 전화로 추심한 사건

[사실관계] 정보와 소속 경찰관 甲은 친구 乙을 만나 이야기 하던 중 A가 사업을 이유로 자신에게 돈을 빌려간 후 이를 갚지 않아 독촉을 하고 있지만 돈이 없다고 하면서 변제하지 않고 있다는 말을 듣고 그 자리에서 A에게 전화를 걸어 '나는 XX경찰서 정보과에 근무하는 형사다. B가 집안 동생인데 돈을 언제까지 해 줄 것이냐. 빨리 안 해주면 상부에 보고하여 문제를 삼겠다.'라고 말하였다. 하지만 A는 이를 무시하고 전화를 끊었다. 甲에게 협박죄의 기수범이 성립하는가?

[판결요지] [1] [다수의견] (가) 협박죄가 성립하려면 고지된 해악의 내용이 행위자와 상대방의 성향, 고지 당시의 주변 상황, 행위자와 상대방 사이의 친숙의 정도 및 지위 등의 상호관계, 제3자에 의한 해악을 고지한 경우에는 그에 포함되거나 암시된 제3자와 행위자 사이의 관계 등 행위 전후의 여러 사정을 종합하여 볼 때에 일반적으로 사람으로 하여금 공포심을 일으키게 하기에 충분한 것이어야 하지만, 상대방이 그에 의하여 현실적으로 공포심을 일으킬 것까지 요구하는 것은 아니며, 그와 같은 정도의 해악을 고지함으로써 상대방이 그 의미를 인식한 이상, 상대방이 현실적으로 공포심을 일으켰는지 여부와 관계없이 그로써 구성요건은 충족되어 협박죄의 기수에 이르는 것으로 해석하여야 한다. (나) 결국, 협박죄는 사람의 의사결정의 자유를 보호법익으로 하는 위험범이라 봄이 상당하고, 협박죄의 미수범 처벌조항은 해악의 고지가 현실적으로 상대방에게 도달하지 아니한 경우나, 도달은 하였으나 상대방이 이를 지각하지 못하였거나 고지된 해악의 의미를 인식하지 못한 경우 등에 적용될 뿐이다. [대법관 김영란, 박일환의 반대의견] (가) 해악의 고지에 의해 현실적으로 공포심을 일으켰는지 여부나 그 정도는 사람마다 다를 수 있다고 하더라도 이를 판단할 수 없다거나 판단을 위한 객관적인 척도나 기준이 존재하지 않는다고 단정할 것은 아니며, 사람

이 현실적으로 공포심을 일으켰는지 여부를 판단할 만한 객관적인 기준 및 개별 사건에서 쌍방의 입증과 그에 의하여 인정되는 구체적인 사정 등을 모두 종합하여, 당해 협박행위로 상대방이 현실적으로 공포심을 일으켰다는 점이 증명된다면 협박죄의 기수에 이르렀다고 인정하고, 이에 대한 증명이 부족하거나 오히려 상대방이 현실적으로 공포심을 일으키지 않았다는 점이 증명된다면 협박죄의 미수에 그친 것으로 인정하면 될 것이다. 기수에 이르렀는지에 대한 의문을 해결하기 어렵다고 하여 모든 경우에 기수범으로 처벌하는 것은 오히려 "의심스러울 때는 피고인의 이익으로"라는 법원칙 등 형사법의 일반원칙과도 부합하지 아니하며 형벌과잉의 우려를 낳을 뿐이다. (나) 결국, 현행 형법의 협박죄는 침해범으로서 일반적으로 사람으로 하여금 공포심을 일으킬 수 있는 정도의 해악의 고지가 상대방에게 도달하여 상대방이 그 의미를 인식하고 나아가 현실적으로 공포심을 일으켰을 때에 비로소 기수에 이르는 것으로 보아야 한다. [2] 정보보안과 소속 경찰관이 자신의 지위를 내세우면서 타인의 민사분쟁에 개입하여 빨리 채무를 변제하지 않으면 상부에 보고하여 문제를 삼겠다고 말한 사안에서, 객관적으로 상대방이 공포심을 일으키기에 충분한 정도의 해악의 고지에 해당하므로 현실적으로 피해자가 공포심을 일으키지 않았다 하더라도 협박죄의 기수에 이르렀다고 본 사례.(대판 2007.9.28. 2007도606 전합)

♣ 돌발퀴즈

인질강요죄의 객체인 제3자에는 국가기관이나 법인이 포함된다.

정답 : ○

해설 : 강요죄와는 달리 인질강요죄의 객체인 제3자에는 국가기관이나 법인이 포함되므로 타당한 지문이다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 절도죄와 강도죄의 차이점이 아닌 것은?

- ① 객체
- ② 행위태양
- ③ 탈취죄
- ④ 특수절도와 특수강도의 태양
- ⑤ 친족상도례의 적용

정답 : ③

해설 : 절도죄와 강도죄는 탈취죄라는 점에서 동일하다.

2. 강요죄의 설명 중 타당하지 않은 것은?

- ① 인질강요죄가 있다.
- ② 인질치상·치사죄가 있다.
- ③ 결과적 가중범의 미수를 처벌하는 규정이 있다.
- ④ 해방감경규정이 없다.
- ⑤ 제324조부터 제324조의6까지의 조문이 있다.

정답 : ④

해설 : 강요죄에는 해방감경규정이 있다.

3. 다음 협박죄에 대한 설명 중 타당하지 않은 것은?

- ① 반의사불벌죄이다.
- ② 미수처벌 규정이 있다.
- ③ 본질은 거동범에 가깝다.
- ④ 특수협박죄의 구성요건이 있다.
- ⑤ 판례에 의하면 협박죄의 미수범은 생겨나지 않는다.

정답 : ⑤

해설 : 판례는 협박죄를 위험범으로 보면서도 미수범을 인정하고 있다.

♣ 학습내용 정리

1. 2자간 명의신탁의 경우에 수탁자의 임의처분에 대해서는 ① 부동산실명법 위반은 민법 제103조에 준하는 불법이 아니어서 수탁자는 보관자의 지위에 있으므로 횡령죄가 성립한다는 횡령죄설 ② 부동산실명법 위반은 민법 제103조에 준하므로 불법원인급여물에 대하여는 횡령죄가 성립할 수 없다는 무죄설 등이 대립하고 있으며, ③ 판례는 수탁자가 명의신탁물을 임의로 처분한 경우에는 횡령죄의 성립을 긍정하는 횡령죄설의 입장이다.
2. 판례는 ‘명의신탁물을 양수하거나 담보제공받는 자는 비록 그와 같은 사정을 알고 있다 하더라도 처음부터 수탁자와 짜고 이를 불법영득하기로 공모하지 아니한 이상 그 횡령죄의 공동정범이 될 수 없다’라고 하여 제한적으로 공동정범을 인정하고 있다.
3. 강요죄가 성립하기 위해서는 ① 폭행 또는 협박을 수단으로 하여 ② 의무없는 일을 행하게 하거나 권리행사를 방해하고 ③ 양자 사이에 인과관계가 있어야 한다.
4. 협박죄의 기수시기에 대하여 판례는 위험범설을 전제로 해악의 고지가 상대방에게 도달한 이상 기수범이 성립한다고 보고 있다.

제33강 횡령죄의 기수시기

♣ 학습목표

횡령죄의 기수시기에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

경영상의 판단과 배임죄의 고의
횡령죄의 기수시기에 대한 고찰
로제-로자알 사건에 대한 해결

♣ 사전테스트

1. 회사대표이사의 경영상의 판단으로 회사의 손해가 발생한 경우에 회사대표이사에게 항상 배임죄가 성립하는 것은 아니다.

정답 : O

해설 : 경영상의 판단이 배임죄가 성립하기 위해서는 회사의 손해발생과 본인이나 제3자의 이익의 취득의 요건을 구비되어야 하므로 타당한 지문이다.

2. 현행 형법은 횡령죄의 미수범을 처벌하는 규정을 두고 있다.

정답 : O

해설 : 횡령죄는 본질상 미수를 인정하기 어렵지만 현행법은 미수범을 처벌하는 규정을 두고 있으므로 타당한 지문이다.

3. 현재 판례는 횡령죄의 미수범을 인정하고 있다.

정답 : O

해설 : 판례는 횡령죄를 위험범 내지는 구체적 위험범으로 보면서도 미수범을 인정하고 있으므로 타당한 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

주식회사 X의 대표이사인 甲은 X회사의 적자가 늘어나고 향후 상장폐지가 될 가능성이 높아 지자 수익 창출을 위한 새로운 사업을 도입이 필요하다고 판단하던 중 마침 고향 선배가 대표 이사인 주식회사 Y의 인수를 추진하였다. 甲은 인수에 필요한 내부보유자금이 거의 없고 이사회 의 적법한 결의도 없음에도 불구하고 회사를 살리기 위해서는 Y회사의 인수가 시급하다고 보고 X회사 명의로 Y회사의 주식을 적정가액인 5억원 보다 훨씬 고가인 12억원에 매입하였다. Y회사 의 인수로 X회사가 심각한 자금난에 빠지자. 甲은 해외로 도피하기 위하여 X회사로부터 위임받 아 사실상 지배·관리권과 대외적 처분권을 갖고 있던 4억원 상당의 X회사 소유의 별장을 매수 인에게 처분하기로 하고 계약금 4천만원을 받았다. 그러나 甲의 행각이 X회사의 법무팀장 A에 게 발각되어 결국 별장을 매수인에게 인도하지 못하였고, 甲은 X회사로부터 해고되고 말았다. 이에 앙심을 품은 甲은 친구 乙을 찾아가 야구방망이 등으로 A를 패달라고 부탁하였다. 甲의 부 탁을 승낙한 乙은 며칠 뒤 23:00경 A의 집 문 옆에서 A를 기다리던 중, 모자를 눌러쓰고 귀가 하던 A의 동생 B를 잘못 알고 소지하고 있던 야구방망이로 B의 등을 내리쳤으나, 사건현장을 지나가던 동네주민 C와 얼굴이 마주치자 황급히 도망하였고, B는 乙의 구타로 전치 3주의 상 처를 입었다.

甲과 乙의 죄책을 논하시오. (60점)

[해설]

1. 사안의 정리

사안에서의 甲과 乙의 죄책을 ① Y회사의 주식을 고가로 매입한 행위 ② 별장을 매매하러 고 계약한 행위 ③ A를 패달라고 하였으나 B를 상해입힌 행위의 순서로 검토한다.

2. Y회사 주식을 고가로 매입한 부분

- (1) 사안에서 甲이 Y회사의 주식을 고가로 매입한 것이 배임죄가 성립되는지는 甲에게 배임 죄의 고의가 있었는지에 달려 있으므로 이를 살펴본다.
- (2) 경영상의 판단을 이유로 배임죄의 고의를 인정할 수 있는지는 문제된 경영상의 판단에 이르게 된 경위와 동기, 판단대상인 사업의 내용, 기업이 처한 경제적 상황, 손실발생의 개연성과 이익획득의 개연성 등 제반 사정에 비추어 자기 또는 제3자가 재산상 이익을 취득한다는 인식과 본인에게 손해를 가한다는 인식하의 의도적 행위임이 인정되는 경우 인지에 따라 개별적으로 판단하여야 한다.
- (3) 사안에서 甲이 Y회사의 주식을 고가로 매입한 부분에 대하여 甲은 회사를 살리려는 의도 만 있었다고 판단되므로 甲에게는 배임죄가 성립하지 않는다.

3. 별장을 매매하기 위하여 계약한 부분

- (1) 사안에서 甲은 회사의 별장을 자신의 해외도피자금으로 활용하기 위하여 매매하고 있으 므로 횡령죄의 고의와 실행의 착수는 인정할 수 있다. 문제가 되는 것은 횡령죄의 기수가 되는가이다.
- (2) 횡령죄는 자기가 보관하는 타인소유물을 영득하는 범죄로서 외관상 점유이전이 없다. 따 라서 영득의사를 가지는 즉시 횡령죄가 성립한다고 할 수도 있지만, 형법은 횡령죄의 미 수범 처벌규정을 두고 있으므로 횡령죄의 기수시기를 언제로 볼 것인지에 대하여 논의가 있다.

- (3) 횡령죄의 기수시기에 대하여는 ① 행위자의 불법영득의사가 외부에 인식될 수 있도록 객관적으로 표현되었을 때 기수가 된다는 표현설 ② 행위자의 불법영득의사가 객관적으로 실현된 때에 기수가 된다는 실현설이 대립하고 있다.
- (4) 판례는 일반적으로 표현설을 따르고 있다고 평가하지만, 일부 판례의 경우에는 표현설의 입장인지 실현설의 입장인지 논의가 있는 판례도 있다. 그러나 최근의 판례는 횡령죄를 위험범으로 보면서 '여기서 위험범이라는 것은 횡령죄가 개인적 법익침해를 전제로 하는 재산범죄의 일종임을 감안할 때 단순히 사회 일반에 대한 막연한 추상적 위험이 발생하는 것만으로는 부족하고 소유자의 본권 침해에 대한 구체적 위험이 발생하는 수준에 이를 것을 요한다'라고 판시하여 횡령행위를 하였으나 추상적 위험에 그친 경우에는 횡령죄의 미수를 인정하고 있다.
- (5) 횡령죄의 본질상 미수를 인정하기는 어렵지만, 현행법에 미수처벌 규정을 두고 있으므로 판례와 같이 횡령죄를 구체적 위험범으로 보면서 추상적 위험만 발생하고 구체적 위험에 이르지 않은 경우에는 미수범을 인정하는 것이 현행법에 보다 부합되는 타당한 해석이다.
- (6) 이러한 구체적 위험범설에 의하면 사안에서 甲은 횡령죄의 미수범의 죄책을 진다.

4. A를 패주라고 하였으나 B를 상해 입힌 행위

(1) 乙의 죄책

- 1) 乙이 야구방망이로 B를 상해 입힌 행위는 위험한 물건을 휴대하여 상해 입힌 사안이므로 폭처법 제3조 제1항 위반의 구성요건에 해당한다.
- 2) 乙은 A를 상해하려고 하였으나 B를 A로 착오한 것은 구체적 사실의 착오 중 객체의 착오에 해당하므로 어떠한 부합설에 따르더라도 B에 대한 고의가 인정되므로 乙은 B에 대한 폭처법상의 특수상해죄의 기수범이 성립한다.

(2) 甲의 죄책

- 1) 사안에서 甲은 乙에게 야구방망이 등으로 A를 상해하라고 하였으나, 乙은 객체의 착오로 인하여 B를 상해하고 있다. 이러한 사안에서 교사자인 甲의 죄책에 대하여 논의가 있다.
- 2) 이에 대하여 ① 법정적 부합설은 구체적 사실의 착오의 경우에는 객체의 착오와 방법의 착오의 효과가 동일하므로 발생사실인 살인기수의 교사범으로서의 책임을 인정하지만 ② 구체적 부합설은 ㉠ 의도한 객체에 대한 살인미수죄의 교사범과 발생사실에 대한 단독의 과실치사의 상상적 경합을 인정하는 견해 ㉡ 의도한 객체에 대한 살인미수죄의 교사범만 인정하는 견해 ㉢ 발생사실에 대한 살인기수의 교사의 책임을 인정하는 견해가 대립하고 있다.
- 3) 이러한 정범의 객체의 착오가 있는 경우에 교사자의 책임에 대하여는 법정적 부합설에 의하면 결론이 간명하지만, 구체적 부합설에 의하면 어떠한 견해를 따르더라도 일정한 비판이 따를 수밖에 없다. 형법은 보호할 가치가 있는 법익을 침해하는 데에 중점이 있으므로 교사자의 의도한 동가치의 법익침해가 발생하였다면 이에 대하여 책임을 묻는 것이 타당하므로 법정적 부합설이 타당하다.
- 4) 이러한 법정적 부합설에 따르면 사안에서 甲은 B에 대한 특수상해죄의 기수범의 교사의 책임을 진다.

5. 사안의 해결

(1) 甲의 죄책

甲은 횡령죄의 미수와 B에 대한 특수상해죄의 기수의 교사의 죄책을 부담한다.

(2) 乙의 죄책

乙은 B에 대한 특수상해죄의 기수범의 죄책을 부담한다.

관련판례

1. 회사자금 대여와 경영상의 판단

[1] 회사의 이사 등이 타인에게 회사자금을 대여하면서 그 타인이 이미 채무변제능력을 상실하여 그에게 자금을 대여하거나 지급보증할 경우 회사에 손해가 발생하리라는 점을 충분히 알면서 이에 나아갔거나, 충분한 담보를 제공받는 등 상당하고도 합리적인 채권회수조치를 취하지 아니한 채 만연히 대여해 주었다면, 그와 같은 자금대여나 지급보증을 타인에게 이익을 얻게 하고 회사에 손해를 가하는 행위로서 회사에 대하여 배임행위가 되고, 회사의 이사는 단순히 그것이 경영상의 판단이라는 이유만으로 배임죄의 죄책을 면할 수는 없으며, 이러한 이치는 그 타인이 자금지원 회사의 계열회사라 하여 달라지지 않는 것이고, 한편 경영상의 판단을 이유로 배임죄의 고의를 인정할 수 있는지는 문제된 경영상의 판단에 이르게 된 경위와 동기, 판단대상인 사업의 내용, 기업이 처한 경제적 상황, 손실발생의 개연성과 이익획득의 개연성 등 제반 사정에 비추어 자기 또는 제3자가 재산상 이익을 취득한다는 인식과 본인에게 손해를 가한다는 인식하의 의도적 행위임이 인정되는 경우인지에 따라 개별적으로 판단하여야 한다. [2] 회사의 대표이사 등이 다른 회사들에 운영자금 명목으로 회사자금을 대여함으로써 회사에 손해를 입힌 사안에서, 위 자금대여 행위가 합리적 경영인이 객관적 근거를 가지고 적합한 절차에 따라 경영상 판단에 의하여 한 것이라고 보기는 어려운데도, 업무상배임의 고의를 인정할 수 없다고 한 원심판단에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례.(대판 2010.10.28. 2009도1149)

2. 횡령죄의 미수를 인정한 판례

[사실관계] A는 2007년부터 B가 자금을 대 구입한 강원도 평창 소재 임야의 소나무 39그루와 팔배나무 1그루를 관리해왔다. A는 2008년 4월 처분권한이 없는데도 C에게 나무 40그루를 1억9000만원에 매도하는 계약을 체결하고, 그 자리에서 계약금 명목으로 5000만원을 받아 임의로 사용하였다. 이후 수목에 대해 A 혹은 C명의로 명인방법 등의 조치를 취한 적도 없었고 수목을 토지에서 분리·보관하거나 분리·반출한 사실도 없는 상황에서 이 사실을 알게 된 B에 의하여 고소되었다.

[판결요지] [1] 횡령죄는 소유권 등 본권이 침해될 위험성이 있으면 그 침해의 결과가 발생하지 않더라도 성립하는 위험범인데, 여기서 위험범이라는 것은 횡령죄가 개인적 법익침해를 전제로 하는 재산범죄의 일종임을 감안할 때 단순히 사회 일반에 대한 막연한 추상적 위험이 발생하는 것만으로는 부족하고 소유자의 본권 침해에 대한 구체적 위험이 발생하는 수준에 이를 것을 요한다. [2] 피고인이 피해자로부터 위탁받아 식재·관리하여 오던 나무들을 피해자 모르게 제3자에게 매도하는 계약을 체결하고 제3자로부터 계약금을 수령한 상태에서 피해자에게 적발되어 위 계약이 더 이행되지 아니하고 무위로 그친 경우, 피고인의 행위를 횡령기수가 아니라 횡령미수에 해당한다고 본 사례.(대판 2012. 8.17. 2011도91113)

♣ 돌발퀴즈

배임죄가 성립하기 위해서는 타인에게 손해를 발생시키는 것만으로 충분하다.

정답 : X

해설 : 배임죄가 성립하기 위해서는 손해발생 이외에 이익의 취득이라는 요건이 필요하므로 타당하지 않은 지문이다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 배임죄에 대한 설명 중 타당하지 않은 것은?

- ① 횡령죄와 처벌이 동일하다.
- ② 횡령죄와는 객체에서 차이가 있다.
- ③ 업무상 가중 처벌하는 것도 횡령죄와 동일하다.
- ④ 미수를 처벌하는 것도 횡령죄와 동일하다.
- ⑤ 배임죄의 객체는 장물이 될 수 있다.

정답 : ⑤

해설 : 배임죄의 객체는 재산상의 이익이므로 장물이 될 수 없다.

2. 구체적 부합설과 법정적 부합설이 결론을 달리하는 착오유형은?

- ① 구체적 사실의 착오 중 객체의 착오
- ② 구체적 사실의 착오 중 방법의 착오
- ③ 추상적 사실의 착오 중 객체의 착오
- ④ 추상적 사실의 착오 중 방법의 착오
- ⑤ 인과관계의 착오

정답 : ②

해설 : 구체적 부합설과 법정적 부합설은 구체적 사실의 착오 중 방법의 착오의 경우에 그 결론을 달리한다.

3. A는 2007년부터 B가 자금을 대 구입한 강원도 평창 소재 임야의 소나무 39그루와 팔배나무 1그루를 관리해왔다. A는 2008년 4월 처분권한이 없는데도 C에게 나무 40그루를 1억9000만원에 매도하는 계약을 체결하고, 그 자리에서 계약금 명목으로 5000만원을 받아 임의로 사용하였다. 이후 수목에 대해 A 혹은 C명의로 명인방법 등의 조치를 취한 적도 없었고 수목을 토지에서 분리,보관하거나 분리,반출한 사실도 없는 상황에서 이 사실을 알게 된 B에 의하여 고소되었다. 판례에 의할 경우 A의 죄책은?

- ① 점유이탈물 횡령죄 ② 횡령죄의 기수
- ③ 횡령죄의 미수 ④ 배임죄의 기수
- ⑤ 배임죄의 미수

정답 : ③

해설 : 판례에 의하면 사안은 횡령죄의 미수가 된다.

♣ 학습내용 정리

1. 경영상의 판단을 이유로 배임죄의 고의를 인정할 수 있는지는 문제된 경영상의 판단에 이르게 된 경위와 동기, 판단대상인 사업의 내용, 기업이 처한 경제적 상황, 손실발생의 개연성과 이익획득의 개연성 등 제반 사정에 비추어 자기 또는 제3자가 재산상 이익을 취득한다는 인식과 본인에게 손해를 가한다는 인식하의 의도적 행위임이 인정되는 경우인지에 따라 개별적으로 판단하여야 한다.
2. 횡령죄의 기수시기에 대하여는 ① 행위자의 불법영득의사가 외부에 인식될 수 있도록 객관적으로 표현되었을 때 기수가 된다는 표현설 ② 행위자의 불법영득의사가 객관적으로 실현된 때에 기수가 된다는 실현설이 대립하고 있다.
3. 최근의 판례는 횡령죄를 위험범으로 보면서 ‘여기서 위험범이라는 것은 횡령죄가 개인적 법익침해를 전제로 하는 재산범죄의 일종임을 감안할 때 단순히 사회 일반에 대한 막연한 추상적 위험이 발생하는 것만으로는 부족하고 소유자의 본권 침해에 대한 구체적 위험이 발생하는 수준에 이를 것을 요한다’라고 판시하여 횡령행위를 하였으나 추상적 위험에 그친 경우에는 횡령죄의 미수를 인정하고 있다.

제34강 정보와 영업비밀 관련범죄

♣ 학습목표

정보의 재물성과 영업비밀에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

정보의 재물성과 관련범죄의 검토

영업비밀과 배임죄의 성부

부작위범의 경우의 정범과 공범의 구별

♣ 사전테스트

1. 현재 판례에 의하면 정보는 절도죄의 객체가 되지 못한다.

정답 : O

해설 : 타당한 지문이다.

2. 영업비밀을 누설한 경우에는 업무상 배임죄가 성립할 수 있다.

정답 : O

해설 : 영업비밀을 누설한 경우에도 업무상 배임죄가 성립할 수 있으므로 타당한 지문이다.

3. 현재 판례는 작위범에 가담한 부작위범에 대하여 방조범만을 인정한다.

정답 : O

해설 : 타당한 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

A선박회사 연구개발부의 직원인 甲은 입사할 때 회사의 영업비밀에 관한 사항은 회사 밖으로 유출하지 않을 것을 서약하였다. 甲은 A선박회사가 甲을 포함한 많은 연구 인력과 비용을 들여 개발한 고부가가치 선박 설계도면을 A선박회사에서 甲에게 제공한 업무용 컴퓨터에 저장·보관하고 있었다. 甲은 위 설계도면을 빼내 외국에 있는 경쟁 선박회사에 팔아 한몫 잡기로 마음먹고, 회사의 A3 복사지 2장에 위 설계도면을 출력하여 자신의 집에 보관하였다. 그 후, 甲은 직접 외국으로 가서 위 설계도면을 사용하겠다는 외국의 경쟁 선박회사와 접촉하여 이를 팔기로 합의한 뒤, 경쟁 선박회사 사장에게 3억원을 받고 위 설계도면을 건네주었다. 한편 甲의 상사인 연구개발부장 乙은 甲의 모든 행위를 처음부터 알고도 아무런 조치를 취하지 아니하였다. 甲과 乙의 죄책은? (30점)

참조조문

부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제18조(벌칙) ① 다음 각호의 1에 해당하는 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

1. 기업의 임원 또는 직원으로서 그 기업에 유용한 기술상의 영업비밀을 정당한 이유없이 외국에서 사용하거나 외국에서 사용될 것임을 알고 제3자에게 누설한 자

[해설]

I. 사안의 정리

사안에서 甲의 죄책과 관련하여 ① 甲이 경쟁 선박회사로 빼내기 위해 설계도면을 출력하여 자신의 집에 보관한 행위 ② 甲이 경쟁선박회사 사장에게 3억원을 받고 설계도면을 건네준 행위로 나누어 검토하고, 乙의 죄책과 관련하여 ③ 甲의 범행에 부작위로 가담한 부분의 죄책을 검토한다.

II. 甲의 죄책

1. 설계도면을 출력하여 자신의 집에 보관한 행위

(1) 정보의 재물성 여부

- 1) 甲이 선박의 설계와 관련된 정보를 빼낸 것이 재산죄의 재물에 해당되는 것인가가 문제된다. 사안에서 문제되는 영업비밀 즉 정보 자체는 관리가능한 유체물이나 동력도 아니므로 재물에 해당하지 않는다.
- 2) 판례는 이와 유사한 사안에서 ‘컴퓨터에 저장되어 있는 정보 그 자체는 유체물이라고 볼 수도 없고, 물질성을 가진 동력도 아니므로 재물이 될 수 없다’라고 하여 정보의 재물성을 부인하고 있다. 따라서 정보 자체는 재물에 해당하지 않으므로 甲의 행위는 절도죄나 업무상 횡령죄에 해당하지 않는다.

(2) 출력한 문서에 대한 절도죄의 성립여부

사안에서 甲이 컴퓨터에 저장된 정보를 출력하여 생성한 문서는 회사보관문서가 아니라 甲이 가지고 갈 목적으로 업무와 관계없이 새로이 생성시킨 문서라 할 것이므로, 이는 회사소유의 문서라고 할 수 없어 이를 가지고 간 행위가 회사소유의 문서를 절취한 것으로 볼 수는 없다.

(3) 복사지에 대한 절도죄의 성립여부

甲은 회사의 복사지를 절취한 것으로 볼 수 있지만, 복사지는 그 경제적 가치가 경미하여 사회적 상당성 이론에 의해 구성요건해당성이 부정되거나 사회상규에 위배되는 않는 행위로서 정당행위에 해당하므로 위법성이 조각된다.

2. 설계도면을 넘겨 준 행위

(1) 업무상 배임죄의 성립여부

사안의 경우 甲은 업무상 타인의 사무처리자이고, 경쟁업체에 영업비밀을 유출하는 행위는 회사와의 신임관계를 저버리는 행위이다. 그리고 배임행위로서 임무에 위배하여 재산상의 이익을 취득하고 회사에 손해를 가했다. 따라서 회사의 영업비밀을 사외로 유출하지 않을 것을 서약한 甲이 경제적인 대가를 얻기 위하여 경쟁업체에 영업비밀을 유출하는 행위는 회사와의 신임관계를 저버리는 행위로서 업무상 배임죄를 구성한다.

(2) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반죄의 성립여부

사안에서 甲은 행위주체로서 기업의 임원 또는 직원이고, 그 기업에 유용한 기술상의 영업비밀을 정당한 이유 없이 이를 제3자에게 누설하였으므로, 부정경쟁방지및영업비밀보호에 관한 법률위반죄에 해당한다.

3. 甲의 죄책

甲은 업무상배임죄 및 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반죄가 성립하며, 두 죄는 상상적 경합관계에 있다.

III. 乙의 죄책

1. 논의점

사안에서 乙은 甲의 배임행위 등을 알고 있음에도 불구하고 아무런 조치를 취하지 않았다. 이러한 乙의 부작위가 형법상 부작위범에 해당할 수 있는지를 검토한다.

2. 부작위범의 성립 여부

사안에서 乙에게 부진정부작위범이 성립되기 위하여는 보증인적 지위가 인정되어야 한다. 이러한 보증인적 지위를 인정하기 위해서는 ① 구성요건적 상황 ② 작위의무 ③ 개별적 행위가능성이 있어야 한다. 사안에서는 ①과 ③의 요건은 구비되어 있으므로 ②의 작위의무만이 문제된다. 그러나 乙은 회사와의 계약에 의하여 甲의 상사로서 甲에 대한 감독의무가 있으므로 계약에 의한 작위의무를 인정할 수 있다. 따라서 乙은 보증인적 지위에 있으며, 그럼에도 불구하고 부작위하였으므로 부작위범이 성립한다.

3. 부작위범의 경우 정범과 공범의 구별

(1) 논의점

사안에서 乙은 甲의 작위범행에 부작위로 가담하고 있다. 사안과 같이 작위범에게 의사연락없이 부작위로 가담한 자를 정범으로 볼 것인지 아니면 공범으로 볼 것인지에 대하여 논의가 있다.

(2) 견해의 대립

이에 대하여는 ① 작위와 부작위를 구별할 필요없이 작위범에 있어서 구별기준을 그대로 적용하면 된다는 작위·부작위 구별 불요설 ② 작위와 부작위의 형태로 수인이 범행에 참가한 경우에 부작위에 의해 참가한 자는 원칙적으로 종범이 된다는 원칙적 종범설 ③ 원칙적

으로 정범이 되지만, 일정한 경우에는 제한적으로 종범이 성립한다는 원칙적 정범설 등이 대립하고 있다.

(3) 판례의 태도

판례는 ‘은행지점장 배임방조 사건’에서 ‘은행지점장이 정범인 부하직원들의 범행을 인식하면서도 그들의 은행에 대한 배임행위를 방치하였다면 업무상 배임죄의 방조범이 성립한다’라고 하여 작위의무 있는 자의 편면적 가담에 대하여 부작위에 의한 방조를 인정하고 있어 일응 원칙적 종범설을 택하였다고 볼 수 있다.

(4) 결 언

생각건대 ① 편면적인 작위의무자의 부작위는 행위지배를 인정하기 어려워 정범성을 인정할 수 없고 ② 부작위범에 대하여 임의적 감경을 하지 않는 현행법하에서는 부작위로 가담한 자를 방조범으로 처벌함으로써 입법상의 불비를 해석론상 보완할 수 있으므로 원칙적 종범설이 타당하다.

(5) 사안의 적용

사안에서 乙의 죄책을 원칙적 종범설에 따라 판단하면 업무상배임죄 및 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반죄의 방조범이 성립한다.

IV. 사안의 해결

- (1) 甲은 설계도면 정보 및 복사지에 대한 절도죄는 성립하지 않지만, 영업비밀에 대한 업무상 배임죄 및 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반죄의 상상적 경합범이 성립한다.
- (2) 乙에게는 甲에게 성립한 범죄에 대해 부작위에 의한 방조범이 성립하므로, 업무상 배임죄 및 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반죄에 대한 방조범의 죄책을 진다.

관련판례

1. 컴퓨터 속의 정보를 종이에 출력하여 가져간 사건

[사실관계] A주식회사는 직물원단고무코팅시스템을 독자적으로 개발하였는데, 동 회사의 직원 甲은 업무용으로 지급한 노트북 컴퓨터에 저장되어 있는 직물원단고무코팅시스템의 설계도면과 공정도를 A2용지에 2장을 출력하여 가지고 나왔다. 甲의 죄책은?

[판결요지] [1] 절도죄의 객체는 관리 가능한 동력을 포함한 ‘재물’에 한한다 할 것이고, 또 절도죄가 성립하기 위해서는 그 재물의 소유자 기타 점유자의 점유 내지 이용가능성을 배제하고 이를 자신의 점유 하에 배타적으로 이전하는 행위가 있어야만 할 것인바, 컴퓨터에 저장되어 있는 ‘정보’ 그 자체는 유체물이라고 볼 수도 없고, 물질성을 가진 동력도 아니므로 재물이 될 수 없다 할 것이며, 또 이를 복사하거나 출력하였다 할지라도 그 정보 자체가 감소하거나 피해자의 점유 및 이용가능성을 감소시키는 것이 아니므로 그 복사나 출력 행위를 가지고 절도죄를 구성한다고 볼 수도 없다. [2] 피고인이 컴퓨터에 저장된 정보를 출력하여 생성한 문서는 피해 회사의 업무를 위하여 생성되어 피해 회사에 의하여 보관되고 있던 문서가 아니라, 피고인이 가지고 갈 목적으로 피해 회사의 업무와 관계없이 새로이 생성시킨 문서라 할 것이므로, 이는 피해 회사 소유의 문서라고 볼 수는 없다 할 것이어서, 이를 가지고 간 행위를 들어 피해 회사 소유의 문서를 절취한 것으로 볼 수는 없다.(대판 2002.7.12. 2002도745)

2. 영업비밀 유출한 사건

[사실관계] S전자의 직원인 甲은 기업의 비밀을 사외에 유출하지 않기로 서약하였음에도 불구하고 경제적 대가를 받기로 하고 S전자의 영업비밀인 64M SDRAM 회로도를 KSTC 사무실 내의 워크스테이션에 입력한 후 데이터 커트리지 테이프에 저장하여 대만의 NTC회사에 그 일부의 출력도면을 건네주었다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 배임죄는 타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배하는 행위으로써 재산상 이익을 취득하거

나 제3자로 하여금 이를 취득하게 하여 본인에게 손해를 가함으로써 성립하는바, 이 경우 그 임무에 위배하는 행위라 함은 사무의 내용, 성질 등 구체적 상황에 비추어 법률의 규정, 계약의 내용 혹은 신의칙상 당연히 할 것으로 기대되는 행위를 하지 않거나 당연히 하지 않아야 할 것으로 기대되는 행위를 함으로써 본인과 사이의 신임관계를 저버리는 일체의 행위를 포함하는 것이므로 기업의 영업비밀을 사외로 유출하지 않을 것을 서약한 회사의 직원이 경제적 대가를 얻기 위하여 경쟁업체에 영업비밀을 유출하는 행위는 피해자와의 신임관계를 저버리는 행위로서 업무상 배임죄를 구성한다.(대판 1999.3.12. 98도4704)

3. 은행장이 부하직원의 배임행위 방지한 사건

[사실관계] 은행장 甲은 그의 부하직원 乙・丙이 부정한 방법으로 A주식회사에 대하여 자금유통의 편의를 봐주고 있는 사실을 발견하였음에도 불구하고 이를 방지하였다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 형법상 방조는 작위에 의하여 정범의 실행행위를 용이하게 하는 경우는 물론, 직무상의 의무가 있는 자가 정범의 범죄행위를 인식하면서도 그것을 방지하여야 할 제반조치를 취하지 아니하는 부작위로 인하여 정범의 실행행위를 용이하게 하는 경우에도 성립된다 할 것이므로 은행지점장이 정범인 부하직원들의 범행을 인식하면서도 그들의 은행에 대한 배임행위를 방지하였다면 배임죄의 방조범이 성립된다.(대판 1984.11.27. 84도1906)

♣ 돌발퀴즈

관리가능성설은 유체물과 관리가능한 동력을 재물로 본다.

정답 : X

해설 : 관리가능성설은 관리가능한 유체물과 동력을 재물로 보므로 타당하지 않은 지문이다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. A주식회사는 직물원단고무코팅시스템을 독자적으로 개발하였는데, 동 회사의 직원 甲은 업무용으로 지급한 노트북 컴퓨터에 저장되어 있는 직물원단고무코팅시스템의 설계도면과 공정도를 A2용지에 2장을 출력하여 가지고 나왔다. 판례에 의할 때 甲의 죄책은? ?

- ① 정보에 대한 절도죄
- ② A2용지에 대한 절도죄
- ③ 출력문서에 대한 절도죄
- ④ 비밀침해죄
- ⑤ 무죄

정답 : ⑤

해설 : 판례에 의하면 무죄가 된다.

2. S전자의 직원인 甲은 기업의 비밀을 사외에 유출하지 않기로 서약하였음에도 불구하고 경제적 대가를 받기로 하고 S전자의 영업비밀인 64M SDRAM 회로도를 KSTC 사무실 내의 워크스테이션에 입력한 후 데이터 커트리지 테이프에 저장하여 대만의 NTC회사에 그 일부의 출력도면을 건네주었다. 甲의 죄책은?

- ① 횡령죄
- ② 업무상 횡령죄
- ③ 배임죄
- ④ 업무상 배임죄
- ⑤ 무죄

정답 : ④

해설 : 판례에 의하면 업무상 배임죄가 된다.

3. 은행장 甲은 그의 부하직원 乙・丙이 부정한 방법으로 A주식회사에 대하여 자금유통의 편의를 봐주고 있는 사실을 발견하였음에도 불구하고 이를 방치하였다. 甲의 죄책은?

- ① 직무유기죄
- ② 업무상횡령죄
- ③ 업무상배임죄
- ④ 업무상횡령죄의 방조범
- ⑤ 업무상배임죄의 방조점

정답 : ⑤

해설 : 판례에 의하면 업무상배임죄의 방조범이 된다.

♣ 학습내용 정리

1. 판례는 ‘컴퓨터에 저장되어 있는 정보 그 자체는 유체물이라고 볼 수도 없고, 물질성을 가진 동력도 아니므로 재물이 될 수 없다’라고 하여 정보의 재물성을 부인하고 있다.
2. 컴퓨터에 저장된 정보를 출력하여 생성한 문서는 회사보관문서가 아니라 업무와 관계없이 새로이 생성시킨 문서라 할 것이므로, 이는 회사소유의 문서라고 할 수 없어 이를 가지고 간 행위가 회사소유의 문서를 절취한 것으로 볼 수는 없다.
3. 회사의 영업비밀을 사외로 유출하지 않을 것을 서약한 甲이 경제적인 대가를 얻기 위하여 경쟁업체에 영업비밀을 유출하는 행위는 회사와의 신임관계를 저버리는 행위로서 업무상 배임죄를 구성한다.
4. 판례는 ‘은행지점장 배임방조 사건’에서 ‘은행지점장이 정범인 부하직원들의 범행을 인식하면서도 그들의 은행에 대한 배임행위를 방치하였다면 업무상 배임죄의 방조범이 성립한다’라고 하여 작위의무 있는 자의 편면적 가담에 대하여 부작위에 의한 방조를 인정하고 있어 일응 원칙적 종범설을 택하였다고 볼 수 있다.

제35강 부진정결과적가중범의 죄수판단

♣ 학습목표

부진정결과적가중범의 죄수판단에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

특수공무집행방해치상죄의 성립요건

부진정결과적가중범의 죄수판단

공모공동정범과 공모관계로부터의 이탈의 관계

♣ 사전테스트

1. 부진정결과적가중범은 중한 결과를 과실에 의한 경우뿐만 아니라 고의에 의하여 발생시킨 경우를 포함하는 범죄이다.

정답 : O

해설 : 부진정결과적가중범의 개념에 따른 타당한 지문이다.

2. 특수공무집행방해치상죄는 부진정결과적가중범이다.

정답 : O

해설 : 특수공무집행방해치상죄는 3년 이상의 징역형이 법정형이므로 형법상의 상해죄인 징역 7년 이하의 형보다 형량이 무거우므로 부진정결과적가중범이다.

3. 공모관계의 이탈이 인정되기 위해서는 다른 공범자의 실행의 착수가 있기 이전에 이탈을 할 필요는 없다.

정답 : X

해설 : 공모관계의 이탈이 인정되기 위해서는 다른 공모자의 실행의 착수가 있기 전에 이탈하여야 하므로 타당하지 않은 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

휴대폰을 생산하는 K전자주식회사의 입사동기생 甲, 乙, 丙은 회사 개발팀에 배치를 받으면서 회사의 영업비밀과 관련한 사항을 회사 밖으로 유출하지 않을 것을 서약하였다. K회사의 경쟁업체 H전자의 상무이사 丁은 甲을 만나 4억을 제시하면서 휴대폰 제조비밀을 입수해 올 것을 제안하였다. 이를 승낙한 甲은 혼자서는 자신이 없어 같은 입사동기인 乙과 丙에게 전화를 걸어 범행을 함께 하여 대가를 분배하자고 권유하였다. 마침 주식폭락으로 돈을 탕진한 乙과 丙은 甲의 계획에 적극 찬동하면서 각자가 해야 할 역할을 분담하는 등 구체적인 범행계획을 세웠다.

다음 날 계획한대로 甲과 丙은 회사의 전 직원이 퇴근한 후 밤11시에 회사 앞에 도착하였다. 그러나 개발실 책임자인 乙은 개발실 금고의 비밀번호를 甲과 丙의 휴대폰에 문자로 송부한 후 양심의 가책을 느껴 더 이상의 가담행위를 포기하고 현장에 나타나지 않았다. 甲과 丙은 乙을 기다리다가 포기하고 乙 없이 결행하기로 마음을 바꾸어 乙이 알려준 비밀번호를 이용하여 금고에 보관되어 있는 메모리카드를 가지고 나왔다. 이들이 개발실을 나오는 순간 경보장치가 작동하였고, 사설경비업체 직원 A와 B가 현장에 출동하였다. A가 甲과 丙의 뒤를 쫓는 사이 B는 회사 안의 상태를 점검하러 들어갔다가 금고문이 열린 것을 사진으로 촬영하고 이 사실을 업무 일지에 기록해 두었다.

한편 A는 甲과 丙이 각기 자신의 차량을 타고 도망가는 것을 따라 가다가 丙의 차량 번호를 암기하여 112에 신고하였고, 신고를 받고 출동한 경찰관 C는 K회사로부터 약 5킬로미터 떨어진 곳에서 丙의 차량을 발견하고 근처에 잠복하여 있다가 편의점에서 나와 차를 타려는 丙을 체포하려고 하였다(체포과정에서의 위법은 없는 것으로 함). 그 순간 丙이 편의점에서 사온 소주병으로 C에게 전치 2주의 상해를 입힌 후 다시 차를 타고 도망을 갔다. 약속한 장소에서 만난 甲과 丙은 메모리카드에 저장된 정보를 甲의 개인용 노트북에 저장한 다음 丁을 불러내어 메모리카드를 현금 4억과 교환하였다.

甲, 乙, 丙, 丁의 죄책은?(특별법위반은 논외로 함) (60점)

[해설]

I. 사안의 정리

사안의 甲, 乙, 丙 및 丁의 죄책을 정범과 공범의 순서 및 중한 범죄의 순서에 입각하여
① 丙의 죄책 ② 甲의 죄책 ③ 乙의 죄책 ④ 丁의 죄책의 순서로 검토한다.

II. 丙의 죄책

1. 甲과 함께 메모리 카드를 탈취한 부분의 죄책

丙은 甲과 함께 야간에 회사에 침입하여 메모리카드를 가지고 나온바, 이는 특수절도인 합동절도에 해당하며 야간주거침입절도는 이에 흡수된다.

2. 경찰관 C를 소주병으로 상해를 입힌 부분의 죄책

(1) 준강도 및 강도상해죄의 성립여부

사안에서 丙이 준강도가 성립하기 위해서는 절도의 실행에 착수한 이후 완료가 되기 이전에 체포를 면탈할 목적으로 폭행을 가하여야 하지만, 사안의 경우에는 계속 추격됨이 없어서 절도범행이 완료된 이후에 범행현장으로부터 5킬로미터나 떨어진 장소에서 폭행을 한 경우이므로 준강도 및 강도상해죄는 성립하지 아니한다.

(2) 특수공무집행방해치상죄의 성립

사안에서 丙이 소주병으로 경찰관 C를 상해하고 있는바 이는 특수공무집행방해치상죄와 개정 형법 제258조의2 제1항의 특수상해죄에 해당할 수 있다.¹²⁾ 그러나 두죄의 죄수와 관련하여서는 ① 다수설은 두죄의 상상적 경합을 인정하지만 ② 판례는 고의범보다 형량이 더 무거운 특수공무집행방해치상죄만을 인정한다. 이러한 판례에 의하면 丙은 특수공무집행방해치상죄가 성립한다.

3. 메모리 카드를 넘겨준 부분에 대한 죄책

- (1) 丙은 회사의 일원으로서 영업비밀을 丁에게 넘겨주고 있는 바 이는 회사의 업무에 대한 배신행위로 손해를 끼치고 이익을 얻고 있으므로 이는 업무상배임죄에 해당한다.
- (2) 丙에게 배임수재죄의 성립여부가 문제되지만 회사업무 그 자체에 대한 부정한 청탁이 있었다고는 보기 어려우므로 배임수재죄는 성립하지 않는다.

4. 丙의 죄책

丙은 합동절도, 특수공무집행방해치상죄, 업무상배임죄가 성립하며 각 실체적 경합관계에 있다.

III. 甲의 죄책

- (1) 甲은 丙과 함께 야간에 회사에 침입하여 메모리카드를 가지고 나와 이를 丁에게 넘겨주고 있는바 이러한 행위는 丙과 같은 논리에 의하여 ① 특수절도죄 ② 업무상 배임죄가 성립한다.
- (2) 그리고 ① 丙이 경찰관 C를 상해한 부분에 대하여는 丙이 준강도가 성립하지 않으므로 甲도 준강도죄나 강도치상죄가 성립하지 않고 ② 丙의 특수공무집행방해치상죄에 대한 부분은 의사의 연락이 없는 丙의 독자적인 행위이므로 甲은 책임지지 아니한다.

IV. 乙의 죄책

1. 논의점

乙은 甲 그리고 丙과 합동절도와 업무상 배임을 모의하였으나 이를 실행하지 않고 중도에서 이탈하고 있다. 이러한 경우에 ① 공모공동정범이 성립할 수 있는지 ② 공모관계로 부터의 이탈이 인정될 있는지에 대하여 논의가 있다.

2. 공모공동정범의 성립 가능성

공모공동정범이 성립할 수 있는가에 대하여 긍정설과 부정설의 대립이 있었으나, 현재의 학설과 판례는 기능적 행위지배설의 입장에서 공모공동정범을 인정하고 있다. 사안의 경우에 乙은 甲, 丙과 범행을 모의하고, 특히 개발설 책임자로서 금고의 비밀번호를 알려주고 있는 바 이는 범행에 대한 본질적 기여로서 공동정범이 성립할 수 있는 기능적행위지배의 정범표지로 보아야 할 것이다.

3. 공모관계로 부터의 이탈의 문제

12) 종래 특수상해죄는 폭처법에 있었으나 2016.1.6. 해당 조문이 삭제되고, 2016.1.6. 형법에 특수상해죄가 신설되었다. <형법> 제258조의2 (특수상해) ① 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제257조제1항 또는 제2항의 죄를 범한 때에는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다. ② 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제258조의 죄를 범한 때에는 2년 이상 20년 이하의 징역에 처한다. ③ 제1항의 미수범은 처벌한다. [본조신설 2016.1.6]

乙에게 공모공동정범이 성립한다고 할 때, 사안에서는 양심의 가책을 느껴 더 이상의 가담 행위를 포기하고 있는바 이러한 乙의 행위가 공모관계로부터 이탈했다고 평가받을 수 있는가가 문제된다. 종래 이탈의 요건에 대하여 논의가 있었으나, 판례는 ① 실행의 착수 이전에 ② 자기의 기능적 행위지배를 제거하였을 때 공모관계에서 이탈된다고 본다. 이러한 판례의 입장에 따르면 乙은 자기의 기능적 행위지배를 제거하고 있지 않으므로 공모관계로 부터의 이탈은 인정되지 않는다. 따라서 乙은 甲과 丙의 합동절도와 업무상배임죄에 대한 공동정범으로서의 책임을 진다.

4. 경찰관 C를 상해한 부분의 죄책

이는 공모의 범위를 초과한 경우이므로 乙은 이에 대하여는 책임지지 아니한다.

5. 乙의 죄책

乙은 합동절도에 대한 공동정범, 업무상배임죄의 공동정범으로서의 죄책을 진다.

V. 丁의 죄책

1. 문제의 제기

사안에서 丁은 甲에게 4억원의 금전을 제시하면서 회사의 영업비밀을 유출하도록 하고 있다. 이러한 丁의 행위와 관련하여 ① 甲의 업무상배임행위에 대한 공동정범의 성립여부 ② 회사의 업무담당자로서의 신분이 없는 丁의 죄책과 처벌이 문제된다.

2. 공동정범의 성립여부

丁은 甲이 근무하는 회사와 경쟁관계에 있는 회사의 상무이사로서 甲의 배임행위에 의하여 이익을 얻거나 그와 밀접한 관련이 있는 자이다. 이러한 丁이 甲의 업무상배임죄의 공동정범이 성립하기 위해서는 판례는 ‘업무상배임죄의 실행으로 인하여 이익을 얻게 되는 수익자 또는 그와 밀접한 관련이 있는 제3자를 배임의 실행행위자와 공동정범으로 인정하기 위해서는 실행행위자의 행위가 피해자인 본인에 대한 배임행위에 해당한다는 것을 알면서도 소극적으로 그 배임행위에 편승하여 이익을 취득한 것만으로는 부족하고, 실행행위자의 배임행위를 교사하거나 또는 배임행위의 전과정에 관여하는 등으로 배임행위에 적극 가담할 것을 필요로 한다’라고 하고 있는데, 사안에서는 丁이 교사행위 등을 통해 적극가담하고 있으므로 공동정범이 성립한다.

3. 공범과 신분

(1) 사안에서 丁은 甲이 업무상배임죄를 범하는 행위에 공동정범으로 가담하고 있는바, 이중 신분법인 업무상배임죄에 신분관계가 없는 丁이 가담한 경우에 丁의 범죄의 성립범위와 과형에 대하여 논의가 있다.

(2) 제33조의 해석에 대한 논의

제33조의 본문과 단서의 해석과 관련하여 ① 본문은 진정신분범의 성립과 처벌을 규정한 것이고, 단서는 부진정신분범의 성립과 처벌을 규정한 것이라고 보는 다수설과 ② 본문은 진정신분범 및 부진정신분범의 성립을 규정하고 진정신분범의 처벌을 규정한 것이고, 단서는 부진정신분범의 처벌을 규정한 것이라고 보는 판례가 대립하고 있다.

(3) 결론 및 사안의 해결

생각건대 범죄의 성립과 처벌은 일치하는 것이 바람직하다는 점을 고려하면 다수설의 입장이 타당하다. 따라서 이러한 다수설의 입장에 따르면 丁은 배임죄의 공동정범의 죄책을 지게 된다.

관련판례

1. 음주단속 경찰관 차로 들이받은 사건

[사실관계] 甲은 승용차를 운전하던 중 음주단속을 피하기 위하여 위험한 물건인 승용차로 단속 경찰관 乙을 들이받아 乙의 공무집행을 방해하고 乙에게 상해를 입게 하였다. 판례에 의할 때 甲의 죄책은? (참고로 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 제3조 집단·흉기 등 상해죄의 형량은 3년 이상의 징역이며, 특수공무집행방해치상죄의 형량도 3년 이상의 징역이다)

[판결요지] [1] 기본범죄를 통하여 고의로 중한 결과를 발생하게 한 경우에 가중처벌하는 부진정결과적 가중범에서, 고의로 중한 결과를 발생하게 한 행위가 별도의 구성요건에 해당하고 그 고의범에 대하여 결과적 가중범에 정한 형보다 더 무겁게 처벌하는 규정이 있는 경우에는 그 고의범과 결과적 가중범이 상상적 경합관계에 있지만, 위와 같이 고의범에 대하여 더 무겁게 처벌하는 규정이 없는 경우에는 결과적 가중범이 고의범에 대하여 특별관계에 있으므로 결과적 가중범만 성립하고 이와 범조경합의 관계에 있는 고의범에 대하여는 별도로 죄를 구성하지 않는다. [2] 직무를 집행하는 공무원에 대하여 위험한 물건을 휴대하여 고의로 상해를 가한 경우에는 특수공무집행방해치상죄만 성립할 뿐, 이와는 별도로 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반(집단·흉기 등 상해)죄를 구성하지 않는다.(대판 2008.11.27. 2008도7311) ※ 본 판례는 형법 개정이전의 폭처법과 관련된 판례이지만, 개정형법상의 특수상해죄와 그 법리가 동일하므로 법리만을 참조하시기 바랍니다.

2. 영업비밀 유출한 사건

[사실관계] S전자의 직원인 甲은 기업의 비밀을 사외에 유출하지 않기로 서약하였음에도 불구하고 경제적 대가를 받기로 하고 S전자의 영업비밀인 64M SDRAM 회로도를 KSTC 사무실 내의 워크스테이션에 입력한 후 데이터 커트리지 테이프에 저장하여 대만의 NTC회사에 그 일부의 출력도면을 건네주었다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 배임죄는 타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배하는 행위로서 재산상 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 이를 취득하게 하여 본인에게 손해를 가함으로써 성립하는바, 이 경우 그 임무에 위배하는 행위라 함은 사무의 내용, 성질 등 구체적 상황에 비추어 법률의 규정, 계약의 내용 혹은 신의칙상 당연히 할 것으로 기대되는 행위를 하지 않거나 당연히 하지 않아야 할 것으로 기대되는 행위를 함으로써 본인과의 사이의 신임관계를 저버리는 일체의 행위를 포함하는 것이므로 기업의 영업비밀을 사외로 유출하지 않을 것을 서약한 회사의 직원이 경제적 대가를 얻기 위하여 경쟁업체에 영업비밀을 유출하는 행위는 피해자와의 신임관계를 저버리는 행위로서 업무상 배임죄를 구성한다.(대판 1999.3.12. 98도4704)

3. 수익자 등의 배임죄의 공동정범 성립요건에 관한 판례

업무상배임죄의 실행으로 인하여 이익을 얻게 되는 수익자 또는 그와 밀접한 관련이 있는 제3자를 배임의 실행행위자와 공동정범으로 인정하기 위해서는 실행행위자의 행위가 피해자인 본인에 대한 배임행위에 해당한다는 것을 알면서도 소극적으로 그 배임행위에 편승하여 이익을 취득한 것만으로는 부족하고, 실행행위자의 배임행위를 교사하거나 또는 배임행위의 전과정에 관여하는 등으로 배임행위에 적극 가담할 것을 필요로 한다.(대판 1999.7.23. 99도1911)

4. 제33조의 해석에 대한 판례

신분관계가 없는 자가 그러한 신분관계에 있는 자와 공모하여 위 상호신용금고법위반죄를 저질렀다면, 그러한 신분관계가 없는 자에 대하여는 형법 제33조 단서에 의하여 형법 제355조 제2항에 따라 처단하여야 할 것인바, 그러한 경우에는 신분관계가 없는 자에게도 일단 업무상배임으로 인한 상호신용금고법 제39조 제1항 제2호 위반죄가 성립한 다음 형법 제33조 단서에 의하여 중한 형이 아닌 형법 제355조 제2항에 정한 형으로 처벌되는 것이다.(대판 1997.12.26. 97도2609)

♣ 돌발퀴즈

부진정결과적가중범과 고의범의 형량이 동일한 경우에 판례는 상상적 경합을 인정한다.

정답 : X

해설 : 부진정결과적가중범과 고의범의 형량이 동일한 경우에는 판례는 부진정결과적가중범만 인정하므로 타당하지 않은 지문이다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 다음 중 부진정결과적가중범이 아닌 범죄는?

- ① 중상해죄
- ② 현주건조물방화치사죄
- ③ 현주건조물일수치상죄
- ④ 특수공무집행방해치상죄
- ⑤ 상해치사죄

정답 : ⑤

해설 : 상해치사죄는 부진정결과적가중범이 아니다.

2. 甲은 승용차를 운전하던 중 음주단속을 피하기 위하여 위험한 물건인 승용차로 단속 경찰관 乙을 들이받아 乙의 공무집행을 방해하고 乙에게 상해를 입게 하였다. 판례에 의할 때 甲의 죄책은?

- ① 특수상해죄
- ② 공무집행방해치상죄
- ③ 특수공무집행방해치상죄와 특수상해죄의 실체적 경합
- ④ 특수공무집행방해치상죄와 특수상해죄의 상상적 경합
- ⑤ 특수공무집행방해치상죄

정답 : ⑤

해설 : 판례에 의하면 특수공무집행방해치상죄만 성립한다.

3. 은행원이 아닌 자가 은행원의 횡령행위에 가담한 경우에 판례의 태도는?

- ① 처벌되지 않는다.
- ② 횡령죄의 공동정범이 성립하고, 횡령죄의 공동정범으로 처벌된다.
- ③ 업무상횡령죄의 공동정범이 성립하고, 횡령죄의 공동정범으로 처벌된다.
- ④ 업무상횡령죄의 공동정범이 성립하고, 업무상 횡령죄의 공동정범으로 처벌된다.
- ⑤ 횡령죄의 공동정범이 성립하고, 업무상횡령죄의 공동정범으로 처벌된다.

정답 : ③

해설 : 판례에 의하면 업무상횡령죄의 공동정범이 성립하고, 횡령죄의 공동정범으로 처벌된다.

♣ 학습내용 정리

1. 부진정결과적가중범과 고의범의 형량이 동일한 경우의 죄수관계에 대하여 ① 다수설은 두 죄의 상상적 경합을 인정하지만 ② 판례는 부진정결과적가중범을 특별관계로 보아 동죄의 성립만을 인정한다.
2. 공모관계에서의 이탈의 요건에 대하여 논의가 있었으나, 판례는 ① 실행의 착수 이전에 ② 자기의 기능적행위지배를 제거하였을 때 공모관계에서 이탈된다고 본다.
3. 판례는 ‘업무상배임죄의 실행으로 인하여 이익을 얻게 되는 수익자 또는 그와 밀접한 관련이 있는 제3자를 배임의 실행행위자와 공동정범으로 인정하기 위해서는 실행행위자의 행위가 피해자인 본인에 대한 배임행위에 해당한다는 것을 알면서도 소극적으로 그 배임행위에 편승하여 이익을 취득한 것만으로는 부족하고, 실행행위자의 배임행위를 교사하거나 또는 배임행위의 전과정에 관여하는 등으로 배임행위에 적극 가담할 것을 필요로 한다’라고 하고 있다.

제36강 장물의 동일성과 거스름돈

♣ 학습목표

장물의 동일성과 거스름돈에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

장물의 범위

거스름돈과 장물

준강도죄의 기수시기에 대한 논거

♣ 사전테스트

1. 장물죄는 사후종범이다.

정답 : O

해설 : 장물죄는 재산범죄로 인한 재물과 관련된 죄이므로 사후종범으로서의 성격을 지니므로 타당한 지문이다.

2. 재산범죄가 아닌 뇌물로 받은 재물은 장물이 아니다.

정답 : O

해설 : 장물은 재산범죄로 취득한 재물이어야 하므로 뇌물로 받은 재물은 장물이 될 수 없다.

3. 재산범죄로 취득한 재산상의 이익도 장물이 될 수 있다.

정답 : X

해설 : 장물은 재산범죄로 취득한 재물이어야 하므로 재산상 이익은 장물이 될 수 없다.

♣ 강의내용

[설문]

甲은 절취한 100만원권 자기앞수표로 디지털카메라를 30만원에 구입하고 거스름돈으로 현금 70만원을 받았다. 그리고 甲은 이러한 사정을 알고 있는 乙에게 카메라와 거스름돈 중 일부인 현금 30만원을 주고, 乙은 이를 받았다. 이어서 甲은 이러한 사정을 알고 있는 丙과 함께 유흥업소에서 술을 마신 후 남은 현금 40만원으로 술값 등을 지불하였다. 한편 유흥업소 종업원인 丁은 절도할 고의로, 甲이 벗어 놓은 상의의 주머니를 뒤지던 중 甲에게 발각되자 아무 것도 훔치지 못하고 도주하면서 체포를 면탈하기 위하여 甲에게 폭행을 가하였다.

1. 乙과 丙의 행위가 장물취득죄에 해당하는가에 대하여 판단하십시오. (10점)
2. 丁의 행위가 준강도죄의 기수범인가 또는 미수범인가에 대하여 논거를 제시하여 판단하십시오. (10점)

[해설]

[1. 문 해설 (10점)]

1. 논의점

장물은 재산범죄로 취득한 재물이다. 사안에서 절취한 자기앞수표가 다른 형태로 乙과 丙에게 제공되고 있는바 이들에 대한 장물성을 검토하여 乙과 丙의 장물취득죄 성립여부를 검토한다.

2. 카메라의 장물성

장물은 ‘재산범죄로 취득한 재물 그 자체’이어야 하므로 대체장물은 장물이 될 수 없는 것이 원칙이다. 따라서 사안에서 乙이 취득한 카메라는 대체장물이므로 장물이 될 수 없다.

3. 거스름돈 30만원의 장물성

- (1) 자기앞수표는 그 액면금을 즉시 지급받을 수 있는 등 현금에 대신하는 기능을 가지고 거래상 현금과 동일하게 취급되고 있는 점에서 자기앞수표는 현금과 동일한 금전으로 취급하여야 한다. 이러한 금전이 사안처럼 다른 형태의 금전으로 바뀔 경우에 장물성을 인정할 것인가에 대하여 논의가 있다.
- (2) 이에 대하여는 ① 금전은 금전 자체는 별다른 의미가 없고 금액에 의하여 표시되는 금전적 가치가 의미가 있으므로 다른 금전의 형태로 바뀔 경우에도 금전인 이상 장물이 될 수 있다는 긍정설 ② 가치가 중요시하다고 하여 가치의 동일성을 물건의 동일성으로 파악하는 것은 유추금지원칙에 반하는 것이므로 장물이 될 수 없다는 부정설 등이 대립하고 있다. ③ 판례는 금전을 다른 금전으로 교환하거나 예금을 한 후에 인출한 경우에도 장물성을 인정하고 있다.
- (3) 생각건대 금전은 가치가 중요하므로 다른 금전의 형태로 바뀌더라도 장물성을 인정하여야 하고, 이는 절취한 금전의 일부분만이 다른 금전으로 바뀔 경우에도 동일하다고 보아야 하므로 사안에서 30만원은 장물성을 유지한다.

4. 술값지불의 장물성

사안에서 甲이 丙과 함께 술을 마시고 술값을 지불한 것은 재산상의 이익에 불과하다. 따라서 丙이 취득한 것은 재물이 아니므로 이는 장물이 될 수 없다.

5. 사안의 해결

사안에서 乙이 카메라를 취득한 부분은 장물죄가 성립되지 아니하며, 30만원의 금전을 취득한 부분은 장물취득죄가 성립한다. 그리고 丙이 얻은 것은 재산상의 이익에 불과하므로 장물취득죄가 성립하지 아니한다.

[2. 문 해설 (10점)]

1. 준강도죄의 기수범이라는 입장

丁의 행위가 준강도죄의 기수범이라는 입장은 기본적으로 ① 준강도의 기수여부는 폭행·협박을 기준으로 판단해야 한다고 보아 ② 준강도의 행위태양이 폭행·협박이므로 절취행위를 기준으로 기수·미수를 논하는 것은 잘못이며 ③ 강도살인죄나 강도상해죄의 경우에도 재물취득여부는 기수시기에 영향을 미치지 못하므로 준강도도 동일하게 보아야 한다는 점을 논거로 한다.

2. 준강도죄의 미수범이라는 입장

丁의 행위가 준강도죄의 미수범이라는 입장은 기본적으로 ① 준강도의 기수여부는 절도의 기수·미수를 기준으로 판단해야 한다고 보아 ② 준강도는 기본적으로 재물죄이며 ③ 강도죄는 재물탈취가 기수의 요건인데 준강도죄의 기수를 폭행·협박으로 결정하게 되면 재물을 탈취하지 못하고 폭행만 하게 되면 기수가 성립되게 되어 처벌의 불균형이 있다는 점을 논거로 한다.

3. 사안의 해결

사안에서 丁의 행위는 준강도의 미수로 파악하는 것이 타당하다. 위에 언급한대로 준강도죄는 기본적으로 재산죄이며, 재물탈취가 미수에 그친 경우에도 기수범으로 처벌된다면 불법이 중한 강도미수보다도 더 무겁게 처벌되는 불합리한 점이 있기 때문이다. 이러한 이유 때문에 종래의 판례는 폭행·협박행위기준시설을 따랐으나 최근 전합판례는 이를 재물취득시설로 변경하였다. 따라서 丁의 행위는 준강도의 미수(제335조, 제342조)에 불과하다.

관련판례

1. 금전을 예금했다 찾은 사건

[사실관계] A주식회사의 과장 甲은 거래처로부터 물품대금으로 교부받아 보관중이던 약속어음 액면 합계 8억원을 영득할 의사로 이를 할인 의뢰할 권한이 없음에도 그 권한이 있는 것처럼 가장하여 乙에게 할인을 의뢰하여, 乙로부터 그 할인금 명목으로 금 7억원을 자기앞수표와 현금으로 교부받아 은행에 예치하였다가 다시 현금으로 인출하였다. 한편 丙은 甲으로부터 그가 위와 같이 취득한 현금 중 금 9,500만원을 보관하여 달라는 부탁을 받고서 이를 교부받아 자신의 집에 보관하였다. 甲과 丙의 죄책은?

[판결요지] 장물이라 함은 재산범죄로 인하여 취득한 물건 그 자체를 말하고 그 장물의 처분대가는 장물성을 상실하는 것이지만, 금전은 고도의 대체성을 가지고 있어 다른 종류의 통화와 쉽게 교환할 수 있고, 그 금전 자체는 별다른 의미가 없고 금액에 의하여 표시되는 금전적 가치가 거래상 의미를 가지고 유통되고 있는 점에 비추어 볼 때, 장물인 현금을 금융기관에 예금의 형태로 보관하였다가 이를 반환받기 위하여 동

일한 액수의 현금을 인출한 경우에 예금계약의 성질상 인출된 현금은 당초의 현금과 물리적인 동일성은 상실되었지만 액수에 의하여 표시되는 금전적 가치에는 아무런 변동이 없으므로 장물로서의 성질은 그대로 유지된다고 봄이 상당하고, 자기앞수표도 그 액면금을 즉시 지급받을 수 있는 등 현금에 대신하는 기능을 가지고 거래상 현금과 동일하게 취급되고 있는 점에서 금전의 경우와 동일하게 보아야 한다.(대판 2000.3.10. 98도2579)

2. 준강도의 기수시기를 절도행위의 기수 여부로 판단한다고 본 전합

[사실관계] 甲과 乙은 합동하여 양주를 절취할 목적으로 장소를 물색하던 중, 2003. 12. 9. 06 : 30경 부산 부산진구 부전2동 소재 5층 건물 중 2층 丙이 운영하는 주점에 이르러, 乙은 1층과 2층 계단 사이에서 甲과 무전기로 연락을 취하면서 망을 보고, 甲은 위 주점의 잠금장치를 뜯고 침입하여 위 주점 내 진열장에 있던 양주 45병 시가 1,622,000원 상당을 미리 준비한 바구니 3개에 담고 있던 중, 주점의 종업원 丁에게 발각되었다. 甲은 양주를 그대로 둔 채 출입문을 열고 나오다가 丁이 甲을 붙잡자, 체포를 면탈할 목적으로 丁에게 폭행을 하고 달아났다. 甲의 죄책은?

[판결요지] [1] [다수의견] 형법 제335조에서 절도가 재물의 탈환을 항거하거나 체포를 면탈하거나 죄적을 인멸할 목적으로 폭행 또는 협박을 가한 때에 준강도로서 강도죄의 예에 따라 처벌하는 취지는, 강도죄와 준강도죄의 구성요건인 재물탈취와 폭행·협박 사이에 시간적 순서상 전후의 차이가 있을 뿐 실질적으로 위법성이 같다고 보기 때문인바, 이와 같은 준강도죄의 입법 취지, 강도죄와의 균형 등을 종합적으로 고려해 보면, 준강도죄의 기수 여부는 절도행위의 기수 여부를 기준으로 하여 판단하여야 한다. [별개의견] 폭행·협박행위를 기준으로 하여 준강도죄의 미수범을 인정하는 외에 절취행위가 미수에 그친 경우에도 이를 준강도죄의 미수범이라고 보아 강도죄의 미수범과 사이의 균형을 유지함이 상당하다. [반대의견] 강도죄와 준강도죄는 그 취지와 본질을 달리한다고 보아야 하며, 준강도죄의 주체는 절도이고 여기에는 기수는 물론 형법상 처벌규정이 있는 미수도 포함되는 것이지만, 준강도죄의 기수·미수의 구별은 구성요건적 행위인 폭행 또는 협박이 종료되었는가 하는 점에 따라 결정된다고 해석하는 것이 법규정의 문언 및 미수론의 법리에 부합한다. [2] 절도미수범이 체포를 면탈할 목적으로 폭행한 행위에 대하여 준강도미수죄로 의율한 원심판결을 수긍한 사례.(대판 2004.11.18, 2004도5074 전합)

♣ 돌발퀴즈

장물죄에는 제328조의 친족상도례의 규정이 그대로 적용된다.

정답 : X

해설 : 제328조의 친족상도례는 제365조에 의하여 수정되어 적용되므로 타당하지 않은 지문이다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 다음 중 장물이 아닌 것은?

- ① 절취한 타인의 시계
- ② 산림절도에 의한 수목
- ③ 임산물 단속법에 위반하여 채취한 버섯
- ④ 강취한 타인의 신용카드
- ⑤ 사취한 타인의 금전

정답 : ③

해설 : 임산물단속법규에 위반하여 채취한 물건은 장물이 아니다.

2. 장물죄의 규정 중 타당하지 않은 것은?

- ① 장물죄에는 일반과실장물죄가 없다.
- ② 장물죄의 행위태양에는 알선행위도 있다.
- ③ 장물범이 피해자의 직계비속인 경우에는 형을 면제한다.
- ④ 장물범이 피해자와 동거하지 않는 가족인 경우에는 친고죄가 된다.
- ⑤ 장물범이 본범의 직계비속인 경우에는 형을 면제한다.

정답 : ⑤

해설 : 장물범이 본범의 직계비속인 경우에는 필요적으로 형을 감면한다.

3. 친족상도례에 대한 설명 중 타당하지 않은 것은?

- ① 친족상도례에 대한 규정은 권리행사방해죄에 있다.
- ② 제328조 제1항의 효과는 형의 면제이다.
- ③ 제328조 제2항의 효과는 상대적 친고죄이다.
- ④ 강도죄와 손괴죄에는 적용이 없다.
- ⑤ 장물범과 본범과의 관계에서도 그대로 적용된다.

정답 : ⑤

해설 : 장물범과 피해자 사이에서는 그대로 적용되지만, 본범과의 관계에서는 수정되어 적용된다. 제365조 참조.

♣ 학습내용 정리

- 1. 금전이 다른 형태의 금전으로 바뀔 경우 장물성 유지여부에 대하여 ① 금전은 금전 자체는 별다른 의미가 없고 금액에 의하여 표시되는 금전적 가치가 의미가 있으므로 다른 금전의 형태로 바뀔 경우에도 금전인 이상 장물이 될 수 있다는 긍정설 ② 가치가 중요시하다고 하여 가치의 동일성을 물건의 동일성으로 파악하는 것은 유추금지원칙에 반하는 것이므로 장물이 될 수 없다는 부정설 등이 대립하고 있다. ③ 판례는 금전을 다른 금전으로 교환하거나 예금을 한 후에 인출한 경우에도 장물성을 인정하고 있다.
- 2. 준강도죄의 기수시기에 대하여 폭행·협박시기준설은 ① 준강도의 기수여부는 폭행·협박을 기준으로 판단해야 한다고 보아 ② 준강도의 행위태양이 폭행·협박이므로 절취행위를 기준으로 기수·미수를 논하는 것은 잘못이며 ③ 강도살인죄나 강도상해죄의 경우에도 재물취득여부는 기수시기에 영향을 미치지 못하므로 준강도도 동일하게 보아야 한다는 점을 논거로 한다.
- 3. 준강도죄의 기수시기에 대하여 절취행위시기준설은 ① 준강도의 기수여부는 절도의 기수·미수를 기준으로 판단해야 한다고 보아 ② 준강도는 기본적으로 재물죄이며 ③ 강도죄는 재물탈취가 기수의 요건인데 준강도죄의 기수를 폭행·협박으로 결정하게 되면 재물을 탈취하지 못하고 폭행만 하게 되면 기수가 성립되게 되어 처벌의 불균형이 있다는 점을 논거로 한다.

제37강 이미지화일과 문서죄

♣ 학습목표

이미지화일과 문서죄에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

사자명의의 사문서위조죄의 성립여부

채권추심에 있어서의 협박과 공갈죄의 성부

이미지화일과 사문서부정행사죄의 분석

♣ 사전테스트

1. 판례는 사자명의 사문서위조행위를 처벌하고 있지 않다.

정답 : X

해설 : 전합판례로 종래의 판례의 태도를 변경하여 사자명의 사문서위조행위를 처벌하고 있으므로 타당하지 않은 지문이다.

2. 자기 채권을 추심하기 위하여 사회상규에 어긋난 협박을 한 경우에 판례는 공갈죄의 성립을 인정하고 있다.

정답 : O

해설 : 판례는 갈취의 불법설을 바탕으로 공갈죄의 성립을 인정하고 있다.

3. 이미지화일도 문서위조죄의 객체가 될 수 있다.

정답 : X

해설 : 이미지화일은 문서위조죄의 객체가 될 수 없으므로 타당하지 않은 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

甲은 자신의 사업자금을 마련하기 위해 수년 전에 사망한 아버지 망(亡) A, 아버지 친구 망(亡)B를 각각 채권자, 채무자로 하는 금전소비대차계약을 작성하였다. 甲은 그 정을 모르는 조직 폭력배 乙에게 이 서류를 주면서 이를 가지고 B의 처 C를 위협하여 채권추심을 해달라고 부탁하였다. 이에 乙은 추심금의 일부를 보수로 받기로 하면서 승낙하였다.

그러나 乙은 이 채권추심을 하지 않고 위 계약을 스캔하여 이미지파일로 만든 후, 컴퓨터 프로그램을 이용하여 모니터 상에서 채권자를 자신의 이름으로 변경하여 저장하였다. 그 후 乙은 평소 거래관계가 있던 사채업자 D와 E에게 컴퓨터 화면에 나타난 금전소비대차계약서의 이미지파일을 순차로 보여주면서 위 허위채권을 담보로 자금대출을 부탁하여, 그 무렵 D로부터 1,000만 원을, E로부터 1,500만 원을 각각 대출받았다.

1. 甲에게 사문서위조죄 및 위조사문서행사죄가 성립하는지 여부와 그 논거를 설명하십시오. (5점)
2. 乙의 죄책을 논하십시오. (20점)

[해설]

[1. 문 해설 (5점)]

1. 사자명의의 사문서에 대한 위조죄 성립여부

(1) 종래 학설의 태도

이에 대하여 종래의 학설은 ① 문서위조죄의 보호법익은 문서의 진정에 대한 공공의 신용이므로 ② 행사할 목적으로 작성된 문서가 일반인으로 하여금 당해 명의인의 권한 내에서 작성된 문서라고 믿게 할 수 있는 정도의 형식과 외관을 갖추고 있으면 문서위조죄가 성립한다고 보았다.

(2) 판례의 태도

종래 판례는 사자명의의 사문서에 대하여 원칙적으로 사문서위조죄가 성립하지 않지만, 사망자의 생전일자로 소급작성된 경우에는 예외적으로 사문서위조죄가 성립한다고 보았으나, 최근의 전합판례에 의하여 학설과 동일한 입장에서 사문서위조죄가 성립하는 것으로 판례를 변경하였다.

(3) 사안의 해결

이러한 현재의 다수설과 판례에 따르면 甲은 사문서위조죄(제231조)의 책임을 진다.

2. 위조사문서의 행사죄 성립여부

사안에서 甲에게 사문서 위조죄가 성립한다면 이러한 정을 모르는 해당 금전소비대차계약을 乙에게 제시·교부한 것은 당연히 행사죄(제234조)가 성립하고 사문서위조죄와는 실제적 경합범이 된다.

[2. 문 해설 (20점)]

1. 사안의 정리

사안에서 乙의 행위는 ① 채권추심을 승낙한 부분에 대한 평가 ② 이미지화일을 새로 작성한 부분에 대한 평가 ③ 이미지화일을 보여준 행위에 대한 평가 ④ 허위채권을 담보로 대출받은 행위에 대한 평가의 순으로 검토한다.

2. 채권추심을 승낙한 부분에 대한 평가

권리행사를 위한 협박이 사회상규에 어긋나는 경우에는 어떤 죄가 성립하는가에 대하여는 ① 불법영득의사가 없으므로(영득의 불법설) 협박죄만 성립한다는 견해와 ② 불법영득의사를 인정할 수 있으므로(절취의 불법설) 공갈죄가 성립한다는 견해가 대립하고 있다. 그러나 사안에서 乙은 협박에 대한 실행의 착수가 없으므로 제31조 제2항에 따른 효과없는 교사에 해당하여 예비죄로 처벌될 수 있으나 협박죄와 공갈죄는 예비를 처벌하지 않으므로 이 부분에 대한 것은 무죄가 된다.

3. 새로운 이미지 파일을 작성한 부분의 죄책

(1) 논의점

사안에서 乙은 위조된 문서에 대하여 다시 위조를 범하고 있다. 그런데 문제는 위조된 문서 자체를 위조하는 것이 아니라 위조된 문서를 이미지화일로 만들어 이의 명의자를 변경하는 위조를 하면서 문서화하는 것이 아니라 이미지화일로 저장하고 있다. 이러한 이미지화일이 ① 문서위조죄의 객체가 될 수 있는지 ② 사전자기록위작죄에 해당하는가에 대하여 논의가 있다.

(2) 문서위조죄의 성부¹³⁾

문서위조죄에 성부에 대하여는 ① 스캔의 방법으로 생성된 이미지 문서는 형법 제237조의 2에서 말하는 ‘복사한 문서’에 해당하고 따라서 이를 위조하는 것도 위조가 된다고 보는 견해가 있지만 ② 컴퓨터 모니터 화면에 나타나는 이미지는 이미지 파일을 보기 위한 프로그램을 실행할 경우에 그때마다 전자적 반응을 일으켜 화면에 나타나는 것에 지나지 않아서 계속적으로 화면에 고정된 것으로는 볼 수 없으므로, 형법상 문서에 관한 죄에 있어서의 문서에는 해당되지 않는다고 보는 것이 타당하다.

(3) 사전자기록위작죄의 성부

사전자기록 위작죄의 성부에 대하여는 논의의 여지가 있지만 사무처리를 그르치게 할 목적이 없으므로 성립되지 않는다고 보아야 할 것이다.

4. 이미지화일을 D와 E에게 보여준 행위에 대한 평가

위조사문서행사죄가 문제되지만 ① 사안에서 이미지화일을 만든 부분에 대하여 위조죄를 인정하는 입장에서 위조문서 등 행사죄에 있어서 행사라 함은 그 문서의 효용방법에 따라 사용하는 것으로서 행사의 방법에 특별한 제한이 있는 것은 아니라고 할 것이므로 행사죄가 성립한다는 견해도 있을 수 있지만 ② 사안에서 이미지화일을 만든 것은 위조가 아니라는 입장에서는 새로운 이미지화일을 보여준 부분은 위조문서의 행사가 되지 아니하고, 이전에 위조된 문서 부분에 대한 것은 고의가 없으므로 이를 이미지화하여 보여준 부분에 대한 것도 역시 행사죄가 성립하지 않는다고 보는 것이 타당하다. 따라서 乙은 위조사문서행사죄가 성립하지 아니한다.¹⁴⁾

13) 자기 명의로 고치는 부분에 대하여 무형위조가 되지않느냐는 의문의 여지가 있겠지만, 채무자의 입장에서 새로운 문서가 창출되는 경우이므로 위조가 된다.

14) 판례는 위조된 문서를 이미지화하여 이를 전송한 경우에 행사죄를 인정하고 있지만, 사안의 경우에는

5. 사기죄의 성립

사안에서 乙은 채무자의 명의를 모용하는 행위를 통하여 새로운 권리관계를 형성시킨 허위의 이미지화일을 보여주면서 허위채권을 담보로 하여 대출을 받고 있다. 이러한 행위는 사기죄의 성립요건인 ① 기망행위 ② 착오 ③ 처분행위 ④ 손해발생의 위험이라는 사기죄의 성립요건을 모두 구비하였으므로 사기죄가 성립한다.

6. 결 언

사안의 경우에 乙은 사기죄(제347조)의 죄책만을 진다.

1. 권리행사와 공갈죄

공갈죄의 수단으로서의 협박은 사람의 의사결정의 자유를 제한하거나 의사실행의 자유를 방해할 정도로 겁을 먹게 할 만한 해악을 고지하는 것을 말하고 여기에서 고지된 해악의 실현은 반드시 그 자체가 위법한 것임을 요하지 아니하며 해악의 고지가 권리실행의 수단으로 사용된 경우라고 하여도 그것이 권리행사를 빙자하여 협박을 수단으로 상대방을 겁을 먹게 하였고 권리실행의 수단 방법이 사회통념상 허용되는 정도나 범위를 넘는다면 공갈죄가 성립한다(대법원 1993.9.14. 선고 93도915 판결, 대법원 2004.9.24. 선고 2003도6443 판결 등 참조).(대판 2007.10.11. 2007도6406)

2. 컴퓨터 모니터 이미지 사건

[1] 컴퓨터 모니터 화면에 나타나는 이미지는 이미지 파일을 보기 위한 프로그램을 실행할 경우에 그때마다 전자적 반응을 일으켜 화면에 나타나는 것에 지나지 않아서 계속적으로 화면에 고정된 것으로는 볼 수 없으므로, 형법상 문서에 관한 죄에 있어서의 '문서'에는 해당되지 않는다고 할 것이다. [2] 컴퓨터 스캔 작업을 통하여 만들어낸 공인중개사 자격증의 이미지 파일이 형법상 문서에 관한 죄의 '문서'에 해당하지 않는다고 한 사례.(대판 2008.4.10. 선고 2008도1013)

3. 이미지 파일 제3자에게 전송한 사건

[1] 위조문서행사죄에 있어서 행사라 함은 위조된 문서를 진정한 문서인 것처럼 그 문서의 효용방법에 따라 이를 사용하는 것을 말하고, 위조된 문서를 제시 또는 교부하거나 비치하여 열람할 수 있게 두거나 우편물로 발송하여 도달하게 하는 등 위조된 문서를 진정한 문서인 것처럼 사용하는 한 그 행사의 방법에 제한이 없다. 또한, 위조된 문서 그 자체를 직접 상대방에게 제시하거나 이를 기계적인 방법으로 복사하여 그 복사본을 제시하는 경우는 물론, 이를 모사전송의 방법으로 제시하거나 컴퓨터에 연결된 스캐너(scanner)로 읽어 들어 이미지화한 다음 이를 전송하여 컴퓨터 화면상에서 보게 하는 경우도 행사에 해당하여 위조문서행사죄가 성립한다. [2] 휴대전화 신규 가입신청서를 위조한 후 이를 스캔한 이미지 파일을 제3자에게 이메일로 전송한 사안에서, 이미지 파일 자체는 문서에 관한 죄의 '문서'에 해당하지 않으나, 이를 전송하여 컴퓨터 화면상으로 보게 한 행위는 이미 위조한 가입신청서를 행사한 것에 해당하므로 위조문서행사죄가 성립한다고 한 사례.(대판 2008.10.23. 선고 2008도5200)

♣ 돌발퀴즈

위조된 문서의 이미지화일은 위조문서행사죄의 객체가 될 수 있다는 것은 판례의 태도이다.

정답 : ○

해설 : 휴대전화 신규 가입신청서를 위조한 후 이를 스캔한 이미지 파일을 제3자에게 이메일로 전송한 사안에서, 이미지 파일 자체는 문서에 관한 죄의 '문서'에 해당하지 않으나, 이를 전송하여 컴퓨터 화면상으로 보게 한 행위는 이미 위조한 가입신청서를 행사한

乙은 甲에게 받은 문서가 위조된 정을 모르고 있다는 점에 차이가 있다.

제38강 위임초과금액인출과 컴퓨터사용사기죄

♣ 학습목표

운동경기의 도박성에 대하여 설명할 수 있다.
위임초과금액인출과 컴퓨터사용사기죄에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

운동경기의 도박성에 대한 검토
사기죄와 도박죄의 관계
위임초과금액의 인출에 대한 죄책의 검토

♣ 사전테스트

1. 판례는 운동경기의 도박성을 인정하지 않고 있다.

정답 : X

해설 : 판례는 '피고인들이 각자 핸디캡을 정하고 홀마다 또는 9홀마다 별도의 돈을 걸고 총 26 내지 32회에 걸쳐 내기 골프를 한 행위가 도박에 해당한다'라고 하여 운동경기의 도박성을 인정하고 있다.

2. 사기도박의 경우에는 도박죄는 성립하지 않는다.

정답 : O

해설 : 사기도박의 경우에는 사기죄만이 문제될 뿐 도박죄는 성립되지 않는다.

3. 절취한 타인의 신용카드로 현금자동지급기에서 현금을 인출한 것을 판례는 재산상의 이익으로 보고 있다.

정답 : X

해설 : 판례는 타인의 신용카드로 현금자동지급기에서 현금을 인출한 것을 재물로 보고 있으므로 타당하지 않은 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

고교동창관계인 甲, 乙, 丙, 丁은 2008년 3월 20일부터 2009년 6월 7일까지 총 32회에 걸쳐 함께 최고 10억 원 상당의 내기골프를 하였는데, 경기방식은 각자 핸디캡(실력 차이에 따른 성적 편차를 줄이기 위해 주어지는 점수)을 정하고 매 홀마다 별도의 돈을 걸어 승자가 갖는 것이었다.

1. 甲, 乙, 丙, 丁의 죄책을 논하라. (5점)
2. 위 사례에서 2009년 6월 10일 집안사정으로 불참한 乙 대신 丙의 친구 A가 내기골프에 참여하였다. 丙, 丁, A는 골프 시작 전 甲이 잠시 자리를 비운 사이 프로골퍼 수준인 A의 핸디캡을 속이는 방식으로 甲의 돈을 따내기로 공모하였고, 甲에게서 딴 돈을 경기가 끝난 후 나눠 가졌다. 이 경우 甲, 丙, 丁, A의 죄책을 논하시오. (10점)
3. 위 2번 문제 사례에서 돈을 많이 잃은 甲이 캐디(경기보조원) B에게 현금카드를 건네주며 300만원을 인출해오라고 하였는데, B는 500만원을 인출하여 그중 300만원만 甲에게 건네주고 나머지 200만원을 임의로 사용하였다. 이 경우 B의 죄책을 논하시오. (10점)

[해설]

[1. 문 해설 (5점)]

1. 도박죄의 성립여부

(1) 운동경기와 도박

도박이 되기 위해서는 재물의 득실이 우연에 의해서 결정되어야 한다. 당사자의 육체적·정신적 능력, 주의의 정도 및 기능과 기량에 의하여 승패가 결정되는 운동경기의 경우 ① 우연의 지배에서 완전히 벗어난 것이 아니라면 도박이 된다는 긍정설과 ② 경기는 기능과 기량에 의해 승패가 결정되므로 우연이 아니라는 이유로 내기경기의 도박성을 부정하는 부정설이 대립하고 있으나, 경기에도 기능과 기량 외적인 우연적 요소가 작용한다는 점이나 기능과 기량이 승패에 영향을 미치는 경우를 모두 도박에서 제외하면 도박은 거의 있을 수 없다는 점에서 내기경기의 도박성을 인정하는 긍정설이 타당하다.

(2) 판례의 태도

판례는 위의 사례와 유사한 사안에서 ‘피고인들이 각자 핸디캡을 정하고 홀마다 또는 9홀마다 별도의 돈을 걸고 총 26 내지 32회에 걸쳐 내기 골프를 한 행위가 도박에 해당한다’고 보았다.

2. 상습도박죄의 성립여부

상습도박죄에 있어서의 상습성이라 함은 반복하여 도박행위를 하는 습벽으로서 행위자의 속성을 말하는데, 이러한 습벽의 유무를 판단함에 있어서는 도박의 전과나 도박횟수 등이 중요한 판단자료가 되나 도박전과가 없다 하더라도 도박의 성질과 방법, 도금의 규모, 도박에 가담하게 된 태양 등의 모든 사정을 참작하여 도박의 습벽이 인정되는 경우에는 상습성을 인정할 수 있다.

3. 사안의 해결

사안의 경우에 甲, 乙, 丙, 丁은 무려 32회에 걸쳐 도박행위를 하고 있으므로 이에 상습성이 인정된다고 평가할 수 있을 것이다. 따라서 甲, 乙, 丙, 丁은 모두 상습도박죄(제246조 제2항)의 죄책을 진다.

[2. 문 해설 (10점)]

1. 논의점

사안에서 ① A는 기망방법에 의한 도박을 하고 있으므로 사기죄의 성립 및 도박죄의 성부가 문제되고 ② 丙과 丁의 경우에는 A와 더불어 공동정범이 성립될 수 있는가가 문제되고 ③ 甲의 경우에 도박죄가 성립할 수 있는가가 문제된다.

2. 기망방법에 의한 도박에 의한 A의 죄책

(1) 사기죄의 성립

우연성은 도박가담자 모두에게 존재해야 한다. 따라서 가담자의 일방에게만 우연성이 있는 사기도박의 경우에는 그 승패가 우연에 의해서 결정되는 것이 아니라 사기도박자의 기망에 의해 결정되므로 도박죄는 성립할 수 없다. 따라서 사안에서 A는 ① 자기의 핸디캡을 속이는 기망행위를 하고 ② 甲은 이에 기망당하여 착오에 빠졌고 ③ 기망에 따른 도박에 의하여 재산적 처분행위를 하였고 ④ 이에 의하여 A는 재산상의 이득을 취득하였고 ⑤ 甲은 손해를 입었으므로 A에게는 사기죄가 성립한다.

(2) 도박죄의 불성립

우연성이 배제된 경우에는 도박죄는 성립하지 않으므로 A에게 사기죄가 성립하는 한 도박죄는 성립하지 않는다.

3. 丙, 丁의 죄책

(1) 丙과 丁은 A와 공모하여 의사의 연락을 하고 있으므로 공동정범의 주관적 요건을 구비하고 있고 또한 A와 같이 사기골프를 함으로써 객관적 요건도 충족하고 있으므로 丙과 丁은 A와 같이 사기죄의 공동정범으로서의 죄책을 진다.

(2) 丙과 丁은 도박도 하고 있으므로 도박죄의 성립이 문제되지만, 우연성이 배제되어 있으므로 도박죄는 성립하지 않는다.

4. 甲의 죄책

甲은 형식적으로는 도박을 하고 있으나 실제로는 사기죄의 피해자에 불과하다. 이러한 경우에 甲에게는 우연성이 배제되어 있으므로 도박죄가 성립하지 아니하고 무죄가 된다. 판례도 사기도박의 피해자에게는 도박죄의 성립을 부정하고 있다.

[3. 문 해설 (10점)]

1. 논의점

사안처럼 타인의 현금카드를 건네받으면서 일정 금액의 인출을 위임받은 자가 그 범위를 초과한 금액을 인출한 후 그 초과금액을 착복한 경우의 죄책에 대하여 절도죄설과 컴퓨터사용사기죄설의 대립이 있다.

2. 견해의 대립

(1) 절도죄설

사안을 절도죄로 파악하는 입장이다. 이러한 견해는 ① 현금자동지급기를 이용하여 초과인출된 금전을 재물로 파악하고 ② 관리자의 의사를 정당한 관리자의 현금인출만을 허용하겠다는 의사로 좁게 해석하는 입장에서 위임의 범위 내에서 인출을 해야 관리자의 의사에 반하지 않게 되고, 초과 인출한 경우에는 관리자의 의사에 반하는 것이 된다는 점을 논거로 한다.

(2) 컴퓨터사용사기죄설

사안을 컴퓨터사용사기죄로 파악하는 입장이다. 이러한 견해는 ① 현금자동지급기를 이용하여 위임범위를 초과인출하는 경우에는 초과인출로 인하여 재산상의 이익을 감소 내지는 재산상의 채무를 증가시켰으므로 재물로써 파악하는 것이 아니라 재산상의 이익으로 판단하고 ② 관리자의 의사를 누구든지 정당한 카드와 비밀번호를 입력하고 현금을 인출해가도록 허용하겠다는 의사로 넓게 해석하는 입장에서 위임범위를 초과하여 현금을 인출하였다 하더라도 관리자의 의사에 반하는 것은 아니라는 점을 논거로 한다.

3. 판례의 태도

대법원 판례는 이와 유사한 사안에서 컴퓨터사용사기죄로 처벌하고 있다.

4. 검토 및 사안의 해결

사안의 경우에 현금을 초과인출하지 않고 계좌이체를 한 경우와를 비교해 본다면 양자를 동일하게 규율하는 것이 구체적 타당성을 실현할 수 있는 방법이 될 것이다. 따라서 사안의 경우의 현금을 재산상 이익으로 보아 제347조의2의 컴퓨터등사용사기죄로 의율하는 것이 타당하다. 다만 입법론으로는 제347조의2의 객체에 재물을 포함시키는 것이 초과금액에 대한 재물성 여부에 대한 논쟁을 종식시킬 수 있는 최선의 방법이 될 것이다.

관련판례

1. 골프도박 사건

[1] 형법 제246조에서 도박죄를 처벌하는 이유는 정당한 근로에 의하지 아니한 재물의 취득을 처벌함으로써 경제에 관한 건전한 도덕법칙을 보호하는 데 있다. 그리고 도박은 '재물을 걸고 우연에 의하여 재물의 득실을 결정하는 것'을 의미하는바, 여기서 '우연'이란 주관적으로 '당사자에 있어서 확실히 예견 또는 자유로이 지배할 수 없는 사실에 관하여 승패를 결정하는 것'을 말하고, 객관적으로 불확실할 것을 요구하지 아니한다. 따라서 당사자의 능력이 승패의 결과에 영향을 미친다고 하더라도 다소라도 우연성의 사정에 의하여 영향을 받게 되는 때에는 도박죄가 성립할 수 있다. [2] 피고인들이 각자 핸디캡을 정하고 홀마다 또는 9홀마다 별도의 돈을 걸고 총 26 내지 32회에 걸쳐 내기 골프를 한 행위가 도박에 해당한다고 한 사례. (대판 2008.10.23. 2006도736)

2. 사기도박 사건

화투의 조작에 속달하여 원하는 대로 끝수를 조작할 수 있어서 우연성이 없음에도 피해자를 우연에 의하여 승부가 결정되는 것처럼 오인시켜 돈을 도하게 하여 이를 편취한 행위는 이른바 기망방법에 의한 도박으로서 사기죄에 해당한다.(대판 1985.4.23. 85도583)

3. 권한 초과하여 현금 인출한 사건

[사실관계] 甲은 '사이버 25시 피씨방'에 게임을 하러 온 乙로부터 그 소유의 농협현금카드로 20,000원을 인출해 오라는 부탁과 함께 현금카드를 건네받게 되자 이를 기화로, 현금자동인출기에 위 현금카드를 넣고 권한 없이 인출금액을 50,000원으로 입력하여 그 금액을 인출한 후 그 중 20,000원만 을에게 건네주어 30,000원 상당의 재산상 이익을 취득하였다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 예금주인 현금카드 소유자로부터 일정한 금액의 현금을 인출해 오라는 부탁을 받으면서 이와 함께 현금카드를 건네받은 것을 기화로 그 위임을 받은 금액을 초과하여 현금을 인출하는 방법으로 그 차액 상당을 위법하게 이득할 의사로 현금자동지급기에 그 초과된 금액이 인출되도록 입력하여 그 초과된 금액의 현금을 인출한 경우에는 그 인출된 현금에 대한 점유를 취득함으로써 이 때에 그 인출한 현금 총액 중 인출을 위임받은 금액을 넘는 부분의 비율에 상당하는 재산상 이익을 취득한 것으로 볼 수 있으므로 이러한 행위는 그 차액 상당액에 관하여 형법 제347조의2(컴퓨터등사용사기)에 규정된 '컴퓨터 등 정보처리장치에 권한 없이 정보를 입력하여 정보처리를 하게 함으로써 재산상의 이익을 취득'하는 행위로서 컴퓨터 등 사용사기죄에 해당된다.(대판 2006.3.24. 2005도3516)

♣ 돌발퀴즈

판례는 위임범위를 초과하여 인출한 현금을 재산상의 이익으로 보고 있다.

정답 : ○

해설 : 판례는 위임범위를 초과된 금액의 현금을 인출한 경우에는 그 인출된 현금에 대한 점유를 취득함으로써 이 때에 그 인출한 현금 총액 중 인출을 위임받은 금액을 넘는 부분의 비율에 상당하는 재산상 이익을 취득한 것으로 보므로 타당한 지문이다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 도박죄에 대한 설명 중 타당하지 않은 것은?

- ① 도박죄는 벌금형이 최고형이다.
- ② 일시 오락의 경우에는 위법성이 조각된다.
- ③ 상습도박죄는 징역형으로 처벌된다.
- ④ 도박장개설죄는 목적범이다.
- ⑤ 도박장개설죄는 도박죄의 방조죄이다.

정답 : ⑤

해설 : 도박장개설죄는 도박죄의 방조죄가 아닌 독자적인 범죄이다.

2. 사기도박에 대한 죄수 판단은?

- ① 사기도박을 한 사람에게만 사기죄가 성립한다.
- ② 사기도박을 한 사람에게만 사기죄와 도박죄의 실체적 경합범이 성립한다.
- ③ 사기도박을 한 사람에게만 사기죄와 도박죄의 상상적 경합이 된다.
- ④ 사기도박을 한 사람은 사기죄, 당한 사람은 도박죄가 성립한다.
- ⑤ 사기도박을 한 사람은 사기죄와 도박죄가 성립하고, 당한 사람은 도박죄가 성립한다.

정답 : ①

해설 : 사기도박을 한 사람에게만 사기죄가 성립한다.

3. 甲은 ‘사이버 25시 피씨방’에 게임을 하러 온 乙로부터 그 소유의 농협현금카드로 20,000원을 인출해 오라는 부탁과 함께 현금카드를 건네받게 되자 이를 기회로, 현금자동인출기에 위 현금카드를 넣고 권한 없이 인출금액을 50,000원으로 입력하여 그 금액을 인출한 후 그 중 20,000원만 을에게 건네주어 30,000원 상당의 재산상 이익을 취득하였다. 판례에 의할 때 甲의 죄책은?

- ① 사기죄
- ② 컴퓨터사용사기죄
- ③ 절도죄
- ④ 횡령죄
- ⑤ 배임죄

정답 : ②

해설 : 판례에 의하면 사안은 컴퓨터사용사기죄가 성립한다.

♣ 학습내용 정리

1. 당사자의 육체적·정신적 능력, 주의의 정도 및 기능과 기량에 의하여 승패가 결정되는 운동 경기의 경우 ① 우연의 지배에서 완전히 벗어난 것이 아니라면 도박이 된다는 긍정설과 ② 경기는 기능과 기량에 의해 승패가 결정되므로 우연이 아니라는 이유로 내기경기의 도박성을 부정하는 부정설이 대립하고 있다.
2. 판례는 내기골프 사안에서 ‘피고인들이 각자 핸디캡을 정하고 홀마다 또는 9홀마다 별도의 돈을 걸고 총 26 내지 32회에 걸쳐 내기 골프를 한 행위가 도박에 해당한다’고 보았다.
3. 판례는 위임범위를 초과하여 현금을 인출하고 영득한 행위에 대하여 ‘예금주인 현금카드 소유자로부터 일정한 금액의 현금을 인출해 오라는 부탁을 받으면서 이와 함께 현금카드를 건네받은 것을 기회로 그 위임을 받은 금액을 초과하여 현금을 인출하는 방법으로 그 차액 상당을 위법하게 이득할 의사로 현금자동지급기에 그 초과된 금액이 인출되도록 입력하여 그 초과된 금액의 현금을 인출한 경우에는 그 인출된 현금에 대한 점유를 취득함으로써 이 때에 그 인출한 현금 총액 중 인출을 위임받은 금액을 넘는 부분의 비율에 상당하는 재산상 이익을 취득한 것으로 볼 수 있으므로 이러한 행위는 그 차액 상당액에 관하여 형법 제347조의2(컴퓨터등사용사기)에 규정된 ‘컴퓨터 등 정보처리장치에 권한 없이 정보를 입력하여 정보처리를 하게 함으로써 재산상의 이익을 취득’하는 행위로서 컴퓨터 등 사용사기죄에 해당된다.’고 보고 있다.

제39강 참고인의 허위진술과 차용사기

♣ 학습목표

참고인의 허위진술과 차용사기에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

참고인의 허위진술에 대한 죄책의 검토
도박자금의 대여와 차용사기죄의 성립여부
적법한 공무집행과 긴급체포의 성립요건

♣ 사전테스트

1. 범인이 아닌 자가 수사기관에서 범인임을 자처한 경우에 판례는 항상 범인도피죄를 인정하고 있다.

정답 : X

해설 : 단순히 범인임을 자처한 경우에는 범인도피죄가 성립하지 아니하므로 타당하지 않은 지문이다.

2. 변제할 의사와 능력도 없이 타인에서 금원을 차용한 경우에는 사기죄가 성립한다.

정답 : O

해설 : 차용금 사기의 예로 타당한 지문이다.

3. 적법한 공무집행이 되기 위해서는 공무원에게 추상적 권한, 구체적 권한, 절차와 방식 등이 구비되어야 한다.

정답 : O

해설 : 적법한 공무집행이 되기 위한 세가지 요건이므로 타당한 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

甲은 도박장을 직접 운영하기로 마음먹고, 단속에 대비하여 마침 직장을 잃고 놓고 있던 사촌 동생 乙에게 ‘도박장 영업을 도와주어 용돈도 벌고, 도박장이 적발되면 내가 도망가더라도 네가 사장이라고 진술을 해달라’고 제의하였고, 乙은 甲의 제의를 승낙하였다. 甲은 생활정보지에 광고하여 도박장에서 일할 종업원들을 채용하였다. 甲은 乙을 사장으로 위장하기 위하여 甲의 자금으로 乙로 하여금 직접 사무실을 임차하도록 하였다.

2013. 10. 1. 저녁 甲은 평소 알고 있던 丙 등 도박꾼들을 속칭 ‘대포폰’으로 연락하여 사무실로 불러 ‘포커’도박을 하도록 하고 자릿값으로 한 판에 판돈에서 10%씩을 떼어 내었고, 乙은 창문으로 망을 보았다. 丙은 도박자금이 떨어지자 옆에서 구경하고 있던 丁에게 사실은 변제할 의사가 없었지만 높은 이자를 약속하고 도박자금을 빌려달라고 하였고, 丁은 丙이 상습도박 전과가 있음을 알면서도 丙에게 도박자금으로 300만 원을 빌려주었다,

근처 주민의 신고로 경찰관 P 등이 출동하여 乙, 丙, 丁은 현장에서 도박 등의 혐의로 현행범인 체포되었고, 甲과 다른 도박꾼들은 도망쳤다. 乙은 경찰서에서 자신이 도박장 주인이라고 하면서 도박장 등의 운영 경위, 자금 출처, 점포의 임대차계약 경위, 종업원 채용 등에 관하여 구체적으로 거짓말을 하였고, 조사를 받은 후 체포된 다른 사람들과 함께 석방되었다.

단속 3일 후 甲이 경찰관 P에게 전화하여 불구속 수사를 조건으로 자수 의사를 밝혀오자 경찰관 P는 일단 외부에서 만나 이야기하자고 하였다. 다음 날 경찰관 P는 경찰서 밖 다방에서 甲을 만나 범죄사실을 요지, 체포의 이유와 변호인선임권을 고지하고 변명의 기회를 준 후 甲을 긴급체포하려 하였다. 그러자 甲은 ‘자수하려는 사람을 체포하는 법이 어디에 있느냐’고 따지며 경찰관 P의 가슴을 밀쳐 바닥에 넘어뜨렸고, P는 넘어지면서 손가락이 골절되었다.

甲, 乙, 丙, 丁의 죄책은? (60점)

[해설]

I. 논의점

사안에서 각자의 범죄를 ① 甲과 乙이 도박장을 개설하고 경찰서에서 허위진술한 행위 ② 丙이 도박한 행위 ③ 도박자금을 빌리고 빌려준 丙과 丁의 행위 ④ 甲이 P를 때려 상처를 입힌 행위의 순서로 검토한다.

II. 도박장을 개설하고 경찰서에서 허위진술하는 행위에 대한 죄책

1. 도박장을 개설하는 행위에 대한 죄책

(1) 甲의 죄책

사안에서 甲은 영리를 목적으로 도박장을 개설하고 있으므로 형법 제247조의 도박장소 등 개설죄가 성립한다.

(2) 乙의 죄책

사안에서 乙은 甲이 도박장을 개설하려한다는 것을 알면서 이를 도와주고 있으므로 乙이 甲과 도박개장죄의 공동정범인자가 문제된다. 그러나 사안에서 甲이 실질적으로 도박장을 개설하고, 乙은 이를 도와주는데에 불과하여 기능적 행위지배인 본질적 기여가 없으므로 방조범만 성립한다.

2. 경찰서에서 허위진술하는 행위에 대한 죄책

(1) 乙의 죄책

- 1) 위계에 의한 공무집행방해죄의 성부 : 사안에서 乙은 자신이 바지사장이면서도 사장인 것처럼 수사기관에서 허위의 진술을 하고 있다. 이러한 경우 위계에 의한 공무집행방해죄의 성립여부가 문제되지만, 수사기관은 실체적진실을 발견해야할 권리와 의무가 있으므로 위계에 의한 공무집행방해죄는 성립하지 않는다.
- 2) 범인은닉죄의 성부 : 사안에서 乙은 실제업주라고 하는 것에 그치지 않고, 실제 업주인 甲으로부터 금전적 이익 등을 제공받기로 하고 단속이 되면 실제 업주를 숨기고 자신이 대신하여 처벌받기로 하는 역할을 맡기로 하는 등 수사기관을 착오에 빠뜨리기로 하고, 도박장 등의 운영 경위, 자금 출처, 점포의 임대차계약 경위, 종업원 채용 등에 관하여 구체적으로 거짓말을 하였으므로 범인은닉죄의 구성요건에 해당한다.
- 3) 친족 간의 특례의 적용 : 乙의 행위가 범인은닉죄의 구성요건에 해당하더라도 乙은 甲의 사촌동생이므로 제151조 제2항의 친족간의 특례의 적용으로 책임이 조각되어 범죄가 성립하지 않는다.

(2) 甲의 죄책

- 1) 사안에서 乙이 범인은닉죄가 성립하지 않지만 제한종속을 구비하였으므로 甲의 범인은닉죄의 교사범의 성립이 문제된다.
- 2) 이에 대하여는 ① 본범이 타인을 교사하여 자기를 은닉 또는 도피하게 한 경우는 자기비호권의 한계를 일탈한 것으로서 기대가능성이 부정되는 경우가 아니므로 자기범인은닉의 교사범을 인정하는 긍정설 ② 본범이 타인을 교사하여 자기를 은닉 또는 도피하게 한 경우는 자기비호권의 연장이라고 볼 수 있으므로 자기범인은닉의 교사범을 부정하는 부정설이 대립하고 있다.
- 3) 판례는 ‘범인이 자신을 위하여 타인으로 하여금 허위의 자백을 하게 하여 범인도피죄를 범하게 하는 행위는 방어권의 남용으로 범인도피교사죄에 해당한다’라고 하여 긍정설의 입장이다.
- 4) 현행법이 자기범인은닉죄를 구성요건화하지 않은 것은 사회적 측면에서 불법을 창출하였더라도 개인적 측면에서 적법행위에 대한 기대가능성이 없기 때문이다. 그렇다면 타인을 교사하여 범인은닉죄를 범하게 하였다고 하더라도 범인자신의 개인적 측면이 고려되어 교사범의 성립을 인정하지 않는 부정설이 타당하다. 이러한 부정설에 따르면 甲에게는 범인은닉죄의 교사범은 성립하지 않는다.

III. 도박행위에 대한 죄책

사안에서 丙은 도박을 하였음은 명백하며 또한 丙은 상습의 습벽이 있는 자이므로 형법 제246조 제2항의 상습도박죄가 성립한다. 그러나 사안에서 丁이 도박을 하였음은 명백하지 않으므로 丁의 도박부분은 무죄가 된다.

IV. 도박현장에서 돈을 대차한 丙과 丁의 죄책

1. 丙의 죄책

(1) 논의점

丙은 변제의사가 없음에도 불구하고 변제의사가 있는 것처럼 기망을 하여 돈을 빌리고 있으므로 원칙적으로 사기죄가 성립한다. 그런데 사안과 같이 도박자금인 불법원인급여물도 사기죄의 객체가 될 수 있는가에 대하여 논의가 있다.

(2) 견해의 대립

이에 대하여는 ① 반사회질서행위를 한 피해자를 형법이 보호해 줄 필요가 없으므로 불법원인급여물에 대하여 사기죄의 성립을 부정하는 부정설 ② 사법상의 반환청구권보다는 형법의 독자성이 강조되어야 하므로 불법원인급여물에 대하여도 사기죄의 성립을 긍정하는 긍정설이 대립하고 있다.

(3) 판례의 태도

판례는 피해자로부터 도박자금으로 사용하기 위하여 금원을 차용한 사건에서 ‘민법 제746조의 불법원인급여에 해당하여 급여자가 수익자에 대한 반환청구권을 행사할 수 없다고 하더라도, 수익자가 기망을 통하여 급여자로 하여금 불법원인급여에 해당하는 재물을 제공하도록 하였다면 사기죄가 성립한다’라고 하여 긍정설의 입장이다.

(4) 결론 및 사안의 해결

생각건대 사기죄의 성립 여부는 사법상의 반환청구권과는 관계없이 형법독자적인 입장에서 판단하여야 하고, 사기죄의 객체인 재산상의 이익을 경제적 재산설에 입각하는 한 불법원인급여물에 대하여도 사기죄의 성립을 긍정하여야 할 것이다. 따라서 사안에서 丙은 사기죄가 성립한다.

2. 丁의 죄책

(1) 논의점

사안에서 丁은 丙이 상습도박자라는 것을 알면서 도박자금을 대여하여 이를 방조하고 있다. 이러한 경우 상습성이라는 가중적 신분을 가진 자에게 신분없는 자가 가담하고 있으므로 丁이 단순도박죄가 되는지 상습도박죄의 방조범이 되는지에 대하여 제33조의 해석과 관련하여 논의가 있다.

(2) 제33조에 대한 논의

제33조의 해석에 대하여는 ① 제33조 본문은 구성적 신분인 진정신분범의 공범의 성립과 과형을 규정한 것으로 보고, 제33조 단서는 가감적 신분인 부진정신분범의 공범의 성립과 과형을 규정한 것으로 보는 다수설 ② 제33조 본문은 진정신분범과 부진정신분범에 대한 공범의 성립 및 진정신분범에 대한 과형을 규정한 것으로 보고, 제33조 단서는 부진정신분범의 과형을 규정한 것으로 보는 판례가 대립하고 있다.

(3) 사안의 해결

원칙적으로 범죄의 성립과 처벌은 일치하여야 하므로 제33조 본문은 진정신분범에게 적용되고, 제33조 단서는 부진정신분범에게 적용된다고 보는 다수설의 입장이 타당하다. 사안에서 다수설에 의하면 丁은 도박죄의 방조범이 성립하고 도박죄의 방조범으로 처벌된다.

V. 경찰관 P를 폭행치상한 甲의 죄책

1. 논의점

사안에서 甲이 경찰관 P를 폭행하여 골절을 입힌 것은 공무집행방해죄와 폭행치상죄의 성립여부가 문제된다.

2. 공무집행방해죄의 성부

사안에 공무집행방해죄가 성립하기 위해서는 경찰관 P의 직무집행이 적법하여야 한다. 사안에서 甲은 자진출석하려고 하였으나 경찰관 P는 이를 이용하여 긴급체포하고 있다. 이러한 긴급체포는 긴급체포의 요건인 ① 중대성 ② 필요성 ③ 긴급성 중 필요성과 특히 긴급성의 요건을 구비하기 어려우므로 위법한 긴급체포가 된다. 따라서 P의 직무집행행위가 위법하다면 甲의 행위는 공무집행방해죄가 성립하지 않는다.

3. 폭행치상죄의 성부

사안에서 甲의 행위는 폭행치상죄의 구성요건해당성이 인정된다. 그러나 P의 긴급체포가 위법한 경우에는 甲의 행위는 자기의 법익에 대한 현재의 부당한 침해를 방어하기 위한 상당성있는 행위로서 정당방위가 인정되므로 위법성이 조각되어 범죄가 성립하지 않는다.

VI. 甲, 乙, 丙, 丁의 죄책

사안에서 甲은 도박장소 등 개설죄가 성립하고, 乙은 도박장소 등 개설죄의 방조범이 성립하고, 丙은 상습도박죄와 사기죄가 성립하며, 丁은 도박방조죄가 성립한다.

관련판례

1. 범인 자처 사건 (종업원이 실제 업주라고 허위 진술한 사건)

[사실관계] 甲은 게임장을 운영하기로 하면서 동업자인 乙을 통하여 A를 이른바 바지사장으로 고용하기로 하였다. 甲은 A 명의로 게임장의 사업자등록을 마치고 그에게 월급 250만 원씩을 지급하기로 하였다. 이후 게임장을 운영하던 甲 등은 게임산업법위반죄로 적발되었는데, 바지사장인 A는 검찰에 조사받으러 가기 전에 甲에게 자신이 벌금형을 받게 되면 벌금을 대신 내달라고 요구하여 응낙의 답변을 받았다. A는 피의자로 검찰 수사에 임하여 자신이 게임장 실제 업주라고 하면서 게임장 운영 경위, 자금 출처, 게임기 구입 경위, 건물의 임대차계약 체결 경위에 관하여 허위로 진술하였다. 甲과 A의 죄책은?

[판결요지] [1] 게임산업진흥에 관한 법률 위반, 도박개장 등의 혐의로 수사기관에서 조사받는 피의자가 사실은 게임장·오락실·피씨방 등의 실제 업주가 아니라 그 종업원임에도 불구하고 자신이 실제 업주라고 허위로 진술하였다고 하더라도, 그 자체만으로 범인도피죄를 구성하는 것은 아니다. 다만, 그 피의자가 실제 업주로부터 금전적 이익 등을 제공받기로 하고 단속이 되면 실제 업주를 숨기고 자신이 대신하여 처벌받기로 하는 역할(이른바 ‘바지사장’)을 맡기로 하는 등 수사기관을 착오에 빠뜨리기로 하고, 단순히 실제 업주라고 진술하는 것에서 나아가 게임장 등의 운영 경위, 자금 출처, 게임기 등의 구입 경위, 점포의 임대차계약 체결 경위 등에 관해서까지 적극적으로 허위로 진술하거나 허위 자료를 제시하여 그 결과 수사기관이 실제 업주를 발견 또는 체포하는 것이 곤란 내지 불가능하게 될 정도에까지 이른 것으로 평가되는 경우 등에는 범인도피죄를 구성할 수 있다. [2] 원심판결 이유에 의하면, 원심은, 그 채용 증거에 의하여 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 피고인은 공소외 1, 공소외 2와 동업으로 이 사건 게임장을 운영하기로 하면서 공소외 2를 통하여 공소외 3을 이른바 바지사장으로 고용하기로 하고, 공소외 3 명의로 게임장의 사업자등록을 마치고 그에게 월급 250만 원씩을 지급하기로 한 점, 공소외 3은 검찰에 조사받으러 가기 전에 피고인과 공소외 2에게 자신이 벌금형을 받게 되면 벌금을 대신 내달라고 요구하여 응낙의 답변을 듣고 검찰 수사에 임하여 자신이 게임장 실제 업주라고 하면서 게임장 운영 경위, 자금 출처, 게임기 구입 경위, 건물의 임대차계약 체결 경위에 관하여 허위로 진술한 점 등에 비추어 보면, 공소외 3의 수사기관에서의 진술은 그 내용이 실제 업주인 피고인을 도피시키기 위하여 자신을 실제 업주로 내세우는 허위 진술로서 적극적으로 수사기관을 기만하여 착오에 빠지게 함으로써 범인의 발견 또는 체포를 곤란 내지 불가능하게 할 정도에 이르렀다고 봄이 상당하여 범인도피죄가 성립하고 이를 교사한 피고인에게 범인도피교사죄가 성립한다.(대판 2010.1.28. 2009도10709)

2. 동생을 피의자로 조사받게 한 사건

[1] 범인이 자신을 위하여 타인으로 하여금 허위의 자백을 하게 하여 범인도피죄를 범하게 하는 행위는 방어권의 남용으로 범인도피교사죄에 해당하는바, 이 경우 그 타인이 형법 제151조 제2항에 의하여 처벌

을 받지 아니하는 친족, 호주 또는 동거 가족에 해당한다 하여 달리 볼 것은 아니다. [2] 무면허 운전으로 사고를 낸 사람이 동생을 경찰서에 대신 출두시켜 피의자로 조사받도록 한 행위는 범인도피교사죄를 구성한다.(대판 2006.12.7. 2005도3707)

3. 도박자금 차용 사기 사건

[1] 민법 제746조의 불법원인급여에 해당하여 급여자가 수익자에 대한 반환청구권을 행사할 수 없다고 하더라도, 수익자가 기망을 통하여 급여자로 하여금 불법원인급여에 해당하는 재물을 제공하도록 하였다면 사기죄가 성립한다. [2] 피고인이 피해자로부터 도박자금으로 사용하기 위하여 금원을 차용하였더라도 사기죄의 성립에는 영향이 없다고 한 사례.(대판 2006.11.23. 2006도6795)

4. 제33조의 해석에 대한 판례

신분관계가 없는 자가 그러한 신분관계에 있는 자와 공모하여 위 상호신용금고법위반죄를 저질렀다면, 그러한 신분관계가 없는 자에 대하여는 형법 제33조 단서에 의하여 형법 제355조 제2항에 따라 처단하여야 할 것인바, 그러한 경우에는 신분관계가 없는 자에게도 일단 업무상배임으로 인한 상호신용금고법 제39조 제1항 제2호 위반죄가 성립한 다음 형법 제33조 단서에 의하여 중한 형이 아닌 형법 제355조 제2항에 정한 형으로 처벌되는 것이다.(대판 1997.12.26. 97도2609)

5. 위법한 공무집행의 효과(오만한 경찰관의 단속태도에 항의한 사건)

공무집행방해죄는 공무원의 직무집행이 적법한 경우에 한하여 성립하는 것으로서 적법한 공무집행이라고 함은 그 행위가 공무원의 추상적 권한에 속할 뿐 아니라 구체적 직무집행에 관한 법률상 요건과 방식을 갖춘 것을 말하는 것이므로, 이러한 적법성이 결여된 직무행위를 하는 공무원에게 항거하였다고 하여도 그 항거행위가 폭력을 수반한 경우에 폭행죄 등의 죄책을 묻는 것은 별론으로 하고 공무집행방해죄로 다스릴 수는 없다.(대판 1992.2.11. 91도2797)

6. 미란다 고지하지 않은 사건

경찰관의 행위가 적법한 공무집행을 벗어나 불법하게 체포한 것으로 볼 수밖에 없다면, 그 체포를 면하려고 반항하는 과정에서 경찰관에게 상해를 가한 것은 불법 체포로 인한 신체에 대한 현재의 부당한 침해에서 벗어나기 위한 행위로서 정당방위에 해당하여 위법성이 조각된다고 한 사례.(대판 2000.7.4. 99도4341)

♣ 돌발퀴즈

무면허 운전으로 사고를 낸 사람이 동생을 경찰서에 대신 출두시켜 피의자로 조사받도록 한 경우 동생에게 범인도피행위가 인정되더라도 범인에게는 범인도피교사죄가 성립하지 않는다.

정답 : X

해설 : 무면허 운전으로 사고를 낸 사람이 동생을 경찰서에 대신 출두시켜 피의자로 조사받도록 한 행위는 범인도피교사죄를 구성한다.(대판 2006.12.7. 2005도3707)

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 도주죄에 대하여 옳지 못한 것은?

- ① 도주죄는 기대가능성으로 인하여 형량이 낮다.
- ② 집합명령위반죄는 진정부작위범이다.
- ③ 도주죄는 미수범을 처벌한다.
- ④ 집합명령위반죄는 미수범을 처벌하지 않는다.
- ⑤ 합동도주죄가 있다.

정답 : ④

해설 : 집합명령위반죄도 미수범을 처벌하는 규정이 있다.

2. 범인은닉죄에 대하여 옳지 못한 것은?

- ① 벌금이상에 해당되는 죄를 범한 범인이어야 한다.
- ② 반드시 진범일 필요는 없다.
- ③ 친족간의 특례 규정이 있다.
- ④ 본인을 위한 경우뿐만 아니라 본인에게 불이익한 경우에도 적용된다.
- ⑤ 친족간의 특례규정은 책임이 조각되는 규정이다.

정답 : ④

해설 : 친족간의 특례규정은 본인을 위한 경우에만 적용된다.

3. 범인이 타인을 교사하여 스스로를 은닉한 경우에 대한 설명 중 타당하지 않은 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 타인은 특별한 사유가 없으면 범인은닉죄가 성립한다.
- ② 타인에게 범인은닉죄가 성립하면 범인은 범인은닉죄의 교사범이 성립한다.
- ③ 타인이 친족이면 범인은닉죄가 성립하지 않는다.
- ④ 타인이 친족이어서 범인은닉죄가 성립하지 않으면 범인도 범인은닉교사죄가 성립하지 않는다.
- ⑤ 범인이 스스로 도피한 경우에는 범죄가 성립하지 않는다.

정답 : ④

해설 : 타인이 친족이어서 범인은닉죄가 성립하지 않더라도 이는 책임이 조각되는 경우이다. 따라서 이미 제한중속을 구비하였으므로 범인은 공범이 성립할 수 있으며, 판례에 의하면 범인은닉죄의 교사범이 성립한다.

♣ 학습내용 정리

1. 바지사장이 실제업주라고 하는 것에 그치지 않고, 실제 업주로부터 금전적 이익 등을 제공받기로 하고 단속이 되면 실제 업주를 숨기고 자신이 대신하여 처벌받기로 하는 역할을 맡기로 하는 등 수사기관을 착오에 빠뜨리기로 하고, 도박장 등의 운영 경위, 자금 출처, 점포의 임대차계약 경위, 종업원 채용 등에 관하여 구체적으로 거짓말을 하였으므로 범인은닉죄의 구성요건에 해당한다.
2. 판례는 ‘범인이 자신을 위하여 타인으로 하여금 허위의 자백을 하게 하여 범인도피죄를 범하게 하는 행위는 방어권의 남용으로 범인도피교사죄에 해당한다’라고 하여 긍정설의 입장이다.
3. 판례는 피해자로부터 도박자금으로 사용하기 위하여 금원을 차용한 사건에서 ‘민법 제746조의 불법원인급여에 해당하여 급여자가 수익자에 대한 반환청구권을 행사할 수 없다고 하더라도, 수익자가 기망을 통하여 급여자로 하여금 불법원인급여에 해당하는 재물을 제공하도록 하였다면 사기죄가 성립한다’라고 하여 긍정설의 입장이다.

제40강 허위공문서작성죄의 간접정범

♣ 학습목표

허위공문서작성죄의 간접정범에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

허위공문서작성죄의 간접정범의 성부
위계에 의한 공문집행방해죄의 성부
직무유기죄의 성립요건

♣ 사전테스트

1. 허위공문서작성죄는 신분범이다.

정답 : O

해설 : 제227조의 허위공문서작성죄는 작성할 권한 있는 공무원만이 주체가 될 수 있는 진정신분범이다.

2. 위계에 의한 공무집행방해죄는 공무집행방해의 결과발생이 필요하다.

정답 : O

해설 : 제136조 제1항의 공무집행방해죄와는 달리 위계에 의한 공무집행방해죄는 공무집행방해의 결과발생이 필요하다.

3. 직무유기죄는 의식적인 방임이 필요한 고의범이다.

정답 : O

해설 : 타당한 지문이다. 따라서 과실이나 무과실로 직무를 유기한 경우에는 직무유기죄는 성립하지 아니한다.

♣ 강의내용

[설문]

甲은 ○○시청에서 개인택시 운송사업면허를 발급해 주는 부서의 중간결재자로 복무하는 공무원이다. 어느 날 乙은 허위의 서류를 첨부하여 개인택시 운송사업면허발급을 신청하였다. 이를 심사하던 甲은 乙이 자신의 친구임을 우연히 알게 되었고, 乙이 제출한 서류가 허위라는 사실을 발견했음에도 불구하고 乙을 도와주기 위하여 자신의 부하직원에게 허위 사실이 기재된 개인택시 운송사업면허발급에 관한 기안문을 작성하게 하였다. 甲은 그 기안문에 스스로 중간결재를 한 후, 이러한 사실을 모르는 최종 결재권자인 국장의 결재를 받았다.

甲과 乙의 죄책을 논하시오. (20점)

[해설]

1. 서 언

사안에서 정범에 해당되는 甲의 죄책을 먼저 검토하고, 이에 가담한 乙의 죄책을 검토한다.

2. 甲의 죄책

(1) 허위공문서작성죄의 간접정범의 성부

1) 사안에서 甲은 선의인 작성권자를 이용하여 허위공문서를 작성하게 하였다. 이러한 경우에 甲이 허위공문서작성죄의 간접정범이 성립될 수 있는가에 대하여 논의가 있다.

2) 견해의 대립

이에 대하여는 ① 보조공무원은 작성명의인은 아니지만 사실상 또는 실질적으로 작성권한을 가지고 있으므로 허위공문서작성죄의 간접정범을 긍정하는 긍정설 ② 허위공문서작성죄의 주체는 작성권한 있는 공무원에 국한되는 진정신분범이므로 보조공무원의 허위공문서작성죄의 간접정범을 부정하는 부정설이 대립하고 있다.

3) 판례의 태도

판례는 ‘보조공무원이 허위공문서를 기안하여 허위인 정을 모르는 작성권자에게 제출하고 그로 하여금 그 내용이 진실한 것으로 오신케하여 서명 또는 기명날인케 함으로써 공문서를 완성한 때에는 허위공문서작성죄의 간접정범이 성립한다’라고 하여 긍정설의 입장이다.

4) 결론 및 사안의 해결

생각건대 허위공문서작성죄는 작성권한이 있는 공무원만이 주체가 될 수 있는 진정신분범이며, 긍정설이 작성명의인과 실질적으로 작성권한 있는 자를 구별하는 것은 유추해석의 여지가 있으므로 부정설이 타당하다. 이러한 부정설에 따르면 甲은 허위공문서작성죄가 성립하지 아니한다.

(2) 위계에 의한 공무집행방해죄의 성부

사안과 같이 출원에 대한 심사업무를 담당하는 공무원이 출원인의 출원사유가 허위라는 사실을 알면서도 결재권자로 하여금 오인, 착각, 부지를 일으키게 하고 그 오인, 착각, 부지를 이용하여 인·허가처분에 대한 결재를 받아낸 경우에는 출원자가 허위의 출원사유나 허위의 소명자료를 제출한 경우와는 달리 더 이상 출원에 대한 적정한 심사업무를 기대할 수 없게 되었다고 할 것이어서 그와 같은 행위는 위계로써 결재권자의 직무집행을 방해한 것에 해당하므로 위계에 의한 공무집행방해죄가 성립한다.

(3) 직무유기죄의 성부

사안과 같이 작위범인 위계에 의한 공무집행방해죄가 성립한 경우에는 부작위범인 직무유기죄는 따로 성립하지 않는다.

(4) 甲의 죄책

甲은 위계에 의한 공무집행방해죄가 성립한다.

3. 乙의 죄책

(1) 허위공문서작성죄의 공범 성립여부

사안에서 乙은 작성권자가 아니므로 허위공문서작성죄의 간접정범이 성립할 수 없으며, 甲이 허위공문서작성죄의 간접정범이 성립되는 경우라 하더라도 甲과 허위공문서작성죄에 대한 의사연락이 없으므로 공동정범이 성립할 수 없으며, 乙의 행위에 의하여 甲의 허위공문서작성죄에 대한 범의가 창출되거나, 범의가 강화내지 실행행위를 용이하게 한 것은 없으므로 교사·방조범도 성립하지 않으므로 무죄가 된다.

(2) 위계에 의한 공무집행방해죄

출원인의 경우에는 충분한 심사를 해도 출원사유가 허위임을 발견하지 못한 경우에만 위계에 의한 공무집행방해죄가 성립되는바, 사안에서는 甲이 이미 허위인 사실을 발견한 경우이므로 乙은 위계에 의한 공무집행방해죄는 성립하지 않는다.

(3) 직무유기죄의 성부

乙은 공무원이 아니므로 직무유기죄가 성립할 수 없으며, 乙과 의사연락도 없으므로 공동정범 등도 성립할 수 없다.

(4) 乙의 죄책

乙은 당 사안과 관련하여서는 무죄가 된다.

관련판례

1. 호적계장 사건

허위공문서작성죄의 주체는 직무상 그 문서를 작성할 권한이 있는 공무원에 한하고 작성권자를 보조하는 직무에 종사하는 공무원은 허위공문서작성죄의 주체가 되지 못하나 이러한 보조직무에 종사하는 공무원이 허위공문서를 기안하여 허위인 정을 모르는 작성권자에게 제출하고 그로 하여금 그 내용이 진실한 것으로 오신케 하여 서명 또는 기명날인케 함으로써 공문서를 완성한 때에는 허위공문서작성죄의 간접정범이 성립된다 할 것인 바, 면의 호적계장이 정을 모른 면장의 결재를 받아 허위내용의 호적부를 작성한 경우 허위공문서작성, 동행사죄의 간접정범이 성립된다.(대판 1990.10.30. 90도1912; 동지대판 1996.10.11. 95도1706)

2. 부하직원이 위계로 농수산국장 결재 받은 사건

피고인이, 출원인이 어업허가를 받을 수 없는 자라는 사실을 알면서도 그 직무상의 의무에 따른 적절한 조치를 취하지 않고 오히려 부하직원으로 하여금 어업허가 처리기안문을 작성하게 한 다음 피고인 스스로 중간결재를 하는 등 위계로써 농수산국장의 최종결재를 받았다면, 직무위배의 위법상태가 위계에 의한 공무집행방해행위 속에 포함되어 있는 것이라고 보아야 할 것이므로, 이와 같은 경우에는 작위범인 위계에 의한 공무집행방해죄만이 성립하고 부작위범인 직무유기죄는 따로 성립하지 아니한다.(대판 1997.2.28. 96도2825)

3. 석산개발진입로 사건

[사실관계] 농지사무를 담당하고 있는 군직원 甲은 A의 농지불법전용사실을 알고 있으면서도 이에 대하여 아무런 조치를 취하지 않을 뿐만 아니라, 농지전용허가를 해주어서는 안된다는 사실을 알면서도 허가하는 것이 타당하다는 취지의 현장출장복명서 및 심사의견서를 작성하여 결재권자에게 제출하였다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 공무원이 어떠한 위법사실을 발견하고도 직무상 의무에 따른 적절한 조치를 취하지 아니하고 위법사실을 적극적으로 은폐할 목적으로 허위공문서를 작성 행사한 경우에는 직무위배의 위법상태는 허위공문서작성 당시부터 그 속에 포함되는 것으로 작위범인 허위공문서작성, 동행사죄만이 성립하고 부작위범인 직무유기죄는 따로 성립하지 아니하나, 위 복명서 및 심사의견서를 허위작성한 것이 농지일시전용허가를 신청하자 이를 허가하여 주기 위하여 한 것이라면 직접적으로 농지불법전용 사실을 은폐하기 위하여 한 것은 아니므로 위 허위공문서작성, 동행사죄와 직무유기죄는 실체적 경합범의 관계에 있다.(대판 1993. 12.24. 92도3334)

♣ 돌발퀴즈

판례는 작성권자를 이용한 허위공문서작성죄의 간접정범을 인정하고 있지 않다.

정답 : X

해설 : 판례는 작성권자를 보조하는 자가 작성권자를 이용한 허위공문서작성죄의 간접정범을 긍정하므로 타당하지 않은 지문이다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 공정증서원본부실기재죄의 객체가 아닌 것은?

- ① 공정증서원본
- ② 면허증
- ③ 허가증
- ④ 주민등록증
- ⑤ 여권

정답 : ④

해설 : 주민등록증은 공정증서원본부실기재죄의 객체인 등록증이 아니다.

2. 다음 중 공정증서원본이 아닌 것은?

- ① 공정증서정본
- ② 상업등기부
- ③ 부동산등기부
- ④ 합동법률사무소명의로 작성된 공정증서
- ⑤ 자동차등록원부

정답 : ①

해설 : 공정증서정본은 공정증서원본이 아니다.

3. 농지사무를 담당하고 있는 군직원 甲은 A의 농지불법전용사실을 알고 있으면서도 이에 대하여 아무런 조치를 취하지 않을 뿐만 아니라, 농지전용허가를 해주어서는 안된다는 사실을 알면서도 허가하는 것이 타당하다는 취지의 현장출장복명서 및 심사의견서를 작성하여 결재권자에게 제출하였다. 판례에 의할 때 甲의 죄책은? ?

- ① 허위공문서작성죄와 동행사죄
- ② 직무유기죄
- ③ 허위공문서작성죄와 동행사 및 직무유기죄의 실체적 경합
- ④ 허위공문서작성죄와 동행사 및 직무유기죄의 상상적 경합
- ⑤ 허위공문서작성죄와 직무유기죄의 실체적 경합

정답 : ③

해설 : 판례에 의하면 허위공문서작성죄와 동행사 및 직무유기죄의 실체적 경합이 된다.

♣ 학습내용 정리

1. 판례는 ‘보조공무원이 허위공문서를 기안하여 허위인 정을 모르는 작성권자에게 제출하고 그로 하여금 그 내용이 진실한 것으로 오신케하여 서명 또는 기명날인케 함으로써 공문서를 완성한 때에는 허위공문서작성죄의 간접정범이 성립한다’라고 하여 긍정설의 입장이다.
2. 출원에 대한 심사업무를 담당하는 공무원이 출원인의 출원사유가 허위라는 사실을 알면서도 결재권자로 하여금 오인, 착각, 부지를 일으키게 하고 그 오인, 착각, 부지를 이용하여 인·허가처분에 대한 결재를 받아낸 경우에는 출원자가 허위의 출원사유나 허위의 소명 자료를 제출한 경우와는 달리 더 이상 출원에 대한 적정한 심사업무를 기대할 수 없게 되었다고 할 것이어서 그와 같은 행위는 위계로써 결재권자의 직무집행을 방해한 것에 해당하므로 위계에 의한 공무집행방해죄가 성립한다.

제41강 범인도피죄와 친족간의 특례

♣ 학습목표

범인도피죄와 친족간의 특례에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

진범이 아닌 자의 범인도피죄의 객체 여부
범인도피죄와 친족간의 특례
소극적 신분과 공범의 성립요건

♣ 사전테스트

1. 판례에 의하더라도 진범이 아닌 자는 범인도피죄의 객체가 될 수 없다.

정답 : X

해설 : 판례에 의하면 진범이 아닌 자도 범인도피죄의 객체가 될 수 있으므로 타당하지 않은 지문이다.

2. 친족이 범인을 도피한 경우에는 책임이 조각되어 처벌되지 않는다.

정답 : O

해설 : 친족이 범인을 도피한 경우에는 친족간의 특례가 적용되어 처벌되지 않는다.

3. 판례는 공범종속설 중 제한종속형식을 따르고 있다.

정답 : O

해설 : 범인이 자신을 위하여 타인으로 하여금 허위의 자백을 하게 하여 범인도피죄를 범하게 하는 행위는 방어권의 남용으로 범인도피교사죄에 해당하는바, 이 경우 그 타인이 형법 제151조 제2항에 의하여 처벌을 받지 아니하는 친족, 호주 또는 동거 가족에 해당한다 하여 달리 볼 것은 아니다.(대판 2006.12.7. 2005도3707)

♣ 강의내용

[설문]

乙은 우연히 친구들이 A를 상해하는 현장에 있게 되었으나 범행에는 전혀 가담하지 않았다. 그러나 이로 인해 乙은 경찰로부터 공범으로 수사를 받게 되자 동생 甲에게 사정을 설명하고 도피자금을 마련해 달라고 부탁하였다. 이에 甲은 乙에게 도피자금으로 500만 원을 제공하였다.

1. 甲에게 범인도피죄가 성립되는지 여부를 그 근거와 함께 설명하십시오. (20점)
2. 乙에게 범인도피교사죄가 성립되는지 여부를 그 근거와 함께 설명하십시오. (10점)

[해설]

[1. 문 해설 (20점)]

1. 논의점

사안에서 甲이 乙에게 도피자금으로 500만원을 제공한 것은 도피하게 하는 행위에 해당하는지에 대하여 ① 乙은 진범이 아니라 범죄혐의자에 불과하므로 범인도피죄의 객체인 죄를 범한 자에 해당하는지 ② 도피자금으로 500만원을 제공한 것이 범인도피행위에 포함되는지 ③ 乙이 甲의 형인 경우에 친족간의 특례가 적용되는지를 검토한다.

2. 乙이 범인도피죄의 객체가 될 수 있는지 여부

(1) 논의점

사안에서 乙은 A를 상해한 진범이 아니지만 수사기관에 의하여 피의자로 인정되고 있으므로 이러한 진범이 아닌 자가 범인은닉·도피죄에 있어 객체가 될 수 있는가에 대하여 논의가 있다.

(2) 견해의 대립

이에 대하여는 ① 진범이 아닌 자에 대한 은닉행위는 국가의 정당한 형벌권행사를 방해한다고 볼 수 없으므로 범인은닉죄의 객체는 진범이어야 한다는 긍정설 ② 진범이 아닐지라도 범죄의 혐의를 받고 수사 또는 소추중인 자를 은닉하는 행위는 국가의 형사사법작용을 해하는 점에서 진범을 은닉하는 경우와 다르지 않으므로 범인은닉죄의 객체는 반드시 진범일 필요는 없다는 부정설이 대립하고 있다.

(3) 판례의 태도

판례는 형법 제151조 제1항 소정의 ‘죄를 범한 자’라 함은 범죄의 혐의를 받아 수사대상이 되어 있는 자를 포함한다. 따라서 구속수사의 대상이 된 공소외인이 그 후 무혐의로 석방되었다 하더라도 위 죄의 성립에는 영향이 없다라고 하여 부정설의 입장이다.

(4) 결론 및 사안의 적용

생각건대 진범인지의 여부는 법원의 확정판결이 있기 전까지는 알 수 없으며, 본죄는 추상적 위험범이라고 할 것이므로 진범 아닌 자를 은닉한 경우에도 본죄가 성립한다는 긍정설이 타당하다. 따라서 乙은 진범이 아니더라도 범인은닉죄의 객체가 되므로 甲에게는 범인은닉죄가 성립할 수 있다.

3. 범인도피행위의 해당여부

- (1) 사안에서 甲은 乙에게 도피자금으로 500만원을 제공하고 있는바, 이러한 행위가 범인은닉이나 도피행위에 해당하는지가 문제된다.
- (2) 범인은닉죄에 있어 은닉이란 수사기관의 발견·체포를 곤란하게 하거나 면할 수 있는 장소를 제공하여 범인을 숨겨주는 적극적인 행위를 말한다. 그리고 범인도피란 은닉 이외의 방법으로 수사기관의 발견·체포를 곤란 내지 불가능하게 하는 일체의 행위를 말한다. 다만 도피행위는 직접 범인을 도피시키는 행위 또는 도피를 직접적으로 용이하게 하는 행위에 한정된다.
- (3) 사안에서 甲의 행위는 乙의 도피를 직접적으로 용이하게 하는 행위로서 범인도피행위에 해당한다.

4. 친족간의 특례의 적용여부

(1) 형법규정

사안에서 甲은 乙의 동생으로서 친족이다. 형법은 제151조 제2항에서 ‘친족 또는 동거의 가족이 본인을 위하여 범인은닉·도피죄를 범한 때에는 처벌하지 아니한다’는 규정을 두고 있다.

(2) 법적 성질

친족간의 특례의 법적 성질에 대하여는 ① 친족간에는 범인은닉을 하지 않을 기대가능성이 없으므로 책임이 조각된다는 책임조각설과 ② 친족간에도 범죄는 성립하지만 친족이라는 점에 비추어 형만 면제된다는 인적 처벌조각사유설이 대립하고 있다. 그러나 제151조의 제2항에서는 ‘처벌하지 아니한다’고 규정하고 있으므로 형법이 면제가 되는 경우에는 ‘면제한다’라고 규정한 것과 다르므로 범죄의 성립을 부정하는 책임조각설이 타당하다.

(3) 사안의 해결

이러한 책임조각설에 따르면 사안에서 甲이 乙에 대하여 범인도피죄를 범하였다고 하더라도 이는 친족간의 특례의 적용으로 책임이 조각되어 甲은 범인도피죄가 성립하지 않는다.

[2. 문 해설 (10점)]

1. 논의점

乙이 동생 甲에게 도피자금을 마련해 달라고 부탁하여 甲이 乙에게 도피자금 500만원을 제공받은바 이러한 乙의 행위는 甲에 대한 교사행위로 볼 수 있다. 甲이 범인도피죄의 구성요건에 해당하고 위법하다면 공범의 종속성설 중 제한종속형식에 따라 甲의 범인도피행위에 가담한 경우 乙은 공범의 성립이 가능할 수 있다. 문제는 범인이 친족을 포함한 제3자에게 자신을 도피시키게 한 것에 대하여 교사범을 인정할 수 있는가이다.

2. 견해의 대립

이에 대하여는 ① 본범이 타인을 교사하여 자기를 은닉 또는 도피하게 한 경우는 자기비호권의 한계를 일탈한 것으로서 기대가능성이 부정되는 경우가 아니므로 자기범인은닉의 교사범을 인정하는 긍정설 ② 본범이 타인을 교사하여 자기를 은닉 또는 도피하게 한 경우는 자기비호권의 연장이라고 볼 수 있으므로 자기범인은닉의 교사범을 부정하는 부정설이 대립하고 있다.

3. 판례의 태도

판례는 ‘범인이 자신을 위하여 타인으로 하여금 허위의 자백을 하게 하여 범인도피죄를 범하게 하는 행위는 방어권의 남용으로 범인도피교사죄에 해당한다’라고 하여 긍정설의 입장이다.

4. 결론 및 사안의 해결

생각건대 현행법이 자기범인은닉죄를 구성요건화하지 않은 것은 국가적인 사법적 기능에서 불법을 창출하였더라도 개인적 측면에서 적법행위에 대한 기대가능성이 없기 때문이다. 그렇다면 타인의 교사하여 범인은닉죄를 범하게 하였다고 하더라도 범인 자신은 개인적 측면이 고려되어 교사범의 성립을 인정하지 않는 것이 타당하다. 이러한 부정설의 입장을 따르면 사안에서 乙은 범인도피죄의 교사범이 성립하지 않고 무죄가 된다.

관련판례

1. 범인은닉 후 무형의로 석방된 사건

범인은닉죄는 형사사법에 관한 국권의 행사를 방해하는 자를 처벌하고자 하는 것이므로 형법 제151조 제1항 소정의 ‘죄를 범한 자’라 함은 범죄의 혐의를 받아 수사대상이 되어 있는 자를 포함한다. 따라서 구속수사의 대상이 된 공소외인이 그 후 무형의로 석방되었다 하더라도 위 죄의 성립에는 영향이 없다.(대판 1982.1.26. 81도1931)

2. 간접적으로 범인이 안심하여 도피할 수 있도록 한 사건

[사실관계] 甲은 A로부터 유가증권 위조, 사기 등의 범행을 범하고 미국으로 도주한 범인 B에게 송금하여 달라는 부탁과 함께 자기앞수표를 받아 이를 가명으로 예금하여 두고 송금은 아직 하지 않았다. 또한 甲은 B가 편취하여 마련한 자금 중 일부를 여러 차례에 걸쳐 가명으로 예금하고 입금과 출금을 되풀이하면서 그 인출한 돈 중 일부를 B의 자녀들의 생활비 및 B의 유령회사들의 운영유지비 등으로 사용하게 하고 B의 도피자금으로 비축하여 B가 안심하고 도피생활을 계속할 수 있도록 하였다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 형법 제151조에서 규정하는 범인도피죄는 범인은닉 이외의 방법으로 범인에 대한 수사, 재판 및 형의 집행 등 형사사법의 작용을 곤란 또는 불가능하게 하는 행위를 말하는 것으로서 그 방법에는 어떠한 제한이 없고, 또 이는 위험범으로서 현실적으로 형사사법의 작용을 방해하는 결과가 초래될 것이 요구되지는 아니하나, 다른 한편 형사사법의 작용을 방해하는 모든 행위 내지 범인을 돕는 모든 행위가 범인도피죄의 구성요건에 해당한다고 본다면 이는 일반 국민의 행동의 자유를 지나치게 제한하는 것으로서 부당하므로, 범인도피행위는 범인을 도주하게 하는 행위 또는 도주하는 것을 직접적으로 용이하게 하는 행위에 한정된다고 봄이 상당하고, 그 자체가 도피시키는 것을 직접의 목적으로 한 것이라고는 보기 어려운 행위로 말미암아 간접적으로 범인이 안심하여 도피할 수 있도록 하는 것과 같은 경우는 이에 포함되는 것이 아니라고 해석하여야 하며, 나아가 어떤 행위가 범인도피죄에 해당하는 것처럼 보이더라도 그것이 사회적으로 상당성이 있는 행위일 때에는 이 또한 처벌할 수 없다고 보아야 한다.(대판 1995.3.3. 93도3080)

3. 동생을 피의자로 조사받게 한 사건]

[1] 범인이 자신을 위하여 타인으로 하여금 허위의 자백을 하게 하여 범인도피죄를 범하게 하는 행위는 방어권의 남용으로 범인도피교사죄에 해당하는바, 이 경우 그 타인이 형법 제151조 제2항에 의하여 처벌을 받지 아니하는 친족, 호주 또는 동거 가족에 해당한다 하여 달리 볼 것은 아니다. [2] 무면허 운전으로 사고를 낸 사람이 동생을 경찰서에 대신 출두시켜 피의자로 조사받도록 한 행위는 범인도피교사죄를 구성한다.(대판 2006.12.7. 2005도3707)

♣ 돌발퀴즈

범인을 간접적으로 도피시킨 경우에는 범인도피죄가 성립하지 않는다.

정답 : O

해설 : 범인도피행위는 범인을 도주하게 하는 행위 또는 도주하는 것을 직접적으로 용이하게 하는 행위에 한정된다고 봄이 상당하고, 그 자체가 도피시키는 것을 직접의 목적으로 한 것이라고는 보기 어려운 행위로 말미암아 간접적으로 범인이 안심하여 도피할 수 있도록 하는 것과 같은 경우는 이에 포함되는 것이 아니다.(대판 1995.3.3. 93도 3080)

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 판례에 의할 때 진범이 아닌 혐의자를 도피한 갑의 죄책은?

- ① 구성요건해당성이 없어 무죄
- ② 위법성이 조각되어 무죄
- ③ 책임이 조각되어 무죄
- ④ 범인도피죄가 성립한다.
- ⑤ 범인도피죄가 성립하지만 처벌이 면제된다.

정답 : ④

해설 : 판례에 의하면 범인도피죄가 성립한다.

2. 친족간의 특례가 적용되지 않는 범죄는?

- ① 범인도피죄
- ② 범인은닉죄
- ③ 도주죄
- ④ 증거인멸죄
- ⑤ 모해증거인멸죄

정답 : ③

해설 : 도주죄는 친족간의 특례가 적용되지 않는다.

3. 도주죄에 대한 설명 중 타당하지 않는 것은?

- ① 특수도주죄가 있다.
- ② 도주원조죄는 도주죄 보다 형이 무겁다.
- ③ 간수자의 도주원조죄는 예비·음모를 처벌한다.
- ④ 도주죄는 미수범을 처벌한다.
- ⑤ 도주원조죄는 예비·음모를 처벌하지 않는다.

정답 : ⑤

해설 : 도주원조죄도 제150조에 따라 예비·음모를 처벌한다.

♣ 학습내용 정리

1. 판례는 형법 제151조 제1항 소정의 ‘죄를 범한 자’라 함은 범죄의 혐의를 받아 수사대상이 되어 있는 자를 포함한다. 따라서 구속수사의 대상이 된 공소외인이 그 후 무혐의로 석방되었다 하더라도 위 죄의 성립에는 영향이 없다라고 하여 부정설의 입장이다.
2. 범인은닉죄에 있어 은닉이란 수사기관의 발견·체포를 곤란하게 하거나 면할 수 있는 장소를 제공하여 범인을 숨겨주는 적극적인 행위를 말한다. 그리고 범인도피란 은닉 이외의 방법으로 수사기관의 발견·체포를 곤란 내지 불가능하게 하는 일체의 행위를 말한다. 다만 도피행위는 직접 범인을 도피시키는 행위 또는 도피를 직접적으로 용이하게 하는 행위에 한정된다.
3. 친족간의 특례의 법적 성질에 대하여는 ① 친족간에는 범인은닉을 하지 않을 기대가능성이 없으므로 책임이 조각된다는 책임조각설과 ② 친족간에도 범죄는 성립하지만 친족이라는 점에 비추어 형만 면제된다는 인적 처벌조각사유설이 대립하고 있다.
4. 판례는 ‘범인이 자신을 위하여 타인으로 하여금 허위의 자백을 하게 하여 범인도피죄를 범하게 하는 행위는 방어권의 남용으로 범인도피교사죄에 해당한다’라고 하여 긍정설의 입장이다.

제42강 수뢰죄의 직무범위와 관련 문제

♣ 학습목표

수뢰죄 관련문제를 확인하고 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

수뢰죄의 직무의 범위

증거인멸행위에 대한 죄책 검토

범인의 범인도피죄 교사범의 성부

♣ 사전테스트

1. 판례에 의하면 수뢰죄와 증거인멸죄는 필요적 공범이다.

정답 : O

해설 : 타당한 지문이다.

2. 증거인멸죄는 친족간의 특례가 적용된다.

정답 : O

해설 : 제155조 제4항에 의하여 증거인멸죄의 경우에도 친족간의 특례는 적용된다.

3. 증거인멸죄에는 자백, 자수의 특례규정이 있다.

정답 : X

해설 : 증거인멸죄의 경우에는 위증죄와는 달리 자백, 자수의 특례규정이 없으므로 타당하지 않은 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

A 경찰서 교통사고조사 담당 경찰관 甲은 관내에서 위조상표 부착 의류 판매점을 운영하여 상표법위반죄를 범하고 있는 乙로부터 불법영업을 목인해 주고 단속에 대비한 여러 가지 편의도 봐 달라는 부탁을 받고 그 사례비로 700만원을 건네받았다.

1. 甲이 乙로부터 700만원을 받은 행위에 대한 甲의 죄책을 논하시오. (5점)
2. 위 사례에서 그 후 A 경찰서의 지적재산권 담당 경찰관 丙이 위 의류 판매점을 단속하고, 단속 현장에서 위조상표 부착 의류 1,000점을 압수하였다. 乙은 단속된 직후 丙에게 찾아가서 “의류 100점만 가지고 영업한 것으로 수사서류를 작성하고, 900점은 돌려 달라.”라고 부탁하였다. 丙은 乙의 부탁대로 위 의류 900점을 乙에게 돌려주었고, 단속 현장에 있었던 위조상표 부착 의류가 100점이었다는 내용으로 丙 명의의 단속보고서를 작성하여 사건기록에 편철한 뒤, 위조상표 부착 의류 100점에 대하여만 수사하였다. 이 경우 乙과 丙의 죄책을 논하시오(특별법위반의 점과 乙이 甲에게 금품을 제공한 점은 논외로 함). (25점)

[해설]

[1. 문 해설 (5점)]

1. 논의점

사안에서 甲은 교통사고조사 담당경찰관임에도 불구하고, 상표법위반죄와 관련된 범죄에 대하여 乙로부터 금품을 받고 있다. 이러한 甲의 행위가 수뢰죄에 해당하는지가 문제된다.

2. 수뢰죄에서의 직무의 범위

수뢰죄가 성립하기 위해서는 직무와 관련된 부당한 대가가 인정되어야 한다. 사안의 경우에는 특히 직무관련성이 문제되는데 수뢰죄에서 말하는 직무의 범위는 ① 공무원의 일반적·추상적 직무권한에 속한 것이면 족하고 ② 현재 구체적으로 담당하고 있는 사무임을 요하지 않으며 ③ 사무분장에 따라 현실적으로 담당하지 않는 직무라도 법령상 일반적인 직무권한에 속하는 직무를 포함한다고 보는 것이 일반적이다.

3. 판례의 태도

판례도 ‘교통계에 근무하는 경찰관이 도박장개설 및 도박범행을 목인하고 편의를 봐주는 데 대한 사례비 명목으로 금원을 수수하고 나아가 도박장개설 및 도박범행사실을 잘 알면서도 이를 단속하지 아니한 경우 직무관련성이 인정된다’라고 하여 직무관련성을 인정하고 있다.

4. 사안의 해결

이러한 학설과 판례의 태도에 따르면 甲은 수뢰죄(제129조 제1항)의 죄가 성립한다.

[2. 문 해설 (25점)]

I. 丙의 죄책

1. 서 언

사안에서 丙은 ① 의류 900점을 돌려주고 ② 허위단속보고서를 작성하고 ③ 의류 100점에 대하여만 수사하고 있다. 이러한 각개의 사안에 대하여 검토한다.

2. 의류 900점을 돌려 준 행위에 대한 평가

丙은 乙의 상표법위반행위의 증거물을 압수하였다가 이를 부당하게 乙에게 돌려주고 있다. 사안의 의류는 상표법위반행위의 증거물이므로 이에 대하여는 증거인멸죄가 성립한다.

3. 허위단속보고서를 작성한 행위에 대한 평가

丙은 실제로는 1000점의 증거물을 압수하였으나, 100점의 증거물을 압수한 것처럼 허위의 단속보고서를 작성하고 있다. 이러한 丙의 행위는 작성권한이 있는 공무원이 허위의 공문서를 작성하고 있는 것이므로 허위공문서작성죄가 성립한다. 또한 이를 기록에 편철하여 두었으므로 이에 대한 행사죄가 성립한다.

4. 의류 900점을 돌려주고 의류 100점에 대하여만 수사한 행위에 대한 평가

실제로 1000점에 대한 범죄행위가 있었지만 이에 대하여 100점에 대한 수사만 진행한 것은 공무원이 정당한 이유없이 직무를 유기한 경우이므로 직무유기죄가 성립한다.

5. 죄수문제와 丙의 죄책

(1) 기본적인 범죄

- 1) 기본적으로 丙의 죄책은 ① 증거인멸죄 ② 허위공문서작성죄 ③ 동행사죄 ④ 직무유기죄가 성립한다고 볼 수 있다. 그러나 이들 범죄에 대한 죄수문제에 대하여 논의가 있다.
- 2) 먼저 허위공문서작성죄와 동행사죄에 대하여 상상적 경합설과 실제적 경합설의 대립이 있으나 실제적 경합으로 보는 것이 다수설과 판례의 태도이다.
- 3) ①의 증거인멸죄와 ④의 직무유기죄의 죄수관계가 문제되나, 종래의 판례는 이를 상상적 경합으로 파악하였으나, 최근 전합판례에서는 ‘작위범인 증거인멸죄가 성립하게 되면 부작위범인 직무유기죄는 따로 성립하지 아니한다’라고 판시하여 그 태도를 변경하였다.
- 4) ②의 허위공문서작성죄와 ④의 직무유기죄의 죄수관계가 문제되나 사안의 경우에는 위법사실을 은폐하기 위한 경우이므로 판례의 입장에 따르면 직무유기죄는 따로 성립하지 아니한다.

(2) 丙의 죄책

丙의 죄책은 다수설과 판례의 논리에 입각하면 증거인멸죄(제155조 제1항), 허위공문서작성죄(제227조), 동행사죄(제229조)의 실제적 경합범이 성립한다.

II. 乙의 죄책

1. 서 언

乙은 丙에게 “의류 100점만 가지고 영업한 것으로 수사서류를 작성하고, 900점은 돌려 달라.”고 교사하여 丙이 이러한 범행을 하고 있으므로 丙의 각개의 범죄에 대하여 교사범이 성립할 수 있는가가 문제된다.

2. 증거인멸죄의 교사범의 성립문제

(1) 논의점

사안에서 乙은 자기범행에 대한 증거인멸을 교사하고 있다. 이러한 자기증거인멸에 대한 교사범이 성립될 수 있는가에 대하여 논의가 있다.

(2) 견해의 대립

자기의 형사사건에 대한 증거를 인멸하기 위하여 타인을 교사한 경우에 ① 비호권의 남용으로 적법행위의 기대가능성이 없다고 할 수 없다는 이유로 교사범이 성립할 수 있다는 적극설 ② 자기비호의 연장일 뿐이며 정범이 될 수 없는 자의 교사행위에 의하여 본죄가 성립하는 것은 인정할 수 없다는 소극설(다수설)이 대립하고 있다.

(3) 판례의 태도

판례는 '자기의 형사 사건에 관한 증거를 인멸하기 위하여 타인을 교사하여 죄를 범하게 한 자에 대하여는 증거인멸교사죄가 성립한다'라고 하여 긍정설의 입장이다.

(4) 검토 및 사안의 해결

생각건대 범인의 증거인멸죄를 처벌하지 않는 것은 범인에게 적법행위에 대한 기대가능성이 없기 때문이므로 범인은 책임조각적 신분이다. 따라서 책임조각적 신분은 개인적인 사유로 인한 경우이므로 범인이 타인에게 증거인멸을 교사하였더라도 처벌되지 않아야 하며 또한 정범이 될 수 없는 자가 보다 가벼운 교사범이 성립된다는 것도 논리상 모순이므로 부정설이 타당하다.

3. 허위공문서 작성죄 및 동행사죄의 교사범

사안에서 乙은 허위의 수사서류를 작성하라고 교사하고 있으므로 허위공문서작성죄의 교사범이 문제된다. 허위공문서작성죄는 작성권한이 있는 공무원만이 범할 수 있는 신분범인데 乙은 신분이 없는 자이므로 동죄의 성립이 문제되지만, 현행법 제33조 본문에 따라 허위공문서작성죄의 교사범이 성립한다. 또한 동행사도 교사한 것으로 평가되므로 허위공문서 등의 행사죄의 교사범도 성립한다.

4. 직무유기죄의 문제

사안에서 乙에게 직무유기죄의 교사범의 성립여부가 문제되지만, 丙에게 범죄가 성립되지 아니하는 한 공범종속성의 원칙상 직무유기죄의 교사범은 성립하지 아니한다.

5. 乙의 죄책

사안에서 乙은 허위공문서작성죄의 교사범 및 동행사의 교사범의 실체적 경합범이 성립한다.

관련판례

1. 교통계 근무 경찰이 도박장 단속하지 않은 사건

[1] 뇌물죄는 직무집행의 공정과 이에 대한 사회의 신뢰에 기하여 직무행위의 불가매수성을 그 직접의 보호법익으로 하고 있으므로 뇌물성은 의무위반 행위나 청탁의 유무 및 금품수수 시기와 직무집행 행위의 전후를 가리지 아니한다 할 것이고, 따라서 뇌물죄에서 말하는 '직무'에는 법령에 정하여진 직무뿐만 아니라 그와 관련 있는 직무, 과거에 담당하였거나 장래에 담당할 직무 외에 사무분장에 따라 현실적으로 담당하지 않는 직무라도 법령상 일반적인 직무권한에 속하는 직무 등 공무원이 그 직위에 따라 공무로 담당할 일체의 직무를 포함한다 할 것이고(대법원 1995.9.5. 선고 95도1269 판결, 1996.1.23. 선고 94도3022 판결 등 참조), 수뢰후부정처사죄에서 말하는 '부정한 행위'라 함은 직무에 위배되는 일체의 행위를 말하는

것으로 직무행위 자체는 물론 그것과 객관적으로 관련 있는 행위까지를 포함한다 할 것이다. [2] 경찰관직무집행법 제2조 제1호는 경찰관이 행하는 직무 중의 하나로 ‘범죄의 예방·진압 및 수사’를 들고 있고, 이와 같이 범죄를 예방하거나, 진압하고, 수사하여야 할 일반적 직무권한을 가지는 피고인이 도박장개설 및 도박범행을 묵인하고 편의를 봐주는 데 대한 사례비 명목으로 금품을 수수하고, 나아가 도박장개설 및 도박범행사실을 잘 알면서도 이를 단속하지 아니하였다면, 이는 경찰관으로서 직무에 위배되는 부정한 행위를 한 것이라 할 것이고, 비록 피고인이 이 사건 범행당시 원주경찰서 교통계에 근무하고 있어 도박범행의 수사 등에 관한 구체적인 사무를 담당하고 있지 아니하였다 하여도 달리 볼 것은 아니라고 할 것이다.(대판 2003.06.13. 2003도1060)

2. 경찰관이 압수물 돌려 준 사건

[사실관계] 경찰서 방법과장이던 甲은 부하직원 乙이 음반·비디오물 및 게임물에 관한 법률 위반 혐의로 A오락실을 단속하여 범죄행위에 제공된 증거물로 오락기의 변조 기판을 압수하여 위 방법과 사무실에 보관중임을 乙로부터 보고받았다. 甲은 위 압수물을 수사계에 인계하고 검찰에 송치하여 범죄혐의의 입증에 사용하도록 하는 등의 적절한 조치를 취해야 할 직무상의 의무가 있음에도 불구하고 이러한 조치를 취하지 않고, 乙에게 압수한 변조 기판을 A오락실 업주에게 돌려주라고 지시하였고, 乙은 이를 A오락실 업주에 돌려주었다. 甲의 죄책은?

[판결요지] 경찰서 방법과장이 부하직원으로부터 음반·비디오물 및 게임물에 관한 법률 위반 혐의로 오락실을 단속하여 증거물로 오락기의 변조 기판을 압수하여 사무실에 보관중임을 보고받아 알고 있었음에도 그 직무상의 의무에 따라 위 압수물을 수사계에 인계하고 검찰에 송치하여 범죄 혐의의 입증에 사용하도록 하는 등의 적절한 조치를 취하지 않고, 오히려 부하직원에게 위와 같이 압수한 변조 기판을 돌려주라고 지시하여 오락실 업주에게 이를 돌려준 경우, 작위범인 증거인멸죄만이 성립하고 부작위범인 직무유기(거부)죄는 따로 성립하지 아니한다.(대판 2006.10.19. 2005도3909 전합)

[판결이유 중 일부 인용] 사법경찰관인 피고인이 피의자 등에게 관련자를 은폐하기 위하여 허위진술을 하도록 교사하였다면 타인을 교사하여 증거인멸죄를 범하게 한 것인 동시에 그것이 또한, 정당한 직무집행을 거부한 것이 된다고 판시한 대법원 1967.7.4. 선고 66도840 판결은 이를 변경하기로 한다.

3. 자기의 형사사건에 관한 증거인멸을 교사한 사건

자기의 형사 사건에 관한 증거를 인멸하기 위하여 타인을 교사하여 죄를 범하게 한 자에 대하여는 증거인멸교사죄가 성립한다.(대판 2000.3.24. 99도5275)

♣ 돌발퀴즈

현행 형법상 모해증거인멸죄는 존재한다.

정답 : O

해설 : 현행 형법은 제155조 제3항에서 모해증거인멸죄를 규정하고 있다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 수뢰죄에 대한 설명 중 타당하지 않은 것은?

- ① 단순수뢰죄는 청탁을 요건으로 하지 않는다.
- ② 사전수뢰죄도 청탁을 요건으로 하지 않는다.
- ③ 제3자 뇌물제공죄는 부정한 청탁을 요건으로 한다.
- ④ 수뢰죄는 공무원 또는 중재인이 주체가 된다.
- ⑤ 알선수뢰죄는 공무원만이 주체가 된다.

정답 : ②

해설 : 사전수뢰죄는 청탁을 요건으로 한다. 제129조 제2항 참조.

2. 수뢰죄의 행위태양이 아닌 것은?

- ① 수수
- ② 요구
- ③ 약속
- ④ 취득
- ⑤ 알선

정답 : ④

해설 : 취득은 수뢰죄의 행위태양이 아니다.

3. 수뢰죄와 배임수재죄의 동일한 점은?

- ① 법익
- ② 객체
- ③ 행위태양
- ④ 미수처벌
- ⑤ 필요적 몰수

정답 : ⑤

해설 : 수뢰죄와 배임수재죄는 필요적 몰수라는 점에서 동일하다.

♣ 학습내용 정리

1. 판례는 ‘교통계에 근무하는 경찰관이 도박장개설 및 도박범행을 묵인하고 편의를 봐주는 데 대한 사례비 명목으로 금원을 수수하고 나아가 도박장개설 및 도박범행사실을 잘 알면서도 이를 단속하지 아니한 경우 직무관련성이 인정된다’라고 하여 직무관련성을 인정하고 있다.
2. 자기의 형사사건에 대한 증거를 인멸하기 위하여 타인을 교사한 경우에 ① 변호권의 남용으로 적법행위의 기대가능성이 없다고 할 수 없다는 이유로 교사범이 성립할 수 있다는 적극설 ② 자기비호의 연장일 뿐이며 정범이 될 수 없는 자의 교사행위에 의하여 본죄가 성립하는 것은 인정할 수 없다는 소극설(다수설)이 대립하고 있다.
3. 판례는 ‘자기의 형사 사건에 관한 증거를 인멸하기 위하여 타인을 교사하여 죄를 범하게 한 자에 대하여는 증거인멸교사죄가 성립한다’라고 하여 긍정설의 입장이다.

제43강 모해위증과 공범과 신분

♣ 학습목표

모해위증사건의 평석을 할 수 있다.

♣ 학습내용

위증죄의 허위의 판단기준

목적의 신분성에 대한 검토

공범의 공범종속성과 책임의 개별화에 대한 검토

♣ 사전테스트

1. 판례는 위증죄의 허위성에 대하여 주관설을 따르고 있다.

정답 : O

해설 : 다수설과 판례는 위증죄의 허위성의 판단에 대하여 주관설을 따르고 있으므로 타당한 지문이다.

2. 판례는 행위관련적인 요소인 목적을 행위자관련적인 요소인 신분으로 보고 있다.

정답 : O

해설 : 판례는 목적을 신분으로 보고 있으므로 타당한 지문이다.

3. 판례는 공범종속성보다 책임의 개별화를 강조한다.

정답 : O

해설 : 판례는 공범종속성보다 책임의 개별화를 강조하고 있다. 즉 제33조 단서를 제31조에 우선하고 있으므로 타당한 지문이다.

♣ 강의내용

[설문]

乙은 상해죄로 기소된 A를 모해할 목적으로 증인 甲에게 “A가 피해자를 상해하는 장면을 보았다고 위증해주면 3백만 원을 주겠다.”라고 제안하였다. 甲은 A가 아니라 B가 피해자를 상해한 것으로 기억하고 있었다. 하지만 甲은 다른 증인들도 있었기 때문에 자신의 위증이 A에게 불이익이 되리라고 전혀 생각하지 않았고, 마침 돈도 궁하였기 때문에 乙의 제안을 받아들였다. 공판기일에 재판정에 출석한 甲은 증인선서를 한 후 “피해자를 상해한 사람은 분명히 A이다.”라고 진술하였다.

1. 피해자를 상해한 사람이 A로 밝혀진 경우, 甲의 죄책을 논하시오. (10점)
2. 피해자를 상해한 사람이 B로 밝혀진 경우, 乙의 죄책을 논하시오. (10점)

[해설]

[1. 문 해설 (10점)]

1. 논의점

설문에서 甲은 상해한 사람이 B라고 기억하였지만 甲은 상해한 사람이 A라고 진술하였다. 이러한 경우에는 위증죄에서 말하는 허위의 진술에서 허위의 내용을 어떻게 파악하느냐에 따라 그 결론이 달라지는바, 허위의 판단기준에 대하여 논의가 있다.

2. 견해의 대립

허위의 판단기준에 대하여는 ① 위증죄는 증인의 불성실을 벌하는 것이 아니고, 객관적 진실과 일치하는 증언은 사법에 대한 진실발견의 위험이 초래될 수 없으므로 허위를 객관적 사실에 반하는 것으로 이해하는 객관설 ② 증인이 자기 기억에 반하는 진술을 한 때에는 이미 국가의 심판기능의 적정한 행사에 대한 추상적 위험을 인정할 수 있으므로 허위를 증인이 자기 기억에 반하는 진술을 하는 것으로 이해하는 주관설이 대립하고 있다.

3. 판례의 태도

판례는 ‘위증죄에 있어서의 허위의 공술이란 증인이 자기의 기억에 반하는 사실을 진술하는 것을 말하는 것으로서 그 내용이 객관적 사실과 부합한다고 하여도 위증죄의 성립에 장애가 되지 않는다’라고 하여 주관설의 입장이다.

4. 결론 및 사안의 해결

생각건대 증인에게 자기의 기억이상의 진술을 기대할 수 없으며, 증인의 사명은 자기의 기억을 진술하여 법원에 의한 실체적 진실발견을 돕는데 그쳐야 하므로 주관설이 타당하다. 이러한 주관설에 따르면 甲은 위증죄가 성립한다.

[2. 문 해설 (10점)]

1. 논의점

甲의 진술에 대해 피해자를 상해한 사람이 B인 경우에는 허위의 내용에 관한 주관설과 객관설 중 어느 학설에 따르더라도 甲은 위증죄가 성립하게 된다. 그러나 甲은 자신의 위증이 A에게 불이익이 되리라고 전혀 생각하지 않았으므로 A에 대한 모해목적이 있었다고 보기 어렵다. 그러나 이러한 모해목적이 없는 사람을 이용한 모해목적을 가진 교사자를 어떻게 처벌할 것인가를 두고 논의가 있다.

2. 견해의 대립

이에 대하여는 ① 모해목적을 신분으로 보고 책임의 개별화를 강조하는 입장에서 乙을 모해목적 위증죄의 교사범으로 보는 모해목적 위증죄의 교사범설 ② 목적을 신분으로 보지 않고 일반적인 종속성의 원리에 따라 乙을 단순위증죄의 교사범으로 보는 단순위증죄의 교사범설이 대립하고 있다.

3. 판례

판례는 소위 모해위증사건에서 목적을 신분으로 보면서 ‘신분관계로 인하여 형의 경중에 있는 경우에 신분이 있는 자가 신분이 없는 자를 교사하여 죄를 범하게 된 때에는 형법 제33조 단서가 위 제31조 제1항에 우선하여 적용됨으로써 신분이 있는 교사범이 신분이 없는 정범보다 중하게 처벌된다’고 하여 모해목적위증 교사범설을 따르고 있다.

4. 결론 및 사안의 해결

생각건대 ① 목적은 행위관련적 요소이므로 공범과 신분에 관한 조문은 제33조의 단서를 적용하는 것은 무리가 있으며 ② 제33조를 적용한다고 하더라도 단서는 처벌을 제한하기 위하여 ‘중한 죄로 벌하지 아니한다’라고 되어 있으므로 정범자에 비하여 교사자를 중한 죄로 처벌하는 것도 부당하며 ③ 교사자의 책임이 무겁다하여도 객관적인 정범자에 의한 불법의 양이 적다면 불법의 양에 따라 작게 처벌하는 것이 소극적 책임주의에 부합하므로 단순위증죄의 교사범으로 처벌하는 것이 타당하다. 따라서 乙은 단순위증죄의 교사범(제152조 제1항, 제33조, 제31조 제1항)으로 처벌되어야 한다.

관련판례

1. 기억하고 있는 사실을 진술한 사건

위증죄는 법률에 의하여 선언한 증인이 자기의 기억에 반하는 사실을 진술함으로써 성립하는 것이므로, 경험을 통하여 기억하고 있는 사실을 진술한 이상 그 진술이 객관적 사실에 부합되지 아니하거나 경험한 사실에 기초한 주관적 평가나 그 법률적 효력에 관한 견해를 부연한 부분에 다소의 오류나 모순이 있다고 하여 위증죄가 성립하는 것은 아니다.(대판 1984.2.14. 83도37)

2. 모해위증 사건

[사실관계] 甲은 A를 모해할 목적으로 A의 재판에서 증인으로 나설 乙에게 위증하도록 교사하여 乙이 기억에 반하는 증언을 하였다. 甲과 乙의 죄책은?

[판결요지] [1] 형법 제33조 소정의 이른바 신분관계라 함은 남녀의 성별, 내·외국인의 구별, 친족관계, 공무원인 자격과 같은 관계뿐만 아니라 널리 일정한 범죄행위에 관련된 범인의 인적관계인 특수한 지위 또는 상태를 지칭하는 것이다. [2] 형법 제152조 제1항과 제2항은 위증을 한 범인이 형사사건의 피고인 등을 ‘모해할 목적’을 가지고 있었는가 아니면 그러한 목적이 없었는가 하는 범인의 특수한 상태의 차이에 따라 범인에게 과할 형의 경중을 구별하고 있으므로, 이는 바로 형법 제33조 단서 소정의 ‘신분관계로 인하여

형의 경중이 있는 경우'에 해당한다고 봄이 타당하다. [3] 피고인이 갑을 모해할 목적으로 을에게 위증을 교사한 이상, 가사 정범인 을에게 모해의 목적이 없었다고 하더라도, 형법 제33조 단서의 규정에 의하여 피고인을 모해위증교사죄로 처단할 수 있다. [4] 타인을 교사하여 죄를 범하게 한 자는 죄를 실행한 자와 동일한 형으로 처벌한다.'고 규정한 형법 제31조 제1항은 협의의 공범의 일종인 교사범이 그 성립과 처벌에 있어서 정범에 종속한다는 일반적인 원칙을 선언한 것에 불과하고, 따라서 이 사건과 같이 신분관계로 인하여 형의 경중이 있는 경우에 신분이 있는 자가 신분이 없는 자를 교사하여 죄를 범하게 된 때에는 형법 제33조 단서가 위 제31조 제1항에 우선하여 적용됨으로써 신분이 있는 교사범이 신분이 없는 정범보다 중하게 처벌된다고 할 것이므로, 이와 달리 정범이 단순위증죄로 처벌된 이상 위 형법 제31조 제1항에 따라 피고인도 단순위증죄의 동일한 형으로 처벌할 수밖에 없다는 소론은 위에서 실시한 법리와 상치되는 독자적 견해에 불과하여 받아들일 수 없다.(대판 1994.12.23. 93도1002)

♣ 돌발퀴즈

주관적으로 진실을 말하려고 하였으나 객관적으로 허위로 판명된 경우에는 허위성의 판단에 대한 주관설과 객관설 모두 위증죄의 성립을 부정한다.

정답 : O

해설 : 주관설에 의하면 당연히 허위성이 없지만, 객관설에 의하더라도 위증의 고의가 없으므로 위증죄는 성립하지 않으므로 타당한 지문이다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 다음 중 허위의 판단방법이 다른 하나는?

- ① 허위공문서작성죄
- ② 허위진단서작성죄
- ③ 허위유가증권작성죄
- ④ 위증죄
- ⑤ 무고죄

정답 : ④

해설 : 위증죄는 주관설을 따라 허위여부를 판단하고, 나머지는 객관설에 따라 판단한다.

2. 위증죄와 증거인멸죄에 대한 설명 중 타당하지 않은 것은?

- ① 위증죄는 목적범이 아니다.
- ② 모해위증죄는 목적범이다.
- ③ 증거인멸죄는 목적범이 아니다.
- ④ 모해증거인멸죄는 규정이 없다.
- ⑤ 증거인멸죄에 대하여는 친족간의 특례규정이 있다.

정답 : ④

해설 : 제155조 제3항에 모해 증거인멸죄의 규정이 있다.

3. 甲은 A를 모해할 목적으로 A의 재판에서 증인으로 나설 乙에게 위증하도록 교사하여 乙은 모해할 목적없이 기억에 반하는 증언을 하였다. 판례에 의할 때 甲과 乙의 죄책은?

- ① 갑과 을은 위증죄의 공동정범
- ② 갑과 을은 모해위증죄의 공동정범

- ③ 을은 위증죄, 갑은 위증죄의 교사범
- ④ 을은 모해위증죄, 갑은 모해위증죄의 교사범
- ⑤ 을은 위증죄, 갑은 모해위증죄의 교사범

정답 : ⑤

해설 : 판례에 의하면 을은 위증죄, 갑은 모해위증죄의 교사범으로 처벌된다.

♣ 학습내용 정리

1. 위증죄의 허위의 판단기준에 대하여는 ① 위증죄는 증인의 불성실을 벌하는 것이 아니고, 객관적 진실과 일치하는 증언은 사법에 대한 진실발견의 위험이 초래될 수 없으므로 허위를 객관적 사실에 반하는 것으로 이해하는 객관설 ② 증인이 자기 기억에 반하는 진술을 한 때에는 이미 국가의 심판기능의 적정한 행사에 대한 추상적 위험을 인정할 수 있으므로 허위를 증인이 자기 기억에 반하는 진술을 하는 것으로 이해하는 주관설이 대립하고 있다.
2. 판례는 ‘위증죄에 있어서의 허위의 공술이란 증인이 자기의 기억에 반하는 사실을 진술하는 것을 말하는 것으로서 그 내용이 객관적 사실과 부합한다고 하여도 위증죄의 성립에 장애가 되지 않는다’라고 하여 주관설의 입장이다.
3. 판례는 소위 모해위증사건에서 목적을 신분으로 보면서 ‘신분관계로 인하여 형의 경중이 있는 경우에 신분이 있는 자가 신분이 없는 자를 교사하여 죄를 범하게 된 때에는 형법 제33조 단서가 위 제31조 제1항에 우선하여 적용됨으로써 신분이 있는 교사범이 신분이 없는 정범보다 중하게 처벌된다’고 하여 모해목적위증 교사범설을 따르고 있다.